

□ الأستاذ الدكتور

□ عبد الله مبروك النجار

□ العميد الأول لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر

□ أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص بجامعة الأزهر

□ عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

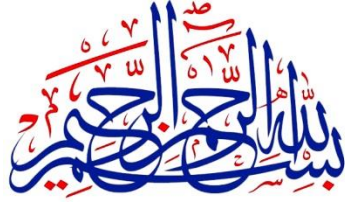
□ محام بالنقض ومحكم دولي

المبادئ العامة لدراسة القانون

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأخيرة

٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م



(وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا)

صِدْقَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

(الإسراء الآية ٨٠)

تقديم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا
ونبينا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه، ومن سار على منوال شريعته
واتبع منهاج دينه إلى يوم الدين... وبعد؛

فإن دراسة القانون تخدم الشريعة - بلا شك - لأن القانون في
مجمله يمثل الفكر الإنساني في سموه ورقيه حين يتجرد ليصنع مبادئ
تقيم العدل، ويقرر نصوصاً تحقق النصفة بين المظلومين، وهذا الفكر
- بما يتمخض عنه من تلك السمة، ويتطلع إليه من هذه الغايات
النبيلة - إنما يمثل الموثل الأكبر لمن يلتمسون عنده الحل، ويقصدون
نصوصه طلباً لتفريج ما يعترض حياتهم من مأزق وكروب، فإذا ما
تمت دراسته، وجرى تحليله، وتم إحصاء ما يعتريه من النقص، عند
التطبيق أو القصور في مجال العمل، أو حين تظهر الدراسة ما قد
يبدو عليه من انفصام بين المقاصد التي تمت صياغته لتحقيقها،
والواقع الذي قد يتغير ليصبح في وادٍ، ونصوص ذلك القانون في وادٍ
آخر، فإن كل ذلك من شأنه أن يظهر ابتداء مدى ما يتمتع به شرع
الله من جودة الصياغة، وإحكام الصنعة التشريعية التي جعلته قادراً
على استيعاب كل ما يتفق عنه العصر، بل وكافة العصور من
تغيرات وتطورات إلى يوم الدين، حيث ينتزه عما يعترى القانون من
تلك الطوارئ التي تدل على قصوره، وتظهر مدى ما فيه من ضعف

وعجز عن تحقيق آمال الناس في عدل حقيقى يسعد حياتهم ويبدد شقاءهم، ويمسح على وجوههم بيد الأمن والطمأنينة، وتبدو - دائماً - قوته، فتية، فيها من حضور التشريع وملاءمة الأحكام ما يصلح لكل زمان ومكان، ومثل تلك المقارنة الأولية لن يتسنى إدراكها، إلا من خلال الدراسة.

وهناك أمر آخر لا يقل أهمية عن تهيئة مثل تلك المقارنة بين التشريع الوضعى، والتشريع السماوى، والتي لابد أن تنتهي لصالح شرع الله، وهو يتمثل فيما تهيئه مثل تلك الدراسات القانونية من تكوين ملكة الفكر التشريعى السوى عند الطالب، لأن منهج تلك الدراسات قد استقر منذ فترة طويلة، بعد أن استفاد من كافة تجارب الفكر البشرى، وأصبح على قدر من الثراء في المنطق، والمنهج، وترتيب الأفكار الذي يفيد - بالطبع - طالب الفقه الإسلامى، ويجعله قادراً على استيعاب المقاصد العامة للتشريع على وجه العموم، والتفكير في إظهارها عند دراسة المواد المتعلقة بفقه الأحكام على وجه الخصوص، كما يفيد كثيراً في إعداد بحوثه وصياغة أفكاره على نحو علمى سديد. كما أن دراسة القانون تفيد طالب العلم الشرعى، حين تبصره بالمواطن التى تحتاج إلى البديل التشريعى الإسلامى، ليجتهد الطلاب والفقهاء والعلماء في إيجاده، وهذا يساعد على تطبيق شرع الله، ولهذا كان من الحق ما قلناه في مستهل ذلك التقديم، وهو أن دراسة القانون تخدم شرع الله، وهذا ما لا يعترينا أدنى شك فيه.

وهذه الدراسة تمثل بداية المبتدى لطالب الدراسات الفقهية في الشريعة والقانون، لأن الطالب لا يدرس قانوناً بالمعنى المحدود للكلمة، وإنما يدرس مبادئ القانون، أو فقه القانون، حتى يكون ما يدرسه ملائماً لكل فروع وأنواعه وأبوابه في كل عصر، وقد حرصت على أن تكون مستوعبة، وشاملة لكافة المستجدات التشريعية المعاصرة، وهذا ما يجعلها - من وجهة نظرنا - متميزة عما يناظرها من الكتابات التي تعالج هذا الموضوع، ولذلك سميتها "المدخل المعاصر لفقه القانون".

أدعو الله تعالى أن يجعلها مفيدة ومحقة للغرض الذي ألفت من أجله، وأن يجعل مسارها في خدمة دينه الحنيف، حتى تكون لبنة فكرية متواضعة في خدمة الحق الذي شرعه، والعدل الذي أوجب علينا القيام به، هذا وبالله التوفيق.

تحريراً في: ٦/أكتوبر/٢٠٢٥م.

الأستاذ الدكتور
عبد الله النجار

تمهيد

تنوع الروابط الاجتماعية

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو لا يمكن أن يعيش منعزلاً عن غيره، لأن الإنسان المنفرد لا وجود له إلا في الفروض الفلسفية البعيدة عن الحقيقة والواقع، وإلا فإنهما ينطلقان بوضوح أن الإنسان يولد في المجتمع ولا يعيش إلا فيه، وبمقتضى تلك الطبيعة الاجتماعية في الإنسان، تعددت روابطه، وكثرت علاقاته، فكانت الروابط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعامة وغيرها، وأدى ذلك إلى ضرورة وجود القواعد القانونية التي تنظم تلك الروابط بما يقيم توازناً عادلاً بين الحقوق والواجبات.

والإنسان في علاقته بغيره لا يمكن أن يتصرف وفق ما يمليه عليه هواه وصالحه، بل يجب عليه أن يكون ملتزماً بقيود المجتمع، تلك التي تحد من الحرية الطبيعية للإنسان، فالحياة في المجتمع توجب على كل فرد أن يقيد من حريته لصالح الآخرين، إذا أراد من هؤلاء احتراماً لمصالحه، فهناك - إذن - قيود اجتماعية ترد على السلوك الإنساني وواجبات تفرضها الحياة في المجتمع، وبعض تلك القيود تفرضها قواعد المجاملات، والآداب العامة، وقواعد الأخلاق، فتلك القواعد تفرض على الإنسان أن يأتي على نفسه ويمد يده للآخرين بالعون والمساعدة إذا كان قادراً، وهو إذا قصر في ذلك لا يكون بمقدور أحد أن يجبره عليه بالقوة، وكل ما هنالك أن يتعرض

لتأنيب الضمير، إن كان من ذوى الضمائر الحية، أو احتقار الناس له وسخطهم عليه.

لكن هناك طائفة أخرى من القيود الاجتماعية تبدو أقوى من مجرد الواجبات الخلقية والمجاملات، ذلك أن هذه الواجبات لا تكفى لتنظيم الحياة في المجتمع، بل يجب أن يوجد إلى جانبها واجبات أشد تكون مشفوعة بوسيلة من الوسائل التى تجبر الفرد على احترامها، وهذه هي الواجبات القانونية التى تفرضها قواعد القانون، فمثلاً إذا قصر الشخص في أداء حق وجب الأداء عليه، فإنه يجبر على ذلك الأداء بقوة القانون قضاء التنفيذ الجبرى على أمواله، وإذا خرج إنسان على نظام المجتمع فارتكب جريمة تعرض للعقاب، وبدون تلك القواعد الأخيـرة - أى القواعد القانونية - لا يمكن أن يستقر حال المجتمع، ولهذا - أيضاً - قيل: يوجد القانون حيثما يوجد المجتمع^(١).

ومن المعروف أنه في حالة اجتماع الناس مع بعضهم في وطن واحد، تنشأ بينهم علاقات روابط متضاربة، وتتزاحم مصالحهم وحرّياتهم، ومن ثم فإنه لا يمكن ترك هذا التضارب بينهم دون تنظيم، فلو ترك الناس وشأنهم لعمت الفوضى بينهم، لأن كل فرد يريد أن يحقق مطامعه ورغباته حتى ولو كان ذلك على حساب غيره، لذلك

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - المدخل للعلوم القانونية - ص ١٣ - دار النهضة العربية - بيروت - سنة ١٩٦٦.

مست الحاجة في المجتمع إلى تنظيم سلوك الأفراد عن طريق سن القواعد القانونية التي تتولى هذا التنظيم^(١)، ويبقى أن نعرف بمضمون تلك القواعد القانونية.

(١) د. جمال الدين طه العاقل - دروس في نظرية القانون ص ١٨ - طبعة ١٩٩٠م.

الباب الأول
التعريف بالقانون وخصائصه
وتمييزه عن القواعد التشريعية الأخرى

الفصل الأول

التعريف بالقانون وخصائصه

المبحث الأول

التعريف بالقانون

تطلق كلمة القانون في اللغة، ويراد بها القاعدة المضطردة باستمرار وفقاً لنظام معين ثابت، وفي هذا الإطار نجد ان لكل شيء قانوناً، فللجاذبية قانون، وللطفو فوق سطح الماء قانون يحكمه، بل أن للأخلاق قانوناً هو الخير، وللعدالة قانوناً هو الحكم بالقسط بين الناس بالحق^(١).

وفي اصطلاح فقهاء القانون يُعرف بأنه: مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية التي تجبر الفرد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء^(٢)، والقانون بهذا المعنى يطلق على كل القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع أياً كان مصدرها، أي سواء كان مصدرها هو الدين، أو السلطة التشريعية العادية، أو عرف الناس، والقانون يجب أن يقوم على العدل، وأن يتوخى كفالة حقوق الأفراد ومصالحهم الخاصة وتحقيق خير المجتمع كله^(٣).

المعاني المختلفة للفظ القانون:

(١) في هذا المعنى: د. عبد الرزاق حسن فرج - المدخل لدراسة القانون - ص ٣ - مطبعة الفخر الجديد.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ١٣.

(٣) د. عبد الرزاق فرج - ص ٤.

وإذا كان لفظ القانون يستعمل في هذا المعنى العام، ليدل على مجموعة القواعد القانونية التى تنظم سلوك الأفراد في المجتمع من خلال مجموعة القواعد القانونية التى تحكم الروابط الاجتماعية في جملتها، والتى من أجلها يسمى: القانون الوضعى، أو علم القانون أو كلية القانون^(١).

إلا أن لفظ القانون قد يستعمل للدلالة على فرع معين من فروع القانون الوضعى، فيقال: القانون المدنى، والقانون التجارى، والقانون الدولى العام، ويقصد به عندئذ مجموعة القواعد التى تنظم ناحية معينة من نواحي النشاط الإنسانى في المجتمع كالنشاط المدنى، أو التجارى أو الدولى، أو غيره.

وقد يستعمل لفظ القانون، ويقصد به: التقنين، أى مجموعة المواد أو النصوص الخاصة بفرع معين من فروع القانون، فيقال: تنص المادة الأولى من القانون المدنى على كذا، ويراد بالقانون هنا: مجموعة من القانون المدنى، أو قانون العقوبات إذا كانت المادة المستدل بها من موارده.

وقد يراد للفظ: التشريع الصادر من السلطة التشريعية، فيقال: القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤، أى القانون الذى يحمل هذا الرقم، أو القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، ويقال أيضاً: قانون تطوير الأزهر

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٧.

وقانون تنظيم الجامعات، وقانون الشهر العقاري، وهكذا، والتشريع هنا أخص من القانون في معناه الأول، إذ التشريع ليس سوى مصدر واحد من مصادر القانون، تقوم إلى جانبه مصادر أخرى تساهم في خلق القواعد القانونية، بينما القانون بهذا المعنى شامل لجملة أنواع منه.

المبحث الثانى

خصائص القاعدة القانونية

ومن خلال تعريف القانون يتضح أنه عبارة عن قواعد تحكم سلوك الأفراد، وهذه القواعد تتميز بالعموم والتجريد، وهي قواعد اجتماعية، وقواعد ملزمة، أى تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة في المجتمع، لكى تضمن لها الاحترام الواجب، ولهذا تتميز القاعدة القانونية بالخصائص الآتية:

أولاً: أنها قاعدة عامة ومجردة:

تتميز القاعدة القانونية أولاً بأنها عامة ومجردة، شأنها في ذلك شأن بقية القواعد القانونية، ومعنى ذلك أن القاعدة القانونية ليست موجهة إلى شخص معين بالذات، ولا تخص واقعة بعينها وذاتها، بل هي تذكر الأوصاف التى يتعين بها الأشخاص المقصودون بخطابها، والشروط التى يلزم بتوافرها في الوقائع التى تنطبق عليها، وكل شخص توافرت فيه هذه الصفات، وكل واقعة جمعت هذه الشروط انطبقت عليها القاعدة القانونية^(١).

ومثال ذلك: القاعدة القانونية التى تقضى بأن سن الرشد في مصر هي إحدى وعشرون سنة ميلادية، فهذه قاعدة عامة بالنسبة إلى الأشخاص المخاطبين بحكمها، وينصرف حكمها على كل من يبلغ

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٨.

هذه السن، وهي موجهة إلى فئة من الأفراد غير متناهية في عددها، ومعينة بأوصافها لا بذواتها^(١).

وإذا كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة من حيث الأشخاص المخاطبين بحكمها، فإنها تتميز عن الأوامر أو القرارات الفردية الخاصة بفرد معين بذاته، وذلك كالقرار الإداري الصادر بتعيين موظف معين، والعمل التشريعي الصادر بمنح الجنسية إلى شخص معين بالذات، فهذا العمل التشريعي - رغم صدوره من السلطة التشريعية - إلا أنه يحمل صفة القاعدة القانونية، لأنه يخص شخصاً معيناً بالذات، وكذلك احكم الصادر من القضاء بإلزام شخص بعمل معين، فهي تتعلق بشخص معين وتنتهي بمجرد تطبيقها أو تنفيذها بالفعل، ولكن القاعدة القانونية تبقى حتى بعد تطبيقها لتحكم حالات معينة لا يمكن حصرها سلفاً ومع ذلك فإن تلك القواعد يمكن أن تكون قواعد عامة إذا وجهت إلى شخص معين بصفته لا بذاته، إذا العبرة ليست بعدد من تتوجه إليهم القاعدة القانونية، بل بصفاتهم، ومن ذلك القواعد التي تطبق على طائفة الموظفين أو المحامين، أو القضاء أو أعضاء النيابة، أو التجار، ففي هذه الحالات وأمثالها تنطبق القاعدة القانونية على فئة معينة من الأشخاص بصفاتهما وليس بذواتهما.

(١) د. عبد الرزاق فرج - السابق - ص ٦.

وقد تتوجه القاعدة إلى شخص معين، كذلك التي تنظم مركز رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الدولة، أو رئيس محكمة النقض، أو الأمين العام للأمم المتحدة، ومع ذلك فإنها لا تتوجه إلى هؤلاء الأشخاص بذواتهم، بل بصفاتهم، أى أنها تتوجه إلى كل من يشغل المنصب سواء أكان الحاضر أم في المستقبل^(١).

وعموم القاعدة القانونية لا يعنى أنها يجب أن توضع لزمن غير محدد، فهناك قواعد قانونية لا توضع إلا لتطبق مدة معينة، كالقوانين الصادرة بإعلان الأحكام العرفية، وما يصدر تطبيقاً لها، فهي معدة للتطبيق فقط في فترات معينة كفترة الحرب.

ومن ناحية أخرى فإن صفة العموم لا تستلزم أن تكون القاعدة القانونية واجبة التطبيق في كل إقليم الدولة، فقد يصح أن تتفرد أجزاء معينة من إقليم الدولة بنظام قانوني خاص، وذلك في حالات استثنائية يغلب أن تكون مؤقتة، وهذا ما حصل - مثلاً - بالنسبة لإقليم إلزاس عند ضمه إلى فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، فقد ترك له نظامه القانوني الخاص، بل أن هذه الظاهرة موجودة في الدول التعاهدية، كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتفظت كل ولاية بسلطة التشريع في مسائل القانون الخاص^(٢).

أهمية عموم القاعدة القانونية وتجريدها:

(١) د. عبد الرازق فرج - ص ٦.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٢٠.

ولا شك ان التجريد والعموم في القاعدة القانونية، يؤديان إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، تلك المساواة التي تقوم على أساس من العدل الذي يؤخذ فيه بالوضع الغالب بالنسبة لجميع الأشخاص، لا على أساس العدالة التي ينظر فيها إلى ظروف كل شخص على حدة، إذ تنطبق القاعدة على الأشخاص المتماثلين، والوقائع المتماثلة حكماً، ويضطرر انطباقها في كل مرة على النسق الذي طبقت به من قبل، كما أنه يبعد القانون عن أن يكون أداة للتعسف والتحكم.

ثانياً: القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الظاهر:

من المعلوم أن القانون يوجد بوجود المجتمع، ومن ثم كان لازماً لتنظيم ما ينشأ من أفراد هذا المجتمع من علاقات وروابط، وهذه الروابط تستلزم قيام مظهر خارجي لسلوك الأفراد، هو موضوع القاعدة القانونية وهدفها.

ومن ثم فإن القانون ليس مطالباً بأن ينفذ إلى ما استقر في النوايا والصدور ما دامت هذه النوايا لم تظهر إلى العالم الخارجي بأفعال مادية ظاهرة، أي كانت الصورة التي تظهر بها هذه الأفعال.

أما ما يستقر في الضمير، وما يكمن في النفس، فلا شأن للقانون به، وإن كان ذلك يعنى بعض القواعد القانونية الأخرى، كقواعد الدين، وقواعد الأخلاق، فمثلاً مجرد التفكير في ارتكاب جريمة والتصميم عليها، لا يقع شيء من ذلك تحت طائلة القانون ما دام أن

ذلك التفكير لم يظهر في الخارج بأعمال مادية ظاهرة تدل عليه، أو ما دام أن الشخص لم يبدأ على الأقل في تنفيذ ما عقد نيته عليه. ومع ذلك، فإنه إذا كان القانون لا يحكم إلا السلوك الظاهر، فإنه إذا اتخذت النية شكلاً خارجياً، أو تصرفاً ظاهرياً يمكن أن يدل عليها، فإنها يمكن أن تكون ذات تأثير في تغيير وصف العقوبة إلى التشديد، وذلك كما في حالة القتل مع سبق الإصرار والترصد، أو القتل بالسم، فإن طريقة القتل في هاتين الحالتين تكشف عن وجود النية وتدلل عليها، ومن ثم ترتفع العقوبة إلى أقصى درجاتها فيحكم بالإعدام، ومع ذلك فإن النية وحدها لا تكفى، وإنما لابد أن تقترن بسلوك ظاهري يدل عليها^(١).

ثالثاً: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:

والغرض من القاعدة القانونية هو تنظيم العيش في المجتمع، فإذا لم توجد المجتمع فلا محل لوجود القانون، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه يولد في مجتمع ولا يعيش إلا فيه، وعن طريق تلك المعيشة المشتركة يكون من الضروري وجود القواعد القانونية التي تحمي حقوق الأفراد وتبين واجباتهم.

والقواعد القانونية لا توجد إلا في مجتمع متطور، تقوم على رأسه هيئة عليا ذات سيادة تقود زمامه، وتفرض هذه القواعد قسراً،

(١) د. سليمان مرقس - فقرة ٩، د. عبد الرزاق فرج ص ٧.

ويكون لها إجبارهم على احترام أحكام القانون، ولكن ليس معنى ذلك أنه يشترط لوجود القواعد القانونية وجود الدولة بالمعنى الحديث، لأن تاريخ القانون يدل على وجود قواعد قانونية في عهد القبيلة، يتولى شيخها تطبيقها، وكان للإقطاعيات قواعد قانونية يستبد الأمير بتطبيقها، ولهذا كان القانون أسبق في الوجود تاريخياً من وجود الدولة بمعناها الحديث.

ويترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أن يختلف القانون من عصر إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، بل وقد يختلف في البنية الواحدة من عصر إلى عصر، فهو يتطور بتطور المجتمع، حتى يستجيب لحاجاته الجديدة، ويساير اتجاهاته المستحدثة، ومن أجل هذا نجد أن المشرع يتدخل من وقت إلى آخر، فيعدل في القانون أو يغير فيه بما يتلاءم مع الظروف الجديدة في المجتمع^(١).

رابعاً: القاعدة القانونية مقترنة بجزء مادي:

وما تتسم به القاعدة القانونية انها ملزمة، وأساس هذا الإلزام يتمثل في اقترانها بجزء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفها، ومؤدى إلزام القاعدة القانونية بالجزاء، أنه يجب على الأفراد أن يحترموا تلك القاعدة رغماً عنهم، فلا يكون لهم اختيار في هذا الاحترام يجعل وجوده رهناً بمشيئتهم، ولولا وجود الجزاء في القاعدة القانونية ما

(١) د. عبد الرزاق فرج - ص ٩.

لقيت احتراماً من أحد، فلم يوجد بعد ذلك الصنف من البشر الذي يحترم القانون حباً فيه، أو عشقاً للمقاصد السامية التي يدعو إليها، ومنها إقامة العدل والانتصار للحق، وإعلاء القيم، والارتقاء بالآداب والمحافظة على النظام العام، فإن الأغراض الشخصية والمصالح الذاتية غالباً ما تطيح لكل تلك المعانى فينتصر الشح في النهاية، ولتعلو أنانية الفرد على مصالح ما سواه، ولهذا كان الجزاء هو العاصم من ذلك، لأنه هو الذي يردع، وهو الذي يجبر على الاحترام، مع أن الأصل في القانون أن يحترم لذاته وأن يكون تنفيذه نابعاً من حرية الأفراد واختيارهم.

المقصود بالجزاء، ضرورته وخواصه:

الجزاء - إذن - هو النتيجة، أو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية، والغرض منه هو الضغط على إرادة الأفراد حتى يمتثلوا لأوامر القانون نواهيه، واحتياطاً يؤدي الجزاء - عند وقوع السلوك المخالف للقانون - إلى إزالة الآثار المترتبة على هذا السلوك وإصلاحها والجزاء لازم لإقرار النظام داخل المجتمع، وتلك هي وظيفته التي لا يمكن تحقيقها إذا تركنا لكل فرد الحرية في الخضوع لقواعد القانون أو عدم الخضوع لها.

ويتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنه حال غير مؤجل، يطبق في الحياة بمجرد وقوع المخالفة، وبأنه مادي أو حسي، أى أن له

مظهراً خارجياً وليس مجرد جزاء معنوي، ومن ناحية ثالثة فإن الجزاء في القاعدة القانونية توقعه السلطة العامة.

وهو من هذه النواحي الثلاث يختلف عن الجزاء المترتب على مخالفة قواعد السلوك الاجتماعي الأخرى، كقواعد المجاملات أو مبادئ الأخلاق، أو أحكام الدين، ذلك لأن الإخلال بهذه الأخيرة يستتبع جزاء من نوع آخر، ومن طبيعة أخرى، لأن كثيراً من جزاءات الدين مؤجلة للأخرة، ومبادئ الأخلاق لا يترتب على مخالفتها جزاء حسي مادي، بل جزاء معنوي، هو استهجان المجتمع، وكذلك الأمر فيما يتعلق بقواعد المجاملات (١).

تطور الجزاء:

وقد شهد الجزاء تطوراً انتهى به في المجتمعات الحديثة لأن يكون بيد الدولة، لن الدولة بما تملك من سلطات، هي التي تكفل حماية القواعد القانونية وتستطيع مجازاة كل مخالف لها، أما في المجتمعات البدائية، فقد كان الأمر متروكاً للفرد، فهو الذي يقتضي حقه بيده، ومعنى ذلك أن الأمر كان متروكاً للقوة، فالأقوى كان هو صاحب الغلبة، وكثيراً ما كانت الأسرة أو العشيرة تعلن تضامنها مع الفرد، وهو ما كان يؤدي إلى وقوع الحروب بين العشائر والقبائل المختلفة.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - مبادئ القانون - ص ١٩، طبعة ١٩٧٢، مكتبة وهبه.

وكان من المستطاع تفادى الانتقام من الخارج بالاتفاق على دية يدفعها مرتكب الفعل المخالف للقانون، فإذا اتضى دفعها، وقبلها المعتدى عليه أو أسرته انتهى الأمر في سلام، وإلا كانت القوة هي البديل للحصول على الحق.

ومع ازدياد قوى السلطة العامة وقوة الدولة أُلغى نظام اللانتقام الفردى وألزمت الدولة المعتدى عليه بقبول الدية، فأصبحت إجبارية تفرضها الدولة وتحدد قدرها ثم انتقلت مهمة تنفيذ القانون وتوقيع الجزاء على من يخرج عليه، من يد الفرد إلى يد الدولة، فهي التي تعاقب مرتكبي الجرائم، وهي التي تمكن صاحب الحق من الوصول إليه ومن رد الاعتداء عليه.

ولم يبق في الوقت المعاصر من آثار حق الانتقام الفردى إلا الحالة التي لا تستطيع فيها السلطات العامة أن تتدخل في الوقت المناسب لرد الاعتداء، وهي حالة الدفاع الشرعى، أى رد الاعتداء غير المشروع على النفس أو العرض أو المال بالقوة المناسبة، فإذا هدد الإنسان في تلك المصالح الضرورية بخطر محقق، كان له الحق في رد هذا الاعتداء بالقوة وذلك بالطبع أمر غريزي، كما أنه لا ينطوى على خطورة بالنظام العام، حيث يستحيل أن تتدخل الدولة لرد الاعتداء في الوقت المناسب^(١).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى المرجع السابق - ص ٢١.

صور الجزاء :

وتتعدد صور الجزاء بتعدد فروع القاعدة القانونية التى تقع المخالفة لها، فهناك الجزاء الجنائى الذى يترتب على مخالفة القانون الجنائى، وهى العقوبات بأنواعها وهناك الجزاء المدنى، وهى التى ينظمها القانون الدنى للخروج على أحكامه، وهناك الجزاءات الإدارية التى تترتب على مخالفة القانون الإدارى، كفصل الموظف، أو حرمانه من الترقية مثلاً، أو توقيع عقوبة اللوم والإنذار أو الخصم من مرتبه، ويحسن بيان ذلك:

(١) الجزاء الجنائى:

يعتبر الجزاء من أشد صور الجزاء، وهو ما يرتبه القانون كنتيجة يتعرض لها من يرتكب فعلاً من الأفعال التى يحرمها، أو هو العقوبة المقررة للجرائم المختلفة، والجريمة فعل غير مشروع يمثل اعتداء على النظام فى المجتمع، ولو كانت فى نفس الوقت تكون اعتداء على حق خاص، ولهذا فإن الجريمة لا تقاس بمقتضى الحق المعتدى عليه وقيمته، بل بقدر ما تتطور عليه من إخلال بنظام المجتمع^(١).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى المرجع السابق - ص ٢٢.

وظيفة العقوبة الجنائية:

وللعقوبة الجنائية وظيفتان هما: المنع والزجر معاً، ذلك أن الخوف من العقوبة يمنع الأفراد - غالباً - من ارتكاب الجرائم، فإذا ما وقعت الجريمة تعرض مرتكبها للعقاب حتى لا يعود إليها، وحتى يكفر عن جرمه ويكون عبرة لغيره.

وهذه الوظيفة للجزاء الجنائي تختلف عنها في الجزاء المدني، لأن الجزاء المدني يراد به حماية حق خاص عن طريق جبر آثار الاعتداء عليه، أما الجزاء الجنائي فيراد به معاقبة من يخرج على النظام الاجتماعي، ولهذا كانت العقوبة فيه حقاً للمجتمع، أما في الجزاء المدني فإنها حق للفرد.

ومن الجرائم ما يعتبر اعتداء على الصالح العام حده في المجتمع، كالخيانة العظمى، وتزوير الأوراق الرسمية، ولكن معظم الجرائم تعتبر اعتداء على حق الفرد وعلى حق المجتمع في آن واحد معاً، وذلك مثل جريمة السرقة، وجريمة القتل، وجريمة إتلاف مال الغير عمداً، وفي هذه الحالة يتولد عن الجريمة جزاءان جزاء جنائي، وجزاء مدني.

أما الجزاء الجنائي:

فهو رد الفعل الذي يوقعه المجتمع على من يخرج على النظام فيه، وهذا الجزاء يتنوع إلى عقوبات مختلفة، منها العقوبة البدنية كالحبس، ومنها العقوبة المالية كالغرامة، ولما كان هدف توقيع الجزاء

هنا هو الدفاع عن المجتمع، فإن الذي يملك توجيه الدعوى لتوقيع العقاب هو من يمثل المجتمع وهي النيابة العامة، وتسمى الدعوى التي تمارسها في تلك الحالة، بالدعوى العمومية أو الجنائية، والقضاء الذي يطبقها هو القضاء الجنائي.

وأما الجزء المدني المترتب على الجريمة؛ فهو الذي يقصد به إصلاح الضرر الذي تسبب عنها، وتعويض المضرور عما أصابه من ضرر بسببها، فهو يتوجه إلى القضاء بتوقيع هذا الجزء المدني، وتسمى الدعوى بالدعوة المدنية، وأساسها الحق الخاص، ويختص بنظرها القضاء المدني.

وعلى أنه يجوز للفرد في حالة ما إذا كان الاعتداء على حقه يكون جريمة، أن يتقدم إلى القضاء الجنائي بدعواه المدنية، وذلك تبعاً للدعوى الجنائية التي ترفعها النيابة العامة، وهذا ما يعرف بالإدعاء المدني، وفي تنظيم هذا الحق، تقضى المادة (٢٥١) إجراءات جنائية بأنه: "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية".

فإذا كانت الجريمة سرقة، فإنه ينشأ عنها حقان، حق المجتمع في توقيع العقاب، وحق المجنى عليه في استرداد الأشياء المسروقة، أو المطالبة بالتعويض عنها، ولهذا الأخير أن ينتظر صدور الحكم الجنائي ثم يرفع دعواه المدنية بالاسترداد أو التعويض أمام المحاكم الجنائية، وله أن يتدخل أمام المحكمة الجنائية التي تنتظر دعوى السرقة

مطاباً بالاسترداد أو التعويض، وكذلك الأمر في كافة الجرائم التي يضار منها المجني عليه، وذلك كالقتل والجرح.

(٢) الجزاء المدني:

والجزاء المدني هو الذي يوقع على من يخالف قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو حقاً خاصاً، وتتولى نصوص القانون المدني، والقانون التجاري بتنظيم هذا الجزاء، وهو يتنوع إلى أنواع هي:

(أ) الجزاء المباشر:

ويقصد به جبر الفرد على أن يقوم بما لم يقم به مختاراً، كالحكم على من يحوز مالاً مملوكاً لغيره بدون وجه حق أن يرده إليه، والحكم بطرد المستأجر من العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإيجار، ومن ذلك التنفيذ جبراً على أموال المدين بمبلغ من النقود لكي يستوفي الدائن حقه من حسيطة بيعها.

(ب) الجزاء العيني:

ومفاد هذا النوع من الجزاء يتمثل في أن يقوم المدين بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة، أي عدم الاعتداء بالعمل المخالف للقانون، وإزالة المخالفة قد تكون عملاً مادياً مثل هدم بناء أقيم في أرض مملوكة للغير، وقد تكون إزالة المخالفة بتقرير البطلان، أي إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وعدم الاعتداء بشئ أثر للتصرف الذي وقع مخالفاً للقانون، وذلك كما لو تم الرهن بشكل

غير رسمي، وبالمخالفة لما نص عليه القانون، وكذلك الأمر فيما يتعلق بهبة العقار، حيث يترتب على عدم مراعاة هذا الشكل اعتبار التصرف كأن لم يكن.

ومن تطبيقات هذه الصورة من صور الجزاء، عدم الاعتداد بالعمل المخالف للقانون، وذلك بعدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير، ويقصد به أن يكون التصرف منتجاً لأثره فيما بين طرفيه، لكن تلك النتيجة لا تكون حجة في مواجهة غيرهما، إذا خالف ما يستلزمه القانون من إجراء، فمثلاً يستطيع الدائن أن ينقل حقه إلى غيره عن طريق الحوالة، ولكي تنفذ الحوالة في حق المدين ويصبح مسئولاً عن الوفاء للمحال بالحق وليس للدائن أن يقبل هذا المدين الحوالة أو يعلن بها، فإذا لم يتحقق ذلك لا تنفذ الحوالة في مواجهته، وإن كانت قد تمت فيما بين الدائن المحيل، والمحال الجديد.

(ج) الفسخ:

والفسخ جزاء مدني يقصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل، وفيه نجد أن التصرف قد ينعقد صحيحاً من جميع الوجوه، ولكن يقع بعد نشوئه ما يحول دون تنفيذه بفسخه ويتحلل الطرفان من آثاره ويعودان إلى حالتها قبل التعاقد، ففي عقد البيع -مثلاً- إذا لم يقع البائع بتسليم المبيع يكون للمشتري حق فسخ العقد، وقد يقوم بهذا الفسخ البائع إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن.

(د) التعويض:

ويمكن أن يكون الجزاء المدني في صورة تعويض الذي يتخذ في الغالب شكل مبلغ نقدي يدفع لإصلاح الضرر أو جبراً لخطر الضرر، وقد يكون التعويض مبلغ نقدي يدفع لإصلاح الضرر أو جبراً لخطر الضرر، وقد يكون التعويض هو الجزاء الأصلي، وذلك كما في حالة التعويض الذي يلزم به صاحب سيارة عن إصابة تسبب فيها للغير فأضر بشخصه أو ماله، وقد يكون التعويض بديلاً للجزاء الأصلي إذا أصبح متعذراً أو مستحيلاً وقد يكون جزاء مكماً، وذلك كما في حالة الحكم على من يحوز أرضاً بغير حق بردها، وبالتعويض عن حرمان مالكها منها في مدة الحياة بغير حق.

(٣) الجزاء الإداري:

وأما الجزاء الإداري، فإنه يتمثل فيما تقوم السلطة الإدارية بتوقيعه على من يخالف قواعد القانون واللوائح، أو عدم إطاعة أوامر الرؤساء.

ومن هذه الجزاءات: الإنذار والخصم من المرتب، والفصل من الخدمة، ويلاحظ أن القانون الإداري ليس له نصوص خاصة يرجع فيها إلى وصف المخالفة وبيان الجزاء المقرر لها وإننا هو - كما يقولون - قانون الإبداع، حيث يعتمد التوصيف للمخالفة فهي على استتباط الحكم من المبادئ العامة للقانون، وذلك على هدى قواعده المستقرة في القوانين السارية، مثل القانون المدني، والقانون الجنائي،

وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، إضافة إلى المبادئ التي استقرت عليها محاكم مجلس الدولة، والمحاكم العليا، مثل محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية.

الفصل الثانى
تفريد القواعد القانونية
عن غيرها

القاعدة القانونية تستهدف تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، ولما كان شأنها كذلك، فإنها قد تختلط بغيرها من القواعد الاجتماعية التي تشترك معها في تلك الغاية، مثل قواعد المجاملات والعادات والتقاليد، وقواعد الأخلاق، ومبادئ الدين، حيث تشترك تلك القواعد مع القانون في تنظيم السلوك، كما أنها تتسم بنوع من الإلزام الذي يضمن لها احتراماً في مجال التطبيق، إلا أنها مع ذلك التشابه تختلف عن القاعدة القانونية من بعض الوجوه، وذلك كما يلي:

أولاً: القواعد القانونية، وقواعد المجاملات والعادات والتقاليد:

وقواعد المجاملات والعادات والتقاليد يقصد بها تلك المبادئ التي يربطها الناس في علاقاتهم اليومية بسبب تعارفه عليها وتواضعهم على احترامها، لأنها - في نظرهم - تعتبر من تقاليد المجتمع، وذلك مثل المواساة في الكوارث، والمشاركة في السراء بالتهاني والمشاطرة في الضراء بالتعازي، وتلبية داعي المكروب، وبجلبه طلب النجدة والملهوف، وغير ذلك مما تعارف عليه المجتمع من العادات والتقاليد، ومن ذلك ارتداء أزياء معينة في المناسبات^(١)، وتبادل السلام والتحية عند اللقاء، فهذه القواعد تؤثر - بلا شك - في السلوك ويشعر الناس نحوها باحترام بالغ يدفعهم إلى الحرص عليها والمواظبة على فعلها، وذلك خوفاً من تأنيب الضمير والشعور المؤلم بمخالفة ما تعارف عليه

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ١٢، د. عبد المنعم البدرأوى - فقرة ٢٧، د. عبد المنعم فرج - فقرة ١٥.

الناس، بيد أنه يبقى الجزاء عن عدم الفعل مختلفاً، فهو في القاعدة القانونية جزاء قانوني حالي ومؤلم وينقذ جيل، أما هنا فإنه لا يتعدى مجرد الاستحسان، واستنكار الناس لمن يخرج على تلك القواعد.

ثانياً: القواعد القانونية وقواعد الأخلاق:

وكلمة الأخلاق كلمة جامعة، تشمل كافة معاني الخير المرزومة للسلوك، والتي تعبر عن ضمير المجتمع في المحافظة عليها واستهجان من يخالفها، وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق الفصائل ومحاربة الرذائل، وتنمية معاني الخير في المجتمع كالوفاء بالعهد، ونجدة المكروب، والمحافظة على قيم الحياة وأصولها، كالدين والنفس والعرض والمال.

والأخلاق بهذا المعنى الجامع تعتبر غاية دينية وإسلامية، فقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتمم مكارم الأخلاق، كما أن الأخلاق الكريمة صفة من صفاته وسمة من سمات حياته التي وصفه بها ربّه حين قال في محكم كتابه { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ }^(١).

(١) أوجه الشبه بين الأخلاق والقانون:

وهناك أوجه شبه واضحة بين القاعدة القانونية، والقاعدة الأخلاقية، لأن كلاّ منهما يعتبر قاعدة عامة يتوجه الخطاب بها إلى كافة أفراد المجتمع، كما أن كلاّ منهما ملزمة وتقترن بجزاء يوقع على

(١) سورة القلم - الآية ٤.

من يخالفها، وتستهدف تنظيم العيش في المجتمع وتوجيه سلوك الأفراد تجاه غايات محددة من أجل رقيه وسعادته، وسعيه نحو الأهداف التي يتوخاها.

(٢) أوجه الاختلاف بين الأخلاق والقانون:

ومع وجود ذلك التشابه الكبير بين القانون والأخلاق إلا أنه يظل الفرق بينهما واضحاً من عدة أمور هي:

(أ) اختلاف الجزاء في كل منهما:

إذا كانت القاعدة الأخلاقية القانونية في الاقتران بجزاء يجعل كلاً منهما ملزمة وحرية الاحترام والتقدير من المجتمع، إلا أن هذا الجزاء يختلف في كلا القاعدتين فهو في القاعدة القانونية جزاء مادي، مثل الحبس، والحجز على مال المدين، وفصل الموظف أو توجيه اللوم إليه، أو الخصم من راتبه، وتقوم السلطة العامة بتوقيعه على كل من يخالف أحكام القانون، أم في القاعدة الأخلاقية فإن الجزاء أدبي أو معنوي يتمثل في تأنيب الضمير، واستنكار المجتمع لم يخالف قواعد الأخلاق فيه، لكن لا توجد سلطة عليا تلزم الأفراد باحترام القواعد الخلقية.

(ب) اختلاف الغاية في كل منهما:

ولا يقتصر أمر الخلاف بين كل من القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية على تباين الجزاء في كل منهما، بل إن ثمة وجهاً آخر من وجوه الخلاف بينهما هو اختلاف الغاية، ذلك أن غاية القاعدة القانونية نفعية، أى تتغيا نفع المجتمع وحماية مصالحه والمحافظة على حقوقه، أما الغاية في الأخلاق، فإنها غاية مثالية تستهدف النزوع بالمجتمع جهة السمو والكمال.

(ج) مصدر الإلزام في كل منهما:

كما أن هناك خلافاً بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية في مصدر كل منهما، وهذا المصدر في القاعدة القانونية يعتبر محدداً واضحاً إما بنص أو عرف أو حكم مقرر في التشريع الإسلامي، أما في القاعدة الأخلاقية فإن هذا المصدر غير محدد، لأنه يتمثل في ضمير الأفراد وسلوكهم، وهو ما يعتريه التغير بحسب الأشخاص، وبحسب الأزمان^(١).

(د) من حيث الاعتداد بالنوايا والسلوك الظاهري:

نجد أن هذا يشكل فارقاً بين القاعدة القانونية، والقاعدة الأخلاقية، لأن الأولى لا تهتم إلا بالسلوك الظاهري، ولا تتعلق إلا به، ولا تنظم سواه، وهذا أمر عادي، لأن الذين وضعوا تلك القاعدة من البشر، وليس لديهم القدرة على الغوص في نفوس الناس وتعقب

(١) في هذا المعنى: د. عبد الرازق فرج - السابق - ص ١٥.

ضماثرهم ونواياهم، فهذه من اختصاص الله - تعالى - الذي خلق الخلق ويعلم ما يسرون وما يعلنون، ولذلك فإنه - سبحانه - وحده هو القادر على أن يعلم ما تنطوى عليه جوانح الإنسان، أما البشر فليس لديهم القدرة على ذلك.

أما قواعد الأخلاق فإنها تركز على الضمير لتسمو به، وليكون ذلك السمو دافعاً لتهذيب السلوك وترقيته والنهوض به لأن غاية الأخلاق هي الوصول بالإنسان نحو الكمال، وإن كان ذلك الكمال ليس من الدنيا، ولا من طبيعتها، ولا هو شيء يدرك ولكن من عظمة هذا الكمال أن استمرار العمل له هو إدراكه.

صلة الأخلاق بالقانون:

ورغم وجود ذلك التباين بين القاعدة القانونية، والقاعدة الأخلاقية، فإنه لا يمكن القول بأن ثمة انفصلاً بين القانون والأخلاق، لأن الغايات التي يتوخاها القانون، ومنها ما يتعلق بالمحافظة على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، وأداء الأمانة والبعد عن الكسب الحرام كالسرقة والاختلاس والرشوة، وما يدعو إليه القانون من الوفاء بالعهود واحترام المواثيق، والبعد عن الغش والخديعة، والاحتيال والنصب، كل هذه الغايات القانونية في حد ذاتها غايات أخلاقية.

إلا أنه رغم ذلك التوحد في الغايات بين القانون والأخلاق يبقى للأخلاق مجالها الخاص في بعض المواطن التي لا ينازعها فيها القانون، وذلك كالصدق ونبذ الحقد والكراهية والضغينة، فهذه الأمور

وغيرها تعتبر ساحة أخلاقية خالصة بعيدة عن إلزام القانون ومجال عمله^(١).

ثالثاً: مبادئ القانون وأحكام الدين:

الدين هو ما شرعه الله - تعالى - لعباده على يد أنبيائه ورسله من لدن آدم - عليه السلام - وحتى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذا الدين قد نزل على هيئة شرائع تختلف باختلاف ما يبعث به كل رسول أو نبي إلى قومه، لأن شرائع السماء قد تعهددت إنحرافات هؤلاء الناس بالتقويم والتصحيح، وإرشاد الناس إلى الطريق الصحيح، ورغم اختلاف الشرائع التى يتألف منها الدين، ذلك الاختلاف الذى أشار إليه قول الله - تعالى -: { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ }^(٢)، إلا أن تلك الشرائع تتفق فيما بينها على حماية مقومات الحياة الأساسية التى لا يمكن لأى مجتمع ان يعيش سعيداً هانئاً بدونها أو بدون واحدة منها، وهذه المقومات هي:

المحافظة على الدين - والمحافظة على النفس - والمحافظة على العرض - والمحافظة على العقل - والمحافظة على المال، فهذه المقاصد، أو الضرورات لا تختلف فيها الشرائع، ولهذا تسمى: مقاصد

(١) د. توفيق فرج - ص ٢٥ وما بعدها.

(٢) سورة الشورى - من الآية ١٣.

الدين، وإنما يقع الخلاف في الفروع التي تتوخى المحافظة على تلك الأصول، وبحسب ما يناسب كل زمان ومكان، حتى ختم الله - تعالى - رسالات السماء برسالة محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - فصارت تلك الرسالة علماً على دين الله وتجسيداً لكل شرائع السماء، وهي المهيمنة عليها، والمبينة لما يريده الله - تعالى - من خلقه إلى يوم الدين.

والدين كرسالة سماوية يمثل تنظيمياً شاملاً لكل علاقات الإنسان وروابطه وصلاته، ومن تلك الروابط والصلات، صلته بربه، وما تقتضيه تلك الصلة من واجبات تشغل بها ذمته، وفاء لحقوق الله - تعالى - وهي العبادات، ذلك أن الصلة في العبادات بين العبد وربه تقوم على الخضوع التام، والامتثال المطلق، والتجسيد الكامل لمعنى العبودية، وفي هذا المجال يقع الواجب كله في ذمة العبد، أما الله - تعالى - فإنه لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، إن أثاب فبفضله، وإن عاقب فبعده، لا يجب عليه شيء ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون.

وإذا كانت العبادات تقوم على فكرة الواجب الطرفي بجانب العبد، ولا تقوم على فكرة الواجب التبادلي، الذي يعنى أن كل حق يقابله واجب في ذمة الطرف الآخر، فإنها بهذا المعنى تختلف عن بقية الصلات والروابط، حيث تتبادل فيها الحقوق وتتلازم الواجبات، ويتجلى ذلك واضحاً في المجالات الأخرى التي ينظمها الدين، وهي

علاقة الإنسان بمجتمعه، وعلاقته بأفراد هذا المجتمع، كما تنظم - أيضاً - علاقته بنفسه، فإن للنفس على صاحبها حقوقاً، منها المحافظة عليها، وعدم الزج بها في المهالك وعدم ظلم النفس، وهكذا كان تنظيم الدين شاملاً لكافة العلاقات، ومختلف الروابط وكان مجاله أوسع من مجال القانون لذلك.

ولا يمكن المراء في أن الدين يتضمن قواعد منظمة لسلوك الأفراد في المجتمع، وأن تلك القواعد ملزمة ومقتربة بجزء يضمن لها الاحترام والتنفيذ، لكن يبقى - مع ذلك - فرق، بل فروق بين قواعد الدين وقواعد القانون كما يلي:

(١) اختلاف المصدر:

مما لا شك فيه أن اختلاف المصدر في كل من القاعدة الدينية، والقاعدة القانونية يمثل فرقاً جوهرياً بينهما، وفي هذا المجال يمكن القول أن مصدر القاعدة الدينية سماوي يتمثل في كتاب الله - تعالى - وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة، والقياس وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها.

أما المصدر في القاعدة القانونية فإنه وضعي، أي نص قام أهل الرأي والنظر في المجتمع بوضعه وذلك لتطبيقه على الوقائع التي تدخل تحت حكمه، أو عن طريق إلحاق واقعة غير محكوم فيها بواقعة مشابهة سبق الحكم فيها، فتعطى مثل هذا الحكم، والاتجاه الأول يعرف بالاتجاه اللاتيني الذي يقوم على تقنين المواد وتطبيقها، أما

الاتجاه الثانى فإنه يمثل الاتجاه الأنجلوسكسونى، وهو المعروف بنظام السوابق القضائية، وهو مطبق فى انجلترا وأمريكا، واختلاف المصدر فى كلا الاتجاهين يمثل وجهاً قوياً من وجوه الاختلاف بينهما.

(٢) اختلاف الجزاء :

والجزاء المختلف - كذلك - فى القاعدة القانونية عنه فى القاعدة الدينية، فإذا كان الجزاء فى الأخيرة يمكن أن يتنوع إلى جزاء دنيوى حالى، وجزاء أخرى مؤجل ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيحاسبهم على ما قدموا، ويجازيهم على ما فعلوا، فإنه فى القاعدة القانونية لا يكون إلا جزاء معجلاً فى الدنيا، ولا تعرف تلك القواعد الجزاء الأخرى المؤجل لما بعد الموت والبعث.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بسلطة توقيع الجزاء، فإن تلك السلطة فى القانون هى السلطة العامة القائمة على حفظ الأمن والنظام فى المجتمع، أما فى القاعدة الدينية فإن الذى يقوم بالحساب وتوقيع الجزاء هو الله - تعالى -، ويتولى خلفاؤه فى الأرض من أولياء الأمور القائمين على حفظ الدين وسياسة الدنيا توقيع هذا الجزاء فى الدنيا، أما فى الآخرة فهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت والمتولى لأمر عباده فى المحاسبة على كافة ما وقع منهم فى الدنيا.

(٣) اختلاف المحل :

ومحل القاعدة القانونية هو السلوك الظاهر، أم القاعدة الدينية فهى أوسع مدى لأنها تنظم السلوك الظاهر، والسلوك الخفى.

الصلة بين القواعد الدينية والقواعد القانونية:

ومع وجود ذلك الخلاف، فإن ثمة صلة وثيقة بين الدين والقانون، وهذه الصلة يمكن إجمالها في أمرين: أولهما: أن هناك بعض الجرائم المؤثمة في الشريعة، وهي في نفس الوقت مؤثمة في القانون، على سبيل المثال: فإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يعتبر جريمة في التشريع الإسلامي ويعاقب عليها بالقصاص، وهو القتل عقاباً لمن يقتل غيره عامداً متعمداً، وهذا الحكم لا يختلف في مجمله عما هو مقرر في القانون، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالسرقة، فإنها تمثل جريمة وتُعد عملاً محرماً شرعاً، وتعاقب عليها الشريعة، ويعاقب عليها القانون، وإن كانت الفكرة التي بنيت عليها العقوبة مختلفة في كلا الاتجاهين، إلا أنه يبقى ذلك التشابه العام بين التجريم والعقاب، والتماثل المطلق في رعاية المصلحة المشمولة بحماية تلك السياسة العقابية المقررة في كل من الشريعة والقانون.

وثانيهما: أن اتجاه القانون في مقصده التشريعي العام يستلهم أحكام الدين فيما يقوم بتنظيمه من روابط الأفراد المختلفة، وفيما يسنه من عقوبات، وبناء على ذلك فإنه إذا اختلف حكمه اختلافاً تاماً مع قاعدة شرعية، أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية فإن هذا الحكم يفقد شرعيته، بل يفقد صلاحيته كنص قانوني ملزم.

وأساس ذلك أن الدستور ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإذا خرج نص عن

هذا الإطار فإنه يكون غير دستوري، وقد كفل القانون للأفراد حق الطعن على هذا النص امام المحكمة الدستورية العليا لتقضى بعدم دستوريته، ومن ثم ينحى عن مجال التطبيق، وهكذا تقوم الصلة بين الدين والقانون على هذا النحو الواضح.

الفصل الثالث
دور القانون فى تنظيم
نشاط المجتمع

المبحث الأول

الأساس العملى للقانون

غاية القانون الأساسية هي تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع بنصوص يفترض أن لها القدر الأوفى من الاحترام وتطبيق في نفوس الناس، وأن من لهم يخضع لحكم القانون اختياراً فإنه يخضع له إجباراً عن طريق إلزامه بالسلطة الجبرية في المجتمع، والقانون مع ذلك يعتبر أداة في يد الدولة تستطيع بها أن تفرض هيمنتها وتحكم سيطرتها وتوجه أهدافها في المجتمع، وهنا يثور التساؤل عن مدى تدخل القانون لتنظيم شئون المجتمع، وبتعبير آخر ما هو المدى الذي يستطيع القانون أن يتدخل فيه ليتولى عن الأفراد تنظيم شئونهم وتوجيه تصرفاتهم؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل مرهونة بالفلسفة السائدة في المجتمع، أو بالفكر الذي يسيطر على أفرادها، وما إذا كان ذلك الفكر جميعاً اشتراكياً، أو فردياً رأسمالياً، أو ما دون ذلك، أو ما بينهما، وبيان ذلك كما يلي:

أولاً: المذهب الفردي:

تقوم فكرة المذهب الفردي على أساس أن الفرد هو قطب الدائرة في ساحة نشاط المجتمع وأن كافة الأنظمة المعمول بها والقوانين السارية، يجب أن تكون وهو إشارته وطوع إرادته، ووفق خدمته، ومن ثم فإن القانون لا يجوز له أن يتدخل في نشاط الفرد أو في شئونه

الخاصة إلا في الإطار الذي لا يتصادم مع إرادته، ولا يجافى توجهه
رغبته، كما لا يجوز لهذا القانون أن يقيد حريته في اختيار النشاط
الذي يريده، أو في تملك ما يقوى على تملكه من المال دون قيد أو
حد، ولهذا يسمى هذا المذهب، بالمذهب الرأسمالي.

ورغم ما يضيفه النظام الفردي على حقوق الفرد، فإنه لا ينظر
إليه على أنه كان يعيش منعزلاً في المجتمع، بل يتعامل على أنه كائن
اجتماعي يعيش داخل جماعة، ويرتبط بعلاقات مع غيره من الأفراد
الذين هم - مثله - مؤئل رعاية القانون ومحل اهتمامه، ولما كان
النشاط الفردي لهؤلاء المجموعة التي تعيش في ظلال المذهب الفردي
بحسب الطاقة والمقدرة والاستطاعة التي تمكن البعض من الوصول
إلى ما يرضاه لنفسه في المركز الاقتصادي أو الملكية الفردية، فإنه
ليس ثمة اختيار أمام القانون سوى المواءمة بين تلك الإيرادات
المتنافسة بما يتيح لها قدراً أكبر من حرية المنافسة، ولا يجوز أن يغل
يد أى منها في الوصول إلى ما تريد، وكما يقول أنصار المذهب
الفردي، أن الفرد لم يخلق للمجتمع، ولكن المجتمع هو الذي وجد
لصالح الفرد، ولهذا فإن كل ما في المجتمع يجب ان يتوجه لخير الفرد
وإسعاده وخدمته.

أساس المجتمع في ظل المذهب الفردي:

والمذهب الفردي بناء على الفكرة التي يقوم عليها، لا يمكن أن ينهض ويسود إلا في إطار اسس خاصة تمثل بيئة اجتماعية، أو بنية تحتية لتأسيس هذا المذهب وقيامه، وذلك من خلال مجالين أساسيين هما: المجال الاقتصادي، والمجال السياسي.

(١) في المجال الاقتصادي:

يقوم المذهب الفردي على أساس أن الفرد ولد حراً، أي أن له الحق في أن يزاول نشاطه المادي والفكري والروحي، ويحق له أن يستأثر بعوائد هذا النشاط، وله على سائر الأفراد حق في أن تحترم حريته هذه، بيد أن حماية حقوق جميع أفراد المجتمع تستلزم بالضرورة تقييد الحقوق الخاصة بكل منهم، حتى لا تقوم حرية الفرد وحقوقه على حساب حرية الآخرين وحقوقهم، ولهذا جاء التقابل بين الحق والواجب، ومن ثم تكون وظيفة القانون هي تهيئة الظروف والأسباب التي يستطيع الفرد فيها استعمال حقوقه والتمتع بحريته، والكفيلة - أيضاً - بمنع اعتدائه على حقوق الآخرين، وبمعنى آخر: تقتصر وظيفة القانون على التوفيق بين الحقوق والحريات الخاصة، ومنع التضارب فيما بينها، وتقتصر وظيفة الدولة على حفظ الأمن في الداخل وفي الخارج.

(٢) وفي المجال السياسي:

تقوم فلسفة المذهب الفردي على أساس من فكرة العقد الاجتماعي، تلك الفكرة التي سادت بين فلاسفة القرنين السابع عشر

والثامن عشر، وخلاصة تلك الفكرة تتمثل في أن المجتمع يقوم على أساس عقد أو اتفاق مبرم بين أفراد المجتمع والمحاكم، وذلك بقصد تكوين المجتمع وتنظيمه وتوجيه دفة الأمور فيه، وصلة الأفراد بالمجتمع لا تجبئ إلا من خلال هذا العقد الذي يعطيهم جملة من الضمانات في مواجهة السلطان، وتقصيل ذلك أن الأفراد كانوا يعيشون في الأصل على حالة من العزلة الطبيعية لا يقيدهم سلطان أو حاكم، حتى انتهت تلك الحالة بواسطة هذا العقد الاجتماعي الذي على أول ما عني بوضع حد لتلك العزلة الفطرية بإيجاد حكومة تنازل لها كل فرد عن جزء يسير من حقوقه الطبيعية نظير احتفاظه بالجزء الباقي منها، وفي مقابل أن يشمل السلطان بحمايته، ويوفر له المرافق الحياتية التي تسهل له مسماه في الحياة وتيسر عليه أسباب النشاط حتى يصل غلى ما يريد، فمهمة الدولة - في ظل تلك الفلسفة - تقتصر على حماية الحقوق الطبيعية التي احتفظ بها الأفراد، مع ملاحظة ان فكرة العقد الاجتماعي في نظر أصحابه ليست حقيقة تاريخية واقعية، وإنما هي فكرة افتراضية تصورية لتفسير أساس وجود المجتمع ليس إلا^(١).

نتائج المذهب الفردي:

(١) في هذا المعنى: د. عبد المنعم البدرأوى - مبادئ القانون - ص ٣٠ وما بعدها.

والمذهب الفردي - وفقاً لفلسفته السائدة - يؤدي إلى نتائج في المجالات السياسية والاقتصادية، والقانونية، تتمثل فيما يلي:

(١) في المجال السياسي:

تتمثل أولى نتائج هذا المذهب في أن الناس ولدوا أحراراً ومن حقهم أن يعيشوا أحراراً ومتساوين في الحقوق والواجبات، فالحرية والمساواة هما الحقان الطبيعيان الأساسيان، وتكون مهمة القانون - وكما سبق القول - منحصرة في التوفيق بين الحريات والحقوق الفردية المختلفة، حتى يكفل وجودها واحترامها، ووسيلته في هذا تقييد هذه الحقوق على سبيل التبادل، ولكن دون أن يتجاوز هذا التقييد القدر الأدنى الضروري لضمان حرية المجتمع وحقوقهم، ومن ثم كان دور القانون هنا دوراً يكاد سكون سلبياً، دائرته ضيقة، ومجاله محدود، في حين أن النشاط الفردي يجب ان ينطلق إلى أوسع مدى.

(٢) وفي المجال الاقتصادي:

يؤدي المذهب الفردي إلى إطلاق حرية المنافسة الحرة، ويعتبرها المظهر الاقتصادي للحرية الفردية، ومفاد ذلك أن باب المنافسة الاقتصادية يجب أن يترك مفتوحاً بين الأفراد في المجال الاقتصادي، ولا يجوز للدولة أن تتدخل من جانبها في هذا الميدان.

وفي هذا المجال يرى (آدم سميث) وهو من زعماء الحرية الاقتصادية، أن سعى الأفراد نحو تحقيق حريتهم الاقتصادية الخاصة فقط وإن كان لا يتوجه قصداً دون أن تتوجه إلى مصلحة المجتمع، إلا

أن هذا سيقود بالضرورة إلى أن يستغل كل فرد ماله فيما يعود على المجتمع بالنفع الكبير.

(٣) وفي المجال القانوني:

يترتب على المذهب الفردي نتيجة هامة من الناحية القانونية، هي جعل الإرادة الحرة والعقد في المكان الأول، فما يرتضيه الفرد بإرادته هو الحق والعدل، ومن ثم فإن العقود لا يجوز أن تخضع في إنشائها وفي الآثار المترتبة عليها إلا لإرادة المتعاقدين وهو ما يعرف مبدأ (سلطان الإرادة) ذلك المبدأ الذي استقر منذ زمان بعيد وأصبح أصلاً من الأصول التي تبنى عليها نظريات القانون، وقد تفرعا عن هذا المبدأ نتيجتان مهمتان:

أولاهما: أن كافة الالتزامات والحقوق، بل إن كل النظم القانونية ترجع في مصدرها إلى الإرادة الحرة، حيث لا يلتزم المتعاقدان إلا بإرادتهما، ولا يلتزم أحد بعقد لم يكن طرفاً فيه بنفسه أو بواسطة نائبه، كما أن الأسرة تقوم كذلك على حرية الإرادة والملكية مبنية على حرية الإباداة، بل إن الإرادة في نظر أصحاب هذا المذهب تمثل الأساس في مشروعية العقوبة الجنائية، لأن الذي يخالف القانون قد ارتضى مقدماً جزاء خروجه على النظام في المجتمع وقبل توقيع العقوبة المقررة عليه، وذلك من خلال افتراض العلم بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وعلم الكافة بسرئانها.

ثانيتها: أن دور الإرادة لا يقتصر على إنشاء الالتزامات، بل يُعد المرجع الأساسي في تحدي دما يترتب على هذه الالتزامات من آثار، فما يرتضيه الفرد بإرادته حق وعدل، فمن تعاقد لا يجوز له ان يتحلل من التزامه بدعوى أن غبناً أصابه، أو ظلماً لحق به، ولهذا فإنه لا يجوز للقاضي أن يتدخل بدعوى العدالة ليعدل من التزامات طرفي العقد مهما تمخض هذا العقد عن ضرر بأحد طرفيه.

تقييم المذهب الفردي:

ولم يسلم المذهب الفردي رغم بريق المبادئ التي ينادى بها، والأفكار التي يقوم عليها من النقد فقد انحرف وهو في غمرة تمجيده للحرية الفردية عن مراعاة الصالح الاجتماعي العام وأدى إلى زيادة سطوة الفرد في مقابل سلطة المجتمع، في ظل وهم يقول: إن الصالح العام يتحقق من تلقاء نفسه بمجرد رعاية المصلحة الفردية، فليس الصالح العام هو حاصل مجموع المصالح الفردية الخاصة، بدليل أن هناك مصالح عامة قد لا يفكر الأفراد في القيام بها كالصحة والتعليم والدفاع والسياسة الخارجية، وهم إن قاموا بها لا يستطيعون أن يضمنوا لها ما تستحق من عناية، وما تقتضيه المحافظة عليها من اهتمام.

وقد غالى المذهب الفردي في إطلاق حرية الأفراد بمقولة أن حقوق الأفراد ما هي إلا حقوق طبيعية كانوا يتمتعون بها من قبل انضوائهم تحت لواء المجتمع، في حين أن إثبات الحرية للفرد المنعزل ما هو إلا محض خيال لا وجود له.

وقد ثبت أن إطلاق الحرية للأفراد حتى يفعلوا ما يحلو لهم، أدى إلى تفشى الأنانية والأثرة، وظهور فتن بين أصحاب رؤوس الأموال الذين يملكون كل شيء في مقابل فئة مغلوبه على أمرها لا تملك من أسباب الحياة أى شيء، وافتقد التواصل الاجتماعى بين كافة فئات المجتمع، فتلاشت أهم عوامل الوحدة فيها.

ثانياً: المذهب المجتمعى:

وعلى نقيض المذهب الفردى يقوم المذهب الاشتراكى الذي يعنى بالمجتمع ويسخر الفرد لخدمته وعندئذ يتدخل القانون إلى أقصى حد في شئون الفرد وفي حريته، ولذلك تتسع دائرة القانون فيه. وتقوم فكرة المذهب الجمعى أو كما يعرف بالمذاهب الاجتماعية أو الاشتراكية على أساس أن الإنسان كائن اجتماعى لا يصح أن ينظر إليه كفرد منعزل ومستقل عن المجتمع، لأن الفرد عنصر من عناصرها، كما أن المجتمع ليس جمعاً من الأفراد المستقلين المنعزلين، ولكنه وحده متجانسة يجب أن توجه جهود أفرادها إلى غاية مشتركة هي صالح المجموع.

ومن ثم فإن القانون في هذا المذهب يجب أن يضع الصالح الاجتماعى في الصف الأول، ويجب أن يسخر الفرد لخدمة الصالح العام، والفرد ليس هو مصدر القانون، وإنما مصدر القانون هو الضرورات والحاجات الاجتماعية، وبهذا لا تكون وظيفة القانون هي المحافظة على حقوق الفرد أو تحقيق سعادته، وإنما تكون له وظيفة

اجتماعية هي توجيه نشاطه نحو غاية مشتركة هي الصالح العام للمجموعة.

وبناء على ذلك؛ فإن القانون لا يجوز أن يقف موقفاً سلبياً امام الحرية الفردية، بل يقوم بدور إيجابي من جهة إصلاح ما يوجد بها من عيوب، وسد ما تتطوى عليه من نقص بواسطة القوانين البشرية التي تضعها المجتمع، وشعار المساواة لا يعنى دائماً وجود المساواة الفعلية، لأن الأفراد يختلفون من الناحية الاجتماعية قوة وضعفاً، فهناك الأقوياء كأرباب العمل والضعفاء كالعمال، وهناك شركات لاحتكار جمهور المستهلكين، ومن ثم أصبحت الحرية الفردية والمساواة القانونية سلاحاً في يد الأقوياء ضد الضعفاء ووسيلة لاستغلال القادر للمعدم. والحرية في نظر أصحاب هذا المذهب ليست حقاً طبيعياً، وإنما هي منحة من المجتمع، فالمجتمع هي المصدر الوحيد للحرية الفردية، ومن ثم فإن الفرد لا يتمتع من تلك الحرية إلا بالقدر الذي تتفضل به المجتمع، وهي - بالطبع - لن تعطيه منها إلا ما يتفق مع تحقيق مصالحها، ولهذا فإن منح تلك الحرية في الضيق والسعة مرهون بتقدير المجتمع ووفق حاجتها.

ويختلف أصحاب هذا المذهب في كيفية تحقيق مبادئه تطرفاً واعتدالاً من أجل الوصول إلى المساواة المنشودة، فمنهم من ذهب إلى حد إلغاء وجود الفرد واعتباره ترساً في الآلة، كما ألغى الملكية الفردية

أو احتفاظهم بها في مقابل أن توجه لصالح المجموع تحت رقابة الدولة، على أن تعتبر الملكية وظيفة اجتماعية وليست حقاً خالصاً. ولا يجوز إطلاق العنان للإرادة بدعوى أنها هي صاحبو السلطان في إنشاء ما ترى من روابط وعلاقات ومراكز قانونية، لأن القانون اليد الطولى في هذا المجال، فهو الذي يملك أن يقيد إرادة الأفراد بنصوص أمرة، وقواعد شكلية لا تجد الإرادة حيلة فيها، ولا تملك حيالها ادنى قدر من الحركة أو النشاط، ومن ثم كان القانون أداة طولى في يد الدولة تدخل بها متى شاءت في نشاط الأفراد لتوجهه إلى حيث تريد، ووفق خطط مرسومة، ولهذا يتسع نطاق القانون في هذا المذهب.

ويظهر اتساع نطاق القانون في المذهب الاشتراكي من خلال أمرين هما:

(١) النصوص التشريعية الآمرة:

وهي نصوص يقررها المشرع ويفرض تطبيقها على نحو أمر لا يجوز معه للأفراد أن يتفقوا على ما سواها، وإذا وقع اتفاقهم على سوى ما هو مقرر بتلك القواعد فإن اتفاقهم هذا يقع باطلاً، وفي النهاية لا يصح العمل إلا بالنص الأمر، حتى ولو اتفق الأفراد على سواه.

(٢) الشكلية في النص القانوني:

والشكلية نظام قانوني يفترض القانون أن التصرف لا يصح غلاً إذا جاء مفرغاً فيه، فإذا لم يفرغ التصرف في الشكل المطلوب، فإنه لا يكون له وجود قانوني ويقع باطلاً.

والغالب في الشكل الذي يستلزمه القانون أن يكون هو الكتابة التي قد تكون رسمية كما هو الشأن في هبة العقار، وفقاً لما تقضى به المادة (٤٨٠) مدني، وقد تكون تلك الكتابة عرفية، كما هو الشأن بالنسبة لعقد الشركة المدنية، وفقاً لما تقضى به المادة (٥٠٧) مدني، وقد لا يكون الشكل هو الكتابة، لكنه يتمثل في تسليم الشيء محل التصرف كما هو الشأن في هبة المنقول، حيث لا تتعقد الهبة فيه إلا بتسليم الموهوب المنقول^(١).

ويلاحظ - كما سبق البيان - أن الاشتراكيين لم يتفقوا على القدر الذي يجب أن يتدخل به القانون فمنهم من توسع في هذا لدرجة المناداة بإلغاء الملكية الخاصة وجعل الدولة مالكة لجميع وسائل الإنتاج، ومنهم من ضيق فنادى بالإبقاء على الملكية الخاصة على أن توضع لها قيود بغية تحقيق الخير للجميع^(٢).

تقييم المذاهب المجتمعية:

(١) لا شك أن المذاهب المجتمعية كان لها أكبر الأثر في إظهار المساوي الاجتماعية والمخاطر التي أحاطت بالمجتمع نتيجة الأخذ بالمذهب الفردي، فقد ظهر بجلاء أن سعادة المجتمع وتحقيق الخير به لا يمكن تحقيقه إذا ترك الحرية للأفراد يعملون وفق ما يريدون وحسب ما تقتضيه مصالحهم الخاصة، بل تسبب ذلك في نتيجة عكسية أدت

(١) د. شمس الدين الوكيل - نظرية الحق - ص ١٨١.

(٢) د. جمال الدين طه العاقل - دروس في نظرية القانون - ص ٣٩.

إلى كثير من الظلم الاجتماعي لأن بعض الطبقات قد أساءت استعمال الحقوق الخاصة في الظلم، وانحرفت عن مجال احلماية المقررة لها قانوناً حتى غدت عقبة في سبيل تقدم المجتمع، وحسرت وسائل الإنتاج من خلال تفرغ العمال للإدارة والقيادة.

(٢) ومن عيوب المذهب الاشتراكي أن المغالاة كان من شأنها أن أدت إلى تدخل الدولة في شتى الميادين تدخلاً أسيء استخدامه إلى إنعدام الحافز الشخصي، وبالتالي ضياع أثر المجهود الفردي، لكن يلاحظ أن كثيراً من الدول التي تأخذ بهذا المذهب لم تصل إلى هذا الحد بل لم تغال في تدخلها إلى أوجه النشاط المختلفة، فهي تحترم الحرية الفردية في حدود ما يسمح به القانون، كما تحترم الملكية الفردية مع وضع قيود عليها حتى لا تخرج عن أداء مهمتها باعتبارها وظيفة اجتماعية.

ويمكن القول: أن المذهب الاشتراكي في صورته المعتدلة تعتنق معظم دول العالم في وقتنا الحالي، وإذا كان الفكر القانوني المعاصر في مصر، قد بدأ يجافيه إلى حد كبير على نحو ما سنرى.

أثر المذهبين في القانون المصري:

ولقد كان لهذين المذهبين أثر بارز في القانون المصري، لكن هذا الأثر اتخذ كشل التتابع التاريخي، أو الانتقال في الأخذ بأى منهما من مرحلة تاريخية غلى أخرى، فأخذ بالمذهب الفردي في بدايات نشوئه، ثم عدل إلى المذهب الاشتراكي في صورة تكاد تكون طاغية

في المذهب الفردي، وتؤكد سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج، ثم بدأ المد الفكري للمذهب الفردي يعود مرة ثانية إلى ساحة الحياة القانونية والاقتصادية من خلال ما يعرف بخصخصة وسائل الإنتاج أو العودة بالنشاط الاقتصادي إلى دائرة النشاط الفردي، ويمكن إلقاء الضوء على ذلك:

في بداية النشاط التشريعي، عندما وضعت المجموعات القانونية المصرية في عام ١٨٧٥ (المجموعات المختلطة) وعام ١٨٨٣ (المجموعات الأهلية) تميزت هذه المجموعات بنزعة فردية واضحة، وجاءت تلك المجموعات تعبيراً صادقاً عن فكر المذهب الفردي.

ولما كانت الملكية هي العلامة الدالة على شكل النظام والفكر الاقتصادي السائد في المجتمع فإنها كانت تعرف الملكية بما يبرز تلك النظرية الفردية الخالصة، وكانت تنص على أن حق الملكية هو: "حق المالك في الانتفاع بملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة"، ولم يتضمن قيوداً على حرية المالك في الانتفاع بملكه، ولا إلى حدود استعمال تلك الملكية.

كما كانت تلك المجموعات تطلق العنان لمبدأ سلطان الإرادة، وتعمل مبدأ العقد شريعة المتعاقدين إلى أبعد مدى، ولم يكن ثمة قيد على حرية الإرادة سوى ذلك القيد العام الذي لا يقضى بعدم الخروج على النظام العام والآداب في المجتمع.

ومع تطور الزمن بدأ المشرع المصري يتأثر بالتيارات الاشتراكية التى بدأت ريحها تهب على مصر في منتصف القرن الماضى، فأصدر بعض التشريعات المنظمة لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، واعترف بالنقابات العمالية، مع ما تتطوى عليه تلك التشريعات من مخالفة واضحة لمبدأ سلطان الإرادة، الذي يعتبر من ثوابت المذهب الفردى، كما أصدر قانون التعويض عن إصابات العمل الذي يسأل به صاحب العمل عن الحوادث التى تصيب العامل، حتى ولو لم يثبت خطأ من جانبه ادى إلى وقوع الإصابة، وقد حل القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ المعروف بقانون العمل الموحد محل تلك التشريعات، كما صدر في نفس الوقت القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ الخاص بالتأمينات الاجتماعية الذي ينظم التأمين ضد إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة.

ولما صدرت المجموعة المدنية الجديدة المعمول بها حالياً والتي بدأ سريانها ابتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ جاءت مدعمة لاتجاه معتدل ينطلق من المذهب الفردى بعد تهذيبه في بعض النواحي على أساس الفكر الاشتراكي، وفي هذا تقول المذكرة الإيضاحية: "والاتجاه الرئيسى الأخير ان المشروع من ناحية ما يقوم ليه من اسس اجتماعية واقتصادية إنما يجارى نزعات عصره، فلا يقف من الديمقراطية عند معناها القديم، بل يساير ما لحق لها من تطورات عميقة، ستكون الآن بعد أن وضعت الحرب أوزارها أبعد مدى وأبلغ أثراً، فالمشروع لا يقدر

حرية الفرد إلى حد أن يضحي من أجلها بمصلحة المجتمع، ولا يجعل من سلطان الإرادة المحور الذي تدور عليه الروابط القانونية، بل هو يوفق ما بين حرية الفرد، ومصلحة المجتمع، ثم هو بين الفرد والفرد لا يترك القوى يصرع الضعيف بدعوى وجوب احترام الحرية الشخصية، فليس الفرد حراً في أن يتخذ ما هيأته له النظم الاجتماعية والاقتصادية من قوة تكنه ليتعسف ويتحكم، لذلك يقف المشروع إلى جانب الضعيف فيحميه كما فعل في عقود الإذعان عندما جعل تفسير ما اشتمل عليه من شروط تعسفية محلاً لتقدير القاضى، وكما فعل في النصوص الخاصة بالاستغلال عندما أوجب على القاضى أن يتدخل لنصرة المتعاقد إذا استغلت حاجته أو طيشه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه، وكما فعل في حماية العامل عندما أحاط عقد العمل بسلسلة قوية من الضمانات تدراً عنه تعسف رب العمل، وهو إلى كل هذا وقبل كل هذا يضع مبدءاً عاماً ينهي فيه عن التعسف في استعمال الحق.

ويبدو المشروع كذلك ظاهر الرفق بالمدين، فهو يوجب على القاضى أن يتدخل لحماية المدين المرهق إذا طرأت ظروف استثنائية لا يمكن توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، فوجب القاضى إذ ذاك أن يوازن بين مصلحة المتعاقدين، وأن ينقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

وتقول المذكرة: ويقيد المشروع حق الملكية فيجعل لهذا الحق وظيفة اجتماعية لا يجوز أن ينحرف عنها المالك، فهو في أول نص يعرف فيه الملكية فيقرر أن لمالك الشيء - ما دام ملتزماً حدود القانون - أن يستعمله وأن ينتفع به وأن يتصف فيه دون أي تدخل من جانب الغير، بشرط أن يكون ذلك من التطبيقات ما يؤكد هذا الاتجاه، فالمالك لا يجوز له أن يغلو في استعمال ملكه إلى حد يضر بملك الجار، فحيث يتعارض حق المالك مع مصلحة عامة، بل ومع مصلحة خاصة هي أولى بالحماية، فالمشروع يقيد من حق الملكية رعاية للمصالح المشروعة وتحقيقاً لمبدأ التضامن الاجتماعي.

وتختتم المذكرة الإيضاحية ذلك بقولها: كل هذا دون غلو ولا إسراف، فلا تزال حرية الفرد وسلطان الإرادة وحقوق الدائنين واحترام الملكية محلاً لنصوص كثيرة في المشروع تلمح فيها أثراً ظاهراً للتوفيق ما بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، وبذلك يكون المشروع قد سجل بأمانة ما تمخض عنه القرن العشرون من مبادئ العدل الاجتماعي، فهو يحمل طابعاً قوياً من حضارة العصر ومدنية الجيل. وهكذا أصدرت المجموعة المدنية المصرية متأثرة بالاتجاهات الاشتراكية الجديدة في بعض نواحيها وذلك بقصد تلافى مساوئ إطلاق المذهب الفردي.

(١) هذا وقد قوى تأثير التيار الاشتراكي في مصر بعد ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢، وأصبح من ضمن أهداف الحكومة إقامة مجتمع

ديمقراطى اشتراكى تعاونى، وكان لهذا التوجه صده فى نواحى التنظيم القانونى المختلفة، فصدرت قوانين الإصلاح الزراعى بقصد القضاء على الإقطاع وتحديد الملكية الزراعية، وأجيز للعمال الزراعيين تكوين نقابات للدفاع عن مصالحهم المشتركة، وصدرت قوانين التأمين.

كما برز الطابع الاشتراكى فى أول دستور قامت الثورة بوضعه وأعلن فى ١٦ يناير سنة ١٩٥٦، وقد نص فى مادته الرابعة على أن التضامن أساس المجتمع المصرى، وأن الاقتصاد القومى يسير وفق خطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية، ونص فى المادة (٣٥) على أن: "الملكية الخاصة مصونة، ولا تُمس إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدماً وفقاً للقانون. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدماً وفقاً للقانون".

كما نص الدستور الذى صدر فى سنة ٢٠١٤م على أن مصر دولة تطلعها ديمقراطى اشتراكى وأن الأساس الاقتصادى لها هو النظام الاشتراكى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويهدف إلى تزويد الفوارق بين الطبقات (مادة ٤) وأن التضامن الاجتماعى أساس المجتمع (مادة ٧).

ثالثاً: الفكر القانونى المعاصر:

بيد أن تلك النزعة الاشتراكية الواضحة والتي وجدت لها اعتباراً في تشريعات الإصلاح الزراعى والتأمين، والتشريعات العمالية التى قامت بتقوية قبضة العمال والفلاحين على وسائل الإنتاج، وأتاحت لهم خرية تكوين النقابات والمشاركة في مجالس الإدارات، والتنظيمات النقابية والمجالس التشريعية بما لا يقل عن خمسين بالمائة لعدد أعضائها وما صاحب ذلك من النظم التى وجدت لها تطبيقاً واسعاً في مجال الملكية الخاصة، والعلاقة بين الملاك والمستأجرين على نحو ينظر إلى العمال والمستأجرين على أنهم الطرف الضعيف الذي يجب حمايته، وكان الطريق لذلك هو شمولهم بالحماية من خلال النصوص القانونية الأمرة التى لا يجوز لأحد الخروج عليها، بل إن القانون قد وصل إلى مدى أبعد من هذا حين فرض للعمال حقوقاً ولم يجر لهم أنفسهم أن يتنازلوا عنها، بمقولة أنه يجب حماية العمال من أنفسهم، وقد أدى ذلك الغلو في مناصرة طرف على آخر إن مالت الكفة لصالح العمال والمستأجرين، فلم يصونوا النعمة، ولم يحسنوا استعمال السلطات الممنوحة لهم، فأهملوا الإنتاج وفوجئنا بمشروعات اقتصادية كانت قبل تلك التغييرات القانونية عملاقة في إنتاجها ضليعة التأثير في الدخل القومى، مثل مصانع النسيج، والحديد والصلب، والألبان والمنتجات الزراعية، يحقق خسارة كبيرة من جراء تلك النظم الاقتصادية التى ركزت على تدليه العمال دون مراعاة للمصلحة العامة، ووضع الضوابط التى تكفل زيادة الإنتاج أو على الأقل

المحافظة عليه، فكان العمال حريصين على ممارسة حقوقهم دون أدنى اهتمام بالواجبات الملقاه عليهم في حماية الإنتاج وزيادته، واستبان بعد فترة ان ما قيل بهذا الصدد، لم يتجاوز مرحلة الشعارات البراقة، والعبارات الرنانة، التي لم تجد لها من الواقع ما يصدقها، وصحا الناس على الخسارات تلو الخسارات تصيب قلاع الإنتاج الصناعي، بل والاستهلاكي، فأصبحت المؤسسات الاستهلاكية التي أنشئت لحماية الناس من استغلال رأس المال الفردي، هي الأخرى تلحق بقوافل المؤسسات الخاسرة من جراء التسيب والاختلاس وعدم الحرص على المصلحة العامة، وقصور ادوات الرقابة عن ملاحقة العمال، حيث لا يجوز توقيع العقاب عليهم إلا بإجراءات مشددة تجعلهم في الأغلب الأعم محصنين من توقيع تلك الجزاءات، بل ومن الفصل، وكان لابد من التغيير الذي يستهدف تصحيح ذلك الوضع عن طريق الخصخصة، والعودة إلى الفكر الرأسمالي، وأفكار المذهب الفردي في الإنتاج وتعيين العمال، وما زال ذلك التوجه في بدايته، لكنه يشهد تطوراً ملحوظاً.

المبحث الثانى

نطاق تدخل القانون من خلال

القواعد الآمرة والقواعد المكملة

وفي نطاق تدخل القانون لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، تنقسم القواعد القانونية إلى قسمين هما القواعد القانونية الآمرة، والقواعد القانونية المكملة، ونبين ذلك في مطلبين:

المطلب الأول

القواعد القانونية الآمرة

يعرف الفقه القواعد القانونية الآمرة، بأنها جملة القواعد القانونية الباتة أو الناهية التى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، أو استبعاد أحكامها، وهذه القواعد مفروضة فرضاً على الأشخاص لا يملكون حيالها أن يتصلوا منها، أو يعملوا ما يخالفها، ولذلك فإن المشرع غالباً ما يوجب إلى تنظيم سلوك الأفراد من خلال تلك القواعد، إذا كانت المصلحة التى يراد حمايتها متعلقة بالنظام العام أو الآداب في المجتمع، أو كان أمرها متعلقاً بالمصالح الأساسية فيه، وذلك يغل المصالح التى تنظم هيئات الدولة أو تلك التى تتعلق بالأمن الداخلى، أو بالأمن الخارجى، أو نظام الأسرة، أو تحديد شكل السياسة الاقتصادية المتبعة، أو تحديد شكل التمثيل البرلمانى بنسبة معينة من العمال والفلاحين، مثل ما هو حاصل الآن بتحديداتها من خلال النص

الآمر الذي لا يسمح بان تقل نسبة تمثيل تلك الفئات عن خمسين بالمائة من جملة الأعضاء الذين يمثلون الأمة.

مجال القواعد القانونية الآمرة:

ومن خلال تعريف القواعد القانونية الآمرة يبدو أن مجالها يتعلق بالمصالح الأساسية في المجتمع والتي لا يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها، ومنها القاعدة القانونية التي تحرم القتل فلا يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها، ولو كان ذلك برضا المجنى عليه، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالنصوص التي تحرم الإتجار في المخدرات، فهذه النصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ولو وقع مثل هذا الاتفاق، فإنه يكون باطلاً مطلقاً ومن هذا القبيل: القاعدة القانونية التي تحرم التعامل بالربا، وتضع سعراً أعلى للعائد لا يجوز للأفراد الزيادة عليه، فهذه القاعدة تعتبر من قبيل القواعد الآمرة، وأيضاً القواعد القانونية المتعلقة بالمحرمات من النساء، وحق الزوج في إيقاع الطلاق، وواجب تربص المرأة فترة العدة عقب الطلاق أو الوفاة، والأحكام المتعلقة بالنسب والضرائب وكل اتفاق على ما يخالف تلك القواعد يعتبر اتفاقاً باطلاً لمخالفته للنظام العام والآداب^(١).

(١) د. عبد الناصر العطار - مبادئ القانون - ص ٥٢ وما بعدها.

المطلب الثانى

القواعد القانونية المكملّة أو المفسرة

والقواعد القانونية أو المفسرة، هي تلك التى يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها، ووجودها لا يؤثر في تزجة الإرادة إلى ما سواها، ولا تؤدى تلك المخالفة إلى بطلان الإرادة، وقد صاغها المشرع لتكون أداة في يد الناس يستأنسون بها عند صياغة اتفاقاتهم أو إنشاء عقودهم، فيهددون بها عند صناعة تلك الاتفاقات، وهي هنا تمثل الرضا المفترض بين الأطراف، بمعنى أنهم إذا ما فكروا في إنشاء عقودهم فإنهم لم يبتعدوا - غالباً - عنها، فهي تنظم السلوك الخاص بالأفراد والذي لا يتعلق بالمصالح الأساسية للمجتمع.

فمثلاً في عقد البيع جرت العادة أن يتفق المتعاقدان فيه على المبيع والثلث ومن النادر أن يتفقا على تحديد وقت تسليم البيع ومكانه أو ضمان عيوبه، وفي هذه الحالة يقوم القائمون بمعالجة هذه المسائل بقواعد مقررة ومكملة لاتفاق المتعاقدين، ومن ثم يكون للمتعاقدين حرية الاتفاق على تحديد وقت التسليم، أو مكان آخر لتسليم المبيع غير الوقت أو المكان الذي حدده القانون^(١).

(١) د. جمال الدين العاقل - السابق - ص ٧٤.

وتسمى هذه القواعد، بالقواعد المقررة، أى التى تقرر الحكم الذي يفترض أن أطراف العقد سيتفقون عليه لتنظيم العلاقة فيما بينهم، وتسمى أيضاً بالقواعد المفسرة، لأنها تفسر إرادة المتعاقدين الغامضة.

حدود الإلزام في القواعد المكلمة:

وليس معنى أن تلك القواعد مكلمة، إنه يجوز استبعاد حكمها أو تلافى تطبيقها أو أنها ليست ملزمة، لأن القواعد القانونية سواء أكانت قواعد أمرة أم مكلمة تعتبر ملزمة، لأن الإلزام شرط من شروط إنشاء القاعدة القانونية، وغاية ما في الأمر، إن أى قاعدة قانونية أمرة، كانت أو مكلمة، لا تنطبق إلا في حالة توافر الشروط اللازمة لانطلاقها، ومن هذه الشروط بالنسبة للقاعدة المكلمة عدم اتفاق الأفراد على استبعاد حكمها، بمعنى أنه إذا لم يتم الاتفاق على ما يخالف حكمها أصبح هذا الحكم ملزماً لهم^(١).

كما أنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض الشراح من أن القواعد المكلمة اختيارية ابتداء ملزمة انتهاء معنى أنها تكون غير ملزمة قبل الاتفاق على ما يخالفها، أو بعد الاتفاق على مخالفتها وملزمة عند عدم الاتفاق على مخالفة أحكامها، لأن القواعد القانونية لا يتصور وجودها إلا إذا كانت ملزمة في الابتداء والانتهاء، ولا يمكن القول بتغيير طبيعتها لسبب راجع إلى إرادة الأفراد، غاية ما في الأمر

(١) د. عبد الناصر العطار - السابق.

أن تطبيق القواعد المكملة معلق على شرط عدم الاتفاق على مخالفتها، وذلك على عكس القواعد الآمرة، فإن تطبيقها ليس معلقاً على هذا الشرط^(١).

ويهدى المشرع في وضع القواعد المكملة لإرادة الأفراد باعتبارين:
أولهما: أنه يهدف في بعض الحالات إلى تلمس الإرادة المفترضة للطرفين، بمعنى أنه ينظم العلاقة القانونية على النحو الذي كانت إرادة الطرفين سوف تتجه إليه، لو أنهما أعلنوا عن إرادتهما صراحة اتفاق خاص، وذلك على نحو ما فعله المشرع في تنظيمه للعقود التجارية كالبيع والإيجار وغيرهما.

ثانيهما: أنه في حالات أخرى يراعى في هذا التنظيم المكمل لإرادة ذوى الشأن العادات الجارية في المعاملات، أما القواعد الآمرة فقد فرضها المشرع على إرادة الأفراد فرضاً، فتلك المسائل التى قدر أنها وثيقة الصلة بالمجتمع، والأسس التى يقوم عليها تنظيمه، وهى مسائل لا يجوز أن تترك لإرادة الأفراد الحرة.

(١) د. جمال الدين العاقل - ص ٧٦، د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٩٣، د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٣٢ وما بعدها، د. توفيق فرج - ص ٨٨، د. أحمد سلامة - ص ٥٥، د. حسن كيرة - فقرة ١٦، شمس الدين الوكيل - فقرة ٦٣.

المطلب الثالث

معيار التفرقة بين

القواعد الآمرة و القواعد المحملة

وإذا كانت القواعد القانونية بتقسيمها إلى أمرة، ومكملة يترتب عليها تلك الآثار القانونية الكبيرة، يكون من المهم بيان معيار التفرقة بين هذين النوعين من القواعد، ويكاد الفقه يتفق على أن هناك معيارين للتفرقة بينهما، هما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي.

الفرع الأول

المعيار الشكلي

والمعيار الشكلي في التفرقة بين القواعد القانونية الآمرة، والقواعد المحملة يستتبط من صياغة النص أو عباراته، فصياغة النص يمكن أن تدل على أننا بصدد قاعدة أمرة أو مكملة، وذلك كما لو ورد في النص مثلاً ما يدل على عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو تقرير بطلان الحكم الذي يجيء مخالفاً لتلك القاعدة، أو تقرير عقاب لمن يخالفها، ومن ذلك:

(١) ما تنص عليه المادة (٤٨) مدني، من أنه: "ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل من أحكامها".

(٢) وما تقضى به المادة (١٣١) مدني، من أنه: "لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة، ولو برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون"، وما تقضى به المادة (٤٩) مدني، من أنه: "ليس لأحد

النزول عن حريته الشخصية"، وما تقضى به المادة (١٧، ٣١) مدني، على أنه: "يقع باطلاً كل شرط يقضى بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع"، وما تقضى به القانون من أنه يقع باطلاً رهن المال المستقبل، وما تنص عليه المادة (١٠٣) من قانون العقوبات، بقولها: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يُعد مرتشياً، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، ويبدو من تلك النصوص وغيرها أنها قد وردت بصيغة أمرة تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عليها أو أن يخالفها، وإلا فإن جزاء ذلك الخروج سوف يكون هو الإهدار أو البطلان أو عدم الاعتداد بذلك الاتفاق.

أما إذا ورد في النص القانوني ما يدل على العمل بحكمه إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بخلافه، فإن ذلك يدل على أن النص من النصوص المكملة أو المفسره، وذلك كما في النصوص الآتية:

(١) تنص المادة (٤٥٦) مدني، على أنه: "يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك".

(٢) تنص المادة (٤٤٨) مدني، على أن: "مصرفات عقد المقايضة، وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك".

(٣) وما تنص عليه المادة (١٠٣) مدني، بقولها: "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك".

(٤) ومن ذلك ما تقضى به المادة (٢/٥٨٦)، بقولها: "يكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك".

ففي الأمثلة المتقدمة وغيرها يفصح منطوق النص وعباراته عن طبيعة الالتزام فيه، وأنه نص مكمل أو نص آمر^(١).

الفرع الثاني

المعيار الموضوعي

كثيراً ما لا تأتي النصوص القانونية بمثل هذا الوضوح في الدلالة على أن النص آمر أو مكمل، وفي هذه الحالة يجب النظر إلى الأساس الذي بنى عليه الحكم الوارد فيها، ومدى اتصاله بالمصالح الأساسية للمجتمع أو عدم اتصاله بها، ومن المقرر أن الأحكام القانونية المتصلة بالنظام العام والآداب العامة هي قواعد أمرة أو ناهية لا يجوز للأفراد أن يخرجوا عليها، ولهذا تخدم معرفة المقصود لكل من النظام العام والآداب.

أولاً: المقصود بالنظام العام:

(١) د. جمال الدين العاقل - ص ٧٨، د. عبد المنعم البدرأوى السابق - ص ٩٤.

يمكن القول: أن النظام العام في المجتمع هو النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والخلقى الذي يقوم عليه كيان المجتمع في الدولة، كما ترسمه القوانين المطبقة فيها، فكل ما يتصل بالمصالح الأساسية العليا للنظام الاجتماعي في بلد معين هو من النظام العام، وبعبارة أخرى فإن قواعد النظام العام هي القواعد التى تعتبر أساساً للقانون في الدولة^(١).

مرونة فكرة النظام العام:

وفكرة النظام العام - على نحو ما سبق - تعتبر فكرة مرنة أو نسبية، فهي تتغير من بلد إلى بلد، وفي البلد الواحد تتغير من زمان إلى زمان، وهذا أمر طبيعى، لأن المجتمع في تطور، وتتغير أسس تنظيمه مع تغيير المبادئ والعقائد والمذاهب الفكرية والاجتماعية والسياسية السائدة فيه وتكفى الإشارة هنا إلى اختلاف الدول في قيامها على أساس المذهب الفردى، أو على أساس المذهب الاشتراكى، لأن دائرة النظام العام تضيق إذا كان المذهب السائد في الدولة هو المذهب الفردى الذي يقدر مبدأ الحرية الفردية، ويترك للأفراد حرية واسعة في تنظيم روابطهم الخاصة، ويقدر مبدأ سلطان الإرادة، أما المذهب الاشتراكى فمن شأنه زيادة تدخل الدولة في الشؤون الخاصة فترتفع بعض المصالح الخاصة إلى مرتبة المصالح العامة الجديرة بالحماية،

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٩٥ وما بعدها.

ولهذا تكثر القيود على حرية التعاقد، حماية للضعفاء من الاستغلال^(١).

ومن ثم كان ما يعتبر من النظام في بلد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، بل قد يعتبر نقيضه من النظام العام، وذلك كالجمع بين أكثر من زوجة، وحق الطلاق، يعتبران من النظام العام في الدول الإسلامية، بحيث لا يجوز النزول عنهما، وكل اتفاق يستبعد حرية المسلم في الزواج بأكثر من واحدة، وحقه في تطليق زوجته هو اتفاق باطل لمخالفته للنظام العام في بلد إسلامي، وهذا عكس ما هو مقرر في كثير من البلاد الغربية، حيث يعتبر عكسه من النظام العام.

كذلك فإن ما يعتبر من النظام العام في وقت معين قد لا يعد كذلك في زمان آخر، فقديمًا ذهبت المحاكم الفرنسية إلى أن الاتفاق على تقييد حق المالك عند التصرف في ملكه يعتبر مخالفًا للنظام العام، وخروجه على أساس من الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها المجتمع وهو حرية تداول الأموال، وعدم حبسها عن التعامل، ولكن المحاكم الفرنسية عادت وأجازت أن يتضمن التصرف الناقل للملكية

(١) المرجع نفسه - ص ٩٦، د. سليمان مرقس - ص ٩٩، د. عبد المنعم الصدة - فقرة ٥٢، د. جميل الشرقاوي - فقرة ٢٧، د. أحمد سلامة - فقرة ٣٨، د. شمس الدين الوكيل - فقرة ٦٧، حسن كيرة - فقرة ١٩.

كالبيع أو الهبة أو الوصية شرطاً يمنع الممتلك من التصرف لمدة معقولة متى وجدت مصلحة خاصة جدية تبرر هذا المنع^(١).

وفي النهاية؛ فإن المشرع لم يحدد فكرة النظام العام، مؤثراً ترك تحديدها للقضاء، فالقاضي في خصوص فكرة النظام العام هو الذي يقع عليه عبء تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر، وهو في سبيل ذلك يستعرض المبادئ الأساسية للنظام الاجتماعي والقانوني في البلد، ويستخلص منها مبادئ النظام العام فيه، وهو في ذلك خاضع لرقابة محكمة النقض، ومن ثم يستطيع القضاء أن يتأثر بالتيارات الخلقية، والاجتماعية والسياسية التي تسود بلده في كل عصر وزمان^(٢).

النظام العام في إطار القانون العام:

تعتبر معظم أحكام القانون العام من النظام العام، وهذا أمر يتفق مع طبيعة تلك القواعد لأن القانون العام يشمل القواعد التي تبين نظام الدولة من النواحي السياسية والدستورية والإدارية والمالية، وتحمي هذا النظام من أى اعتداء، فكل ما يتعلق بالقانون الدستوري هو من النظام العام، فالتنظيم السياسي للدولة والحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي (الدستور) كلها من النظام العام، ولذلك فإنه لا يجوز - مثلاً - الاتفاق على النزول عن حق الانتخاب أو استعماله

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٩٧.

(٢) المرجع نفسه.

على وجه معين لصالح أحد المرشحين، ولا يجوز لأحد النزول عن حرياته العامة بجميع صورها، كحرية العقيدة مثلاً، أو حريته في التنقل، أو في سائر مظاهر الحرية الشخصية، ولا يجوز أن تكون الوظيفة العامة موضوع تعامل، فلا يجوز النزول عن الوظيفة العامة لصالح شخص آخر غير الموظف، وفي القانون المالي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من الضرائب التي أوجبها القانون، وفي القانون الجنائي يبطل الاتفاق على الجريمة أو على النزول عنها من جانب المجنى عليه، ولا يعتد برضائه بها.

وقوانين التنظيم القضائي كلها من النظام العام، لاتصالها بتنظيم السلطة القضائية^(١).

النظام العام في دائرة القانون الخاص:

أما في دائرة القانون الخاص، فإن فكرة النظام العام تعتبر أقل ظهوراً، سيما في تلك الشرائع التي يسودها المذهب الفردي، أما في البلاد ذات النزعة الاشتراكية فإننا نجد أن فكرة النظام العام تدخل في القانون الخاص إلى مدى بعيد، ولهذا أصبح القانون الخاص في تلك البلاد يقترب من القانون العام ويتطبع بطبعه على أن دخول فكرة النظام العام في مجال القانون الخاص ليس بدرجة واحدة، لأن هذه الروابط تنقسم إلى روابط الأحوال الشخصية، وروابط المعاملات المالية

(١) د. عبد المنعم البدرأوى المرجع السابق - ص ٩٨.

والنظام الغام لا يدخل هذين النوعين من الروابط بدرجة واحدة، ولهذا ينبغي بيان الفرق بينهما:

(١) النظام العام وروابط العلاقات الأسرية:

الأحوال الشخصية؛ هي المسائل المتصلة بحالة الشخص وأهليته، وبنظام الأسرة، ولما كانت الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، كان من الطبيعي أن يكون تنظيمها أمراً لاتصاله بالنظام العام، وذلك كالزواج، وما ينشأ عنه من العلاقات الأسرية، وحالة الشخص القانونية وأهليته، كل ذلك من الموضوعات الآمرة التي لا يجوز تركها لحرية الإرادة، ومن ثم كانت جميع القواعد المنظمة للأهلية قواعد أمرة، ولهذا نصت المادة (٤٨) مدني، على أنه: "ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها، فالسن التي يحددها القانون للرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، فلا يجوز إنقاصها أو زيادتها بالاتفاق، ولا يجوز للقاصر أن يتنازل عن حقه في إبطال العقد عند بلوغه، وكل نزول عنه - وقتئذ - يُعد باطلاً وذلك كالطلاق والحضانة، والطاعة والولاية، لأن تلك السلطات لم تمنح للمصلحة الخاصة لشخص من منحت له، وإنما لمصلحة الأسرة كي تقوم على أساس متين.

(٢) النظام العام والروابط المالية:

ومن المعلوم ان تنظيم الروابط المالية متروك - بحسب الأصل - لحرية الأفراد، لأن مبدأ سلطان الإرادة هو أساس هذا التنظيم، لكن بعض نواحي الروابط المالية والاقتصادية والاجتماعية قد يقتضي أن

تنظمها الدولة بقواعد أمرة، ويمكن إرجاع المسائل المالية المتصلة
بالنظام العام فيما يأتي:

(أ) القواعد المتصلة بالشكل:

القاعدة العامة ان التصرفات القانونية رضائية، أى تتم بمجرد
التراضى دون حاجة إلى أن تفرغ في شكل معين كالكتابة مثلاً، بيد أنه
استثناء من هذا الأصل، قد يشترط المشرع إفراغ التصرف في شكل
معين، وإلا فلا يعتد به ولا يرتب عليه الأثر الذي أراده المتعاقدان،
وذلك كاشتراط الشكل الرسمي المتمثل في اتمام التصرف امام موظف
رسمى هو موثق العقود، وذلك في بعض العقود كالهبة (مادة ٤٤٨)
مدني، التى تنص على أنه: " تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت
باطلة"، وكالمادة (١٠٣١ مدني) التى تنص على أنه: " لا ينعقد الرهن
إلا إذا كان بورقة رسمية، فالشكل الذي يجب ان ينعقد في إطاره هذان
العقدان يعتبر من انلظام العام، فإذا يتم العقد في إطاره فإنه ينعقد
باطلاً.

(ب) القواعد المتعلقة بمراعاة أحد المتعاقدين:

وكما هو معروف، فإن القانون يلقي على عاتق كل مسئول
حماية مصالحه ورعايتها في العقد، ولكن المشرع لاحظ أن مركز
المتعاقدين في بعض العقود لا يكون متساوياً، بحيث يكون أحدهما
ضعيفاً والآخر قوى يمكن أن يفرض عليه شروطاً تعسفية أو يستغله
على نحو ما، ولهذا تدخل لحمايته بنصوص أمرة لا يجوز استبعاد

حكمها باتفاق الطرفين، وذلك مثل القواعد المنظمة لعقد العمل، ولعقد التأمين، والمقكرة لحماية أحد المتعاقدين في عقود الإذعان، ومن أثر الظروف الطارئة، وكذلك القواعد المقررة لحماية الإرادة من العيوب التى يمكن أن تعتريها كالتدليس أو الاستغلال أو الإكراه.

(ج) القواعد المنظمة لحقوق العينية العقارية:

القواعد المتعلقة بتنظيم الملكية تعتبر قواعد أمرة، لأن الملكية هي من النظم الأساسية في المجتمع.

ومن ذلك القواعد المتعلقة بشهر التصرفات المتعلقة بالملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى التى ترد على العقارات كالارتفاق والرهون، ومقتضى قواعد الشهر، أن الملكية أو الحق العيني على العقار لا ينشأ، أو لا يحتج به على الغير إلا إذا تم شهره، وفقاً للإجراءات التى ينظمها قانون الشهر العقارى، فهذه القواعد تعتبر من النظام العام التى لا يجوز الخروج عليها.

(د) القواعد المتعلقة بالصالح الاقتصادى العام:

وذلك مثل تنظيم الائتمان العام، وتسعير بعض السلع تسعيراً جبرياً، والقوانين التى تصدر في أوقات الأزمات بإعطاء آجال للمدينين، والقوانين التى تفرض لأوراق البنكنكوت سعراً إلزامياً، والقواعد المتعلقة بتحديد سعر العائد، كل تلك القواعد تعتبر أمرة وذلك لتعلقها بأمور تعتبر من النظام العام في المجتمع.

ثانياً: الآداب العامة:

والآداب العامة تمثل جزءاً من انلظام الأخلاقى الذى يعتبره المشرع أساساً للتنظيم القانونى فيه، وهى تتكون مع مرور الأيام بفعل المعتقدات الموروثة، وما جرى عليه العرف وتواضع عليه الناس، ولهذا فإن تلك القواعد تعتبر غير منضبطة، كما تعتبر نسبية ومرنة على نحو ما هو معروف فى النظام العام.

كما أن فكرة الآداب العامة - هى الأخرى نسبية - تختلف باختلاف الزمان والمكان فيما يعتبر فى بلدنا مخالفاً للآداب العامة، قد لا يكون كذلك فى بلد آخر، وما يعد من الآداب العامة داخل المجتمع فى وقت معين لا يعتبر كذلك فى وقت آخر، وذلك مثل عقد التأمين على الحياة اعتبرته كثير من الشرائع فى أول ظهوره من العقود المخالفة للآداب والنظام العام أيضاً، وذلك بدعوى أن حياة الإنسان لا يجوز أن تكون موضوع تعامل ولأن وفاة الإنسان لا يجوز أن تكون مصدر اغتناء لغيره، ولأنها خشيت أن يتعجل المستفيد وفاة المؤمن عليه، ثم ما لبثت هذه القوانين أن اختلفت نظرتها للتأمين على الحياة فأقرته، ووضعت له القواعد التى تكفل عدم خروجه على الآداب العامة وأصبح اليوم نظاماً مسلماً به فى كل الشرائع.

ومن تطبيقات فكرة الآداب العامة، إبطال القضاء للاتفاقات التى يقصد منها إيجاد علاقة جنسية غير مشروعة او الاستمرار فيها، وكذلك الاتفاقات المتعلقة بممارسة الأنشطة المحرمة كالدعارة والمقامرة

والرهان، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالاتفاق على أمر يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يعتبر باطلاً لذلك^(١).

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٣٨٧، د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٠٢، والوسيط السنهوى - ج ١ - فقرة ٢٢٨، د. عبد الودود يحيى - ص ٧٠، د. جمال الدين العاقل - ص ٨٤ وما بعدها.

الباب الثانى

أنواع القواعد القانونية

ينقسم القانون في الجملة إلى قانون عام وقانون خاص، وهذا التقسيم قديم يرجع إلى عهد القانون الروماني، لكنه مع قدمه ما زال قائماً ومعمولاً به حتى اليوم.

والقانون العام، يطلق ويراد به جملة القواعد التي تنظم كيان الدولة والعلاقات التي تكون كرفاً فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان، ويشمل مجموعة القواعد التي تبين نظام الدولة الأساسى، وتنظيم العلاقات التي تنشأ بين السلطات المختلفة، وتلك التي تنشأ بين السلطات المختلفة، وتلك التي تنشأ بين الدولة وغيرها من الدول أو بينها وبين الأفراد.

أما القانون الخاص، فإنه يطلق على مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم وبين الدولة، لكت ليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان، وإنما باعتبارها فرد عادى، لأن الدولة قد تمارس بعض الاختصاصات القانونية وهي صاحبة سيادة مثل قيامها بالقبض على المجرمين ومحاكمتهم، وقد تقوم بالعمل ليس على هذا النحو، وإنما كفرد عادى مثل قيام الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية بتأجير وحدة سكنية من شخص أو بالبيع والشراء منه، فإنها هنا لا تتعامل باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان، ولكن كفرد عادى، فتخضع عغد القاضى للقضاء العادى، وليس القضاء الإدارى.

ومن الطبيعى أن تختلف قواعد القانون العام عن قواعد القانون الخاص، ولهذا قال مونتسكيو في كتابه (روح القانون): من غير

الصواب أن نخضع القانون العام الذي ينظم الأمة والدولة والعالم لنفس
القواعد التي تنظم حقوقنا الخاصة^(١).

(١) نقلاً عن: د. عبد المنعم البدرأوى، السابق - ص ٥٨

الفصل الأول

فروع القانون العام

القانون العام - وكما سبق القول - ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السلطان الأعلى في المجتمع، وهذا القانون يتنوع إلى نوعين هما القانون العام الداخلي، و القانون العام الدولي.

المبحث الأول

القانون الدولي العام

والقانون الدولي العام يتمثل في مجموعة القواعد التي تحكم تصرفات الدول المتمدينة، وذلك فيما يقوم بينها من علاقات، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب.

ويبدأ القانون الدولي العام ببيان أشخاص العلاقات التي ينظمها، سواء أكانت دولاً، أم هيئات ومنظمات دولية، ويعد حقوقها وواجباتها كحق الدولة في البقاء، وحقها في الحرية والسيادة، وحقها في المساواة والاحترام المتبادل، ثم يبين إقليم الدولة ومدى حق الدولة على هذا الإقليم.

كما يبين القانون الدولي الأحوال التي تتعرض فيها الدولة للمسئولية الدولية، وتنظيم العلاقات الدولية من حيث التمثيل الخارجي والمؤتمرات والمعاهدات، والمنظمات الإقليمية العامة، كما يرسم الطرق الودية لفض المنازعات الدولية، كالمفاوضة والتحكيم، وتسمى القواعد التي تنظم تلك الروابط بقانون السلم.

فإذا لم تقلح الوسائل الودية لفض المنازعات الدولية، وقامت الحرب، فإن المجتمع الدولي ينقسم إلى قسمين، الدول المحاربة والدول المحايدة، ويتولى القانون الدولي العام، وضع قواعد للحرب مبيناً كيفية إعلانها، ووسائلها المشروعة وغير المشروعة، وحقوق وواجبات كل من المتحاربين تجاه العدو، ثم هو بعد ذلك ينظم علاقة الدول المحاربة بالدول المحايدة من خلال تحديد حقوق وواجبات كل منها تجاه الأخرى، وهذه القواعد المنظمة للحرب والحياد تعرف باسم قانون الحربي والحياد.

مصادر القانون الدولي العام:

وللقانون الدولي العام مصادر أساسية ثلاثة: هي العرف، والمعاهدات، ومبادئ القانون العامة التي أقرتها الدول المتمدينة، ونبين ذلك:

(١) العرف:

يمثل العرف أهم مصدر من مصادر القانون الدولي العام، لأن الجانب الأكبر من قواعده لا يزال عرفياً، وفي هذا يختلف القانون الدولي العام عن القانون الداخلي، حيث يعتبر العرف مصدراً في المرتبة الثانية بعد التشريع.

والعرف الدولي يتكون بنفس الطريقة التي يتكون منها العرف الداخلي، أي بتكرار الأعمال المماثلة في سلوك دول مختلفة بالنسبة

لأمر من الأمور، حتى تصبح تلك القواعد ملزمة بفضل الاعتقاد الذي يترسخ لدى الدول بذلك.

وقد يكون هذا العرف إقليمياً، إذا كان وليد ظروف خاصة بجماعة معينة، من الدول، أو بمنطقة محدودة من العالم، كما قد يكون العرف عاماً أو دولياً إذا تناول الشئون الدولية للكوكب الأرضي.

(٢) المعاهدات الشارعة:

وهي تلك الاتفاقات الدولية التي تقرر قاعدة من قواعد القانون الدولي العام، أو تقرر أو تحدد، أو تعدل أو تلغى قاعدة من هذه القواعد.

والمعاهدات الشارعة نوع من المعاهدات، لأن المعاهدات قد تكون خاصة، وقد تكون عامة، والمعاهدات الخاصة هي تلك التي تكون بين عدد محدود من الدول في أمر خاص بها، وهي بطبيعة الحال لا تلزم إلا المتعاقدين، ولذلك فإنها لا تعتبر بذاتها مصدراً لقواعد القانون الدولي العام، ولكنها قد تكون سبباً في خلق قاعدة دولية إذا تكرر إبرام مثلها، ومن ذلك القاعدة التي تحرم سبباً في خلق قاعدة دولية إذا تكرر إبرام مثلها، ومن ذلك القاعدة التي تحرم تسليم اللاجئين السياسيين، وهنا تصبح هذه القاعدة ملزمة بالعرف الذي ينشأ من تكرار إبرام الاتفاقات بشأنها.

أما المعاهدات العامة، فهي تلك التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول، في شأن يهم الدول جميعاً، وذلك بقصد وضع قواعد

دولية عامة، وتسمى لذلك بالاتفاقات الشارعة، وذلك مثل اتفاقيات لاهاي لسنة ١٨٩٩، ١٩٠٧، التي تعتبر بمثابة تقنين للقواعد المنظمة للحرب، والقواعد الخاصة بتسوية المنازعات الدولية، تسوية سلمية، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة المبرم في سان فرانسيسكو سنة ١٩٤٥.

(٣) المبادئ القانونية العامة:

وهي المبادئ الأساسية التي تستند إليها وتقرها النظم القانونية في معظم بلاد العالم المتمدنية، ومن تلك المبادئ ذلك المبدأ القانوني الذي يقضى بمسئولية من فعل الضرر بالتعويض عنه، ومبدأ احترام العقود، ومبدأ الظروف الطارئة، ومبدأ التحلل من العقد إذا أخل به الطرف الآخر، وغير ذلك من المبادئ القانونية المقررة^(١).

وقد أثار عدم القواعد القانونية المتعلقة بالقانون الدولي العام بجزء يكفل تطبيقها من المجتمع الدولي تساؤلاً عن مدى اعتبارها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح الذي تقترب فيه القاعدة بجزء، وأثار ذلك خلافاً في الرأي.

فذهب بعض الفقهاء إلى أن قواعد القانون الدولي العام ليست قواعد قانونية بالمعنى الصحيح نظراً لعدم وجود سلطة عليا فوق الدولة

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٦٠ وما بعدها.

تتولى تنفيذ احكامها وتوقيع الجزاء على الدول التى تخالف هذه القواعد.

وذهب فريق آخر من الشراح إلى أن قواعد القانون الدولى العام لها صفة القانون بمعناه الصحيح، وقد رأوا على الرأى الآخر بأن الجزاء متوافر في هذه القواعد، وأن المجتمع الدولى هو الذى يناط به تنفيذ أحكامها ويتولى توقيع الجزاء على الدولة المخالفة، وأن المجتمع يقوم بتفويض الدولة المعتدى عليها في توقيع الجزاء المناسب، غير أن هذا التفويض - وإن سلمنا بوجوده - فإنه لا يكون مجدياً إلا في حالة ما إذا كانت الدولة المعتدى عليها قوية الجانب، أما إذا كانت ضعيفة فلا يتسنى لها ردع الدولة المعتدية بتوقيع الجزاء المناسب عليها^(١).

ومما هو جدير بالذكر أن ميثاق الأمم المتحدة قد نص على إنشاء حرس دولى مهمته ضمان احترام قواعد القانون الدولى، وكان ممكناً توافر توقيع صفة الجزاء عن طريق، غير أن الدول الكبرى تحول دون ذلك لتحقيق مطامعها الشخصية، وتحاول أمريكا الآن أن تقوم بهذا الدور في إطار ما تروج له من شيوع فكرة العولمة.

والحقيقة أن قواعد القانون الدولى قواعد قانونية خاصة، وذلك لعدم جدية الجزاء المقرر عند الخروج عليها، ونادراً ما تحترم هذه

(١) د. جمال الدين طه العاقل - ص ٣٦٠، د. سليمان مرقس - ص ٥٢، وما بعدها، د. حسن كيرة - ص ٨٢.

القواعد إذا كانت هنالك دول منتصرة في الحرب، أو دولة قوية تكيل في المواقف الدولية بمكيالين.

ومع هذا فإن القانون الدولي العام معترف بوجوده من جانب الدول جميعاً، ولم تقدر أى دولة على التصريح ينفى الاعتراف بهذا القانون، لأنه - على الأقل - يكشف عن رغبة كل دولة في أن تعيش على ضوء المبادئ الدولية التي يتبناها.

ونظراً لأن هذا القانون في دور التطور فإن بعض قواعده لا تزال محل إهمال من بعض الدول، أو عدم احترام كامل له. ومما لا ريب فيه أنه سيأتى الوقت الذي تصبح فيه احكام هذا القانون قد بلغت من القوة والاحترام ما يكفل تنفيذها في المجتمع الدولي بأسره^(١)، حيث إن العلم متجه بفضل تقدم العلوم وسرعة الاتصال إلى أن يكون كالدولة الواحدة، بل كالقرية الواحدة.

(١) د. جمال الدين العاقل - السابق - ص ١١٩.

المبحث الثانى

القانون العام الداخلى

والقانون العام الداخلى يتنوع إلى عدة فروع منها القانون الدستورى، والقانون الإدارى، والقانون المالى، والقانون الجنائى، ونخصص لدراسة كل فرع مطلباً.

المطلب الأول

القانون الدستورى

هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلى الذى يضمن مجموعة القواعد الأساسية التى تحدد شكل الدولة ونوع الحكومة، وكيفية تنظيم السلطات العامة فى الدولة من حيث تكوينها واختصاصاتها، وتنظيم علاقة السلطات بعضها ببعض، وتقرير الحقوق الأساسية للأفراد، وتنظيم علاقتهم بالدولة وسلطاتها.

والقانون الدستورى مرتبط بوجود الدولة، حيث لا يمكن ان يوجد مجتمع على شيء من النظام بدون قواعد أساسية تبين نظام الحكم فيه، وسواء أكانت تلك القواعد مدونة فيما يسمى بالدستور المكتوب، أم وليدة سوابق عرفية مستقرة لها في نفوس المجتمع إلزام القانون.

فالقانون الدستورى، يحدد شكل الدولة، ونوع الحكومة، وهل هي ملكية أو جمهورية أو استبدادية أو ديمقراطية أو دكتاتورية، برلمانية أو غير برلمانية، بسيطة أو اتحادية، وغير ذلك من الأشكال التى يمكن ان تتخذها الدولة.

ثم هو يحدد السلطات العامة للدولة، فيبين كيفية تشكيل واختصاص كل منها وتنظيم العلاقة بين هذه السلطات. ثم هو يبين الحريات والحقوق العامة، ويحدد مدى سلطان الدولة في مواجهة الأفراد، وذلك كله من خلال الدستور. والدستور هو القانون الأساسى للدولة، حيث يقوم ببيان المسائل السابقة جميعها وتختلف الدساتير من حيث كيفية وضعها، فمنها ما يصدر في شكل منحة من صاحب السلطان، ومنها ما يصدر عن جمعية تأسيسية تشكل لذلك، ومنها ما يوضع باستفتاء شعبى، ومنها ما يتكون نتيجة للأعراف والتقاليد، وقد يكون الدستور مرناً يسهل تعديله بواسطة السلطة التشريعية العادية، وقد يكون جامداً لا يعدل إلا بهيئة خاصة ينص الدستور على تشكيلها، ويرسم لها إجراءات خاصة في مباشرة عملها.

المطلب الثانى

القانون الإدارى

وهو ذلك الفرع من فروع القانون العام الذي يتضمن جملة القواعد المتعلقة بنشاط الدولة الإدارى في قيامها بوظيفتها الإدارية، أو هو مجموع القواعد التى تتعلق بالمرافق العامة للدولة من حيث إنشاء تلك المرافق، وتنظيمها، وإدارتها بواسطة السلطات والهيئات الإدارية، ومن حيث علاقة هذه المرافق بالجمهور. وأساس ذلك، أن وظائف الدولة يمكن إرجاعها إلى ثلاثة مهام:

أولها: الوظيفة التشريعية؛ ويقصد منها تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل الدولة عن طريق سن القوانين اللازمة لذلك.

وثانيها: الوظيفة القضائية؛ أى التى تهدف إلى حماية الحقوق، وإعمال حكم القانون فيما ينشأ بشأنها من منازعات.

وثالثها: الوظيفة الإدارية؛ التى تضطلع بتقديم الخدمات للأفراد عن طريق القيام بمشروعات عامة تنشئها الدولة وتنظمها وتديرها، وتسمى هذه المشروعات بالمرافق العامة، وهذه المرافق العامة تقوم بها السلطات الإدارية المختلفة، سواء أكانت سلطات مركزية أم سلطات محلية، أم سلطات إقليمية، وهذه السلطات الإدارية المركزية والمحلية تتولى إدارة المرافقة العامة بمقتضى مالها من سلطات تنظيمية من خلال وضع اللوائح، وسلطات تأديبية لتأديب المخطئين من موظفى ومستخدمى هذه المرافق، وإدارية تتمثل في إصدار القرارات الإدارية الآمرة أو الناهية من الرؤساء الإداريين لمروءسيهم، وهذه الوظيفة الأخيرة للدولة، وهي الوظيفة الإدارية تمثل موضوع القانون الإدارى، الذى يمكن تعريفه بأنه: "ذلك الفرع من فروع القانون العام الذى يحكم المرافق العامة، من حيث تنظيمها وبيان كيفية سيرها، وجدير بالذكر أن السلطة التنفيذية تقوم بأداء نوعين من الأعمال، وهما: أعمال السيادة، وأعمال الإدارة، والأولى مثل إعلان الحرب ودعوة المجلس التشريعى للانعقاد، والثانية مثل تنظيم شئون الحياة في المجتمع كتحيين الموظفين وفصلهم إصدار القرارات الإدارية.

ويدخل في نطاق القانون الإدارى الموضوعات الآتية:

أولاً: عمال المرافق العامة، أى بيان الأشخاص الذين يتولون الوظائف المتعلقة بسير المرافق العامة وإدارتها، وذلك بتحديد حقوقهم وواجباتهم، وبيان السلطات الإدارية المختلفة وما تتمتع من حقوق وامتيازات.

ثانياً: أموال المرافق العامة، وهي تلك الأموال المنقولة والعقارية التى تستخدمها السلطات الإدارية فى إدارتها للمرافق العامة.

ثالثاً: الطرف المختلفة لاستغلال وإدارة المرافق العامة، ويضاف إلى ذلك القضاء الإدارى الذى يعتبر تابعاً لتلك الجهات الإدارية من أجل فض المنازعات المتعلقة بها استقلالاً عن جهة القضاء المدنى.

مصادر القانون الإدارى:

القانون الإدارى قانون حديث لم يظهر إلا منذ عهد قريب، ولم يكتمل نموه بعد فى معظم دول العالم فلم تكن الدولة تسأل أمام القضاء عن أعمالها الضارة وغير المشروعة بوصفها صاحبة السلطان، لكن إذا شب نزاع مدنى بينها وبين الأفراد وتجردت عن صفتها تلك فإنها كانت تخضع لأحكام القانون المدنى.

إلا أنه لما تقرررت مسئولية الإدارة عن جميع أعمالها بدا أن قواعد القانون المدنى لا تلائم علاقات القانون العام، فأخذت قواعد القانون الإدارى تظهر مستقلة و متميزة عنه، وقد بدأ ذلك الاستقلال فى فرنسا، ثم انتهى إلى مصر، فتم إنشاء مجلس الدولة الذى شارك

القضاء المدني في بعض المنازعات الإدارية، وإن كان القضاء المدني قد ظل مختصاً بالنظر في دعاوى المسؤولية المدنية التي ترفع على جهة الإدارة لطلب التعويض عن ضرر حدث منها، ولهذا يمكن اعتبار تلك المصادر كما يلي:

أولاً: قواعد القانون المدني، والقانون الخاص على وجه العموم، حيث أن تلك القواعد تعتبر مصدراً لكثير من أحكام وقواعد القضاء الإداري في مصر.

ثانياً: المبادئ القانونية للقضاء الإداري، ذلك أنه نظراً لحدثة ظهور القانون الإداري وعدم تقنينه، فإنه قد يسمح لنفسه كثيراً بأن يضع مبادئ قانونية دون أن يستند إلى نصوص تشريعية، ولذلك فإنه يصح القول الشهير: أن القانون الإداري قانون قضائي، أي من صنع القضاء.

ثالثاً: التشريعات المتفرقة لبعض موضوعات القانون الإداري، فمن المعروف أن هناك جملة من التشريعات التي تنظم بعض مسائل القانون الإداري، ولكنها لم تجمع إلى الآن مجموعة واحدة، ولذلك نجد بعضها في الدستور، وبعضها في قوانين ولوائح متفرقة، مثل قوانين الموظفين، والعاملين بالدولة، وبالقطاع العام، والإدارة المحلية، وقانون مجلس الدولة، وقانون التزام المرافق العامة، وقانون ديوان الموظفين وغيرها.

رابعاً: وفيما يتعلق بالإجراءات، فإنه لم يصدر بعد قانون خاص بها لبيين الإجراءات التي تتبع أمام القضاء الإداري، وذلك على غرار قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تلتزم به المحاكم المدنية، ولهذا نص قانون مجلس الولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ على بعض الإجراءات في المواد ٢٢ - ٢٧ وأحال إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يرد فيه نص، وذلك إلى حين صدور قانون الإجراءات الخاص بالقضاء الإداري^(١).

مميزات القانون الإداري:

ويمكن إجمال ما يتميز به القانون الإداري فيما يلي:

(١) أن القانون الإداري قانون غير مقنن بمعنى أنه لا تشمله مجموعة واحدة مبوبة كالقانون المدني أو التجاري أو الجنائي، ومن أجل ذلك فإن قواعده متناثرة ومبعثرة في طيات القوانين واللوائح المتعددة، ونظراً لعدم وجود تقنين خاص، فإنه قد أتاح للقضاء أن يبدع في استنباط أحكام قضائية من المبادئ العامة للقانون، وسمى قضاة الإبداع لذلك.

(٢) أن غالبية القانون الإداري تعتبر من خلق مجلس الدولة وابتكاره، وذلك بسبب عدم وجود النص القانوني المكتوب في كل مجالات هذا الفرع من القانون.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٦٧.

(٣) تتسم قواعد القانون الإدارى بالتطور والتغير - كما أشرنا - لأنه يحاول التوفيق بين مقتضيات الإدارة المتغيرة وبين حماية حقوق الأفراد، وذلك نظراً لعدم وجود النص الذي يحكم أفق التفكير القانونى بعيداً عن الإبداع^(١).

المطلب الثالث

القانون المالى

يمكن تعريف القانون المالى بأنه: مجموعة القواعد القانونية التى تنظم مالية الدولة، أى ميزانيتها من حيث الإيرادات والمصروفات كما تشمل دراسة الضرائب والقروض، والقواعد التى تحكم ميزانية الدولة على وجه العموم.

وعلى ذلك فالقانون المالى يبين موارد الدولة وطرق جبايتها ويحدد طرق إنفاقها.

ويراعى أن التشريع المالى كان إلى عهد قريب جزءاً من القانون الإدارى يختص بالجانب المالى للسلطة الإدارية، إلا أنه قد استقل وصار فرعاً مستقلاً من فروع القانون^(٢).

موضوعات القانون المالى:

(١) فى هذا المعنى: د. جمال الدين العاقل - ص ٥٤.

(٢) د. جمال الدين طه العاقل - ص ٥٧ ، د. عبد الرازق فرج - ص ٢٤.

ويبدو من التعريفات بالقانون المالي أن موضوعاته تدور حول ميزانية الدولة بما تنقسم إليه من إيرادات ومصروفات، وكيفية جمع الإيرادات، وإنفاق المصروفات.

ومصادر الإيرادات متنوعة، فهناك الضرائب، وما تأخذه الدولة نظير خدمات تؤديها بواسطة المرافق العامة التي تديرها أو تشرف عليها، وما يعود على الدولة من أموالها الخاصة، أو ما تتبعه منها، وهناك القروض التي تقترضها الدولة لتقوم بتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى أموال خاصة.

أما المصروفات، أو النفقات العامة، فهي ما تنفقه الدولة على المرافق العامة كالدفاع، والأمن والتعليم والصحة والقضاء، وغير ذلك من المرافق، كما تشمل النفقات أيضاً، رواتب الموظفين والعمال، وما تنفقه في سبيل التكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور^(١).

المطلب الرابع

القانون الجنائي

يعرف القانون الجنائي بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم المعاقب عليها، والعقوبات المقررة لمن يرتكبها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٦٨.

وبناء على ذلك فإنه ينقسم إلى فرعين رئيسيين هما:
أولاً: قانون العقوبات؛ وهو ذلك الفرع من القانون الجنائي الذي يحدد الجرائم المعاقب عليها، والعقوبات المقررة لمن يرتكبها.
ثانياً: قانون الإجراءات الجنائية؛ وهو الفرع الذي يعنى بدراسة الإجراءات التى تتبع في محاكمة المتهمين، وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم.

أما القسم الأول وهو قانون العقوبات فينقسم بدوره إلى قسمين:

(أ) القسم العام من قانون العقوبات.

(ب) القسم الخاص من قانون العقوبات.

(١) المسائل التى ينظمها القسم العام:

يتولى القسم العام من قانون العقوبات تنظيم الموضوعات الآتية:

(أ) بيان المبادئ العامة للمسئولية الجنائية دون التعرض للأحكام الخاصة بكل جريمة على حده.

(ب) كما يبين أنواع الجرائم وما تنقسم إليه من مخالفات وجنح وجنایات.

والمخالفات جمه مخالفة، وهي الجريمة التى تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع والغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأما الجنحة: فهي الجريمة التى تكون عقوبتها الحبس مدة تزيد على أسبوع وغرامة تزيد على مائة جنيه.

وأما الجنائية: فإنها الجريمة التي تكون عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة أو الإعدام، وكما يبدو فإن هذا التقسيم بين تدرج الجرائم في جسامتها من خلال شدة العقوبات المقررة لها.

(ج) كما يبين - كذلك - العقوبة من حيث أنواعها وتعددتها وسقوطها والإعفاء منها، والعوامل التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند الحكم بها تشديداً وتخفيفاً، بحسب ظروف كل جريمة، وسلوك كان جان عند اقترافها بحيث تتلاءم العقوبة مع الجريمة، كما يوضح الركنين اللازم توافرها لقيام الجريمة، وهما ركنان: ركن مادي، وركن معنوي؛ والأول يتكون من السلوك والنتيجة وعلاقة السببية بينهما، والثاني هو القصد، الذي يتكون من العلم والإدارة، أى علم الجاني بأن ما يفعله جريمة.

(٢) وأما القسم الخاص من قانون العقوبات:

فإنه يبين الأحكام الخاصة بكل جريمة على حده كما يوضح أن نوع الجرائم متعددة، فمنها ما يقع على الدولة مباشرة فيدخل بأمنها الداخلى والخارجى، مثل جرائم التزيف في العملة والاختلاس والرشوة والتجسس وإفشاء الأسرار الحربية.

وقد تقع الجرائم على الأفراد، فيكون منها ما يصيب النفس كالقتل والضرب، وقد تقع على أموالهم كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة.

ومن الجرائم ما يقع على العرض والشرف كالزنا والقذف والسب.

ثانياً: قانون الإجراءات الجنائية:

هو مجموعة القواعد التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الجريمة سواء تعلقت هذه الإجراءات بالتحقيق أو بالمحاكمة أو بطريق الطعن فيها، أو بتنفيذها.

ويلاحظ أن قواعد الإجراءات الجنائية قواعد شكلية تبين الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الجريمة فتحدد السلطة التي تتولى التحقيق وكيفية القيام بهذا التحقيق، وتوضح كذلك متى يجوز القبض على المتهم ومتى لا يجوز، ومتى يحبس احتياطياً وكيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وطرق السير فيها وتحدد طرق الطعن في الأحكام.

ومن ثم يبدو أن الإجراءات الجنائية قواعد شكلية لا تبحث في موضوع الجريمة وإنما تبحث في الإجراءات التي يجب أن تتبع في إسنادها للمتهم والحكم عليه بالعقوبة المقررة، وتنفيذ هذه العقوبة، على خلاف قانون العقوبات الذي يعنى بموضوع الجريمة وبيان أركانها وشروط الإسناد فيها.

الفصل الثانى

فروع القانون الخاص

القانون الخاص: هو ذلك الفرع من القانون الذي يتولى تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم سواء أكانت هذه العلاقات، علاقات أسرية أم علاقات مالية، ويعتبر القانون المدني هم فروع ذلك القانون، لأنه هو الأصل الذي تفرعت عنه سائر الفروع.

ففي الأصل، كانت علاقات جميع افراد تخضع لقانون واحد، هو القانون المدني، ثم أظهر الواقع أن بعض المعاملات المالية، وهي المتعلقة بالمجال التجاري على وجه الخصوص تحتاج إلى الإنفراد بقانون ينظم شئونها، يأخذ في اعتباره طبيعة تلك المعاملات والوسط الذي تمت فيه، فظهر القانون التجاري والبحرى واستقل عن القانون المدني، ومن ثم تفرع القانون الخاص إلى قسمين هما: القانون المدني، والقانون التجاري.

وأما القواعد التى تنظم الحقوق الخاصة عن طريق اللجوء للقضاء، أو ما يعرف بالقواعد الإجرائية والشكلية، فقد استقل بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولما كثرت العلاقات واتسع نطاق أطرافها ودخل فيها العنصر الأجنبى، كان لابد من وضع القواعد التى تبين القانون الواجب التطبيق على تلك العلاقات ذات العنصر الأجنبى، فظهر القانون الدولى الخاص، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون الدولى الخاص، وسوف نبين تلك الفروع على أن نخصص لكل منها مبحثاً.

المبحث الأول

القانون المدني

يعتبر القانون المدني هو أساس القانون الخاص، ويمكن تعريفه بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية والأحوال الشخصية للأفراد، إلا أن القانون المدني المصري لا يتظم سوى العلاقات المالية التي تنشأ بين الأفراد، تاركاً مسائل الأحوال الشخصية للدين، حيث تحكمها الشريعة الإسلامية بالنسبة لمسلمين، وأحكام الشرائع المالية بالنسبة لغير المسلمين.

والقانون المدني هو الشريعة العامة في ميدان القانون الخاص، فهو القانون الذي يجب تطبيقه على جميع العلاقات إذا لم يرد نص ينظمها في فرع آخر من فروع القانون، أى أنه الشريعة العامة التي يجب تطبيقها إذا لم يوجد نص خاص يتولى تنظيم المسألة في فروع القانون المختلفة، ولذا يمكن القول أن القانون المدني يشمل القواعد الموضوعية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد في المجتمع إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون.

الموضوعات التي ينظمها القانون المدني:

ينظم القانون المدني نوعين من العلاقات هما: العلاقات المالية والعلاقات الأسرية المتعلقة بالأحوال الشخصية.

أولاً: العلاقات المالية:

أما العلاقات المالية ويطلق عليها اصطلاح الأحوال العينية أو المعاملات المالية، فإنها تشمل كل ما يتعلق بنشاط الأفراد من الناحية المالية والقواعد التي تنظم الروابط المالية بين الأفراد وتشمل نوعين من الحقوق هما:

(١) **الحقوق الشخصية:** وهي عبارة عن العلاقات التي تنشأ بين

الأفراد والتي يترتب عليها حقوق مالية لبعضهم تجاه البعض الآخر بحيث يكون أحدهم دائناً والآخر مدنياً، وتعرف بأنها علاقة بين طرفين أحدهما دائن والثاني مدين بمقتضاها يلتزم الدين في مواجهة الدائن بأن يؤدي شيئاً أو يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل.

(٢) **الحقوق العينية:** وهي عبارة عن سلطة يباشرها شخص على

شيء معين تمكنه من استعماله واستغلاله والتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات كحق الملكية وحقوق الارتفاق فالعلاقات المالية يدخل فيها تعريف المال وتحديد الحقوق المالية المتباينة وطرق كسب هذه الحقوق، وانتقالها، وانقضائها، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالمعاملات.

ثانياً: العلاقات الأسرية:

أما بالنسبة للعلاقات الأسرية؛ فهي روابط الأحوال الشخصية التي تنشأ بين الفرد وغيره من بنى جنسه باعتباره فرداً في أسرة، فهي تضم المسائل المتعلقة بالأهلية والزواج والطلاق والميراث والوصية

والنسب والقرابة وغير ذلك من المسائل التى تدخل فى نطاق الأحوال الشخصية.

ويلاحظ أن روابط الأحوال الشخصية لم ينظمها القانون المدني وترك تنظيمها للقواعد الدينية التى تختلف باختلاف الأديان، ومع ذلك فقد نظم بعض المسائل المتصلة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والهبة.

ونظراً لاعتبارات تاريخية واجتماعية اقتصر القانون المدني المصرى على تنظيم الأحوال العينية دون الأحوال الشخصية وإن كان يسير بخطى وئيدة، فنظم بعض مسائل الأحوال الشخصية وترك تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لقواعد الشريعة الإسلامية والقواعد المالية المختلفة مراعاة منه للصلة الوثيقة بين الدين وروابط الأحوال الشخصية.

وقد تم وضع أول مجموعة مدنية مصرية فى أواخر القرن الماضى فصدرت المجموعة المختلطة فى سنة ١٨٧٥، والمجموعة الأهلية المدنية سنة ١٨٨٣، ومعظم أحكام هاتين المجموعتين قد اقتبست من القانون المدني الفرنسى وقد اقتصر على تنظيم الأحوال العينية دون غيرها، وقد استمر تطبيق أحكام المجموعتين المشار إليهما حتى صدور القانون رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨ الذى حل محله القانون المدني المصري الحالى الذى بدأ تطبيقه فى ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩، بعد أن تم إلغاء المحاكم المختلطة وانتهاء فترة الانتقال.

وأصبح هذا القانون الجديد سارياً على المجتمع دون تفريق بين وطنى وأجنبى.

والقانون المدني المصرى الجديد يتكون من (١١٤٩) مادة وتم تبويبه تبويماً علمياً، ويساير في الوقت نفسه الناحية العلمية:

في الباب التمهيدي: عالج مصادر القانون وتطبيق القانون من حيث الزمان والمكان والشخصية الطبيعية والشخصية المعنوية وتقسيمات الأشياء والأموال.

ثم بعد ذلك ينقسم القانون المدني إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول: بين فيه الالتزامات أو الحقوق الشخصية.

القسم الثانى: تكلم فيه عن الحقوق العينية الأصلية والتبعية.

والقانون المدني الجديد يتسم بأنه تقادى أوجه النقص في القانون القديم، ونظم بعض الموضوعات التى لم يعالجها القانون القديم كنظام المؤسسات وحالة الدين وتصفية التركة وغير ذلك من المسائل.

وقد جاء هذا القانون الجديد متمشياً مع روح العصر وسلك موقفاً معتدلاً من المذاهب الاجتماعية المختلفة فكان مقبولاً فى منهجه وموضوعه وموافقاً فى مضمونه العام لمبادئ الشريعة الإسلامية^(١).

(١) د. جمال الدين العاقل - ص ٦١.

المبحث الثانى

القانون التجاري

والقانون التجاري هو مجموعة القواعد التى تنظم الأعمال التجارية، وبعبارة أخرى هو مجموعة القواعد القانونية للنشاط المالى ذى الصفة التجارية فهو ينظم حياة التجار أفراداً كانوا أو شركات، وينظم أنماط التعامل التجاري والأوراق التجارية^(١).

والقانون التجاري يحكم الأعمال ذات الصبغة التجارية فهو يحدد معنى كلمة تاجر ويبين متى يعتبر العمل تجارياً ومتى لا يعتبر، وينظم العقود والشركات التجارية بجميع أنواعها المختلفة ويضع أحكاماً للأوراق التجارية بكافة أنواعها، مثل: الكمبيالة والشيك والسند الأدنى والسند لحامله.

ويبين واجبات التجار كمسك الدفاتر التجارية والقيود فى السجل التجاري.

كما ينظم إفلاس التاجر وما يترتب عليه من آثار وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالنشاط التجاري، وقد كان القانون التجاري جزءاً من القانون المدنى، ثم انفصل عنه وأصبح فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص وذلك فضلاً عن زيادة النشاط التجاري وما استتبع ذلك

(١) د. عبد المنعم الصدة - فقرة ٤٠، د. حسن كيرة - فقرة ٣٦، د. جميل الشرقاوى - فقرة

٢٠، د. جمال الدين العاقل - ص ٦٢، د. عبد الرزاق فرج - ص ٢٩

من ضرورة وضع قواعد خاصة تنظم العلاقات التجارية بطريقة تلائم ما تتطلبه هذه المعاملات من سرعة وثقة في التعامل.

أسباب استقلال القانون التجاري عن القانون المدني:

يمكن القول: أن استقلال القانون التجاري عن القانون المدني يرجع إلى اعتبارين تختص بهما الأعمال التجارية وهما:

أولاً: الأعمال التجارية قوامها السرعة:

لا شك أن السرعة من الأمور التي تستلزمها الأعمال التجارية - وبخاصة - بعد اتساع مجالها وزيادتها المضطربة وهذه السرعة لا تتحقق مع وجود القيم التي يفرضها القانون المدني، سيما ما يستغرقه من إجراءات تأخذ وقتاً قد تضيع فيه فرصة ذهبية على التاجر.

والمعاملات التجارية قوامها السرعة، وذلك على عكس المعاملات المدنية التي لا تتم بهذه البطء حيث يعتمد الناس في المعاملات المدنية إلى المساومة والأخذ والرد، كما يلجئون إلى التروى من أجل تمحيص الرأي ووزن الصفة وفقاً لظروف العرض والطلب ولتغلب الأحداث السياسية التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار واحتكار السلع تربصاً للغلاء المنتظر كما أن البضائع قد يتسارع التي تستلزمها المعاملات التجارية تستدعي تنظيماً قانونياً خاصاً، وتجعل أحكام القانون المدني عاجزة عن مجاراتها.

وتحقيقاً لهذه السرعة اتسمت قواعد القانون التجاري بالمرونة وبساطة الإجراءات الخاصة بإبرام العقود، وإثباتها وتنفيذها، ونقل الحق من شخص غلى آخر، ومن مظاهر السرعة في الأعمال التجارية ما يلي:

(١) حرية الإثبات في المعاملات التجارية:

إذا كانت القاعدة العامة في القانون المدني، هي وجوب الإثبات بالكتابة كلما زاد موضوع التصرف القانونى عن خمسمائة جنيه^(١)، أو إذا كان غير محدود القيمة، فإن الإثبات في المواد التجارية حر من القيود، فيجوز إثبات التصرف التجاري بالقرائن أو بالبيئة أياً كانت قيمته.

(٢) يسر تداول الحقوق التجارية:

كذلك فإن القانون التجاري يحقق السرعة من خلال تيسير تداول الحقوق التجارية الثابتة في صكوك، فبينما يستلزم القانون المدني إجراءات خاصة لحالة الحقوق الشخصية من الدائن إلى غيره، نجد القانون التجاري يكتفى من السندات التجارية بتسليمها إذا كانت واجبة الجفع لحاملها، أو بتظهيرها عن طريق كتابة بين على ظهرها يفيد أن حاملها قد نقلها من شخص إلى آخر.

(١) وفقاً لما تقضى المادة (٦٠) من قانون الاثبات، والتي تم تعديلها أخيراً بالقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٩٩م - الجريدة الرسمية، العدد (١٩) مكرر (أ) فى ١٧/٥/١٩٩٩م.

(٣) تيسير إجراءات تنفيذ الرهن:

في القانون المدني، إذا أراد الدائن ان ينفذ الرهن، فإنه يجب ان يكون بيده سند واجب التنفيذ كحكم أو سند رسمي، وذلك حتى يمكنه التنفيذ على الشيء المرهون ضماناً لحقه واستيفاء هذا الحق من حصيلة البيع، أما في القانون التجاري فإن الأمر لا يقتضى ذلك، حيث يرد الرهن على بضاعة تتقلب أسعارها، ولو ألزمت الدائن استصدار حكم أو الحصول على سند تنفيذي، فلربما تنخفض قيمة البضاعة المرهونة فلا يحصل على حقه كاملاً، ولهذا اجاز القانون التجارة للدائن متى حل أجل الدين ولم يقم المدين بالوفاء، أن ينبه عليه بالوفاء، فإذا لم يقم المدين بالدفع خلال الأيام الثلاثة التالية للتنبيه، فإن له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية ويحصل منه على إذن بيع الشيء المرهون، وذلك دون حاجة إلى استصدار حكم بدينه^(١).

ثانياً: المعاملات التجارية قوامها الثقة:

من سما المعاملات التجارية أن الثقة فيها تمثل قيمة قد تفوق قيمة المال الذي تتم المتاجرة به، وأساس ذلك أنها لا تتم بغير الائتمان، لأن أغلب العمليات التجارية تتم بأجل فلا يقوم المدين فيها

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٧٦، د جميل الشرقاوى - السابق، د. حسن كيرة - السابق، د. رمضان أبو السعود - المدخل إلى القانون - ص ٨٤، وما بعدها - الدار الجامعية ١٩٨٥.

بتنفيذ التزامه إلا بعد مدة معينة من تمامها وتنفيذها، والائتمان لا غنى عنه في الأعمال التجارية، فالتاجر قد يشتري البضاعة ويودعها مخازنه، أو محله دون أن يتمكن من بيعها في الحال، ومن ثم فإنه يجب منحه أجلاً للوفاء بأثمانها وإذا لم يقم من يتعامل مع التاجر بمنحه أجلاً للوفاء، لا يكون ثمة بديل أمامه سوى اللجوء إلى أحد المصارف للاقتراض منه، فنعود مرة ثانية إلى الائتمان.

لهذا، ولما كان الائتمان سمة أساسية وضرورة لازمة في المعاملات التجارية كان لابد من تنظيم خاص به ليحقق للتاجر فرصة الحصول عليه وليضمن - من ناحية أخرى - توقيع جزاء صارم وسريع على من يخل به، فقرر القانون افتراض التضامن بين المدينين ووضع نظاماً بتصفية أموال المدين التاجر، وهو نظام الإفلاس، ومن مظاهر تقوية جانب الائتمان وتدعيم الثقة ما يلي:

(أ) افتراض تضامن المدينين:

الأصل في القانون المدني، أن التضامن بين المدينين لا يفترض، فإذا تعدد المدينون بدين واحد، فإن كلاً منهم لا يسأل إلا عن حصته فيه، ولا يتقرر التضامن إلا بنص في القانون أو باتفاق صريح عليه، أما في المعاملات التجارية فإن التضامن يفترض عند تعدد المدينين دون حاجة إلى نص أو اتفاق، ومن ثم يكون كل واحد من المدينين المتعددين مسؤولاً وحده عن كل الدين في مواجهة الدائن لا عن نصيبه فقط.

(ب) نظام الإفلاس التجاري:

ويعتبر الإفلاس التجاري دعامة من دعائم الثقة في المعاملات التجارية، لأنه يعتبر بمثابة الجزاء الرادع لمن يزدري تلك الثقة ولا يقوم بواجباتها، فإذا توقف التاجر المدين عن دفع ديونه، فإن مقتضى نظام الإفلاس أن تتم تصفية أمواله سداداً لحقوق دائنيه، حتى لا تتعطل أعمالهم، أو يعجزوا بدورهم عن الوفاء في ذممهم من التزامات، فتزيد سلسلة التعثر في السداد ويختل نظام التعامل.

وفي سبيل حماية الدائنين من غش المدين أو تصرفاته الضارة بهم، قرر القانون التجاري عدم سرقات طائفة من تلك التصرفات في مواجهة الدائنين إذا باشرها المدين وهو مفلس، أو إذا كان على شفا الإفلاس، ثم أن تنظيم الإفلاس من شأنه ألا يترك الدائنين يتزاحمون ويتسابقون في التنفيذ على أموال المدين، بل نظم رجوعهم عليه، وضمن لكل منهم نصيباً في أمواله، ومن ثم كان نظام الإفلاس قوياً للائتمان التجاري، ليقدم الدائن على منح ائتمانه للتاجر وهو مطمئن.

ولم يكن لمثل هذا التنظيم نظير في القانون المدني، وإن كانت المجموعة المدنية الجديدة قد نظمت الإعسار المدني، فأجازت شهر إعسار المدين الذي لا تكفي حقوقه للوفاء بما عليه من ديون مستحقة الأداء، فاقتبست بعض نظام الإفلاس دون أن تنقله بحذافيره^(١).

(١) المواد: ٢٤٩ - ١٦٤، مدني.

القانون الذي ينظم الأعمال التجارية في مصر:

لقد ظلت الأعمال التجارية محكومة بتقنين مصرى عتيق وضع عام ١٨٨٣، وقد استمر هذا القانون في التطبيق حتى نهاية الألفية المنصوصة، رغم أن كثيراً من نصوصه أصبحت غير قادرة في أفكارها أو صياغتها على مجاوة الأعمال التجارية في العصر الحديث، إلى أن أثمرت الجهود وتحققت الآمال في تعبير هذا الوضع وصدر القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعروف بقانون التجارة، والذي صيغ صياغة عصرية ملائمة، استلهمت روح التشريع في مثير من الأنظمة القانونية العالمية، وجاء هذا القانون محققاً للآمال في وثبة تشريعية مصرية تصل بالتجارة إلى الغد المأمول، كما تمت مراجعة نصوصه حتى تجيء موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء^(١).

ومن المفيد أن يأخذ الطالب فكرة عن هذا الإنجاز التشريعي العظيم من خلال حديث القانون عن نفسه، وقد جاء في مذكرته الإيضاحية ما يلي:

(١) في الربع الأخير من القانون الماضى وقع في مصر حدثان تاريخيان كان لهما أثر بالغ الأهمية في النظام القضائى والتشريعي في

(١) كان لى شرف المشاركة فى مراجعة نصوص هذا القانون وفق أحكام الشريعة الإسلامية بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل مفتى الجمهورية، والدكتور/ عبد الرحمن العدوى عضو مجمع البحوث الإسلامية.

البلاد، هما إنشاء المحاكم المختلطة أولاً، ثم المحاكم الوطنية في أعقابها على أنماط وأساليب أوروبية، الأمر الذي اقتضى وضع تشريعات تناسب هذا النهج الجديد، فصدرت التقنيات المختلطة ثم الوطنية مشتقة من القوانين الأوروبية - لا سيما - من القانون الفرنسي الذي كان يتمتع في ذلك الحين بقبول وإقبال عالميين، وجاء التغيير شاملاً لجميع فروع القانون، المدني والتجاري والجزائي والإجرائي، ولم يقتصر المصري بما يأخذ به القضاء الفرنسي في تفسير النصوص، وأن يردد الفقه المصري آراء الفقهاء الفرنسيين وغيرهم من الفقهاء الأوروبيين.

(٢) في هذا المناخ العام وضع القانون التجاري، فقد صدر القانون المختلط عام ١٨٧٦، ثم تلاه القانون الوطني عام ١٨٨٣، حيث نقل إليه واضعه أحكام القانون المختلط نقلاً يكاد يكون حرفياً، مما يمكن معه القول دون حرج إن التقنيين التجاريين المصريين ينبعان من التقنين الفرنسي مع بعض فروق شكلية لعل أهمها أن التقنيين المصريين لا يشتملان على أحكام المعاملات التجارية البحرية كما هو الحال في التقنين المصري، وإنما أفرد الشارع المصري لهذا الفرع من القانون تقنياً قائماً بذاته نقله بدوره عن الأحكام الفرنسية، وظل هذا التقنين سارياً في مصر حتى ألغاه الشارع المصري وأحل محله قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون ٨ لسنة ١٩٩٠ بتاريخ ٢٢ إبريل سنة ١٩٩٠.

(٣) وجاء وضع التقنين التجاري الفرنسي في وقت غير ملائم، إذ كان العالم على أبواب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي حدثت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، كتطور الطاقة حتى بلغت الذروة، وإضافة الطائرة إلى وسائل النقل، وتركز رؤوس الأموال وانتشار شركات المساهمة وعمليات لائتمان والتعامل بال شيكات، وغير ذلك مما يجود به العلم من مخترعات وفلسفات، ولم يستطع التقنين الفرنسي التنبؤ بهذا التطور المذهل فلم يهيئوا التشريع له، ولذا ما كاد التقنين الذي بذلوا في إعدادة الجهد والعرق يخرج إلى العمل ويواجه الواقع حتى كشف عن مواطن عديدة للنقص، وعجز عن مسايرة الأحداث، وأدركه الشارع الفرنسي فظل يعدل فيه ويضاف إليه ويبتز منه حتى تغيرت معالمه وصار إطاراً يضم شيئاً غير مضمونة الأصل.

(٤) وبينما كان التقنين التجاري الفرنسي محلاً للتغيير والتحديث، ظل التقنين المصري على ما هو عليه، فظلت شركات المساهمة لحقبة طويلة دون تنظيم قانوني رغم انتشارها في البلاد، ولا يزال الشيك مع ذبوع استعماله منسياً دون تنظيم مفصل، ولا تزال الكمبيالة والسندات لأمر، تخضع لأحكام عفا عليها الزمن، ولم ينل القانون التجاري في مصر في السنوات السابقة على إلغاء الامتيازات الأجنبية من رعاية الشارع إلا قسطاً زهيداً لا يذكر منه إلا القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٣٤ الذي أدخل نظام السجل التجاري في البلاد.

(٥) والحق أن لا لوم على الشارع المصرى في هذه السلبية، إذا كانت حريته في التشريع مكبلة بقيود نظام الامتيازات الأجنبية، ولما طرح أغلاله وعاد من "منترو" عام ١٩٣٧، حراً طليقاً انطلق يدرك ما فات ويصلح ما أعوج من أمر التشريع في مختلف نواحيه، ونال التشريع التجاري نصيبه من تلك الصحة التشريعية، فصدرت قوانين عديدة تكمل نقائصه، وتسد ثغراته كقانون بيع ورهن المتجر، والقوانين المنظمة للملكية الصناعية والملكية الذهنية، والقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٤٥ بشأن شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات المسؤولية المحدودة، وقانون الصلح الواقى من الإفلاس، وغير ذلك كثيراً وكان بعض هذه القوانين التكميلية محلاً لتعديلات أوجبها أحياناً تقدم التكنولوجيا، وأحياناً أخرى تغير الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد، بيد أن هذه التشريعات الاجتماعية وإن اكملت نقصاً أو اصلحت عيباً فإنها بعثرت الأحكام التى تنظم النشاط التجاري في البلاد، وصار معها "قانون التجارة" يحمل هذه التسمية، وهو في الواقع لا يضمن أحكامها إلا القليل.

(٦) وكان لزاماً أن يجمع الشارع المصرى شمل التقنين، وأن يبادر إلى تنقيحه وتحديثه، فشكلت لهذا الغرض لجان منذ الأربعينات من هذا القرن شارك فيها فقهاء مصريون مشهود بعلمهم وفضلهم، نذكر منهم دون حصر، الدكتور محمد صالح الأستاذ بكلية الحقوق، والأستاذ مصطفى فاضل المستشار بمحكمة النقض، وأعدت هذه اللجان

مشروعاً للإصلاح، ولكنه وقف عند هذا الحد، ولم يقدر له النجاح الذي صادفه مشروع شقيق له أعدته لجنة أخرى للمعاملات المدنية، هو مشروع القانون المدني الذي استطاع أن يشق طريقه حتى صدر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، وعملية ابتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩.

(٧) ولما وقعت الوحدة بين مصر وسوريا عام ١٩٥٨ وأخيراً توحيد التشريع ليكون أول لجنة في صرحها، شكلت لهذا الغرض لجان شملت مختلف وجوه التشريع، وكان من بينها لجنة لتوحيد القانون التجاري والقانون البحري، وأعدت هذه اللجنة ثلاثة مشروعات موحدة، الأول للقانون التجاري، والثاني للقانون والبحري، والثالث للشركات، وقد استحسنّت اللجنة فصل هذه الأحكام عن القانون التجاري وإصدار قانون قائم بذاته في شأنها، ولم يقدر لهذه المشروعات أو لغيرها مما أعدته اللجان الأخرى أن ترى النور، ثم تكرر الأمر مع ليبيا عندما تمت الوحدة بينها وبين مصر عام ١٩٦٩، فشكّلت لجان لتوحيد التشريعات وأعدت اللجان مشروعات كان نصيبها - بدورها - أي تصدر بتقويض الوحدة بعد وقت قصير من ميلادها.

(٨) وفي عام ١٩٧٣ دخلت مصر حرباً مع إسرائيل، وطغت شئون الحرب على اهتمامات الحكومة والناس فلما وضعت الحرب أوزارها وعاد السلام إلى ربوع البلاد، عاد معه الاهتمام بالشئون العادية للدولة في مقدمتها إصلاح الاقتصاد وإنعاش التنمية، ولما كان إصلاح التشريع التجاري من ركائز الإصلاح الاقتصادي فقد وجهت إليه

الحكومة عناية خاصة، ورؤى التركيز أولاً في القانون البحري، فسار العمل فيه بهمة حتى صدر القانون البحري في إبريل من عام ١٩٩٠ - كما سبق القول - أما التقنين التجاري فقد شكلت له لجنة بقرار من وزير العدل بتاريخ ٢٢ من مارس ١٩٩٠ (رقم ١٦٦٨ لسنة ١٩٩٠)^(١).

(١) نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل على تشكيل اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور محسن شفيق وعضوية كل من المستشار أحمد فتحى مرسى من الشخصيات العامة، والأستاذ الدكتور على جمال الدين عوض والأستاذ الدكتور سمير الشرفاوى من الجامعات، والمستشار الدكتور محمد فتحى نجيب والمستشار السيد عبد المنعم حشيش، والمستشار الدكتور عصام أحمد محمد من إدارة التشريع بوزارة العدل، والأستاذ المستشار أحمد سليمان من مجلس الشيوخ، ولحق ذلك صدور قرارات المستشار وزير العدل بضم أعضاء آخرين للجنة وبذلك انضم إليها من رجال القضاء المستشار محمد إبراهيم خليل والمستشار الدكتور سعيد أحمد عبد الماجد والمستشار الدكتور عادل قورة والمستشار كمال جورجى دانيال، ومن الجامعات الأستاذ الدكتور أبو زيد رضوان والدكتور ثروت عبد الرحيم والدكتور حسام عيسى، ومن إدارة التشريع الأستاذة الدكتورة جورجيت صبحى عده قلبنى، كما شارك اللجنة في جزء من أعمالها كل من السيد المستشار محمد رفيق البسطويسى، والسيد المستشار زكي إبراهيم المصرى، والسيد المستشار عبد الرحيم محمد صالح والأستاذ الدكتور عبد المهيم بكر، والأستاذ فاروق موسى مهنى من البنك الأهلي والأستاذ فتحى زكريا من البنك المركزى، وتشكلت اللجان الفرعية من الأستاذ المستشار الدكتور محمد كمال حمدى، والأستاذ الدكتور على محمد البارودي، والأستاذ الدكتور ثروت حبيب والأستاذ المستشار حسن السيد محمد بسيونى، والأستاذ الدكتور حسن المصرى، وقد شكلت لجنة لمراجعة القانون المذكور وفق أحكام الشريعة الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى وفضيلة مفتى الجمهورية الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن العدوى عضو مجمع البحوث الإسلامية، والعبد الفقير مؤلف هذا الكتاب.

وعهدت اللجنة إلى رئيسها بإعداد مشروع تمهيدي يكون بمثابة ورقة عمل، مشتملاً على جميع موضوعات القانون التجاري بما فيها موضوع الشركات التجارية^(١)، ولما تم إعداد المشروع التمهيدي نوقش في اللجان الفرعية وفي اللجنة الرئيسية، واستقر الرأي على المشروع المرفق، ويقوم المشروع على الأصول الآتية:

أولاً: الحفاظ على جوهر التقنين القديم مع استكمال مواطن النقص فيه وتحديثه، لأن التغيير الجذري يحدث من الضرر أكثر مما يحقق من نفع فهو يوهن الثقة، ويزلزل المعاملات المستقرة ويربك خطط التجار ومقدراتهم، ثم إن قضاءً مصرياً خالصاً نشأ حول التقنين القديم وأوجد مبادئ رسخت في التعامل وليس من المرغوب فيه التضحية بهذه الثروة القضائية بإحداث تغيير جوهري في أسس التشريع يصير معه القضاء السابق أثراً لا حياة فيه.

ثانياً: تحقيق وحدة القانون التجاري بلم شمله في تقنين واحد يكون بمثابة موسوعة جامعة لما تفرق واندثر من أحكامه، ومن أمثلة ذلك: إدخال بعض القوانين التكميلية فيه كقانون الصلح الواقى من الإفلاس، بيد أن المشروع حرص على ألا يتقل التقنين بما تشمله بعض هذه القوانين من قواعد إجرائية معرضة بطبيعتها لكثرة التعديل والتبديل فأبقى بعضها خارج التقنين واكتفى في شأن بعضها الآخر بذكر

(١) أعدت اللجنة مشروعاً للشركات، ولكن انتهى الرأي إلى سحبه وضمه إلى مشروع آخر للشركات تقوم به لجنة أخرى.

القواعد الموضوعية وأحال الإجراءات إلى قوانين أو قرارات خاصة، والقانون في الوضعين يظل تابعاً للتقنين التجاري مكملاً لأحكامه مصنفاً مع مرتبته في سلم المصادر التشريعية للمعاملات التجارية.

ثالثاً: اختيار الحلول التي تتفق وتقاليد البلاد وعاداتها، دون التقيد بنظريات أو مذاهب معينة، فجاءت أحكام المشروع متسمة بطابع عملي نابعاً من البيئة المحلية مناسباً لها، ومن الأمثلة البارزة على هذا الاتجاه موقف المشروع من المذهبين المادى والشخصى للقانون التجاري، فقد تولى الميل إلى أحدهما دون الآخر خشية أن يفقده الميل حرية الحركة، فجمع بين المذهبين، واستخلص مزيجاً يقوم على اعتبار بعض الأعمال تجارية بذاتها ولو وقعت منفردة (المذهب المادى) وبعضها الآخر لا يكتسب هذه الصفة إلا إذا وقع على سبيل الاحتراف (المذهب الشخصى)، وكذلك تحرر المشروع من التزام النقل عن أى تشريع أجنبي معين، وآثر انتهاج أسلوب علمى سليم للإفادة من تجارب الغير، فاستقصى المصالح المشروعة، وقارن بين الحلول التي اتبعت لحمايتها من مختلف التشريعات، ثم اختار الحل المناسب للوضع المناسب، ويختلف المشروع في هذا عن التقنين القائم الذي سار في ذيل التشريع الفرنسى، يقوده إلى حلول صنعت لبيئة غير بيئته.

رابعاً: وبقدر نفور المشروع من السير في فلك تشريع أجنبي واحد، كان حرصه على الاستعانة بالأحكام التي وضعتها الاتفاقيات الدولية بشأن

موضوعات القانون التجاري، وبالأحكام التى جمعتها المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر، وذلك لما لهذه المراجع من قيمة علمية سامية، وحرصاً من المشروع على إلحاق التقنين الوطنى بركب التشريع العالمى، ومن أمثله الأحكام الدولية التى اقتبس منها المشروع القواعد التى أعدتها غرفة التجارة الدولية لبيان مضمون البيوع التجارية التى تبرم باستعمال مصطلحات معينة كالبيع "سيف"، والبيع "قوب"، وقواعد اتفاقيات جنيف لشأن الأوراق التجارية، وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع التجاري الدولى (اتفاقية فيينا لسنة ١٩٨٠).

خامساً: تبسيط الإجراءات لأن تعقيدها للتجارة معوق ومضيق للوقت، وأمثلة ذلك كثيرة منها إجازة عمل الإخطارات والإشعارات بالطرق الحديثة كالبرق والتلكس والفاكس، فضلاً عن الطرق التقليدية كالبريد العادى أو المسجل، وإجازة تداول الصكوك الإذنية بطريق التطهير ولو لم تكن من الأوراق التجارية، وفي باب الإفلاس أمثلة أخرى حيث حرص المشروع على تيسير طرف التقلية واقتضاب مواعيد إجراءاتها لتبلغ غايتها في وقت معمول، لا هو بالقصير المخل، ولا هو الطويل الممل.

كما روعى في صياغة نصوص المشروع أن تكون على شيء من المرونة لتستجيب العمل وللاجتهد الحر، وإذا كانت مراعاة هذه المرونة لازمة في صياغة النصوص التشريعية عامة، فهي إلزام في النصوص التجارية التى تعد لمواجهة نشاط سريع الحركة، شديد الحساسية كثير التقلبات، وجاءت المذكرة التفسيرية للمشروع مؤكدة هذه

المرونة، إذ توقفت الشروح المسهبة، والمفاضلات بين مختلف الآراء والنظريات لكيلا تتجمد النصوص مع مرور الزمن عند الرأي الذي ترجحه أو النظرية التي تفضلها، وآثرت المذكرة اقتضاب العرض واستظهار الهدف واستقصاء المصلحة التي تسعى إلى حمايتها.

سادساً: استحداث أحكام بشأن موضوعات ظهرت الحاجة إلى تنظيمها وقد أغفلها التقنين القائم والقوانين المكملة له إما لأنها وليدة تقدم تكنولوجي لم يدركه المشروع السابق، وإما لأن أهميتها لم تتكشف إلا أخيراً، ومن أمثلة هذه المستحدثات تنظيم عقد نقل تكنولوجيا وذلك للحد من الشروط المقيدة التي تضيع على مستورد التكنولوجيا جزءاً من النفع الذي يرجوه من استثمارها ومكافحة المناقشة غير المشروعة بقاعدة عامة تبسط ما نهيه من حماية على مطلق حالات سوء النية والغش، وتنظيم مسؤولية المنتج عن الضرر الذي يحدثه الإنتاج، وضمان سرية الحسابات المصرفية، ووضع تنظيم خاص للتقليسات الصغيرة.

سابعاً: مسايرة التحول الكبير الذي وقع للاقتصاد المصري عن طريق الإصلاح الاقتصادي وإعادة البناء الذي ظهرت تباشيره تباعاً والذي عبر عنه السيد الرئيس حسنى مبارك بقوله: "في غضون سنوات محدودة تحولت مصر من دولة تعاني عجز الموارد والقدرات إلى حد يقترب من الإفلاس، إلى أقرب منطقة جاذبة للاستثمارات في الشرق الأوسط، وتحول الاقتصاد الوطنى الذي أعجزه الخلل المزمن عن إحداث أية معدلات تنمية حقيقية، إلى اقتصاد نشط تتصاعد فيه

معدلات التنمية على نحو مستمر لتصل إلى ما يقارب من ثلاثة أمثال معدل السكان قبل عام ٢٠٠٠^(١).

هذه التنمية الصاعدة على نحو يمكن مصر من دخول مرحلة إنطلاق جديدة فتحت أبواب المشاركة للجميع، وهيأت الفرصة لاستثمار كل الطاقات الوطنية وأسقطت - ولا زالت تسقط - كل العوائق والعقبات حتى يقوم القطاع الخاص بدوره في عملية التنمية. ولا شك أن هذا الأداء المتمم بالحسم والجرأة ييف اقتحام المشكلات، وإزاحة العقبات التي تعوق مسيرة العمل الوطنى، كان له أبلغ الأثر في التيسير على المواطنين وتعزيز روح الثقة في نفوسهم، وخلق مناخ جديد، تتطلع فيه الجماهير إلى مزيد من العمل والإنجاز. ومن هذا المنطلق أعد المشروع ليواجه هذا المستقبل.

(٩) ويقع المشروع في خمسة أبواب الأول في الجارة بوجه عام، والثانى في الالتزامات التجارية، والثالث في عمليات البنوك، والرابع في الأوراق التجارية، ثم الباب الخامس في الإفلاس والصلح الواقى منه. **خصائص القانون التجاري:**

ويمكن القول أن للقانون خصائص معينة نذكر منها ما يلي:
أولاً: أن القانون التجاري لا يزال مرتبطاً بالقانون المدني ارتباط الفرع بالأصل، وقد سبق بيان أن القانون المدني هو الشريعة العامة للقانون

(١) من بيان رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب والشورى (١٠ نوفمبر سنة ١٩٩٦).

الخاص، ومن ثم فإنه مع حالة عدم وجود نص في القانون التجاري يحكم المسألة المطروحة، فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص القانون المدني. **ثانياً:** أن العرف يلعب دوراً كبيراً في مجال إنشاء قواعد القانون التجاري، وبناء على ذلك فإن النصوص التشريعية ليست هي المصدر الوحيد لأحكامه، بل يُعد العرف من المصادر الهامة للقانون التجاري^(١).

القانون البحري:

يقوم القانون البحري بتنظيم العلاقات الخاصة بالملاحة البحرية، ويمكن تعريفه بأنه: مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة في البحار والتجارة البحرية. وتدور هذه العلاقات حول السفينة، فيتناول تنظيم ما يرد عليها من حقوق وتنظيم بيعها وتأجيرها وتنظيم عقد العمل البحري وعقد النقل البحري وعقد القرض البحري، والتأمين على السفينة والبضائع التي تشحن عليها، كما يتناول تنظيم ما يرد على السفينة من حقوق. وقد نشأ القانون البحري في أحضان القانون التجاري بسبب أن الملاحة البحرية تتم أساساً بقصد الإتجار.

وإذا كانت هذه الأعمال في الأصل أعمالاً تجارية، إلا أنه توجد بعض الاعتبارات التي دعت إلى فصل القانون البحري عن القانون التجاري، وترجع هذه الاعتبارات إلى أكبر حجم السفينة، وتعرضها

(١) د. جمال الدين العاقل، ص ٦٥، د. عبد الرزاق فرج - السابق.

للكثير من الأخطار الجسيمة وهي في عرض البحر وذلك بالإضافة إلى أنها في معظم الأوقات تكون بعيدة عن رقابة صاحبها، فهذه الأمور وغيرها اقتضت ضرورة وضع قواعد خاصة بتنظيم الملاحة البحرية^(١).

القانون الجوي:

والقانون الجوي هو: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة الجوية.

وتتركز هذه العلاقات حول الطائرة من حيث ملكيتها وجنسياتها وتسجيلها، وتنظيم أحكام عقد النقل الجوي، والمسئولية الناجمة عن الأضرار التي تلحق الركبات أو تصيب من هو على سطح الأرض إلى غير ذلك من الموضوعات المتصلة بالملاحة الجوية^(٢).

(١) د. جمال الدين العاقل - ٦٦، د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٧٩.

(٢) د. جمال الدين العاقل - المرجع نفسه.

المبحث الثالث

قانون المرافعات المدنية والتجارية

يتكفل قانون المرافعات المدنية والتجارية بحماية العلاقات القانونية الناشئة عن القانونين المدني والتجاري، ورد الاعتداء عنها، ومن ثم كان هذا القانون من القوانين الشكلية، أو المتعلقة بالإجراءات. وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية الموضوعات الآتية:

أولاً: النظام القضائي:

وذلك من خلال بيان الأصول التي يقوم عليها هذا النظام، وتشكيل المحاكم في مختلف درجاتها، ثم بيان الأفراد والهيئات التي تتعاون في أداء العدالة، وذلك من خلال بيان قواعد وشروط تعيين أعضائها من القضاة والمستشارين، ونقلهم وترقياتهم وعزلهم، والضمانات المقررة لهم، كما تنظم عمل أعوان القضاء مع املحامين والكتبة والمحضرين، والخبراء القضائيين.

ثانياً: الاختصاص القضائي:

وذلك من خلال بيان توزيع ولاية القضاء على المحاكم المتعددة ودرجاتها المختلفة، وهذه القواعد منها ما يتعلق بتوزيع ولاية القضاء على جهاته المختلفة، وذلك كالقواعد المنظمة لولاية القضاء الإداري بالنسبة للقضاء المدني، وبعضها يتعلق بالاختصاص النوعي، أي اختصاص المحكمة من حيث نوع الدعوى وأهميتها وما إذا كانت تختص بها المحاكم الجزئية، أو المحاكم الابتدائية، وبعض تلك القواعد

يتعلق بالاختصاص المحلى، كتلك التى تبين الدائرة الإقليمية التى تباشر املحكمة وظيفتها داخل حدودها، مثل تحديد اختصاص محكمة القاهرة أو محكمة الإسكندرية.

ثالثاً: إجراءات التقاضى

وهي الإجراءات التى تتبع في الالتجاء إلى المحاكم، أى في رفع الدعاوى وفي تحقيقها، وفي الحكم فيها، وكذلك الإجراءات التى تتبع في تنفيذ الأحكام القضائية^(١).

المبحث الخامس

القانون الدولى الخاص

يمكن تعريف القانون الدولى الخاص بأنه: مجموعة القواعد التى تحكم العلاقات ذات العنصر الأجنبى، أو هو القانون الذى يبين القانون الواجب التطبيق على علاقة خاصة ذات عنصر أجنبى، ومدى اختصاص القضاء الوطنى بنظرها^(٢).

إن نشاط الفرد لم يعد قاصراً على النطاق الذى يعيش فيه، أو على الدولة التى يحيا فيها، ولكن هذا النشاط جاوز حدود الأوطان، وكثرت ظاهرة انتقال الأشخاص من دولة إلى أخرى، ومن ثم نشأت جملة من الروابط المتميزة عن تلك التى تتم داخل حدود الوطن بوجود

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٨٠ د. عبد الرزاق فرج - ص ٣٠.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٨٥.

عنصر أجنبي فيها، وهنا تكون مهمة القانون الدولي الخاص تحديد المحكمة المختصة، والنظام الذي يجب تطبيقه في كل نوع من أنواع هذه العلاقات.

فإذا باع مصرى لمواطن آخر في مصر عقاراً موجوداً فيها، كانت العلاقة الناشئة عن هذا البيع وطنية في كل عناصرها، ومن ثم لا نكون بصدد الحاجة إلى إعمال قواعد القانون الدولي الخاص.

أما إذا تضمنت العلاقة التي ثار النزاع حول عنصراً اجنبياً بأن كان أحد طرفيها اجنبياً، أو أن العلاقات نشأت في بلد أجنبي، أو أن موضوع العلاقة كان موجوداً في بلد أجنبي، فإن قواعد القانون الدولي هي التي تحكم هذا القانون، ببيان المحكمة المختصة بنظره، وهل هي المحكمة الوطنية، أو المحكمة الأجنبية، كما تبين النظام الواجب التطبيق، وهل هو القانون الوطنى أم القانون الأجنبي^(١).

موضوعات القانون الدولي الخاص:

ومن خلال تعريف القانون الدولي الخاص يبدو أن هناك موضوعين أساسيين يختص بهما، وهذان الموضوعان هما: تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص، ويلحق بعض الشراح بهذين الموضوعين، مركز الأجانب، أى تحديد مدى ما يمكن أن يتمتع به

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٨٢ وما بعدها.

الأجنبي من حقوق في الدولة، وما يجوز أن يفرض عليه من تكاليف، ثم موضوع الجنسية، ويلحق به الموطن الدولي للشخص. ويلاحظ أن القانون الدولي الخاص، هو قانون وطنى بحت، رغم تلك التسمية التى قد توحى بأنه غير وطنى، لأن القاضى المصرى يلتزم باحكام القانون الدولي الخاص المصرى أما وصفه بأنه دولى، فمرده إلى دخول العنصر الأجنبي أو الدولى فيه.

مصادر القانون الدولي الخاص:

يعتبر التشريع الوطنى المصرى المصدر الأول للقانون الدولي الخاص، فقد أوردت المجموعة المدنية المصرية أحكاماً لتتازع القوانين في الباب التمهيدي (المواد من ١٠ إلى ٢٨)، أما ما يتعلق بقواعد تتازع الاختصاص القضائى، فقد وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(٢) المعاهدات:

وإلى جانب التشريع الوطنى، توجد المعاهدات كمصدر من مصادر القانون الدولي الخاص، ذلك أنه كثيراً ما تتفق دولتان أو أكثر على وضع حل لمسألة تتازع القوانين والاختصاص أو تنفيذ حكم القضاء الصادر من إحدى محاكمها في دولة أخرى طرف في المعاهدة.

(٣) العرف:

وإذا لم يجد القاضى نصاً مكتوباً أو معاهدة، فلن يكون أمامه بد من اللجوء إلى العرف، وهذا العرف قد يكون داخلياً، أى نشأ

واستقر داخل الدولة، وقد يكون دولياً أى مستقراً في عدد من الدول بشأن مسألة من المسائل.

(٤) المبادئ المستقرة تشريعاً وفقهاً:

وهي تلك المبادئ المسلمة في الفقه والتشريع عند كثير من الدول الأجنبية، أو التي يمكن استنباطها من خلال دراسة قوانين الدول المختلفة، وقد أشارت إليها المادة (٢٤) مدني، بقولها: "تتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين، مبادئ القانون الدولي الخاص"، وعلى هذا النحو تتحدد مصادر القانون الدولي الخاص، كما تتحدد أنواع القانون التي يجب على الطالب الإلمام بها.

الباب الثالث

مصادر القانون

يقصد بمصادر القانون، الأصل الذي استقى القانون منه موضوعه ومادته، وهذا يفترض وجود عدة عوامل مختلفة، منها ما هو اجتماعي، أو اقتصادي أو سياسي أو ديني، وهذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تشارك في خلق قاعدة معينة تدعو الحاجة إلى وضعها، تسمى القاعدة القانونية، ويوصف المصدر في هذه الحالة بأنه مصدر مادي أو موضوعي، أو حقيقي، فهذه المصادر تعتبر بمثابة المادة الأولى التي تساهم في تشكيل القاعدة القانونية وتكوينها^(١)، وقد يقصد بالمصدر هنا الأصل التاريخي أو المصادر التاريخية.

وقد استمد المشرع المصري قواعد كثيرة من الشريعة الإسلامية، فهي تعتبر مصدراً تاريخياً له، كما استمد القانون الفرنسي بدوره أحكاماً كثيرة من القانون الروماني الذي يعد مصدراً تاريخياً للقانون الفرنسي، وللقانون المصري - كذلك - في الحدود التي أخذ فيها عن القانون الفرنسي.

وقد يقصد بمصدر القانون المصادر التفسيرية، وفي هذا الإطار يعتبر كلاً من الفقه والقضاء مصدراً تفسيرياً لقواعد القانون، وما تزال السوابق القضائية معتبرة من قبيل المصادر الرسمية للقانون حتى اليوم في النظام الأنجلوسكسوني.

(١) د. سليمان مرقس - ص ١٥، د. حسن كيرة - فقرة ٦٤، د. منصور مصطفى منصور - ص ٩٥ وما بعدها، د. عبد المنعم فرج الصدة - ص ٧٨، د. شمس الدين الوكيل - ص ١٠٩، د. عبد الرزاق فرج - ص ٣٩.

وقد يستقى المشرع المادة القانونية مما استقر عليه العمل في المحاكم، وما ترجح من آراء الفقهاء، وهذا واضح في التقنين المدني المصري الحالي، فقد أخذ المشرع المبادئ التي قررها القضاء في الملكية الشائعة، وقسمة المهايأة، وحقوق الارتفاق والتزامات الجوار، والتعاقد بالمراسلة، وغيرها من المبادئ، مما استقر عليه القضاء.

الشرعية الإسلامية مصدر تاريخي لكافة النظم القانونية:

ومن الإنصاف والعدل أن تعطى الشريعة الإسلامية حقها، لأنها تعتبر حتى الآن، وستظل كذلك - إن شاء الله - إلى يوم الدين هي أقدم تشريع موثق ومنضبط على ظهر الأرض، حيث لا يوجد قانون أو تشريع قد نقل إلى الناس موثقاً محفوظاً من التغيير والتبديل مثل تلك الشريعة الغراء التي حفظها الله كما حفظ أحكامها بحفظه لكتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن المعلوم - أيضاً - أن كافة القوانين المعمول بها على ظهر الأرض أقصر تاريخاً من التشريع الإسلامي الذي قارب عمره ألفاً ونصف ألف عام، وكل التشريعات الوضعية دون هذا التاريخ بكثير، وربما لم يصل عمرها إلى مقدار نصفه أو ربعه، ولا يمكن إنكار أن التشريعات تتأثر ببعضها، وأن اللاحق يقتبس من السابق ويأخذ منه، فإذا وجد بينهما بعض التشابه في الأحكام يكون التشريع السابق هو المنقول عنه، والتشريع اللاحق هو الناقل.

لما كان هذا، وبإنزال ما تقدم على واقع التشريعات المعاصرة، نجد أن ثمة تشابهاً بينها وبين الشريعة الإسلامية في بعض المسائل التشريعية، فمثلاً النظام القانوني الاشتراكي أخذ من الشريعة الإسلامية فكرته المعروفة عن حدود استعمال الملكية، وأنها يجب أن تقتيد بعدم الإساءة في استعمالها إلى حقوق الغير، وقد تم اقتباس تلك الفكرة من الشريعة الإسلامية، بعد أن تم تطويرها وصياغتها على النحو الذي قال به هذا الاتجاه، وهو أن يكون للملكية وظيفة اجتماعية.

وفي النظام الجرمانى نجد فكرة المصلحة، أو النظرية الموضوعية في الالتزام، وبمقتضاها لا يشترط لقيام المسؤولية على الشخص ان يكون مميزاً، فإذا اتلف قاصر مالاً أو حدث إتلاف المال من غير شخص عاقل مدبر، فإن الذي يعنى هذا الاتجاه هو تعويض المال الذي تم الإضرار به، أو جبر الخسارة التي حدثت، وإن كان الخطأ يقتضى في معظم النظم عنصراً مادياً، وعنصراً معنوياً هو التمييز، وأن هذا العنصر المعنوي إذا فقد لا يقوم الخطأ، فإن هذا الكلام لا يسرى عند أصحاب النظرية الموضوعية، ولا يتفق مع المنطق الفكري الذي تقوم عليه، لأن المقصود هو جبر الضرر الذي حصل بصرف النظر عن تمييز الفاعل أو عدم تمييزه، وهذه الفكرة مأخوذة مما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية لمساءلة الصغير في ماله إذا اتلف مالا، أو من خلال تكليفه بالعبادات المالية ومنها الزكاة، حيث تجب في مال الصغير على الرأي الراجح في الفقه الإسلامي.

والنظام اللاتيني أخذ من التشريع الإسلامي الشكل وكثيراً من الموضوعات، ففيما يتعلق بالشكل ترى أنه أخذ من الفقه الإسلامي طريقة الاستنباط المستفادة من شرح النص لبيان دلالته على المطلوب، وأخذ الحكم الشرعى فيه، وهذه الطريقة ذاتها هي المعروفة في النظام اللاتيني بفكرة (الشرح على المتن) التى التزمت بها مدارس التزام النص، والتى هي نتاج طبيعى لحركة التقنين التى سادت في عهد نابليون حين أراد أن يقضى بها على تعدد النظم القانونية في فرنسا^(١).

ولم يقتصر الأمر على الشكل والمنهج، ولكنه أخذ كثيراً من الموضوعات عن التشريع الإسلامي، وذلك مثل نظرية البطلان، ونظرية الظروف الطارئة، وفسخ العقد، وغير ذلك من الموضوعات ذات الأصول المعلومة في التشريع الإسلامي.

والنظام الأنجلوسكسونى وإن كان مصدره الأساسى للقضاء، أو السوابق القضائية التى تكون المصدر الأساسى فيه، حيث نشأ القانون الإنجليزى نشأة عرفية، إلا أنه قد حاد عن ذلك من خلال بعض الأعمال الفقهية لعدد من الفقهاء الإنجليز منهم الأستاذ (دايسى)، والسير (جيمس ستيفن)، والأستاذ (جنكز) وغيرهم، بيد أن هذه الأعمال لا تعدو أن تكون عملاً خاصاً لهؤلاء الفقهاء وليست ذات

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١١٧.

صفة رسمية^(١)، ومع ذلك فإنها قد جاءت متأثرة بالمنهج الذي سار عليه التشريع الإسلامي، وأخذة عنه الاتجاه اللاتيني.

ولم يقتصر الأمر على ذلك الاقتباس المحدود من المنهج، ولكنه تعدى إلى بعض الموضوعات المأخوذة عن الفقه الإسلامي، وذلك مثل فكرة الدين كوصف تشغل به الذمة، وفكرة الوصية لما بعد الموت وتأقيت المنفعة، وغير ذلك من الموضوعات التي سبق إليها الفقه الإسلامي.

ولذلك فإن الإنصاف يقتضى أن نقرر ما يلي:

أولاً: أنه إذا كان التشريع الإسلامي هو الأسبق في الوجود والنشأة من كافة النظم القانونية الموجودة على ظهر الأرض، يكون التشابه الحاصل بين بعض تلك النظم وما هو مقرر في التشريع الإسلامي ناشئاً عن الأخذ منه، وهذا حق يتعين الاعتراف به.

ثانياً: أن اقتباس تلك النظم من التشريع الإسلامي، فيه دليل على مدى قدرة التشريع المقتبس منه على علاج الحالات الملحة، والتي لولا إلحاحها على حاجات المجتمع ما وجد نفسه مضطراً للاستعانة بها، وهذا في مجمله يعتبر شهادة حق التشريع الإسلامي، وفيه دلالة على صلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على حكم تصرفات الناس أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - المدخل للعلوم القانونية - ١٦٨ وما بعدها.

وإذا كان المصدر الرسمي هو الوسيلة التي تخرج بها القاعدة القانونية إلى الأشخاص وتكتسب صفة الإلزام ويصبح تطبيقها أمراً واجباً، فإن هذه المصادر الرسمية قد أشارت إليه المادة الأولى من التقنين المدني المصري بقولها:

(١) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص.

(٢) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعده العدالة.

ومن هذا النص يبدو أن التشريع هو المصدر الرسمي الأول للقواعد القانونية، ويتعين على القاضي حين يقوم بتطبيق القانون، أن يرجع إليه أولاً، فإذا لم يجد نصاً تشريعياً فإنه يرجع إلى العرف، فإذا لم يجد فإن عليه أن يلجأ إلى قواعد الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد فعليه وفق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

وعلى هذا فإن مصدر القانون الرسمية وفقاً لهذا الترتيب الذي أورده المشرع المصري تتمثل فيما يلي:

أولاً: التشريع.

ثانياً: العرف.

ثالثاً: مبادئ الشريعة الإسلامية.

رابعاً: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

خامساً: الفقه والقضاء كمصدرين تفسيريين للقانون المصري.
وسوف نقوم ببيان كل مصدر منها وفقاً للترتيب السابق، على أن
نخصص لكل مصدر فصلاً.

الفصل الأول

التشريع

كان التشريع - ولا يزال - هو الأداة الاجتماعية ذات القدرة على مواكبة التغيرات والتطورات المستجدة في حياة الناس، حيث تتوفر فيه الخصائص التي تجعل منه وسيلة فعالة في هذا المضمار، ليسر صناعته وسرعة إصداره مع اختوائه على المميزات الذاتية التي تحدد مضمونه، وتكشف عن المقصود من عباراته، وذلك من شأنه أن يسهل الاحتكام له، وشمول الحالات المستجدة في حياة الناس بوجوه الحماية التي يتضمنها، ووسائل الدفاع التي يقرها، وربما كانت السرعة في إصدار التشريع، مع تحديد مضمونه ووضوح عباراته في مجال التطبيق، هي إحدى مميزاته التي يتسم بها، والتي جعلت له أهمية خاصة في مواجهة التغيرات السريعة والمتلاحقة في حياة المجتمع، سيما في مجال الحماية الجنائية التي لا تتحدد المسؤولية فيها عند الإسناد من خلال نص يحدد الجريمة المرتكبة والعقوبة المقررة لها.

وسوف نبين في هذا الفصل مدى دور التشريع في ظل التطورات والمستجدات الحديثة، وذلك بالتطبيق على بعض الظواهر المستجدة في حياة المجتمع مثل امراض الإيدز، والاستنساخ وغسيل الأموال، وجرائم المعلومات، وذلك كما يلي:

المبحث الأول

دور التشريع في مواجهة الوقائع وتطبيقاته

المطلب الأول

دور التشريع في مواجهة الواقع

بات من المسلم أن التشريع عو الأداة الطيعة في يد المجتمع، والتي يستطيع أن يواجه المتغيرات الحاصلة، والمستجدات الطارئة اتلى تهب على ساحة الحياة الاجتماعية دون أن يكون لها مثال سابق، وذلك لمرونته وقدرته على مواجهة تلك المستجدات من خلال السرعة التي يتسم بها، والتي يمكن أن يظهر بها إلى حيز التنفيذ في ظرف أيام أو أقل، ولهذا كان من أنسب الأدوات التشريعية التي يقوى بها المجتمع على مواجهة تلك التغيرات الطارئة، وللتشريع في سبيل تحقيق المواجهة مع المستجدات الحديثة طريقان هما: إخضاع الواقعة المستجدة لنص قائم، او صياغة نص جديد يضطلع بتنظيم شئونها، وينبغي بيان ذلك.

أولاً: خضوع الواقعة المستجدة لنص قائم:

من خصائص النص التشريعي - وكما سبق القول - أنه يصاغ صياغة عامة ومجردة، بمعنى أن التكليف الذي يتضمنه لا يمكن أن يكون إلا تكليفاً عاماً مجرداً يتوجه إلى كل من تتوافر فيه صفة بعينها، لا إلى شخص بعينه، ويواجه كل واقعة تتوافر فيها شروط معينة لا واقعة معينة بذاتها، ومن هنا جاء ما يتميز به القانون من تواتر

التطبيق واضطراده كلما توافرت الصفة المطلوبة في فرد أياً كان، أو اجتمعت الشروط المعينة لواقعة أياً كانت، فالعموم والتجريد اللذان يتميز بهما القانون يصدقان في حق الأشخاص المخاطبين بما يتضمن من تكليف، كما يصدقان في حق الوقائع أو الروابط التي ينصرف إلى تنظيمها هذا التكليف، ويلاحظ وبعبارة أخرى، فالقواعد القانونية تتميز بالعموم والتجريد، وهما وجهان لعملة واحدة بالنسبة إلى أشخاصها وإلى موضوعها على حد سواء^(١).

والقانون باعتباره تكليفاً عاماً مجرداً لا يستنفذه تطبيق ما على شخص معين أو واقعة معينة، ولذلك فهو يكتسب صفة الدوام، بمعنى أنه لا يقتصر على الحال، بل يمتد كذلك إلى الاستقبال، فيتربص دائماً بصفة الشخص أو نوع الواقعة، وهو ما يتسع لعدد غير محدود أو محصور من الحالات^(٢).

لهذا، ونظراً لا يتسم به التشريع من عموم وتجرد، فإنه يمكن أن يستوعب المستجدات المعاصرة، إذا كان من الممكن شموله لها، أو دخولها تحت حكمه، ومن ثم لا يكون المطلوب - حينئذ - أكثر من تمحيص النص وتطبيقه على الواقعة المستجدة.

ويلاحظ أن إخضاع الواقعة لنص قائم، لا يجوز أن يعنى قياس جريمة على أخرى، أو عقوبة على عقوبة أخرى، لأنه لا يجوز

(١) د. حسن كيرة - المرجع نفسه - ص ٢٣.

(٢) المرجع نفسه.

إعمال القياس في مجال التشريع الجنائي، لا من جهة إلحاق واقعة غير مجرمة بواقعة مجرمة، ولا من جهة إلحاق عقوبة غير منصوص عليها بعقوبة منصوص عليها، لأن إرادة المشرع هي التي تقرر ذلك، وإنما الذي يعنيه ذلك الإخضاع للنص القائم، ان يمثل الفعل في ذاته جريمة نص عليها المشرع بنص سابق، وذلك مثل جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة بطريق غير مشروع، وذلك منعاً لمصادرتها، وكجريمة إحداث عاهة مستديمة فإنه يمكن أن يدخل في إطارها ويندرج تحت النص الحاكم لها، نقل الدم الملوث بالإيدز أو الفيروسات الكبدية القاتلة وغيرها، فإن مثل هذا العمل يمثل عاهة تورث المجنى عليه الأمراض القاتلة التي تظل ملازمة له حتى يلقي حتفه، وهكذا.

وقد يتسع إعمال النصوص القائم من خلال ما يسمى بالمصادر غير المباشرة للتشريع الجنائي، ذلك أنه قد يكون لبعض قواعد العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية، وقواعد العدالة دور في مجال القواعد الجنائية، إلا أن هذا الدور قليل الأهمية في مجال التجريم، حيث يسود مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويكون النص هو المصدر الوحيد لقاعدة التجريم، ومع ذلك فقواعد العلاف مثلاً يمكن الرجوع إليه في تحديد مفهوم (الإخلال بالحياة)، كذلك فإن العرف القضائي يمكن أن يستقر على بعض المفاهيم القانونية بتفسير في

مجال التطبيق يحدد معناها، وذلك كمفهوم الضرر في جريمة التزوير، ومفهوم الاختلاس في جريمة السرقة^(١).

وفي خارج نطاق التجريم والعقاب، يمكن أن يكون للمصادر غير المباشرة دور أكبر، فيمكن الاستناد إلى العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية في تقرير بعض حالات الإباحة أو تخفيف العقاب كما في حال حق الزوج في تأديب زوجته وأولاده، وكذلك يرجع إلى قواعد العرف في تقرير إباحة بعض الأعمال أو منعها، وعلة ذلك أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يكون بالنسبة لقواعد التجريم والعقاب فقط^(٢).

ثانياً: مواجهة الواقعة المستجدة بنص جديد:

وإذا كان من غير الممكن شمول النص القائم للواقعة المستجدة، فإنه لا يوجد ثمة مانع من إنشاء نص جديد يتولى تنظيمها، وبيان أحكامها، ووضع الضوابط التي تحدد التعامل معها، وذلك أمر ممكن في إطار الأهمية التي تمثلها تلك المسألة المستجدة ومدى تأثيرها على الحياة في المجتمع، والقدرة المتوافرة للمجتمع في إصدار التشريعات التي يستطيع أن يواجه بها مثل تلك التغيرات الطارئة، ومدى ما تحمله في طياتها من عوامل الجدة والحادثة غير المسبوقة بنظير.

(١) د. سمير الجنزوري - المرجع السابق - ص ٢٩.

(٢) د. سمير الجنزوري - المرجع نفسه.

بيد أن تلك الحالة تحتاج إلى نوع من الاستعداد التشريعي القائم على فهم الواقع وحسن تصويره مع القدرة على دقة الصياغة وإحكامها، وسلامتها من أوهام التصور المجافى للواقع، أو خضوع القائمين عليها لظروف نفسية عارضة تجعل حكمهم على أحد المراكز القانونية في الرابطة المراد تنظيمها جائراً أو غير متوازن، أو مبالغاً في تأديبه أو توقيع العقاب عليه.

المطلب الثاني

دور التشريع في إطار الواقع المعاصر

في مجال تطبيق التشريع لبيان مدى دوره في مواجهة المستجدات الحديثة، يمكن القول: إن الخصائص التي تميز بها، وجعلته قادراً على استيعاب تلك المستجدات، هي التي تحتوى مفرداتها، وتنطوى على ما يظهر منها، وذلك إما من خلال النصوص القائمة، أو من خلال استحداث نصوص جديدة في الأمور التي لا يمكن تخرجها في ظل نص قائم، أو قانون معمول به، وسوف نقوم بدراسة هذه التطبيقات في إطار تلك القدرات التشريعية للقانون، ومن خلال ما هو موجود، أو ما سويجد من النصوص الحاكمة للمستجدات المعاصرة، وذلك بالتطبيق على أمراض الإيدز، والاستنساخ، وغسيل الأموال، وجرائم المعلومات وغيرها من المستجدات.

المبحث الثانى

مزايا التشريع وعيوبه

ويمكن إجمال مزايا التشريع - إضافة إلى ما سبق - وعيوبه فيما يلى:

المطلب الأول

مزايا التشريع

من المعروف أن للتشريع دوراً أساسياً في مواجهة الواقع، وقدرة ملحوظة في علاج نوازل العصر، التى تحتاج إلى مجابهة سريعة، وعلاج لا يحتمل التأخير، ويمكن إبراز مزايا التشريع مجملة فيما يلى:

أولاً: يؤدى التشريع إلى صياغة القاعدة القانونية كتابة، ومن شأن تلك الصياغة أن تجعلها واضحة جلية لا يثير تفسيرها أو معرفة كنهها نزاعاً أو خلافاً، فالصياغة الدقيقة تحقق للقاعدة القانونية قدراً من الاحتياط، والتحديد والانضباط، وهذا يؤدى إلى سهولة تعرف الأفراد على حقوقهم وواجباتهم، وكيفية ممارسة هذه الحقوق وأداء الواجبات كما أن التشريع يساعد القائمين بتطبيقه على حسن أدائهم لمهمتهم مما يؤدى إلى استقرار المعاملات وسيادة الأمن في المجتمع، وهذا بخلاف المصادر الأخرى للقانون، ومنها العرف، إذ هو مصدر غير واضح، وغير مدون كالتشريع، وذلك من شأنه أن يؤدى إلى صعوبة التحقق

من وجوده ويشير النزاع حول قيامه وتكوينه وتحديد مضمونه مما يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات واضطرابها.

ثانياً: والتشريع به أهمية خاصة، من جهة أنه يعتبر وسيلة سريعة لملاحقة التطورات والاستجابة لضرورات المجتمع، وما قد يستجد فيها من ظروف تقتضى وضع قواعد عاجلة، لا يمكن أن يسعف فيها العزف، لبطء تكوينه، واحتياجه إلى وقت طويل لنشوئه.

ثالثاً: ومن مميزات التشريع أنه يتسم بالعمومية، فهو يسرى في كل إقليم الدولة، ويطبق على جميع المخاطبين بأحكامه، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق وحدة أبناء الوطن الواحد في ظل تشريع موحد يحكم عليهم جميعاً، كما يؤدي ذلك إلى الاستقرار والتجانس في حكم المعاملات، وتتوافر فيه ضوابط القاعدة القانونية الصحيحة، فهو ينظم السلوك ويقترن بجزاء توقعه السلطة العامة عند الاقتضاء^(١).

رابعاً: ومن مزايا التشريع - كذلك - أن يخضع القواعد القانونية للدراية والبحث، وبالتالي يكون القانون حصيلة نشاط القوى العاقلة المدبرة التى تتولاه بالبحث والفحص والدراسة والنقد والتمحيص والتدقيق والتحليل بغية تطويره وجعله ملائماً لمجابهة الواقع^(٢).

(١) د. أحمد سلامة - فقرة ٤٧، د. عبد المنعم فرج الصدة - فقرة ٦١، د. جميل الشرقاوى -

فقرة ٤٤، د. منصور مصطفى منصور - ص ١٠٩، د. عبد الرزاق فرج - ص ٤٣ وما

بعدها، شمس الدين الوكيل - ص ١٤٠ وما بعدها.

(٢) فى هذا المعنى: د. جمال الدين طه العاقل، ص ٩١.

خامساً: و التشريع - مع كل ذلك - يحقق انتقال الأنظمة القانونية من دولة إلى أخرى ومن جماعة إلى جماعة، لأن الدول تهتدى بما يسن في بعضها من القوانين عند وضع تشريعاتها، فتأخذ ما فيها من مميزات، وتتلافى ما يسفر عنه تطبيقها من مؤاذات^(١).

ولهذه الأسباب جميعاً أصبح للتشريع في المجتمعات الحديثة الغلبة على ما سواه من مصادر القانون الأخرى، وزاد من أهميته كثيراً انتشار الأفكار الاجتماعية التي تسمح للدولة بالتدخل الكبير في تنظيم العلاقات الخاصة.

المطلب الثاني

عيوب التشريع ومناقشتها

ورغم المزايا التي يتصف بها التشريع، إلا أن مما يعاب عليها ما يلي:

(١) أنه من عمل المحاكم، وقد يؤدي إلى أن يقوم بإصدار تشريعات ضد رغبات الشعب من أجل تأكيد سطوته وإحكام قبضته، وهذا النقد وإن كان وجيهاً، إلا أن مبعثه قد يكون نابعاً من سوء الظن بالحاكم أو عدم الثقة في السلطة الحاكمة، واتهامها من غير دليل بأنها لا تتحسن نبض الجماهير التي تحكمها ولا تدرى بما يدور حولها، وهذا لا يعدو أن يكون اتهاماً بغير دليل، وتعميماً في الحكم على الأشياء لا يصدقه

(١) المرجع نفسه.

الواقع، ولا يقبله المنطق، سيما وأن التشريعات قد تصدر من أعرق الدول في ممارسة الديمقراطية، ولا يمكن تصور إنحيازها وقت صدورها للحاكم لأن في تلك الدولة من الحرية ما يقوى معه المحكمون على مجابهة الحاكم بالنقد، ورده أولاً بأول إذا حدث منه إنحراف أو تجاوز، ولو كان لمثل تلك التحصات حظ من الصدق أو القول، لظهر أثر ذلك في حركة التشريعات على مستوى العالم فنهاها في ذبول وتقلص، لكن الواقع يشير إلى غير هذا، فهي في اضطراب دائم وتقدن مستمر، ومن ثم لا يكون لمثل تلك التقولات أثراً^(١).

كما يمكن رد ذلك بأن التشريع يصدر على سلطة منتخبة من الشعب وممثلة لإرادته منفذة لمقتضيات ظروفه وأحوال، وأن المشرع يتدخل من وقت إلى آخر فيعدل التشريع بحسب حاجة المجتمع إلى ذلك^(٢).

(٢) ويعاب على التشريع كذلك، أنه يتسم بالجمود ولا يساير الظروف الجديدة في المجتمع، وهذا النقد بدوره مردود، لأن المشرع يتدخل من وقت لآخر فيلغى التشريع أو يعدل من أحكامه كلما اقتضى الأمر ذلك^(٣).

(١) في هذا المعنى: د. جمال الدين طه العاقل، ص ٩٢.

(٢) د. عبد الرازق فرج - ص ٤٤ وما بعدها، د. سليمان مرقس - ص ٩٠ وما بعدها، د.

منصور مصطفى منصور - فقرة ٤٣، د. جميل الشراوى - فقرة ٤٤.

(٣) د. الرازق فرج - المرجع نفسه، ص ٤٥.

(٣) وقد يكون من أكبر ما يؤخذ على التشريع، أن ظروف اصداره قد تكون ظرفاً إنفعالية يحكمها التسرع وعدم التروى، أو قد يكون عارضاً لتحقيق مصالح فئة معينة على حساب أخرى من فئات المجتمع، وذلك في ظل ظروف تاريخية معينة، على نحو ما حدث في فترة الستينات في مصر، حيث صدرت قوانين عديدة بهدف إنصاف العاملين ونصرتهم على أصحاب الأعمال، ورعاية المستأجرين رعاية تجاهلت حقوق الملاك المؤجرين، إضافة إلى قوانين القطاع العام وغيرها من القوانين التي صدرت في فترة مؤقتة وفي ظل طفرة اتفعال تشريعي عارض، وفي غمرة رغبات شعبية طارئة، بعيدة عن الموضوعية والتجرد والحكم على الرابطة القانونية من كافة نواحيها، والنظر إلى المآلات البعيدة، والآثار السيئة التي يمكن أن تترتب على ذلك التشريع، خاصة وأن الذين يقومون بصناعة التشريع بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الجنوح للمصالح الفئوية على حساب المصالح العامة، ومن الانتصار للنفس على حساب الانتصار من الغير.

(٤) كما يلاحظ أن التقنين بعد صدوره - وعلى ما قد يكون فيه من مواد - يحظى بفترة من التقديس لنصوصه، ثم لا يلبث الواقع أن يكشف عن ذلك الوهم، ويستبين للناس أن هذا التشريع ما هو إلا خدعة كبرى^(١).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١١٧.

ولكن ذلك العيب على كبره، قد لا يكون له أثر كبير إذا تم اختيار أعضاء الهيئات التشريعية والبرلمانية بأسلوب جيد، إضافة إلى التغيير المتاح لتلك القوانين كلما وجدت الحاجة إلى التغيير، ورغم تلك الانتقادات فإن التشريع سيظل دائماً هو المصدر الأول والأكثر انتشاراً.

المبحث الثالث

سن التشريع

يقوم دستور كل دولة ببيان الجهة التي تختص بسن التشريع وهذه الجهة تسمى السلطة التشريعية، وهي قد تكون فرداً واحداً إذا كان حاكماً مطلقاً أو ملكاً، وقد تكون مجلساً أو مجلسين نيابيين يقوم الشعب بانتخابهما، كمجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومن ثم فإنهما ينيوبان عنه في سن التشريعات، وقد يشارك رئيس الدولة المجلس النيابي بما يثبت له من حق التصديق أو الاعتراض على التشريعات، كما في النظم البرلمانية التي تقوم على مبدأ التعاون بين السلطات ومنها مصر. وأحياناً يقوم رئيس الدولة بسن التشريع إذا وجدت ظروف معينة تستلزم ذلك.

ويلاحظ أن السلطة التي تقوم بوضع التشريع تختلف بحسب أهمية هذا التشريع فقد يعالج التشريع أموراً خطيرة تتعلق بمصالح البلاد العليا أو يتناول التشريع النظام السياسي للدولة، وفي هذه الحالة لا يكفي بالسلطة التشريعية العادية، بل يوكل الأمر إلى هيئة مشكلة

على نحو معين أو يرجع في ذلك إلى الشعب ليقدر ما يراه محققاً للصالح العام، أو إلى جمعية تأسيسية تشكل لهذا الغرض. وقد يكون التشريع عادياً فتختص بوضعه السلطة التشريعية العادية في البلاد مثل مجلس النواب في مصر. وقد يتعلق التشريع بمسائل تفصيلية لها أهمية ثانوية تتصل بالتطبيق العملي فيتولى وضعه السلطة التنفيذية نظراً لاتصالها الدائم بميدان العمل بين الناس، ولهذا تكون أقدر على إدراك مدى حاجتهم (١).

وسن التشريع يختلف بحسب نوعه وتدرجه من حيث القوة، ولهذا ينبغي بيان ذلك:

أولاً: تدرج التشريعات بحسب القوة:

تتعدد التشريعات وتختلف من حيث قوتها لحسب أهمية المسائل التي تعالجها، ومن ثم فإنها تدرج في القوة فأعلاها الدستور وهو التشريع الأساسي ويليه التشريع العادي أو الرئيسي وهو يشمل القوانين العادية، ثم يلي ذلك في القوة التشريع الفرعي وهو اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية.

ويترتب على هذا التدرج التشريعي، أن التشريع الأدنى درجة لا يجوز أن يخالف التشريع الأعلى منه، فلا يجوز أن تخالف القوانين

(١) د. جمال الدين العاقل - ص ٩٣.

العادية أو اللوائح والقرارات الإدارية الدستور، ولا يصح ان يخالف التشريع الفرعى (اللوائح والقرارات الإدارية) التشريع العادى أو الرئيسى، عند تعارض تشريعين من درجتين مختلفتين تكون الغلبة للتشريع الأعلى درجة على التشريع الآخر، والقضاء هو الذي يقوم بالفصل في ذلك^(١).

وسندرس فيما يلى الأنواع المختلفة للتشريعات وبيان كيفية سنها والسلطة المختصة بوضعها.

ثانياً: أنواع التشريعات بحسب درجتها وطريقة إصدارها:

ينقسم التشريع بحسب درجته وطريقة إصداره إلى التشريعات المختلفة التالية:

(١) التشريع الأساسى؛ ويسمى الدستور: ويختص بوضعه هيئة سياسية عليا عادة، أو جمعية تأسيسية تنتخب لهذا الغرض.

(٢) التشريع العادى أو الرئيسى: وهو عبارة عن القوانين التى تقوم بوضعها السلطة التشريعية، وهي مجلس النواب عندنا في مصر.

(٣) التشريع الاستثنائى: وهو القواعد القانونية التى يقوم بوضعها رئيس الدولة في ظروف معينة كحالات الضرورة، أو غير دور انعقاد السلطة التشريعية (مجلس النواب).

(١) المرجع نفسه - ص ٩٤.

(٤) **التشريع الفرعى:** وهو يتمثل في اللوائح والقرارات الإدارية ذات الصبغة التشريعية التى تتولى وضعها الوزارات المختلفة أو الهيئات العامة، أو الوزراء المختصون أو مديروا العموم وهم بصدد تنظيم الأعمال داخل وزارتهم أو إدارتهم، وسوف نبين طريقة سن كل تشريع في مطلب على حدة.

المطلب الأول

سن التشريع الأساسى (الدستور)

يعتبر التشريع الأساسى كما عرفنا من قبل هو الدستور، وهو يشمل القواعد القانونية التى تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ويحدد السلطات العامة فيها، واختصاص كل منها، ويقر الحقوق الأساسية للأفراد وواجباتهم والضمانات العامة لحمايتهم، وقد سبق بيان ذلك.

السلطات المختصة بسن الدستور:

تختلف السلطة المختصة بوضع الدستور من بلد لآخر، وفي البلد الواحد من زمان لآخر، فقد يتولى وضع الدستور هيئة سياسية عليا قد تتمثل يفي الحاكم، وقد تكون جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب وقد تكون السلطة التشريعية في البلاد، وقد يكون الشعب نفسه عن طريق الاستفتاء.

وكان أول دستور صدر في مصر سنة ١٩٢٣ في شكل منحة من الملك فؤاد للشعب، وقد صدر دستور جمهورية مصر العربية

المتحدة في ٢٥ مارس سنة ١٩٦٤م، كما صدر دستور في ١١/٩/١٩٧١م، حيث تم هذا في التاريخ إعلان دستور مصر الدائم، والذي تم تعديله بقرار مجلس النواب في ٣٠/٤/١٩٨٠م. وأخيراً صدر دستور عام ٢٠١٤م، وتعديلاته ٢٠١٩م.

طريقة سن الدستور وتعديله:

كما تختلف طريقة سن الدساتير عن طريقة تعديلها وبحسن بيان ذلك مع بيان دستورية القوانين:

أولاً: طريقة سن الدستور:

يمكن القول أن الدساتير تنقسم من حيث طريقة سنّها إلى أنواع ثلاثة هي:

(١) الدستور الممنوح:

وهو الدستور الذي يصدر في شكل منحة من الحاكم للشعب، ومن أمثلة ذلك: الدستور المصري الصادر سنة ١٩٢٣م، حيث كان منحة من الملك فؤاد.

(٢) الدستور الاتفاقي:

وقد يصدر الدستور في صورة عقد بين الشعب والحاكم، يقوم الحاكم بمقتضاه بإصدار الدستور الذي يكفل حقوق الشعب.

ويلاحظ أن إنجلترا كانت أسبق الدول إلى فكرة التعاقد، فقد ثار النبلاء في وجه الملك وأجبروه على إمضاء العهد الأكبر، وفي فرنسا تنازل الملك شارل العاشر عن العرش واجتمع نواب الأمة ووضعوا

مشروع دستور سنة ١٨٣٠م، وتلى هذا الدستور الصادر بهذه الطرق،
بالدستور الاتفاقي.

(٣) الدستور الشعبي:

وهناك طريقة أخرى لسن الدستور وهي: أن يقوم الشعب نفسه
بوضع الدستور عن طريق هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب، أو تقوم
الحكومة بوضع الدستور ثم يطرح على الشعب للاستفتاء، وقد حدث
ذلك بالنسبة للدستور المصري الصادر سنة ١٩٥٦م، ويسمى الدستور
الصادر بتلك الطريقة، بالدستور الشعبي، وهو أكثر أنواع الدساتير^(١).

ثانياً: طريقة تعديل الدستور:

تنقسم الدساتير من حيث الطريقة التي يجب اتباعها لتعديل
أحكامها أو إلغائها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة، وهذا مما
لا يختلف فيه نظر الفقه.

(١) الدستور المرن:

هو الذي يكفي لتعديله أو إلغائه اتباع نفس الإجراءات اللازمة
لتعديل القوانين العادية، ومثال الدستور المرن: الدستور الإنجليزي،
حيث يمكن تعديله بما تعدل به القوانين العادية.

(٢) وأما الدستور الجامد:

(١) في هذا المعنى: د. جمال الدين العاقل - ص ٩٦.

فإنه لا يمكن تعديله إلا بعد إجراءات طويلة، وتوافر شروط معينة لا يلزم تشدداً، ويعتبر الدستور المصرى الصادر سنة ١٩٧١م مثلاً لذلك، فقد نصت المادة (١٨٩) منه، على ما يلى: "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادراً من مجلس النواب، وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلسي على الأقل، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراراً في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة النظر في تعديل المواد ذاتها قبل مضي شهر على هذا الرفض.

فإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتاءه في شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

ثالثاً: دستورية القوانين:

من المقرر أن الدستور يعتبر أعلى مراتب التشريع، ولهذه المرتبة فإنه لا يجوز أن تخالف النصوص القانونية أحكام الدستور، ومع ذلك فإن تلك المخالفة رغم صحة الحكم عليها مجردة، إلا أن مضمونها قد أثار خلافاً في رأى حول طبيعة الإجراء الذي يلزم اتخاذه نحوها، وما إذا كان يجوز معه للقاضى أن يمتنع عن تطبيق

النص المخالف للدستور أم لا يجوز له ذلك؟ وبعبارة أوضح: هل من حق المحاكم أن تراقب مبدأ دستورية القوانين.

لقد أثار هذا الحكم خلافاً في الرأي، وقد جاء هذا الخلاف من جراء سكوت المشرع المصرى عن تقرير حكم في الموضوع، حيث لم يعط المحاكم هذا الحق، ولم يمنعها منه، ومن ثم ظل الأمر متروكاً لاجتهاد الفقهاء والمحاكم، وهذا الاجتهاد يفرق بين مخالفة القانون للدستور من الناحية الشكلية، ومخالفته له من الناحية الموضوعية، ولكل حالة من هاتين المخالفتين حكماً:

(١) المخالفة الشكلية:

فيما يتعلق بالمخالفة الشكلية نجد أن الفقهاء يتفقون على ثبوت الحق للمحاكم في أن تراقب دستورية القوانين من حيث الشكل، وبناء على ذلك فإن للمحاكم الحق في الامتناع عن تطبيق القانون الذي جاء مخالفاً للدستور من حيث الشكل، وذلك كأن يكون القانون قد صدر غير حائز للأغلبية المطلوبة، أو لم ينشر في الجريدة الرسمية، أو لم يصدره رئيس الجمهورية، ففي هذه الأحوال يكون القانون غير نافذ ولا يصح تطبيقه^(١).

(٢) المخالفة الموضوعية:

وأما المخالفة الموضوعية، فقد حدث فيها خلاف كبير بين الفقهاء تركّز حول أحقية المحاكم في مراقبة دستورية القوانين، فذهب

(١) د. جمال الدين العاقل - ص ٩٨.

رأى إلى عدم إعطاء الحاكم الحق في مراقبة دستورية القوانين في هذه الحالة، ومن ثم لا يحق للقاضي أن يمتنع عن تطبيق القانون غير الدستوري، لن ذلك يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الفصل والسلطة القضائية المختصة بتطبيقه، فإذا امتنع القاضي عن التنفيذ فإنه يترتب على ذلك تعطيل القانون الذي يشكل افتئاتا على اختصاص السلطة التشريعية.

وذهب الجانب الأكبر من الفقهاء واحكام القضاء إلى وجوب الاعتراف للمحاكم بحق رقابة دستورية القوانين، لأن الأمر لا يعدو ان يكون مجرد تغليب قاعدة على قاعدة أخرى في حالة تعارض القاعدتين، وهنا يجب على القاضي أن يغلب القاعدة الدستورية لأنها أعلى مرتبة من التشريع العادي، والقاضي إذ يفعل ذلك لا يكون قد اعتدى على السلطة التشريعية بل يكون قد سائر منطق تدرج التشريعات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنه إذا لم تخول الدولة الحق في رقابة دستورية القوانين فإن هذا سيعنى أن السلطة التشريعية تجبر السلطة القضائية على تنفيذ القوانين المخالفة للدستور، وحين يكون لها الحق في رقابة دستورية القوانين تستطيع أن تتلخص من هذا الإجبار.

هذا بالإضافة إلى أن الجميع يسلمون بأن للمحاكم حقاً في الرقابة على دستورية اللوائح، ولم يرق أحد بمنع هذه الرقابة بمقولة أنها تشكل اعتداء على السلطة التنفيذية، فالقياس صحيح على ذلك للمحاكم الحق في رقابة دستورية القوانين.

وقد تأكد هذا قضائياً فذهبت محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الإدارية العليا إلى إثبات حق رقابة دستورية القوانين للمحاكم عند مخالفة القانون لنص دستورى، أو عند خروجه على روح الدستور، وقد أصبح الخلاف المتقدم بين الفقهاء والقضاء غير ذوى جدوى، سيما بعد صدور القرار بقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩م، والذي بموجبه أصبحت المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين، وذلك في حالة الدفع بعدم دستوريته أمام أى محكمة.

وتقرر المادة الأولى من هذا القانون: "أن المحكمة التى يتمسك أمامها بعدم دستورية القانون، لا يجوز لها الفصل في هذا الدفع بنفسها، بل يتعين عليها أن تقرر وقف الفصل في الدعوى الأصلية، وتحدد للخصم موعداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا"، والحكم الصادر من هذه المحكمة يكون حكماً مهائياً وملزماً لكافة المحاكم^(١).

المطلب الثانى

سن التشريع العادى

يطلق اصطلاح التشريع العادى في هذا الموطن من الدراسة، ويقصد منه: القانون بالمعنى الضيق الذي يراد به مجموعة القواعد القانونية التى تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والذي تقوم به السلطة

(١) المرجع نفسه - ص ٩٩، ود. عبد المنعم البدرأوى - السابق.

التشريعية في حدود اختصاصها بسن التشريع على النحو المبين بالدستور.

ويتولى السلطة التشريعية في مصر، مجلس النواب، وقد نصت المادة (١٠١) من الدستور المصرى الحالى الصادر في سنة ٢٠١٤م، على أنه: "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور".

المراحل التى يمر بها سن التشريع العادى:

يمر التشريع العادى عندسنه بعدة مراحل هي: مرحلة الاقتراح والمناقشة والتصويت، والتصديق، وإصدار التشريع، ونبين هذه المراحل بالتفصيل الذي تقتضيه الدراسة، وذلك كما يلى:

أولاً: مرحلة الاقتراح:

التشريع شأنه شأن أى فكرة يراد لها أن تظهر إلى حيز الوجود، ولذلك فإنه يبدأ اقتراحاً، والاقتراح هو الصياغة الأولية التى تتجسد فيها فكرة التشريع، فلا بد أن نكون بصدد فكرة، ولا بد أن تتجسد تلك الفكرة في صياغة محددة يدور حولها النقاش، ويتجادب المتناقشون فيها أطراف الحديث، ويشتد حول بعض نصوصها الخلاف حتى يحتد، ثم ينتهي برفع أيدي الأغلبية للموافقة، أو ظهور أصوات الموافقين

والمخالفين على شاشة ضوئية تعطى قراءة سريعة برأى الأغلبية في المسائل التي يدور حولها الخلاف بالموافقة أو بالمخالفة.

وحق اقتراح القوانين مقرر أولاً للسيد رئيس الجمهورية، وهو لن يمارس هذا الحق بنفسه، حيث لا يتصور فيه الإحاطة بكل شيء، ولا يفترض فيه أنه متخصص في كل الأمور، وإنما سيمارسه بواسطة أعوانه من الخبراء والمستشارين والوزراء الذي يعدون المشروع بواسطة اللجان الفنية في وزاراتهم، فإذا ما انتهت تلك الصياغة التي لا يتصور فيها إلا أن تكون أولية، أحال الوزير المختص المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغته ابتداءً، إذا كان الاقتراح المقدم فكرة يراد لها أن تتخذ شكل قانون، أول لمراجعة صياغته إذا كان قد أحيل بعد صياغته صياغة أولية، وبعد ذلك يعرض على السيد رئيس الجمهورية، فإذا ارتضى ما قدم له، أحاله إلى مجلس النواب، والاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية يسمى (مشروع بقانون)، وهذا المسمى يختلف عن ذلك الاقتراح بقانون، الذي يقدم من أحد أعضاء مجلس النواب، حيث يسمى (اقتراح بقانون)، وقد نصت المادة (١٢٢) من دستور ٢٠١٤م على أنه "الرئيس الجمهورية، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب، حق اقتراح القوانين. ويحيل مجلس النواب مشروعات

القوانين المقدمة من الحكومة، أو من رئيس الجمهورية، أو من عشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لفحصها"....^(١).

ثانياً: المناقشة والتصويت:

بعد فحص مشروعات القوانين من اللجان المختصة يجب عرضها على المجلس حتى تتم مناقشتها وجرى التصويت عليها، وبعد أن يعرض المشروع على المجلس بكامل هيئته تجرى مناقشته، وبعد المناقشة يؤخذ الرأي على المشروع أو الاقتراح مادة مادة^(٢).

وتتم الموافقة على المشروع أو الاقتراح بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر المشروع قانوناً^(٣)، ومن الضوابط التي وضعها الدستور لذلك أنه:

- (أ) لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
- (ب) وأن المجلس تتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ويراد بالأغلبية هنا حضور عدد يزيد على نصف أعضاء المجلس، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية أو تساوت الآراء فإن الموضوع يعتبر مرفوضاً كما سبق بيانه.

(١) مادة ١٢٢ من الدستور الحالي، وراجع، د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٢٢، د. جميل

الشرقاوى - ص ١١١ وما بعدها، د. أحمد سلامة - فقرة ٤٧، د. عبد الرزاق فرج -

ص ٤٨ وما بعدها، د. عبد المنعم فرج الصدة - فقرة ٦٦، د. منصور مصطفى منصور

- ص ١١٣ وما بعدها.

(٢) مادة ١٠٧ من الدستور.

(٣) نفس المادة.

(ج) ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
(د) كل مشروع قانون اقترحه الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة ثانية في نفس دورة الانعقاد^(١).

وبعد مناقشة نصوص المشروع مادة مادة يعرض للتصويت، فإذا وافقت عليه الأغلبية كان ذلك موافقة على المشروع.

ثالثاً: تصديق رئيس الجمهورية:

بعد موافقة مجلس النواب على المشروع يعرض على رئيس الجمهورية الذي أعطاه الدستور حق الاعتراض على القانون^(٢)، والتصديق على هذا النحة يعتبر عملاً تشريعياً، حيث يعتبر مظهراً لاشتراك رئيس الدولة مع السلطة التشريعية كأحد نتائج الأخذ بالنظام البرلماني الذي يعتمد على التعاون بين السلطات، وليس على الفصل التام بينهما على نحو ما هو مقرر في النظام الرئاسية.

فإذا أرسل المشروع إلى رئيس الجمهورية ووافق عليه ولم يرده ثانية إلى المجلس في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس له اعتبر قانوناً وأصدر^(٣).

أما إذا اعترض رئيس الجمهورية على المشروع، فإنه يجب عليه أن يرده إلى المجلس في مدة الثلاثين يوماً المحددة بالدستور من

(١) مادة ١٢٣ من الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في ٢٣ / أبريل / ٢٠١٩.

(٢) مادة ١٢٣ من الدستور.

(٣) مادة ١٢٣ من الدستور.

تاريخ إبلاغ المجلس له، فإذا رده إلى المجلس في الموعد السابق وجب على المجلس إعادة المناقشة وأخذ الأصوات عليه من جديد، وفي هذه الحالة فإنه يشترط أن يوافق عليها ثلثا الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وليس ثلثي الحاضرين فقط، فإذا حاز المشروع تلك الأغلبية اعتبر قانوناً وأصدر.

ومن ثم يبدو أن حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروع القانون لا يؤدي إلى إسقاطه بمجرد الاعتراض، وإنما قد تؤدي - فقط - إلى مجرد تأخيره، وذلك في حالة ما إذا أعيد عرضه على مجلس الأمة، وأقره بالأغلبية المطلوبة في الدستور، وذلك فإنه من الأوفق أن يسمى ذلك الاعتراض، بالاعتراض التوفيقى ليس إلا^(١).

رابعاً: إصدار التشريع:

بعد موافقة رئيس الجمهورية على المشروع، أو عدم اعتراضه عليه، أو اعتراضه عليه وإقراره من مجلس النواب بعد ذلك الاعتراض على نحو ما سبق، تتم العملية التشريعية ويوجد القانون، إلا أن هذا القانون لا ينفذ إلا بإجراء من جانب رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية الموكول إليها تنفيذ القانون.

فالإصدار: عمل من رئيس الجمهورية مفيد لتحقيق أمرين هما:

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - مبادئ القانون - ص ١٢٣.

(١) إثبات وجود التشريع، أى إعلان أن السلطة التشريعية قد أصدرت قانوناً وفقاً لأحكام الدستور، فالإصدار بمثابة شهادة الميلاد بالنسبة للقانون الجديد.

(٢) أن الإصدار يتضمن أمراً من رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية، لسائر أعضاء هذه السلطة وعمالها، بتنفيذ المشروع الجديد كقانون من قوانين الدولة، ومن ثم يصبح واجب النفاذ.

والإصدار واجب على رئيس الجمهورية، لأنه إن لم يفعل قد عطل تنفيذ قانون اعتمدته السلطة التشريعية، وهو ما ينطور على معنى الاعتداء عليها، ومن ثم لا يجوز له الامتناع عن الإصدار أو تأخيره، وهو ليس ملزماً بانتظار مدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض ليصدر القانون، بل إن بمقدوره أن يصدره بمجرد إبلاغه به، ويتضمن هذا بالطبع عدم استعماله حق الاعتراض على المشروع.

ويستهل التشريع بالعبرة الآتية:

- مجلس النواب.
 - رئيس الجمهورية.
 - قرر مجلس النواب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه.
- ويشار إلى التشريعات في مصر برقم مسلسل خلال السنة التي صدرت فيها، ويأخذ القانون تاريخ إصداره بواسطة رئيس الجمهورية، فيقال مثلاً: القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وفي نهايته: يبصم هذا

القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من ثوانينها، صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ المحرم سنة ١٣٨١ هـ (٥ يوليو سنة ١٩٦١).

خامساً: نظر التشريع:

يصبح التشريع واجب النفاذ بإصداره، ولكنه لا يجوز أن يطبق في حل الأفراد إلا إذا توافرت لهم وسيلة العلم به، ولهذا كان من العدل أن يعلق تطبيق التشريع على نشره، فالنشر إجراء يقصد به تمكين الأفراد من العلم بالقانون ليكونوا ملزمين بأحكامه، وقد اختارت الشرائع الحديثة طريقة خاصة للنشر هي نشر التشريع في جريدة خاصة تعرف في مصر بـ (الجريدة الرسمية)، فلا يجوز النشر في سواها، ولا يقوم مقامها أى إجراء آخر، ومن ثم فى يجرى النشر إذا تم في الصحف اليومية، أو بطريق الإذاعة، أو التلفزيون، أو عبر شبكة الإنترنت الدولية، أو إخطار الفرد به شخصياً بطريق آخر كخطاب أو إنذار على يد محضر، حيث لا يغنى عن نشر التشريع في الجريدة الرسمية شيء سواها، وهذا النشر واجب بالنسبة لكافة صور رعات، يستوى في هذا التشريع الدستورى، والتشريع العادى، والتشريع الفرعى.

وقد ألزم الدستور السلطة التنفيذية بنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها بواسطة رئيس الجمهورية، وإذا تم نشر القانون في الجريدة الرسمية فإنه يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا صدر لذلك ميعاد آخر، وإذا تم النشر فإن علم الكافة بالقانون يفترض، لأن هذا النشر يعد قرينة

قاطعة على علم الجميع به، فلا يجوز لأحد منهم بعد ذلك أن يدعى شخصياً انه لم يعلم بالقانون، حيث لا يقبل من أحد أن يدعى جهله بالقانون، أولاً يفترض في أحد الجهل بالقانون، وبدون هذا الافتراض يختل تطبيق التشريع عنه صفة العمومية.

المطلب الثالث

سن التشريع الفرعى

يشتمل التشريع الفرعى فيما تسنه الدولة من خلال سلطتها التنفيذية من لوائح تنظيم وتفصيل التشريع العادى، ولترتيب المرافق والمصالح العامة، ولحفظ الأمن وصيانة الصحة العامة، واللوائح التى يحتويها التشريع الفرعى ثلاثة هي: اللوائح التنفيذية، واللوائح التنظيمية، ولوائح الضبط، وتشريع الضرورة، ونبين كلاً منها تباعاً:

أولاً: اللوائح التنفيذية:

وهي تلك التى تصدر تنفيذاً للقانون الصادر من السلطة التشريعية، وذلك من خلال اتصالها المستمر بالجماهير، وتعرفها على التفاصيل الدقيقة اللازمة لوضع هذه الأسس والقواعد موضع التنفيذ. وقد نصت المادة (١٧٠) من الدستور الصادر في سنة ٢٠١٤م، على أنه: " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بعد مراجعة مجلس الدولة، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ".

ومن أمثلة اللوائح التنفيذية الصادرة من رئيس الجمهورية تنفيذاً للقانون، القرار الجمهوري رقم (٢٥٠) لسنة ١٩٧٥، بشأن القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦١، ويجب أن تنقيد هذه القرارات بوضع الإجراءات التي تكفل تنفيذ القانون، ولا تتجاوز ذلك إلى حد تعديل أحكام القانون أو تعديلها.

ثانياً: اللوائح التنظيمية:

وهي التي توضع لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، وترتيبها وتنسيق سير العمل في هذه المرافق والمصالح والإدارات الحكومية، وهذه اللوائح مستقل بذاتها، ويستقل بوضعها رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. دون استناد إلى تشريع قانون كما هو الشأن بالنسبة للوائح التنفيذية، وذلك بناء على ما تقضي به المادة (١٧١) من الدستور الحالي. هذه اللوائح تختص بوضع الأسس التفصيلية التي لا يعنى بها القانون غالباً، وهو معنى بوضع الأسس العامة للتنظيم الإداري للدولة.

ثالثاً: لوائح الضبط:

وتسمى هذه اللوائح؛ لوائح الضبط أو البوليس، وهي الأخرى من اللوائح المستقلة أي التي لا تستند إلى تشريع رئيسي يقوم بتنفيذه، وهذه اللوائح أكثر خطورة من اللوائح التنظيمية لأنها تمس الأفراد في حرياتهم وأموالهم مباشرة وغيرها لا يتعدى إلى ذلك.

والقصد من سن تلك اللوائح المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، وقد نصت المادة (١٧٢) من الدستور على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء"، وبدهي فإن السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تنظم هذه الأمور الثلاثة بدون أن تحد من حريات الأفراد وتصرفاتهم. ومن أمثلتها لوائح المرور، واللوائح الخاصة بمراقبة الأغذية، والخاصة بمنع انتشار الأوبئة، واللوائح الخاصة بالمحال العامة، والخطرة، والمقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة. وتتضمن لوائح الضبط بعض العقوبات، ولكنها مقررّة بالنص عليها في قانون العقوبات في المادة (٣٧٣)، التي تنص على أن: "كل من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية، يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح".

رابعاً: تشريع الضرورة:

وتشريع الضرورة، هو ما يصدره رئيس الجمهورية في حالة الضرورة، وفي الأحوال الاستثنائية بناء على تفويض من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وهذه القرارات لها قوة القانون، وهذا التفويض يجب أن يكون لمد محددة، وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات، والأسس التي تقوم عليه، ويجب عرض هذه القرارات على

مجلس النواب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها، زال ما كان لها من قوة القانون. وقد نصت المادة ١٥٦ من الدستور سنة ٢٠١٤ المعدل في ٢٣/٤/٢٠١٩ على أنه: إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية للمجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، كما نصت المادة ١٥٧ لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، ويجب التصويت على كل واحدة منها^(١).

الرقابة على شرعية اللوائح:

(١) مادة ١٥٧ من دستور سنة ٢٠١٤ المعدل بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩.

من المقرر أن اللائحة لا يجوز أن تخالف القانون، وهذا يصدق على جميع اللوائح سواء أكانت تنفيذية أو تنظيمية أم لوائح ضبط، وهنا يثور تساؤل: ما الحكم إذا خالفوا الضبط اللائحة القانون؟، وهل يجوز للقضاء أن يمارس سلطة رقابة شرعية اللوائح؟، لقد جرى القضاء في مصر على ممارسة ذلك، متى ثبت له أن اللائحة مخالفة للقانون، فإذا وجدها كذلك، فإن له أن يمتنع عن تطبيقها، ولكنه لا يملك الحكم ببطلانها استقلالاً، لكن له أن يمتنع عن إنزال حكمها في الدعوى المرفوعة أمامه من تلقاء نفسه، حتى ولو لم يطلب منه أحد ذلك.

أما القضاء الإداري، فإن له فضلاً عن عدم تطبيق اللائحة المخالفة للقانون، الاختصاص بأن يحكم بإلغائها متى طعن أصحاب المصلحة فيها بدعوى خاصة تعرف بدعوى الإلغاء، وقد أعطى قانون إنشاء مجلس الدولة لمحكمة القضاء الإداري، الاختصاص بالنظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة^(١)، وميعاد الطعن بالإلغاء ستون يوماً من

(١) مادة ٨ من قانون مجلس الدولة.

تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويصدق ذلك من باب أولى في حالة مخالفة اللائحة لأحكام الدستور^(١).

عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون:

من المعلوم أن الطريقة الوحيدة التي يعتد بها القانون في إعلام الناس بالتشريع، هي نشره في الجريدة الرسمية.

وبناء على ذلك؛ فإنه إذا نشر التشريع في الجريدة الرسمية وانقضت المدة القانونية فإنه يفترض أن الناس قد علموا بالقانون وأصبحوا مطالبين بتنفيذه، حتى ولو كانوا في حقيقة الأمر يجهلون القراءة والكتابة أو لم يطلعوا على الجريدة الرسمية المنشور بها التشريع، فلا يصح لأحد أن يحتج بأنه يجهل القانون حيث لا يعذر أحد بجهله بالقانون، وهذه قاعدة من القواعد المقررة في الدستور، ومسلم بها كما أنها قد حظيت بشهرة ارتفعت بها إلى مستوى الأصول القانونية، ويراعى أن هذه القاعدة لا تطبق إلا بالنسبة للالتزامات التي يفرضها القانون على الأفراد، أما بالنسبة للحقوق التي يمنحها القانون فإن هذه الحقوق تتحدد قبل نشر القانون^(٢).

كما يراعى - أيضاً - أن الأجانب الذين يتواجدون على إقليم الدولة، تسري عليهم أحكام التشريع كما يسرى على المواطنين بحيث

(١) د. عبد المنعم البدروى - ص ١٣٠.

(٢) د. جمال الدين طه العاقل - ص ١٥٣، د. عبد المنعم البدروى - ص ١٣٢.

إذا وجد واحد منهم في مركز قانوني ينظمه التشريع الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية فلا يقبل منه الاحتجاج بجهله القانون.

هذا وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون تسري أيضاً على السلطة القضائية، وكذلك السلطة التنفيذية حيث يفترض في القاضي العلم بالقانون كما ينبغي على السلطة التنفيذية عندما تصدر قراراتها أن تكون هذه القرارات متفقة مع القانون، وإلا كانت عرضة للإلغاء، حيث لا يقبل منه الاحتجاج بجهله القانون، لأنه لو أبيع ذلك لأي أحد، لانتشرت الفوضى وساد الاضطراب في المجتمع.

مبررات هذه القاعدة:

قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون مؤسسة على مقتضيات عملية هي وجوب تطبيق القانون دون هوادة، لأنه لو فتحنا باب الاعتذار بالجهل بالقانون لأدى ذلك إلى عدم تطبيقه على غالبية الأفراد، فالقليل منهم هو الذي يعرف أحكام القانون وقواعده، وقد يشفع للأخذ بهذه القاعدة فوق ما تخظى به من أهمية، أنها في الغالب يقتصر تطبيقها على قانون العقوبات، كما أن معظم الجرائم الواردة فيه تحرمها الأخلاق، فهي تعتبر من المعلوم للناس بالضرورة^(١)، وحتى لا تضيع عمومية القانون ويحتل مبدأ المساواة بين الناس أمامه.

(١) د. جمال الدين العاقل - ص ١٥٤.

نطاق تطبيق المبدأ:

وتطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ليس على إطلاقه، وإنما هي مقيد بمجموعة من الاستثناءات التي ترد عليه، وهي كما يلي:

(١) حالة القوة القاهرة:

تعتبر حالة القوة القاهرة واحدة من الاستثناءات الواردة على المبدأ ويقصد بالقوة القاهرة هنا، قيام ما يحول دون وصول العلم بالقانون إلى المخاطبين به، فإذا وجدت ظروف مادية قاهرة تمنع هذا العلم كزلازل أو حرب أو مرض وبائي، أدى إلى عزل منطقة فقليم الدولة يكون للفراد المعزولين الحق في التمسك والاحتجاج بعدم علمهم بأحكام القانون، ومن العدل والإنصاف أن يعذروا بسبب ذلك الظاهر القاهر.

وكذلك لو قام جيش من العدو بمحاصرة مكان فأدى هذا الحصار إلى عدم علم الأشخاص الموجودين داخله بالقانون، فإن لهؤلاء الأشخاص ان يتمسكوا بعدم العلم بالقانون، ويعذروا بذلك^(١).

(٢) الغلط في القانون:

في المسائل غير الجنائية يمكن للأشخاص الاحتجاج بالغلط في القانون، عملاً بالمادة (١٢٢) من القانون المدني المصري، التي

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٣٣، د. جمال الدين العاقل - ص ١٥٧.

تقضى بجواز إبطال العقد إذا الدافع إليه الغلط في القانون، ومثال ذلك أن يقوم ببيع نصيبه في التركة اعتقاداً منه أنه الربع، وهو في حقيقته النصف، فهنا يحق للوارث المطالبة بإبطال البيع للغلط الذي وقع فيه. وكذلك الأمر بالنسبة لمن تصالح من قريب له على أنه وارث، فأتضح أنه غير وارث شرعاً، ويرى بعض الفقهاء الاستناد إلى أن المشرع غنماً أجاز التمسك بالغلط في القانون للوصول إلى أن الجهل بالقانون يعتبر عذراً، قول غير صحيح، لأنه يختلط بين الجهل بالقانون والغلط فيه.

وكذلك تستثنى من هذه القاعدة حالة الجهل بقوانين غير جنائية حيث يمنع المسؤولية الجنائية إذا كانت العقوبة مؤسسة عليه، والقضاء والفقهاء في فرنسا مستقر على ذلك وبناء عليه فقد حكمت محكمة باريس ببراءة من استولى على كنز موجود في أرض غير جاهلاً أن نصيبه النصف فقط، ولا يعد هذا خروجاً على المبدأ القائل بعدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون، فمن عثر على الكنز في أرض مملوكة لغيره لا يعاقب لعدم توافر القصد الجنائي لديه، وهو ركن من أركان الجريمة^(١).

ويلاحظ - أيضاً - أنه في المسائل غير الجنائية قرر المشرع المصري إعفاء الموظف العمومي من المسؤولية املدنية إذا ارتكب

(١) د. جمال الدين العاقل - ص ١٥٨.

فعلاً غير مشروع وكان يعتقد مشروعيته، إذا كان هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة^(١).

(٣) في المسائل الجنائية:

كما قرر المشرع - أيضاً - إعفاء الموظف العمومي من العقوبة الجنائية عملاً بالمادة (٦٣) من قانون العقوبات، وذلك إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر رئيسه، أو اعتقد أن جراء الفعل من اختصاصه، وعلى الموظف أن يثبت ذلك، وأنه كان يعتقد - بناءً على أسباب معقولة - مشروعيته.

والخلاصة أن قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون تمثل مبدأ عاماً يصدق عليه كل القواعد القانونية أياً كان مصدرها، وسواء كانت آمرة أو مكملة عرفية كانت أو دينية^(٢).

ويلاحظ أن الاستثناء الخاص بالقوة القاهرة يكون محدداً بمدة معينة وهي التي توجد فيها حالة القوة القاهرة، فإذا زال الاستثناء، كما أن هذا الاستثناء قاصر على القواعد التشريعية لأنها وحدها التي تنتشر في الجريدة الرسمية، وتعتبر معلومة للناس بعد نشرها في هذه الجريدة^(٣).

(١) مادة ١٦٧ مدني مصري.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٣٣.

(٣) د. جمال الدين العاقل - ص ١٥٩، وقارن ما ذهب إليه د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ١٣٢ وما بعدها، حيث يرى أن المبدأ يشمل جميع القواعد القانونية مهما كان

وفي النهاية يلاحظ ان هذا المبدأ يتوجه للقاضى وللأفراد جميعاً، لأن القاضى يفترض فيه العلم بالقانون، ويلتزم بتطبيقه من تلقاء نفسه وعليه أن يتحرى عنه، ويعمل بنفسه دون حاجة إلى طلب بذلك من الخصوم، ودون أن يلزم أحد هؤلاء بإرشاده إلى نص القانون واجب التطبيق، حيث يفترض أن المحكمة تعرف القانون^(١).

المبحث الرابع

تفسير التشريع وإلغاؤه

المطلب الأول

تفسير التشريع ووسائله

عند تطبيق التشريع وإنزال حكمه على الواقع، قد يكشف ذلك التطبيق عن وجود غموض في النص يقتضى فضه، وبيان حقيقة المراد منه، كما يجب على القاضى قبل تطبيق التشريع أن يتفهم المراد به حتى يستطيع تطبيقه على ما يعرض عليه من منازعات، ويعرف التفسير بأنه: "توضيح المراد بالنصوص الشرعية، أو الاستدلال على الحكم القانونى من نصوص التشريع، وهو يتحقق بوضوح ما غمض

مصدرها، وسواء كانت من قواعد القانون الخاص أو العام، وسواء أكانت عرفية أم دينية،

وفى هذا المعنى: د. عبد الرزاق فرج - ص ٥٨.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق.

من ألفاظ القانون وفض التعارض الذي قد يكون موجوداً بين نصوصه، واستكمال ما نقص من أحكامه.

تفسير النصوص القانونية وأنواعه:

وأنواع تفسر النصوص القانونية هي التفسير القضائي، والتفسير الفقهي، والتفسير التشريعي، ونبين مضمون هذه الأنواع فيما يلي:

(١) التفسير القضائي:

والتفسير بهذا المعنى هو عمل القضاء، يقوم به بمناسبة ما يعرض عليه من خصومات، ومن ثم فإن التفسير عند القضاء ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة يستخدمها بقصد الفصل في المنازعات، ولذلك فإنه لا يقبل من أحد أن يرفع دعوى إلى القضاء طالباً تفسير نص من النصوص الغامضة، لأن التفسير في العمل القضائي يعتبر شأناً قضائياً يستعمله القضاة عند الضرورة، ومن ثم فإن التفسير يجب أن يكون بمناسبة نزاع فعلي معروض على القضاء^(١).

ويمتاز التفسير القضائي عن التفسير الفقهي بالطابع العملي، لأن القضاء يفسر القانون بمناسبة نزاع فعلي معروض عليه، وقضايا ينظرها، كما أنه يتأثر في تفسيره بالضرورات والحاجات العملية.

(٢) التفسير الفقهي:

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٤٠.

وأما التفسير الفقهي، فهو الذي يقوم به الفقهاء وشرح القانون مما نراه مبسوطاً في كتبهم ومؤلفاتهم، ويغلب على هذا التفسير طابع المنطق البحثي أكثر من مراعاته لمقتضيات الحياة العلمية، لأن الفقيه لا تعرض عليه حالات واقعية يطلب منه الفصل فيها.

(٣) التفسير التشريعي:

وهو ذلك النوع من التفسير الذي يقوم به المشرع حين يجد غموضاً يلف النص، أو يقع في تطبيقه من قصور المعنى ما يقتضى التوضيح، وقد يجد المشرع أن المحاكم قد فسرت قانوناً (ما) على وجه يخالف الحقيقة، أو يجافى في ما يقصده من وراء سنه، وعندئذ يتدخّل لتفسير هذا التشريع وبيان حقيقة قصده وبيان المراد منه.

ومثال ذلك ما حدث في المرسوم بالقانون الصادر في ١٩٣٥/٥/٢ بتفسير البنكنوت، وبطلان شرط الدفع بالذهب، حيث ذهبت بعض الأحكام إلى بطلانه، وذهب بعض الأحكام الأخرى إلى صحته، وذهبت طائفة ثالثة من الأحكام إلى التمييز بين المعاملات الداخلية وإبطال هذا الشرط فيها، والمعاملات الخارجية واعتبار هذا الشرط صحيحاً فيها، ولذلك صدر المرسوم رقم (٥٥) لسنة ١٩٣٥، ليحسم به ذلك الخلاف الذي نشب بين الحكام القضائية في مسألة واحدة، هي شرط الدفع بالذهب، فأعلن أنه شرط باطل في

المعاملات الداخلية والمعاملات الخارجية على السواء، واعتبر هذا تفسيراً لمرسوم سنة ١٩١٤ الذي ورد عاماً بدون تخصيص.

ومثل هذا التفسير التشريعي، أى الذي يفسر تشريعاً سابقاً لا يعتبر تشريعاً جديداً أتى بحكم جديد، ولذلك فإنه يطبق على كل الوقائع التى حدثت منذ صدور التشريع الأول، فهو يعتبر كاشفاً أى مظهراً للحقيقة المراد من ذلك التشريع^(١).

والتفسير التشريعي يصدر من نفس الهيئة التى أصدرته، ولكنه قد يعطى المشرع سلطة تفسير تشريع معين لهيئة أخرى غير الهيئة التى أصدرت التشريع، وهذا هو ما فعله القانون رقم (٢٦٤) لسنة ١٩٥٢، الذي أضاف إلى قانون الإصلاح الزراعي، القانون رقم (١٧٨) لسنة ١٩٥٢، مادة جديدة رقم (١٤) مكرراً، تعطى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي سلطة تفسير أحكام هذا القانون واعتبرت قراراتها في هذا الشأن تشريعاً ملزماً، وتتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

وقد أجاز قانون المحكمة العليا الصادر في أول سبتمبر سنة ١٩٦٩، لوزير العدل أن يطلب إليها تفسير النصوص التى تستدعى عن ذلك بسبب طبيعتها، أو أهميتها ضماناً لوحدة التطبيق ويكو قرارها

(١) المرجع نفسه - ص ١٤١.

الصادر بالتفسير ملزماً، وبذلك لا تكون هناك حاجة للالتجاء إلى إصدار تشريعات تفسيري أو إنشاء لجان لهذا الغرض.

حالات التفسير التشريعي:

ومما سبق يبدو أن التفسير قد يكون بنص جديد، فإذا وجد هذا النص، فإن القاضي يقوم بتطبيقه وتنتهي بذلك مشكلات التفسير عنده، لكن يتبقى بعد ذلك حالات التفسير الواقعة على النص املوجود، حين لا يوجد نص آخر يفسره، وهنا ينبغي التفرقة بين حالتين:

(١) حالة النص السليم.

(٢) حالة النص المعيب.

وينبغي بيان التفسير الحاصل في كل من هاتين الحالتين وهو كما يلي:

الفرع الأول

تفسير النص السليم

إذا كان نص القانون واضحاً فإنه يفهم في هذه الحالة بمجرد فهم ألفاظه، ومن ثم فإنه لا يجوز للقاضي أن يترك حكم النص بدعوى أنه غير عادل، أو لأن هناك حكماً آخر في نظره أعدل منه وأصلح، لن حكم الشارع واجب الاتباع، ووظيفة القاضي هي تطبيق

التشريع، أما تعديله فهو من شأن المشرع، وكما يقولون: فإن القانون هو القانون ولو كان قاسياً^(١).

طريقة تفسير العبارات:

واستخلاص المعنى من عبارات النص يكون - أولاً وقبل كل شيء - عن طريق عبارته وألفاظه كما نطق بها، والنصوص لا يقتصر معناها على ما يفهم مباشرة من صيغته وعبارته، بل قد يدل على معنى آخر بطريق الإشارة أو بطريق الدلالة، وهو ما يفهم من روح النص^(٢)، وقد أرشدت إلى هذا المعنى في تفسير النصوص: المادة الأولى من التقنين المدني المصري حين قالت: "تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

ومؤدى ذلك أنه لا يصح تفسير جميعه أساليب التعبير، أن نقف عند حد عبارتها، بل يجب استقصاء كل وجوه الدلالة التي تستفاد من روحها، سواء كان ذلك من منطوق العبارة، أو من طريق ما تنطوى عليه من إشارة أو دلالة، إذ أن التفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعانى التي ينطوى عليها النص^(٣)، مع الاستهداء في

(١) المرجع نفسه - ص ١٤٣.

(٢) د. سليمان مرقس - الوافى في شرح القانون المدني - ج ١ - ص ٣٤٠.

(٣) فى هذا المعنى: حكم النقض المدني فى ٣٠/٥/١٩٨١، فى الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ٤٦ ق وهو ما يوافق الفقه الإسلامى، فى مبادئ تفسير النصوص بصفة عامة، راجع:

مجال النصوص القانونية بالحكمة العامة للتشريع ومبادئ العدالة^(١)، ولئن كان ذلك في نطاق مجال تفسير النصوص التشريعية، إلا أنه كمبدأ عام يمكن أن يعالج تفسير النصوص ومدلول العبارات في حدود إدارة قائلها^(٢)، ويمكن القول: أن تفسير العبارات في فقه القانون يتخذ أسلوبين وفقاً لوجود عبارات المتحدث أو القائل.

أولهما: الوقوف عند إرادة المشرع الحقيقية:

فإن كانت عبارة النص واضحة في صياغتها، ولا خفاء في معناها، فإنها في تلك الحالة تكشف في يسر عن إرادة قائلها بمجرد تفسير العبارات تفسيراً لفظياً أو لغوياً، مما يكاد يقتصر معه دور المفسر على الفهم اللفظي للنص، دون اجتهاد في اختلاف معان غير تلك التي يحتملها اللفظ، وإن كان من النادر أن تأتي عبارات المتحدثين في جميع صورها واضحة ووضوحاً لا تحتاج معه إلى

د. محمد زكريا البرديسي - أصول الفقه - ص ٢١٤ - طبعة ١٩٥٩، عبد الوهاب خلاف - علم أصول الفقه - ص ١٠٢، طبعة ١٩٤٢.

(١) د. سليمان مرقس - السابق - ص ٣٤١.

(٢) ويعرف ذلك بالتفسير الموسع، حيث يطلق في مقابل التفسير الضيق، الذي يقف عند حد المعنى الحرفي الذي يفيد منطوق العبارة، ويرى معظم الفقه أنه يجب أن يقتصر على هذا النوع من التفسير، في إطار النصوص التجريبية، أو التعبيرات ذات الصيغة الأمرة. وفي هذا المعنى: د. حسن كيرة - المدخل إلى القانون - ٤٠٧ - الطبعة السادسة ١٩٩٣ منشأة المعارف بالإسكندرية، د. عبد الحى حجازي - المدخل لدراسة العلوم القانونية - ص ٣٥٤ وما بعدها - طبعة ١٩٦٦.

تفسير، فقد يكون التعبير مبهماً، أو ناقصاً، وهنا يمكن اللجوء إلى عناصر خارجية لا تستمد من ألفاظه، وإنما تستفاد من الظروف التي قيل فيها، أو الملابس التي وافقت صدوره^(١)، وفي هذه الحالة تنتوع وجوه الدلالة من خلال دلالة منطوق اللفظ إلى:

(١) عبارة النص:

ويراد بها: صيغته المكونة من مفرداته وجملته، والمراد بها في هذا الخصوص ما يفهم من هذه الصيغة من معنى يتبادر إلى الذهن بمجرد فهم ألفاظها، فأى لفظ يتحدث به يمكن أن يستدل بوضوح من صياغته على ما يدل عليه معناه دلالة واضحة^(٢).

(١) د. حسن كيرة - المرجع نفسه - ص ٤٠٣ وما بعدها، وراجع في هذا المعنى: حكم النقص المدني في ١٩٧٠/٤/٧، مجموعة أحكام النقض ١٨-٥٧١-٨٩، وفي ١٩٧٢/٣/١٥ - المجموعة ٢١ - ٥٧٦، وفي ١٩٨٤/١/٩ - المجموعة ٢٥-١١٤-٢١، وفي ١٩٧٧/٤/٦ - المجموعة ٢٨-١٩٣٦-١٦٠، وراجع: حكم النقص المدني في ١٩٧٤/١٠/٢٩ - المجموعة ٢٥-١١٦٥-١٩٤، وفي ١٩٧٦/٣/١٤ - المجموعة ٢٧-٦١٧-١٢٣، وهذه الأحكام تفيد أنه في حالة النص الواضح يجب على القاضي والمفسر التقيد به ولا يجوز الخروج على النص الصريح الجلى أو تأويله.

(٢) د. عبد المنعم البدر - المدخل للعلوم القانونية - ص ٢١٧ - دار النهضة العربية - ١٩٦٦م، د. أحمد سلامة - المدخل لدراسة القانون - ص ٢٠٢، دار النهضة العربية - طبعة ١٩٧٤م، د. رمضان أبو السعود - المدخل إلى القانون - ص ٢٠٨ - دار الثقافة الجامعية ١٩٨٥ - د. توفيق حسن فرج - المدخل للعلوم القانونية - ص ١٦٠ - دار الثقافة الجامعية ١٩٩٢، د. عبد الرشي مأمون - المدخل للعلوم القانونية - ص ١٦٦ - دار النهضة العربية ١٩٨٢، د. جميل الشراوى - دروس في أصول القانون - ص ٢٠٤ وما بعدها - طبعة ١٩٧١، د. سليمان مرقس - السابق - ص ٣٤٢ وما بعدها، د. منصور مصطفى منصور - المدخل للعلوم القانونية - ص ٣٠٨، طبعة ١٩٧٠، د.

(٢) إشارة النص:

ويراد بإشارة النص: المعنى الذي لم يقصد المتحدث إليه من إيراد النص، ولكنه مع ذلك ملازم للنص لا ينفك عنه، فإشارة النص هي دلالة على معنى التزامى لم يقصد من الكلام قصداً آلياً، وهذا المعنى الملازم للنص هو معنى محتاج إدراكه إلى شيء من التأمل والنظر، لعدم كونه المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد قراءة العبارة أو سماعها، ولذلك سميت دلالة النص على هذا المعنى البعيد: "إشارة النص"، على حين سميت دلالة النص على المعنى المتبادر القريب: "عبارة النص".

وهذه الدلالة قد تكون ظاهرة يمكن فهمها بأدنى تأمل، وقد تكون خفية يحتاج فهمها إلى دقة نظر وزيادة تأمل، ولهذا كانت محل اختلاف كبير بين المجتهدين، فقد يفتن بعضهم إلى ما لا يفتن له غيره، فيأخذ من العبارة الواحدة الكثير من الأحكام^(١).

هذا؛ ويجب الاحتياط في الاستدلال بطريق الإشارة، وقصره على ما يكون لازماً لمعنى من معانى النص لزوماً لا فكاً له، لأن

عبد الحى حجازى - السابق - ص ٣٥٧ وما بعدها، د. محمود جمال الدين زكى - دروس فى مقدمة الدراسات القانونية - ص ٢٥٤ - الطبعة الثانية.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ٢١٨ د رمضان أبو السعود - السابق د. توفيق فرج - السابق، د. جميل الشرقاوى - السابق - ص ٢٠٤ وما بعدها، د. منصور مصطفى منصور السابق - ص ٣٠٩، د. جمال الدين زكى - السابق، د. أحمد سلامة - السابق - ٢٠٣.

هذا هو الذي يكون النصر دالاً عليه، إذ الدال على الملزوم دال على لازمه، وأما تحميل النص بمعاني بعيدة، لا تلازم بينها وبين معنى فيه، بزعم أنها إشارية، فهذا شطط في فهم النصوص، وليس هو المراد بدلالة الإشارة^(١).

(٣) دلالة اقتضاء النص:

ويراد بدلالة الاقتضاء أو المقتضى، دلالة الكلام على مسكوت عنه، يتوقف عليه صدق الكلام، ويفترض هذا أن صيغة النص ليس فيها لفظ يدل عليه، ولكن صحة هذه الصيغة واستقامة معناها تقتضى هذا اللفظ، ومن ذلك قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} ^(٢)، أى زواج، وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ} ^(٣)، أى أكل، فلفظ الزواج في الآية الأولى، والأكل في الآية الثانية، مما تقتضيهما صحة الصيغة واستقامتها^(٤).

ثانيهما: اللجوء إلى الإرادة المفترضة للمشرع:

إذا لم يكن الوقوف على إرادة المشرع الحقيقة من خلال طرق التفسير السابقة، فإنه لن يكون هناك مناص من البحث عن الإرادة

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ٢١٩، د. رمضان أبو السعود - السابق، د.

جمال الدين زكى - السابق، د. سليمان مرقس - ص ٣٤٤.

(٢) سورة النساء - من الآية ٢٣.

(٣) سورة المائدة - من الآية ٣.

(٤) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٢١٩ وما بعدها، د. منصور مصطفى منصور - السابق

ص ٣١٠، د. عبد الرشيد مأمور - السابق - ص ١٦٨، د. رمضان أبو السعود - السابق

- ص ٢٠٩ وما بعدها..

المفترضة للمشرع من خلال الاستنتاج المنطقي^(١)، ويمكن في تلك الحالة اللجوء إلى دلالة المفهوم.

معنى المفهوم وأنواعه:

ويقصد بالمفهوم دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام، وهي تأتي في إطار دلالة النص، والمفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة، ومفهوم المخافة.

(١) مفهوم الموافقة:

ومفهوم الموافقة يسمى (دلالة النص) أو (فحوى الخطاب)، أى مقصده وممرماه، ويقصد به دلالة النص على ثبوت حكم المنصوص عليه، للمسكوت عنه، بواسطة علة الحكم التى يمكن فهمها بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد والرأى، فهو الحكم الذي يفهم من روح النص وموضوعه.

فالنص قد يدل بلفظه وعبارته على حكم معين، لعله استوجب هذا الحكم، ولا يتوقف فهم هذه العلة على الاجتهاد والرأى، بل يفهمها كل من يعرف الألفاظ ومعانيها، فإذا وجدت حالة لا يتناولها هذا النص بمنطوقه، ولكنها تشترك مع الحالة المنصوص عليها في العلة التى استوجب الحكم في المنصوص عليه، وفي هذه الحالة نثبت نفس الحكم للحالة المسكوت عنها، وذلك سواء كان المسكوت عنه مساوياً لمنصوص عليه في العلة، أو كانت العلة متوافرة فيه بشكل أقوى،

(١) د. حسن كيرة - السابق - ص ٤٠٤ وما بعدها، د. أحمد سلامة - السابق - ص ٢٠٤.

ويسمى: مفهوم الموافقة، أو "القياس الجلى"، في الحالة الأولى، والقياس الأولوى، أو المفهوم من "باب أولى"، وفي حالة الثانية^(١).
 ومن أمثلة القياس المساوى: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ^(٢)،
 ومن أمثلة القياس الأولوى: قول الله تعالى: {إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} ^(٣)، الآية، حيث حرمت مجرد أن يقول الولد لأحد أبويه: "أف"،
 التى تدل على التضجر من تصرف صدر منهما نحوه، وهي تفيد
 تحريم السب والضرب من باب أولى^(٤).

(٣) مفهوم المخالفة:

ويقصد بمفهوم المخالفة: دلالة اللفظ على مخالفة حكم
 المسكوت عنه لحكم المنطوق، وذلك لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ٢٢١، د. عبد الحى حجازى - السابق -

ص ٣٥٨ وما بعدها، د. توفيق فرج - السابق - ص ١٦٢، د. عبد الرشيد مأمون -

السابق - ص ١٦٨، د. منصور مصطفى منصور - السابق - ص ٣١١ وما بعدها، د.

جمال الدين زكى - السابق - ص ٢٥٧، د. حسن كيرة - السابق - ص ٤٠٥، د.

سليمان مرقس - ص ٣٤٦ وما بعدها، د. أحمد سلامة، ص ٢٠٤ وما بعدها.

(٢) سورة النور - الآية ٤.

(٣) سورة الإسراء - الآية ٢٣.

(٤) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ٢٢١ وما بعدها.

هذا الحكم^(١)، ومن أمثلة هذا النوع من الدلالة ما تقتضى به المادة (٤٦٦) مدني: "من أنه: إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، والمفهوم المخالف لهذا النص إن بيع الشيء غير المعين بالذات ليس قابلاً للإبطال.

كما نصت المادة (٤٣٧) مدني، على أنه: "إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، فسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان كان الهلاك بعد إعدار المشتري لتسليم المبيع"، ويستفاد من هذا النص بمفهوم المخالفة: أنه إذا هلك المبيع بعد التسليم، أو هلك بعد إعدار المشتري لتسلم المبيع، لا يفسخ البيع ولا يسترد المشتري الثمن.

أحكام هذه الدلالات:

والدلالات السابقة، سواء من دلالة المنطوق، أو دلالة المفهوم تقيد الحكم الثابت بها، ويكون النص حجة على هذا الحكم، ولكنها متفاوتة في قوة الدلالة، فعبرة النص أقوى من الإشارة، لأن الأولى

(١) د. عبد الحى حجازي - السابق - ص ٣٥٩ وما بعدها، د. توفيق فرج - السابق - ص ١٦٣، وما بعدها، د. عبد الرشيد مأمون - السابق - ص ١٦٩، د. منصور مصطفى منصور - السابق - ص ٣١٤ وما بعدها، د. جمال الدين زكى - السابق - ص ٢٥٨ وما بعدها، د. عبد الرزاق السنهوري، د. حشمت أبو ستيت - أصول القانون - ص ٢٤٧ - طبعة ١٩٥٠م، د. حسن كيرة - السابق - ص ١٠٦، د. سليمان مرقس - السابق - ص ٣٤٧ وما بعدها.

تدل على المعنى المقصود بسياق النص، والثانية تدل على معنى غير مقصود بالسياق.

وكذلك فإن الإشارة أقوى من المفهوم (الدلالة)، لأن الأولى تدل على المعنى بنفس اللفظ وصيغته، والثانية تدل على الحكم بمعقول النص ومفهومه، ويظهر هذا التفاوت في القوة عند التعارض، فإذا تعارض الحكم الثابت من العبارة مع الحكم الثابت بالإشارة، ترجح الأول على الثاني^(١).

ويلاحظ أن ما قرره فقه القانون في مجال تفسير النصوص، لا يبعد كثيراً عما قرره علماء الأصول في الشريعة الإسلامية، وربما كان هو الأصل لما انتهى إليه فقه القانون.

الفرع الثاني

النص المغيب وكيفية تفسيره

المقصد الأول

النص المغيب

قد يحدث أن يكون النص القانوني معيباً بأحد العيوب، وعندئذ يجب على المفسر أن يصلح هذا العيب بطرق مختلفة، والعيوب التي تلحق النص هي: الخطأ المادي، والغموض، والنقص والتعارض.

(١) الخطأ المادي في النص:

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ٢٢٤.

ويتحقق ذلك الخطأ في حالة ما إذا وقع في ألفاظ النص خطأ غير مقصود، بأن جاءت به لفظة غير مقصودة، أو سها واضعوه عن ذكر شيء فيه لا يستقيم الحكم إلا به، ومثال هذا الخطأ المادى، وما كانت تنص عليه المادة (١٠٣) من القانون المدني القديم، في تعريف الشرط الذي يعلق عليه الالتزام التعاقدى، بأنه أمر مستقل (أو) غير محقق الوقوع، والصحيح أن الشرط أمر مستقبلي (و) محقق الوقوع، فهنا يقوم المفسر بإصلاح الخطأ، لأنه واضح غير مقصود من المشرع، ولأنه خطأ مادي لا يتعذر تصويبه بالنظر السليم.

(٢) غموض النص:

والغموض معناه أن يكون في النص لفظ يحتمل أكثر من معنى، أو تحتمل عبارته في جملتها معنيين أو أكثر، دون أن يكون أحدهما لفظياً والآخر اصطلاحياً، حيث يتعين في هذه الحالة المصير إلى المعنى الاصطلاحي، لكن المقصود بالغموض هنا هو الخفاء الذي يحتاج إلى نظر وتأمل أو تفسير ومن ذلك الخفاء، والغموض والنقص والتعارض.

(أ) خفاء اللفظ في النص:

يراد باللفظ الخفى: أنه الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة، ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد غموضاً وخفاءً لزيادة أو نقص فيها عن المعنى المعبر عنه باللفظ الأصلي، وهنا يثور التساؤل عن مدى تعلق الحكم القانوني بتلك الزيادة أو هذا النقصان؟، إن من أمثلة

ذلك الخفاء؛ تطبيق مفهوم جريمة السرقة على سرقة التيار الكهربائي، وسبب ذلك أن المشرع عرف السرقة بأنها اختلاس المنقول الملوک للغير، والمقصود بالمنقول عادة هو الشيء المادی الذي يمكن نقله من مكانه، فأثار تطبيق السرقة بالنسبة للتيار الكهربائي بعض الصعوبات في تطبيقه، وما إذا كان يعتبر منقولاً أو لا يعتبر، وقد انتهت محكمة النقض إلى أنه يعتبر منقولاً، لتوافر خصائص المنقول فيه، لأن له قيمة مالية، ويمكن ضبطه وحيازته، ونقله من حيز إلى آخر، ومتى كان كذلك يكون داخلاً تحت لفظ المنقول، الوارد في المادة (٢١١) عقوبات، ولا محل لإخراج اختلاسها من حكم السرقة^(١).

ومن الخفاء أيضاً ما ثار في جريمة اتلزيور من تساؤل حول الموظف الذي يغفل عمداً إثبات ما كان يجب إثباته في المحرر، كالمحصل الذي يغفل فيجبي بعض ما يحصله من النقود بقصد اختلاسها، فهل يعتبر هذا تزويراً؟

إن مرجع الخفاء في ذلك يتمثل في أن المشرع نص على الطرف التي يقع بها التزوير، ومنها جهل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فالمعنى المتبادر إلى الذهن هو أن يثبت الموظف في المحرر بيانات غير صحيحة، أى على خلاف الواقع، وفي المثلث الذي معنا لم يقم بإثبات شيء في المحرر، بل تعتمد عدم الإثبات لواقعة معينة فيه، فهل يدخل فعله السلبي هذا في صورة جعل واقعة

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ١٥٠.

مزورة في صورة صحيحة؟، قد يقال: إن الترك لا تعتبر تغييراً للحقيقة، لأن التغيير يقتضى عملاً إيجابياً من جانب مرتكبه، والذي ترك شيئاً كان يجب إثباته لا يأتى شيئاً من ذلك، ولكن محكمة النقض أدخلته في مدلول جريمة التزوير، لأن اترك يؤدي إلى التغيير في مجموع المحرر، وبالتالي يعتبر تزويراً معاقباً عليه^(١).

(ب) اللفظ المشكل:

والمراد باللفظ المشكل، هو الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، وإنما لابد من قرينة خارجية تحدد ما يراد منه، أو هو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى واحد، أو استعمل في غير معناه، لمعنى مجازى اشتهر به، وليس في صنعة دلالة على تعيين معنى لما وضع له، فلا بد من قرينة خارجية تعينه.

وطريقة إزالة هذه الأشكال تتمثل في الاجتهاد من خلال القرائن والأدلة حتى يزول، ومن ذلك لفظ الليل، الذي جعله المشرع ظرفاً مشدداً لعقوبة السرقة في المادة (٣١٣) عقوبات، فلم يرد في التشريع تعريف الليل، إذ قد يراد به الليل بمعناه الفلكي المحدد بغروب الشمس وشروقها، وقد يراد به الفترة التي يسود فيها الظلام فعلاً، وهذا المعنى الأخير هو الذي أخذت به أحكام القضاء في أول الأمر، لأنه الفترة

(١) نقض ١٩٥٣/٣/٤ - مجموعة عمر - ج٣ - رقم ٣٢٨ - ص ٤١٨، ونقض ١٩٥٠/٤/١٠ - مجموعة أحكام النقض س ٢ - ص ٩٣٦ - رقم ٣٤٦..

التي تتوافر فيها حكمة التشديد، نظراً لما يبعثه في نفس الناس من رهبة، وما يهيئه الظلام للجاني من تسهيل ارتكاب الجريمة^(١). لكنها عادت وأخذت بالمعنى الفلكي لليل^(٢)، وتوجهها هنا توجه رشيد وذلك لبسط مزيد من الحماية على أموال الناس من الجريمة، وتشديد العقوبة على السارقين.

(ج) اللفظ المجمل:

واللفظ المجمل هو الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، ولا توجد قرائن لفظية، أو قرائن تكشف عن حقيقته، ولذلك فإنه يكون من الصعب بيان المراد باللفظ المجمل، لأن الطريق إلى بيانه وإزالة إجماله وتفسير المراد منه، هو الشارع نفسه، والشارع قد يبينه بشكل واف، وعندئذ يكون الأمر سهلاً، وقد يبينه بشكل غير واف، وعندئذ ينتقل المجمل إلى بيان الشكل فيتعين فهم المراد به بالاجتهاد.

ومن أمثلة ذلك، اصطلاح (الأحوال الشخصية) الذي كان وارداً في المادة (١٦) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، حيث كان تحديد ما يدخل ضمن هذا الاصطلاح مثار خلاف بين جهات القضاء المصري حتى قام المشرع بتفسيره.

(د) النقص في عبارة النص:

(١) نقض ١٩١٠/١/٢٢، المجموعة الرسمية ١١-١٢، وفي ١٩١٥/٦/٢٦، المجموعة

الرسمية ١٧-٣٥ مشار إليهما في د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ١٥.

(٢) نقض ١٩٤٨/١/١٦ - مجموعة عمر - ج ٥ - رقم ٤٨٣ - ص ٦٤٦.

وقد يكون العيب كامناً في ورود عبارات النص ناقصة، بحيث لا يمكن ان يفهم حكمها ومعناها إلا بتكملة عباراتها، وعندئذ ينبغى على المفسر أن يكمل هذا النص مستهدياً في ذلك بقصد الشارع. ومن ذلك ما كانت تنص عليه المادة (١٥١) مدني، من أن: "كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزوميه فاعله بتعويض الضرر، حيث لم يقصد المشرع بذلك مساءلة الفاعل الذي يصيب غيره بضرر مطلقاً، وإنما يقصد أن يكون سببه فعلاً خاطئاً، فالمراد هو الخطأ، وليس مجرد الفعل، ولهذا تدارك المشرع ذلك النقص في المادة (١٦٣) من القانون المدني الجديد، ونص على أن: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض.

وقد كانت المادة (٧٦) من القانون الدنى القديم تنص على التقادم المكسب القصير المدة الذي يتم بالحياة خمس سنوات، واشترطت فيه الحياة، والسبب الصحيح فقط، ولم تذكر شرط حسن نية الحائز، ولكن اقضاء والفقه أكملوا هذا النقص، واشترطوا حسن النية لتطبيق التقادم الخمسى^(١).

(هـ) تعارض النصوص:

ومن صور عيوب النص، تعارضه مع نص آخر، سواء وجد هذا التعارض بين نصوص تشريع واحد، أو بينها وبين نصوص تشريع آخر، وفي هذه الحالة يفض التعارض بمراعاة النص الأقوى والأبقى،

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ١٥٢.

فإذا كان اتعارض بين تشريعيين متلاحقين، يكون التالى منهما ناسخاً للسابق، حيث ينسخ الحدث القديم، وإذا كان التعارض بين نصوص تشريع غير متساوية في القوة يقدم الأقوى عملاً بمبدأ تدرج التشريع، وإذا كان التعارض وارداً بين نصوص تشريع واحد، او نصوص تشريعات تساوية في القوة، وجب اتباع قواعد الاستطلال، فتقدم دلالة العبارة على الإشارة، كما تقدم دلالة الإشارة على الدلالة (المفهوم)، وفي جميع الأحوال يجب على المفسر أن يبذل جهده في التوفيق بين النصوص المتعارضة مستعيناً في ذلك بوسائل التفسير المختلفة.

المقصد الثانى

كيفية تفسير النص المعيب

إذا وجد في النص عيب من العيوب السابقة، فكيف يتم تفسيره وكشف النقاب عن حقيقته؟

إن وسيلة ذلك تتمثل في تبين القصد الحقيقى للمشرع من خلال وسائل معينة، منها: تقريب النصوص، والرجوع إلى الأعمال التحضيرية، والاستعانة بالمصادر التاريخية، ثم البحث عن حكمة التشريع، ونبين ذلك فيما يلي:

(١) تقريب النصوص:

إن وسيلة تقريب النصوص من وسائل تفسير النص المعيب، إذ من خلال تلك المقاربة بين النصوص التشريعية تتحقق المقارنة

التى يمكن أن يبرز من خلالها المعنى الصحيح، لأن النصوص التشريعية يكمل بعضها بعضاً، فيخصص بعضها ما جاء عاماً، ويفسر ما كان مجملاً، وبعضها يقيد مطلق بعضها، كما أن منها ما ينسخ الآخر.

(٢) الأعمال التحضيرية:

الأعمال التحضيرية؛ هي مجموعة الوثائق الرسمية التى تلت أو صاحبت صدور التشريع، ومن قبيل ذلك، المذكرات التفسيرية، أو الإيضاحية التى تصاحب التشريع عند صدوره أو عند تقديمه كمشروع اقتراح إلى المجلس التشريعى، ومناقشات مجلس النواب ولجانه، وأعمال اللجان الفنية التى أعدت مشروع التشريع، فهذه الوثائق كلها تقيد المفسر في الكشف عن قصد المشرع حين يكون النص غامضاً، أو يقوم تناقض بينه وبين غيره من النصوص، بل إن هذه الأعمال قد تقيدنا أحياناً في تعريف حكم ما سكت عنه التشريع.

ويلاحظ أن تلك الأعمال التحضيرية رغم أهميتها في تفسير النص المعيب إلا أنها لا ترتفع إلى مرتبة التشريع ولا تعد جزءاً منه أو مكملته له، ومن ثم فإن ما يرد فيها لا يعد ملزماً للقاضى متى وجد أن النص يمكن أن يتمشى معه أو مع المذكرة الإيضاحية للقانون، لأن ذلك قد يكون من قبيل الاجتهاد الشخصى من جانب واضعيها، وهو اجتهاد قد يكون غير موفق في بعض الأحيان، فيعتبر ذلك تزايداً من

واضعيها، ولهذا كله يجب مراعاة الحذر الشديد عند الاستعانة بالأعمال التحضيرية.

(٣) المصادر التاريخية:

والمصدر التاريخي هو المصدر الذي استقى منه المشرع نصوص التشريع، والرجوع إلى المصدر التاريخي يساعدنا في كثير من الأحوال على تعرف قصد المشرع من النصوص، فيمكن الاستعانة به في كشف الغموض، وتكملة النقص، ورفع التعارض بين النصوص التشريعية، وهذا ما يفسر لنا كثرة استعانة القضاء والفقهاء في مصر في ظل المجموعة المدنية القديمة، بنصوص القانون الفرنسي على اعتبار أن هذا القانون كان هو المصدر التاريخي لتلك المجموعة، ومن ثم يجب الرجوع إلى التقنيات المختلفة التي استقى واضعوا المجموعة منها بعض النصوص، كما يجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية لتفسير النصوص المستقاة منها.

(٤) حكمة التشريع:

كما يستعين المفسر أيضاً بحكمة التشريع في سبيل فهم المقصود بالنصوص التشريعية وتكملتها وسد ما بها من نقص أو قصور.

ويقصد بحكمة التشريع تلك الفلسفة العامة التي يراد تحقيقها من خلال سنه، أو الدافع اباعث عليه، ذلك أن المشرع إنما قصد من وراء

التشريع تحقيق مصلحة تعود على الأفراد والمجتمع، فحكمة التشريع - إذن - تتمثل في تبصر تلك المصلحة التي قد تكون مصلحة اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية أو خلقية، يرمى المشرع إلى تحقيقها من وراء النص.

ومعرفة هذه المقاصد من أهم ما يستعان به على فهم النصوص وتطبيقها على وجه الوقائع، لأن دلالة اللفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل أكثر من وجه، والذي يرجح وجهاً من هذه الوجوه على غيره هو الوقوف على مقاصد الشارع من التشريع، ولأن الدلالة الجزئية قد يتعارض بعضها من بعض في ظاهر الأمر، فيحتاج إلى التوفيق بينها ومعرفة ما يعمل به منها وما لا يعمل به، كما أن بعض التفاصيل التي توجد قد لا تتناولها عبارات النصوص التشريعية، وتعدو الحاجة فيها إلى معرفة الحكم بطريق القياس أو غيره، وذلك لا يتأتى إلا من خلال فهم مقاصد التشريع العامة^(١)، ولكن ذلك ينبغي أن يكون في حالة النص المعيب، أما إذا كان النص سليماً، فإنه لا يجوز الخروج عليه بمقولة: إننا نهتدي بحكمة التشريع.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ١٥٦.

المطلب الثاني

إلغاء النص التشريعي

الإلغاء لغة: الإبطال والمحو والإسقاط، يقال: ألغى الشيء أبطله، وألغى من العدد كذا، أى أسقطه، وهو في الاصطلاح: إبطال الحكم بالتشريع ورفع قوته الملزمة، سواء أكان ذلك باستبدال نصوص أخرى بنصوصه، أو إبطال مفعوله دون سن تشريع جديد يحل محله، ويسمى عند فقهاء الشريعة بالنسخ.

والسلطة تملك الإلغاء، هي تلك التي سنته، وقد تكون سلطة أعلى منها، لأن الأعلى يمك الأدنى ولا عكس، ولأن النسخ لا يكون إلا بالأقوى أو بالمساوى.

وبناء على مبدأ تدرج التشريعات، نجد أن التشريع الأدنى يتقيد بالتشريع الأعلى ولا يجوز أن يخالفه، والعكس غير صحيح، وعلى ذلك فإن التشريع الأساسي لا يلغى إلا بنظيره، وهو الدستور، والتشريع العادي لا يلغى إلا بنظيره، أو ما هو أعلى منه وهو الدستور، وكذلك فإن التشريع العادي يلغى بتشريع مماثل له، أو تشريع عادي أو دستور، ولكن أن تصدر لائحة تلغى أو تعدل من أحكام القانون العادي أو الدستور^(١).

(١) د. سليمان مرقس - ص ٩٣، د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٣٤، د. شمس الدين الوكيل - فقرة ١٣١، د. منصور مصطفى منصور - ص ١٧٧، د. أحمد سلام - فقرة ١٣١،

والإلغاء قد يكون صريحاً، وقد يكون ضمناً، وقد نصت المادة الثانية من التقنين المدني المصري على نوعي الإلغاء المذكورين بقولها: "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، وينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ونبين نوعي الإلغاء:

أولاً: الإلغاء الصريح: يتحقق الإلغاء الصريح في حالة ورود نص في التشريع اللاحق يقضى صراحة بإلغاء العمل بحكم قاعد قانونية سابقة عليه، ومن أمثلة الإلغاء الصريح ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨، بشأن إصدار القانون المدني الحالي بقولها: "يلغى العمل بالقانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية، والصادر في ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٧٥، ويستعاض عليهم بالقانون المدني المرافق لهذا القانون، وهنا نجد ان المشرع قد نص صراحة على إلغاء القانون السابق، وإحلال قانون آخر محله^(١).

وقد ينص التشريع الجديد على إلغاء بعض القواعد القانونية للتشريع السابق أو على إلغاء قاعدة معينة، كما ينص على أنه يلغى ما يخالف هذا التشريع، ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من

د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ١٠٤ وما بعدها، د. عبد المنعم فرج الصدة - فقرة ١٢٨، د. جمال الدين العاقل - ص ١٩٦.

(١) د. جميل الشرقاوي - ص ٢١٦، د. منصور مصطفى منصور - ص ١٧٩، د. عبدالحى حجازي - فقرة ٢٧٩، د. حسن كيرة - ص ١٨٠، د. شمس الدين الوكيل - فقرة ١٣٥، د. سليمان مرقس - ١٣٠، د. عبد الرزاق فرج - ص ١٠٧.

قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٤٩ والمعدل بالقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠م: " عدا الكتاب السابع من لآباب الأول الخاص بالمعارضة، والمواد من ٨٦٨ إلى ١٠٣٢ من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كما يلغى الباب الخاص بحالات النقض وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويستعاض عن النصوص الملغاه بنصوص القانون المرفق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه^(١).

ومن قبيل الإلغاء الصحيح - كذلك - انتهاء الأجل المحدد في القانون لسريان التشريع، وقد ينص في التشريع على العمل به إلى حين تحقق أمر معين، ومن أمثلة ذلك التشريعات المؤقتة بمدة معينة، أو بمناسبة محددة، كذلك التي تصدر في وقت الحرب، وينص فيها على أن يعمل بها في مدة الحرب فقط، وكذلك القوانين الخاصة بالتسعير الجبري الذي يسرى في أوقات الأزمات الاقتصادية، أو الأوامر العسكرية التي تصدر في فترة الأحكام العرفية.

فمثل هذه التشريعات تعتبر ملغاه بانتهاء الأجل أو الظروف المحددة لها دون حاجة إلى إصدار تشريع بإلغائها.

(١) د. عبد الرزاق فرج - ص ١٠٨.

ثانياً: الإلغاء الضمني:

والإلغاء الضمني، هو الذي يفهم عقلاً من وجود حكم في تشريع لاحق يعارض حكماً موجوداً في تشريع سابق، بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخاً والسابق منسوخاً، فيلغى السابق، ويظل اللاحق.

وقد يكون الإلغاء الضمني - أيضاً - بصدر قانون جديد ينظم الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده تشريع سابق، وقد بينت هذا النوع من الإلغاء الضمني، بعد بيانها للإلغاء الصريح، المادة الثانية من التقنين المدني بقولها: ".... أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع"، ومن ثم يبدو أن للإلغاء الضمني صورتين:

الأولى: هي التعارض بين التشريعين القديم والجديد.

والثانية: صدور تشريع جديد يتولى تنظيم الموضوع الذي كان ينظم القانون القديم، ويتعين بيان ذلك:

(١) التعارض بين التشريعين القديم والجديد:

إذا تعارض تشريعان قديم وجديد، تكون الغلبة للتشريع الجديد، لأن الشيء الجديد دائماً له رونق، ويكون الإلغاء من حظ التشريع القديم، إلا إذا تم التوفيق بينهما فلا يقع الإلغاء.

والتعارض الذي يقع بين التشريعين قد يكون تاماً، أى شاملاً لجميع الأحكام وعندئذ يكون الإلغاء كاملاً، وقد يكون التعارض جزئياً

وفي بعض الأحكام، وعندئذ لا يلغى من التشريع القديم إلا الأحكام المتعارضة مع التشريع الجديد فقط، وتظل سائر أحكامه سارية.

صور التعارض بين التشريعين القديم والجديد:

والتعارض بين التشريعين القديم والجديد قد يتخذ الصور الآتية:

(أ) قد يقع الإلغاء بسبب التعارض إذا كان التشريع الجديدي قد تضمن حكماً عاماً يخالف حكماً عاماً في التشريع السابق، أو كان يتضمن حكماً خاصاً يخالف حكماً خاصاً فيه، وفي هاتين الحالتين ينسخ الجديد القديم، فالعام ينسخ بالعام، والخاص ينسخ بالخاص.

(ب) وقد يقع التعارض بين حكم عام في القانون القديم، وحكم خاص في القانون الجديد، وعندئذ يعتبر القانون الجديد ناسخاً للقديم في خصوص هذا الحكم، فالعام يشمل جميع الأفراد حتى يرد نص بالتخصيص فيكون العمل به، ويخرج حكمه من حكم العام.

ومن ذلك ما كانت تقضى به المادة (٤٥) من القانون المدني القديم بقولها: "الملكية في الأموال منقولة كانت أو ثابتة تنتقل بمجرد حصول العقد المتضمن التملك، متى كان المال ملكاً للمتصرف"، فلما صدر قانون التسجيل سنة ١٩٢٣، ونص على أن ملكية العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل لا بمجرد التصرف، فكان ذلك بمثابة حكم خاص يتضمن إلغاء ضمناً لنقل الملكية في العقارات بمجرد العقد الثابت بعموم نص المادة (٤٥) من القانون المدني القديم.

(ج) إذا كان التعارض واقعاً بين حكم خاص في التشريع القديم، وحكم عام في التشريع الجديد، فإن التشريع القديم يبقى معمولاً به في هذه الحالة الخاصة، وذلك كاستثناء من المبدأ العام الذي أتى به التشريع الجديد، ما لم يكن التشريع الجديد قد نص صراحة على سريان حكمه في جميع الحالات^(١).

ومثال ذلك؛ أن المادة (٢٠٤) من القانون المدني الصادر سنة ١٩٤٨، رغم نصها على أن الملكية والحق العيني ينتقلان بمجرد الاتفاق، إلا أنها لا تعتبر ناسخة لقانون الشهر العقاري الصادر سنة ١٩٤٦، والذي يشترط شهر التصرف لانتقال الملكية في العقارات، فنص القانون المدني أتى بحكم عام، أما حكم قانون الشهر العقاري، فهي أحكام خاصة ومن ثم فإنها تبقى رغم صدور هذا القانون قبل المجموعة المدنية.

كما أن العمل بأحكام القانون المدني في عقد الإيجار سنة ١٩٩٦، لا يلغى الأحكام التي تتعلق بالامتداد القانوني وفقاً للشروط المقررة في القوانين السابقة عليه.

(١) صدور تشريع جديد لنفس الموضوع:

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٣٧، د. حسن كيرة - ص ١٨٣، د. منصور مصطفى منصور - ص ١٧١، د. جميل الشرقاوى - ص ٢١٧، د. توفيق فرج - ص ١٧٥، د. عبد الرازق فرج - ص ١١٠، د. شمس الدين الوكي - ص ٢٢٤، د. سليمان مرقس - ص ١٣١، د. عبد المنعم فرج الصدة - ص ١٨٧.

وقد يكون الإلغاء الضمني في صورة تشريع جديد ينظم نفس الموضوع الذي ينظمه القانون القديم، فإذا صدر قانون جديد يتولى بالكامل تنظيم أمر من الأمور كان ينظمه قانون سابق اعتبر ذلك القانون منسوخاً جملة وتفصيلاً، ولو انتفى التعارض بين نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه، وغالباً ما ينص التشريع اللاحق على إلغاء السابق، وحتى إذا لم يوجد هذا النص، فإن الإلغاء يكون قائماً بدلالة الحال^(١).

ويلاحظ أم العرف وعدم الاستعمال لا يلغيان التشريع، لأن العرف أدنى مرتبة منه، وهو إن كان يكمل التشريع لأنه لا ينسخه، وقد جرى على هذا نص المادة الأولى من القانون المدني في فقرتها الثانية، حيث تقول: "يطبق العرف إلا إذا لم يجد القاضي نصاً تشريعياً يمكن تطبيقه"، وهذا يعنى أن القاضي ملزم بالتشريع طالما وجدّه، فإذا لم يجده يلجأ للعرف، كما أن المادة الثانية صريحة في بيان ذلك، حيث تقرر أنه: "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بنص تشريعي لاحق".

كما لا يجوز القول بسقوط التشريع بعدم الاستعمال مدة طويلة، لأن عدم الاستعمال يعنى نشوء عرف سلبى مخالف للتشريع، وما دام العرف لا يلغى التشريع فإنه لا يسقط بعدم الاستعمال^(٢).

(١) المرجع السابق.

(٢) في هذا المعنى: د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٣٩.

المبحث الخامس

سريان القانون من حيث المكان والزمان

بعد أن تكتمل عناصر القاعدة القانونية وتستجمع مقومات وجودها ونفاذها على المخاطبين بأحكامها فإنها في تلك الحالة تكون واجبة النفاذ والسريان، وذلك يقتضى بين نطاق تطبيق القواعد القانونية من حيث المكان، وما إذا كان يسرى على كافة الموجودين داخل الدولة، أم أنها تتبع المخاطبين بأحكامها ممن هم خارج الدولة كذلك، كما يقتضى ذلك التطبيق تحديد نطاقه من حيث الزمان، وذلك ببيان الوقت الذي يبدأ فيه والوقائع التى يشملها، وعلى هذا فإن منطق الدراسة يقتضى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

أولهما: لبيان سريان القانون من حيث المكان.

وثانيهما: لبيان سريان القانون من حيث المكان.

المطلب الأول

سريان القانون من حيث المكان

من المعلوم أن نطاق تطبيق القانون من حيث المكان يخضع لمبدأ إقليمية القانون، وهذا المبدأ يعنى أن القانون يسؤى على جميع الأشخاص الموحودين داخل إقليم الدولة سواء كانوا مواطنين أم أجنبى، كما يسرى على كافة الوقائع القانونية التى تحدث على أرض الإقليم دون ان يتجاوز سريانه حدوده، ولا ينطبق على ما يقع فى الخارج ولو كان من المواطنين^(١)، وأساس ذلك التحديد المكانى بالحدود الجغرافية للدولة، أن القانون يعتبر مظهرًا من مظاهر سيادتها الخاصة على مواطنيها، وهذه السيادة تقف عند حدود الإقليم حتى لا تتعدى على سيادة دولة أخرى، بيد أن هذا المبدأ وإن كان قد ساد فى الماضى لانعزال الدول عن بعضها وتعذر اتصالها فيما بينها، ولتشدد فى الأخذ بفكرة السيادة التى دعت إلى قرية صغيرة، جعل بمقدور الإنسان فى أى مكان من أرض الله أن يقف فى التو واللحظة على ما يقع فى آخر أطراف الدنيا، بل ويتخاطب مع الأفراد ويناجيهم ويتعاقد معهم بوسائل الاتصال الحديثة مما أدى إلى تشابك علاقات الدولة وتنامي المصالح ذات الروابط الأجنبية، أضف إلى ذلك وجود التمثيل السياسى الذى يدعم ذلك التواصل ويحميه، كل هذا أدى إلى الحد من

(١) د. شمس الدين الوكيل - فقرة ١٢٧، د. عبد الرزاق فرج - ص ٩٧.

إطلاق العمل بمبدأ السيادة، خاصة على الأجانب الذين لم توضع لهم القوانين، ولم ترع عند وضعها ظروفهم وعاداتهم وحاجاتهم.

مبدأ شخصية القانون وإقليمته:

في إطار ذلك التطور العالمي في الاتصال ويسر الانتقال من مكان إلى آخر، ظهر مبدأ شخصية القانون، الذي يقوم على أساس أن القانون لا يسرى إلا على أبناء الدولة دون نظر إلى المكان الذي يتواجدون فيه، سواء كانوا من داخل البلاد أم من خارجها، ورغم ظهور هذا المبدأ إلا أنه لم يؤدي إلى اختفاء مبدأ الإقليمية كلية، بل يكفي كل منهما جنباً إلى جنب، تتفاوت الدول في الأخذ في كل منهما بحسب ظروفها وما تقتضيه مصلحتها، ومن هنا نشأت فكرة تنازع القوانين، ومست الحاجة إلى تفريد قواعد القانون الدولي الخاص، لحل ذلك التنازع ومعرفة القانون الذي يجب تطبيقه على النزاع المعروض^(١).

تطبيق القانون من حيث المكان في مصر المحروسة:

وفي مصر الأمانة المحروسة، يعتبر مبدأ إقليمية القانون هو الأصل في قانونها، فالقوانين تسري داخل نطاق إقليمياً على المواطنين والأجانب المقيمين داخل إقليم الدولة بدرجة سواء، ولا تتجاوز حدود الإقليم، ومع ذلك فإن مبدأ الإقليمية وإن كان يتمثل أصلاً، إلا أنه يرد

(١) د. عبد الرازق فرج - ص ٩٨.

عليه بعض الاستثناءات التي تتفاوت في مداها من فرع قانونى إلى آخر، وذلك كما يلى بيانه:

(١) القانون الدولى العام:

إذا كان الأصل أن القانون - وفقاً لمبدأ إقليمية القانون الذي يأخذ به المشرع المصرى - يطبق على الموجودين داخل حدود الدولة - واطنين أم أجنب - فإننا نجد أن بعض هؤلاء الأجانب - وهم رؤساء الدولة الأجنبية، والممثلين الدبلوماسيين لا يخضعون للقانون المصرى، ولا يحاكمون أمام القضاء الوطنى، حيث ينطبق عليهم قانون دولتهم.

(٢) القانون الدستورى:

كما نجد أن حقوق المواطنة خاصة ما يرد منها في القانون الدستورى يقتصر تطبيقها والتمتع بها على المواطنين دون الأجانب في كثير من الأحيان، فمثلاً الحقوق والواجبات العامة المقررة للمواطنين يختلف حظ المواطنين في التمتع بها عن حظ الأجانب، بالقطع فإن حظ المواطنين أوفر، كذلك بعض الحقوق السياسية مثل حق الانتخاب والترشيح لمجلس بالشعب فإنهما مقصوران على المواطنين، وأما حق تلى الوظائف فهو في الأصل مقصور عيهم، ولا يباح للأجانب إلا بشرط معين، وعلى سبيل الاستثناء وبشروط خاصة، وهناك بعض الواجبات العامة لا يكلف بها سوى المواطنين مثل الخدمة العسكرية.

(٣) القانون المالى:

وفي مجال القانون المالى نجد أن الأجانب يخضعن له، فإذا قام الأجنبى بممارسة نشاط تجارى معين يخضع للضرائب، فإن يلتزم بدفعها تطبيقاً لأحكام قانون الدولة التى تحتضن هذا النشاط، وكذلك الأمر إذا تقرر بعض الرسوم على الخدمات المختلفة مثل الاتصال، او دخول البيلاذ، او منح تأشيرة دخولها، أو رسوم مغادرتها، فإنه يخضع لذلك في التطبيق ولا يعفى منه لأنه أجنبى، بل تسري أحكامها عليه.

(٤) قانون العقوبات:

وفي قانون العقوبات يعتبر مبدأ إقليمية القانون هو الأصل في التطبيق، وقد نصت على هذا المادة الأولى من قانون العقوبات المصرى، فقالت: "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه"، ومن هذا النص يبدو أن القانون الجنائى يطبق على من يوجد داخل إقليم الدولة مواطناً كان أم أجنبياً، ولا يسرى خارج هذا الإقليم ولو كان الذي ارتكب الجريمة مصرياً.

الاستثناءات الواردة على هذا الأصل:

وهذا الأصل يرد عليه بعض الاستثناءات وهي كالاتى:

(أ) إذا قام بعض الأفراد الموجودين خارج مصر سواء كانوا مصريين أم أجانب بإرتكاب جريمة وقعت كلها أو بعضها على أرض مصر^(١).

(ب) الجرائم التي تقع خارج مصر إذا كانت تتطوى على مساس بأمن الدولة كإرتكاب جناية مخلة بأمن العام، أو جناية تزوير أو تقليد العملة الورقية أو المعدنية^(٢).

(٥) القانون الإدارى:

وفي القانون الإدارى يسرى مبدأ إقليمية القانون على المواطنين والأجانب إذا عينوا في إحدى الوظائف، ولكن هذا لا يمنع من وضع القواعد الخاصة بتشغيل الأجانب داخل إقليم الدولة وتطبق عليهم.

ثانياً: نطاق القانون الخاص:

الأصل أن يطبق القانون الخاص على المواطنين عملاً بمبدأ إقليمية القانون، ومع ذلك نجد أن المشرع المصرى في الباب التمهيدي من القانون المدني قد عالج مسائل تتنازع القوانين من حيث المكان، وحدد القانون الذي يجب تطبيقه على مسائل الأحوال الشخصية، وعلى المسائل المتعلقة بالأموال^(٣)، وذلك كما يلي:

(١) مسائل الأحوال الشخصية:

(١) مادة ١/٢ من قانون العقوبات المصرى.

(٢) المواد ٢، ٣، ٤ من قانون العقوبات المصرى.

(٣) المواد من ١٠-١٨ من القانون المدني المصرى.

في المسائل التي تتعلق بالحالة والأهلية والزواج والطلاق والنفقة والميراث والوصية يقرر القانون أن مبدأ التطبيق التشريعي هو مبدأ شخصية القانون فينطبق قانون الدولة التي ينتمى إليها الشخص، فالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم^(١)، وأما الشروط الموضوعية لصحة الزواج فيرجع فيها إلى قانون كل من الزوجين^(٢)، فالزوجان الإنجليزيان المقيمان في مصر يخضعان لقانون بلدهما، والزوجان المصريان المقيمان في إنجلترا يخضعان للقانون المصري، وآثار الزواج يحكمها قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج^(٣).

كما يسرى على الطلاق قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق^(٤).

ويسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون بلد المدين بها^(٥)، ويسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجوزين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته^(٦).

(١) مادة (١١) من نفس القانون.

(٢) مادة (١٢) من نفس القانون.

(٣) مادة (١/١٣) من نفس القانون.

(٤) مادة (٣/١٣) من القانون المدني المصري.

(٥) مادة (١٥) من نفس القانون.

(٦) مادة (١٦) من نفس القانون.

ويسرى على شكل الوصية قانون بلد الموصى وقت الإيلاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة لما بعد الموت^(١).

(٢) في مسائل المعاملات المالية:

يسرى على الحياة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون البلد الذي يوجد به العقار موضوع التصرف^(٢)، ويسرى على المنقول قانون البلد الذي يوجد فيه هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحياة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها^(٣)، ويسرى على العقود من حيث الشكل الذي يجب اتباعه في إبرامها قانون البلد الذي أبرمت فيه، ويجوز - أيضاً - أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن املتاعدين أو قانونهما الوطنى المشترك^(٤).

ويسرى على العقود من حيث الموضع قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدین إذا اتخذوا موطناً، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق الطرفان، أو

(١) مادة (٢/١٧) من نفس القانون.

(٢) مادة (١٨-١) من نفس القانون.

(٣) مادة (٢/١٨) من نفس القانون.

(٤) مادة (٢٠) من نفس القانون.

استبان من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه، سواء كان هذا القانون الوطني أم القانون الأجنبي^(١).

ويسرى على العقود التي أبرمت بشأن العقار، قانون البلد الذي يقع فيه هذا العقار^(٢)، وأما الالتزامات غير الإرادية، كالعمل غير المشروع، فإنه يسرى عليها قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام^(٣)، إلا إذا كانت الأفعال غير المشروعة مباحة في مصر فإنها لا تخضع لهذا القانون حتى لو كانت مما يعتبر غير مشروع في البلد الذي وقعت فيه^(٤)، وفيما يتعلق بمسائل الاختصاص والإجراءات، فإنها تخضع لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات^(٥).

ولا يجوز أن يطبق قانون اجنبي في مصر تطبيقاً لمبدأ شخصية القانون إذا كان تطبيقه يخالف النظام العام أو الآداب في مصر^(٦).

ويبدو من تلك التطبيقات القانونية أن مبدأ إقليمية القانون هو الأصل، بمعنى أن القانون يطبق على كل من يوجد داخل حدود

(١) مادة (١٩) من نفس القانون.

(٢) مادة (٣/١٩) من القانون المذكور.

(٣) مادة (١/٢١) من نفس القانون.

(٤) مادة (٢/٢١) من نفس القانون.

(٥) مادة (٢٢) من نفس القانون.

(٦) مادة (٢٨) من نفس القانون.

الوطن، ولا يطبق على غيرهم، اما مبدأ شخصية القانون فإنه يطبق على سبيل الاستثناء خاصة في المسائل المتعلقة بالأسرة^(١).

المطلب الثانى

سريان القانون من حيث الزمان

إذا تم صدور القانون ونشره وتحدد موعد نفاذه، ثم جاء هذا الموعد، فإنه يجب أن يطبق على كل التصرفات والوقائع التى تحدث في ظله، وهذا هو معنى التطبيق الفورى للتشريع أو الأثر المباشر له. ولا صعوبة في ذلك، إذا ما كانت الواقعة القانونية قد نشأت وترتبت عليها كافة آثارها في ظل قاعدة قانونية واحدة، ففي هذه الحالة لا تثار مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان، فلو أن شخصاً كان قد وضع يده على عقار وتملكه بالتقادم على هذا النحو، فلا يؤثر في كسب ملكيته لهذا العقار بهذا السبب القانونى، صدور قانون آخر بعد ذلك يعدل في مدة التقادم أو شروطه، لأن كسب الملكية قد نشأ وترتبت عليه آثاره في ظل القانون القديم.

(١) وراجع فى نطاق التطبيق المكانى للقانون وما يرد عليه من استثناءات: د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٢٤٤، عبد المنعم - فرج الصدة - فقرة ٣٧٣، د. منصور مصطفى منصور - ص ١٧٢، د. جميل الشرقاوى - فقرة ٥٧ وما بعدها، د. عبد الرازق حسن فرج - ص ٩٨ وما بعدها، د. حسن كيرة - ص ٨٦، د. سليمان مرقس - ص ١٦٧ وما بعدها، د. أحمد سلامة - فقرة ١١٦ وما بعدها، د. توفيق فرج - ص ٣٦٦ وما بعدها.

ولكن الأمور كلها لا تكون بتلك السهولة، فقد يدق بعضها وتثور مشكلة تحديد تطبيق القانون من حيث الزمان إذا ما ألغيت القواعد القانونية، وحل محلها قواعد أخرى، وكانت هناك آثار ممتدة لبعض الوقائع القانونية، وهنا يثور التنازع لمعرفة الحد الفاصل بين نطاق تطبيق كل منهما، وما إذا كانت القواعد القانونية القديمة هي التي تنطبق على آثار العلاقات التي نشأت في لها، أم أن القاعدة القانونية الجديدة هي التي ستحكمها إعمالاً للأثر الفوري للتشريع، ولما هو سلم به أن التشريع الجديد هو الذي يحكم الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، كما إذا صدر تشريع جديد يستلزم شكلاً معيناً في انعقاد عقد من العقود، فإن هذا الشكل يجب أن يستوفى في العقود التي تتم بعد سريانه.

الافتراضات التي يثيرها تطبيق القانون من حيث الزمان:

وتطبيق القانون من حيث الزمان يثير ثلاثة افتراضات:

أولها: أنه قد تنشأ وقائع لاحقة على صدور القانون الجديد، وفي هذه الحالة فإن القانون الجديد هو الذي يحكمها، وهذا هو أبسط الفروض الثلاثة.

ثانيها: أنه قد تكون هناك وقائع وأعمال سابقة على نفاذ التشريع الجديدة انتهت آثارها كاملة قبل صدوره واكتملت آثارها في ظله، ولا يطبق عليها القانون الجديد.

ثالثها: الوقائع التى نشأت فى ظل القانون القديم، ولكن آثارها ما زالت ممتدة ونتائجها مستمرة عند صدور القانون الجديد، وهنا يثور التساؤل عن تلك الوقائع التى نشأت فى ظل القانون القديم وما زالت آثارها ممتدة عند العمل بالقانون الجديد وسريانه، فهل يسرى على تلك الآثار الممتدة للقانون الجديد إعمالاً للأثر الفورى للتشريع، أم أنها تظل خاضعة للقانون القديم، ولا تخضع للقانون الجديد، ذلك ما يجب تفريده وبيانه:

أولاً: الوقائع اللاحقة للقانون الجديد:

هذا هو الافتراض الأول؛ الذى يتحقق وجوده حين تكون الوقائع الجديدة قد نشأت لاحقة على صدور القانون الجديد، وهنا نجد أن هذا القانون الجديد هو الذى يحكمها بدون أقل صعوبة أو أدنى شبهة، فإذا استلزم القانون الجديد شكلاً معيناً (الرسمية مثلاً) لانعقاد عقد من العقود، فإنها يجب أن تتم وفقاً لما اشترطه القانون، وإذا استلزم القانون الجديد إجراءً معيناً لانتقال الملكية، كان هذا الإجراء لازماً لانتقالها وإذا رتب القانون أثراً معيناً على فعل ما كالمسئولية مثلاً، انطبق هذا القانون على كل الأفعال التى تقع بعد سريانه.

ثانياً: الوقائع السابقة على صدور القانون الجديد:

وهذه الوقائع هي محل الافتراض الثانى، الذى يقوم على أساس أن ثمة وقائع قد قامت وأنتجت آثارها كاملة قبل صدور القانون الجديد، وهذه الوقائع تخضع فى نشأتها وآثارها وكافة أحكامها للقانون

القدين الذي نشأت في ظله ولا يسرى عليها القانون الجديد حيث لا يجوز أن يسرى القانون الجديد بأثر رجعى ليحكم مثل تلك الوقائع، أى أن تلك الوقائع بتمام وقوعها وترتيب آثارها في ظل القانون القديم قد تحصنت من السريان بأثر رجعى للقانون الجديد عليها، فما هو المقصود بهذا المبدأ؟ ذلك ما يجب بيانه.

مبدأ عدم رجعية التشريع:

يقصد بمبدأ عدم رجعية التشريع، أن القانون لا يجوز أن يسرى على الماضى، فالقانون الجديد لا يجوز أن يسرى على الوقائع والتصرفات التى اكتملت قبل نفاذه، بل تظل هذه الوقائع والتصرفات محكومة بالقانون الذي تمت في ظله، ولا يجوز للقانون الجديد أن يتعرض لها سواء من حيث تكوينها، أو من حيث الآثار المتعلقة بها بالنقيض أو التعديل أو الإلغاء، فقد نشأت هذه الوقائع وترتبت عليها آثارها طبقاً لقانون قائم، فهذا القانون وحده هو الذي يحكمها، ولا يصح أن تتأثر بعد ذلك بتغيير التشريع، فلا يحكمها التشريع الجديد^(١)، وتلك هي القاعدة المعروفة بمبدأ عدم رجعية القانون الجديد على الماضى التى تمثل أهمية كبرى في التشريع حتى إن قوانين ودساتير كافة الدول العربية تنص عليها، كما حرص على النص عليها دستور الصادر عام ٢٠١٤م، في المادة (٢٢٥) منه بقوله: "لا تسري أحكام القوانين

(١) حكم محكمة النقض في ٢٢/١١/١٩٦٦م، المجموعة س ١٧ - ص ١٥٢٥.

إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز - في غير المواد الجنائية - النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

ومن هذا النص يبدو مبلغ حرص الدستور على هذا المبدأ، فهو عندما أجاز للسلطة التشريعية الخروج عليه قيدها أولاً، بعدم المساس به في المسائل الجنائية، كما أنه قيد الخروج عليه في غير المسائل الجنائية بأغلبية خاصة، وهذا يقطع بأن الرخصة التي أعطيت للمشرع يجب أن تستعمل بحكمة بالغة، وأن تقتصر على الحالات التي تقضيها حماية مصلحة اجتماعية أو وطنية عليا وبعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وليس بالأغلبية العادية اللازمة لسن التشريع واتخاذ القرارات، وهي أغلبية الحاضرين من الأعضاء^(١).

كما أكد ذلك دستور ٢٠١٤م - حين نص في المادة (٩٥) منه، على أنه: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

مبررات قاعدة عدم رجعية التشريع:

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٥٩ وما بعدها، حسن كيرة - ص ١٨٨ وما بعدها، د. عبد المنعم فرج الصادرة - ص ١٩٢، د. توفيق فرج - ص ١٨١ وما بعدها، د. أحمد سلامة - ص ٢٠٢ وما بعدها، د. سليمان مرقس - ص ١٤٠، د. عبد الرزاق فرج - ص ١١٤، وما بعدها، د. منصور مصطفى منصور - ص ١٧٦ وما بعدها.

ولا شك ان قاعدة عدم رجعية التشريع تستند إلى مبررات تتصل باحترام العدالة، واستقرار المعاملات، والمنطق القانوني، والاعتبارات المتعلقة بالحريات العامة، وذلك كما يلي:-

(١) من حيث احترام العدالة:

نجد أنه ليس من العدل من شيء القول بسريان القانون على الماضي، وعلى الوقائع التي تمت قبل صدوره فلا يستساغ القول بتطبيق تشريع جديد يقر عقوبة على أفعال كانت مباحة قبل صدوره، وبناء على هذا فإنه ليس بمطلوب من الأفراد سوى احترام القوانين الموجودة حالياً وليس القوانين التي تصدر في المستقبل، التي لا يعلمون عنها بالضرورة شيئاً.

(٢) احترام استقرار المعاملات:

كما أن احترام استقرار المعاملات يعتبر من مبررات قاعدة عدم رجعية التشريع، لأن القول بسريان التشريع الجديد على الماضي، يؤدي إلى اضطراب المعاملات، ويفقد الأفراد الثقة في القانون، ولهذا فإن المصلحة العامة تقتضى عدم سريان التشريع على الماضي استقرار للمعاملات في المجتمع، وعدم بقاء الأفراد مهددين بصدور تشريع جديد يقوض مصالحهم، ويؤدي إلى انتشار الفوضى في المجتمع، وبالتالي عدم استتباب الأمن فيه، ولا يتصور وجود حياة تملؤها الثقة والطمأنينة على النفس والمال، إذا ما عاش الأفراد في

خوف مما يهددهم م نصدور قوانين جديدة تلغى أو تغير من مضمون ما قاموا به من تصرفات قد يكون مقابلها عمرهم^(١).

(٣) من حيث المنطق القانوني:

نجد أن القاضى يجب عليه أن يرجع عند بحثه في العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار إلى القانون الذي يسرى عند نشوئها وترتيبها لهذه الآثار، ولا يعقل أن نطالبه بأن يطبق عليها قانوناً آخر، أما كون النزاع لم ينشأ إلا بعد ذلك، أى بعد صدور قانون جديد، فإن ذلك لا يجوز أن يغير من الأمر شيئاً ومن ثم لا يجوز أن يؤثر ذلك القانون على حل النزاع.

(٤) احترام الحريات العامة:

تبدو قاعدة عدم مرجعية التشريع أساساً من اسس احترام الحريات العامة، حيث لا يستساغ صدور قانون يطبق على وقائع لم تكن تعتبر جرائم قبل صدوره، ولهذا كان هذا المبدأ من القواعد الدستورية يفى المسائل الجنائية التى لا يجوز الخروج عليها حتى بواسطة المشرع نفسه، وهو ما يتفق مع قمل الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}^(٢).

المبدأ يخاطب القاضى والمفسر، ولا يخاطب المشرع:

(١) في هذا المعنى: د. أحمد سلامة - فقرة ٨٧.

(٢) سورة الإسراء - من الآية ١٥.

وفي غير المسائل الجنائية فإن المبدأ يخاطب القاضى والمفسر لا المشرع، فإن المشرع يستطيع ان يخرج عليه بنص صريح في القانون نفسه، وبشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب في غير المسائل الجنائية، ولا يكون ذلك الخروج إلا عند الضرورة القصوى، فيجب على المشرع ألا يستعمل تلك الرخصة فيسحب أثر القوانين على الماضى إلا إذا كان لذلك داع قوم ن دواعى المصلحة العامة. الاستثناءات الواردة على المبدأ:

ومبدأ عدم رجعية التشريع ليس على إطلاقه، بل ترد عليه عدة استثناءات يمكن إجمالها فيما يلي:

(١) جواز الخروج للمشرع:

مما سبق يتبين أن المشرع يجوز له الخروج على المبدأ، لأن القاعدة تخاطب القاضى والمفسر، ولا تخاطب المشرع، وذلك في غير القوانين التى تقرر الجرائم والعقوبات، وبأغلبية المجلس التشريعي.

(٢) القوانين التفسيرية:

يرى بعض الشراح أن القوانين التفسيرية، أى تلك التى يصدرها المشرع لتفسير ما غمض من التشريع، إنما هي قوانين ذات أثر رجعى.

والواقع أن الأمر على خلاف ذلك، لأن هذه القوانين لا تعتبر استثناء بالمعنى الصحيح من قاعدة عدم رجعية التشريع، لن القانون التفسيري لا يتضمن حكماً جديداً يقصد منه الإفصاح عن إراد المشرع

إذا اتضح أن في التشريع غموضاً، وذلك فإنه يعتبر جزء من القانون الذي جاء مفسراً له، ويتحدد تاريخ سريانه بتاريخ القانون الذي يفسره^(١).

(٣) القانون الجنائي الأصلح للمتهم:

والواقع أن الاستثناء الحقيقي من قاعدة عدم رجعية القانون هو ذلك الاستثناء الخاص بالقانون الجنائي الأصلح للمتهم، إذ إن مبدأ عدم رجعية التشريع وإن كان مبدأ عاماً يمتد إلى جميع فروع القانون، إلا أنه ألزم في القانون الجنائي منه في فروع القانون الخارجي، بل إن هذه القاعدة تعتبر هنا - وكما سبق القول - من القواعد الدستورية التي لا يجوز للمشرع نفسه أن يخرج عليها.

ومن شأن تطبيق هذه القاعدة في المسائل الجنائية أنه لا يجوز العقاب على الفعل إلا طبقاً للقانون به وقت ارتكابه، فإذا در قانون لاحق على ارتكاب الفعل، لم يكن له أثر على الأفعال السابقة، حتى ما لم يقدم منها إلى القضاء.

وهذه القاعدة تطبق في حالة ما إذا كان القانون الجديد ينشئ جريمة أو يشدد في عقوبة جرائم موجودة، فلا يجوز أن يعاقب الفعل أو الجاني إلا بالقانون الساري وقت وقوع الفعل، أو وقت ارتكاب الجريمة.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٦٤.

ولكن المشرع رأى الخروج عليها في حالة ما إذا صدر قانون جديد يبيح الفعل، أو قانون جديد يخفف العقوبة، فجعل للقانون الجديد أثراً رجعياً، ليطبق ليس فقط على الأفعال التي تقع بعد نفاذه، بل - وأيضاً - على ما سبق من أفعال.

مبررات رجعية القانون الأصلح للمتهم:

واستثناء القانون الأصلح للمتهم من مبدأ عدم رجعية التشريع له ما يبرره من الناحية الاجتماعية، ومن ناحية العدالة، إذ يكون من التناقص والظلم أن تطبق على المتهم عقوبة في الوقت بالذي اكتشف المشرع فيها عدم جدواها، واعترف بعدم فائدتها، أو بزيادتها عن الحد اللازم، وليس من حق المجتمع أن توقع العقوبة إذا ظهر أن توقيعها ليس في مصلحتها، لأن العقوبة تقدر بالقدر اللازم لتحقيق هذه المصلحة، ولهذا جرى العمل بها في معظم التشريعات.

وقد تقرر هذا الاستثناء في المادة (٥) من قانون العقوبات حيث تقول: "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل، وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم، فهو الذي يتبع دون غيره.

شروط رجعية القانون الأصلح للمتهم:

ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء وهو جواز رجعية القانون

الأصلح للمتهم ما يلي:

(١) أن يكون القانون الجديد في صالح المتهم:

من شروط تطبيق رجعية القانون الأصلح للمتهم، أن يتوافر فيه شرط المصلحة من جانب المتهم، وليس المراد بالمصلحة هنا ما يراد بها في قانون المرافعات مشروط لقبول الدعوى من رافعها، وإنما المراد بها أن يكون القانون الجديد متمخضاً عن حكم يجعل مركز المتهم أحسن في مجال إسناد الفعل إليه، أو تخفيف العقوبة المقررة له، أو إعفائه من التجريم أو العقاب، وذلك بالمقارنة بين هذا الوضع الجديد وبين القانون الذي ارتكبت في ظله.

وتقدير مبدأ مصلحة المتهم في ظل القانون الجديد - على نحو ما سبق - لا ينظر إليها باعتبار شخصي، ولكن يجب ان ينظر إليها على أساس موضوعي مستمد من القانون نفسه، وعلى هذا فإن القانون الجديد يكون أصلح للمتهم إذا كان يبيح الفعل الذي كان يعاقب عليه القانون القديم، أو كان يستلزم للعقاب عليه شرطاً لم ينص عليه، أو كان يقرر وجهاً للإعفاء لم يكن مقررراً من قبل، أو كانت العقوبة المقررة فيه أخف من العقوبة المقررة في القانون السابق، أو كان يقرر وجهاً للطعن في الحكم غير وارد فيه.

(٢) أن يصدر القانون الجديد قبل الفصل في الدعوى نهائياً:

ويجب أن يكون القانون الأصلح للمتهم قد صدر قبل الحكم في الدعوى نهائياً، فلا يطبق القانون الجديد إلا إذا كان صدر وأصبح نهائياً وناظراً قبل الفصل في الدعوى على وجه نهائي، وذلك على نحو ما ورد في المادة (٥) عقوبات، وهذا أمر منطقي، لأن مركز المتهم لا يتحدد إلا بالحكم النهائي، ويكون الحكم نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه، أو فوات المواعيد المقررة للطعن، ومع ذلك فإن القانون قد قرر إعفاء المتهم من هذا الشرط، وهو صدور القانون بعد الحكم عليه نهائياً، وذلك في حالة ما إذا جعل القانون الجديد الفعل غير معاقب عليه، وعلى هذا نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، بقولها: "على أنه إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجانبية"، وهذا النص يعتبر استثناء من شرط صدور القانون الأصلح للمتهم قبل الحكم النهائي.

وكما يبدو من نص القانون فإن الاستثناء قاصر على حالة واحدة هي أن يكون القانون الجديد قد جعل الفعل الذي حكم عليه المتهم من أجله غير معاقب عليه، أي رفع العقوبة إطلاقاً بأنه أزال عن الفعل الصفة الجنائية، أو قرر عذراً معيافاً من شأنه عدم توقيع العقاب، ففي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم وتزول كل الآثار الجانبية المترتبة عليه.

(٣) أن يكون القانون غير مؤقت:

ويجب أن يكون الجديد من القوانين العادية غير المؤقتة، أى التى تعاقب على جرائم في فترة محددة، ذلك أن انقضاء هذه الفترة لا يترتب عليه عدم السير في إجراءات الدعوى أو إتمام مراحل المحاكمة أو عدم تنفيذ العقوبة، وإن كان الفعل قد أصبح مباحاً تبعاً لسقوط القانون الذي يعاقب عليه بانقضاء مدة تطبيقه.

وعلى هذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة (٥) عقوبات مصري، بقولها: "غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم الإدانة فيها، وكان ذلك عن فعل مخالف لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

ثالثاً: الوقائع القانونية ذات الآثار الممتدة:

هذا هو الافتراض الثالث من الافتراضات الثلاثة التى يثيرها موضوع تنازل القوانين من حيث الزمان، وهو أهمها، فقد نجد أنفسنا أمام وقائع نشأت في ظل القانون القديم، ولكنها لم تستنفذ بعد كل آثارها القانونية جمعاء، قبل صدور التشريع الجديد، إما لأن كل آثارها مستقبلية، وإما لأن بعضاً من آثارها قد نشأ في ظل القانون القديم والبعض منها ما زال قابلاً للنشوء في ظل القانون الجديد، وإما لأنها نشأت وضعاً مستقراً ومستمراً للمستقبل في ظل التشريع الجديد.

وفي هذا الغرض وحده، يفرض علينا التنازع الحقيقي بين القوانين نفسه على الواقعة المنظورة، ويقوم التصارع بين التشريعين القديم والجديد، لبيان من منهما هو الذي سيحكم الآثار الممتدة لتلك الوقائع والأعمال، أهو القانون الجديد الذي أصبح العمل به نافذاً وواجباً؟ أم هو القانون الذي كان معمولاً به وقت نشوء هذه الأعمال والوقائع؟ وهذا هو مكن التنازع الحقيقي.

الأمثال توضح ما يقال:

ولنضرب لذلك أمثلة توضح مضمون المشكلة وأبعادها،

ووضعها في مجال التطبيق:

(١) لو افترضنا ان قانوناً معمولاً به يحدد مدة معينة لاكتساب الملكية بالتقادم هي خمسة عشر سنة، ثم صدر قانون جديد يرفعها إلى ثلاثين سنة، او يحرم اكتساب الملكية بالتقادم مطلقاً، فهل يطبق هذا القانون الجديد فوراً على تلك الواقعة فتسري المدة الجديدة أو الحكم الجديد؟ أم يطبق القانون الذي بدأ سريان المدة في ظله، وبمعنى آخر إذا كانت قد مضت مدة عشرة سنوات فهل يمتلك الشيء بعد خمس سنوات؟ أم بعد عشرين سنة، او لا يمتلكه مطلقاً وفقاً للقانون الجديد؟

(٢) لو افترضنا أن قانوناً صدر بتحديد سن الرشد بثمانى عشرة سنة، وقد كان ذلك هو المقرر بالفعل في قانون المجالس الحسبية القديم المعمول به قبل عام ١٩٢٥م، ثم صدر القانون المدني، وعمل به

في ١٥/١٠/١٩٤٨م، حيث حاد بلوغ سن الرشد بإحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.

فهل يسرى هذا القانون على من بلغوا قبل نفاذه ثمانى عشرة سنة بالفعل ولكنهم لم يتموا عند العمل به إحدى وعشرين سنة، ويعودوا بالتالى قصراً إلى حين بلوغ هذا السن، أم يخضعوا للقانون القديم، وتكون اهليتهم قد اكتملت به وبلغوا سن الرشد.

(٣) كان قانون الإثبات يجيز إثبات الالتزام التعاقد بشهادة الشهود إذا كانت قيمته عشرين جنيهاً، ثم صدر قانون يرفع هذا النصاب إلى مائة جنيه أو خمسمائة جنيه، وفقاً للمادة (٦٠) من قانون الإثبات بعد تعديلها بالقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٩٩م في ١٧/٥/١٩٩٩م، فهل يسرى هذا القانون على الوقائع التى نشأت قبل نفاذه، أم تظل تلك العقود فيما يتعلق بالإثبات خاضعة لأحكام القانون التى نشأت في ظله؟

(٤) إذا تزوج شخص غير مسلم في ظل قانون يجيز الطلاق للزوج بإرادته المنفردة، ثم صدر قانون جديد يجعل الطلاق بيد القاضى، ثم إراد هذا الشخص أن يطلق زوجته، فهل يجوز له أن يطلقها وفقاً لأحكام القانون الذي تم الزواج في ظله، والذي يجيز له الطلاق؟ أو يسرى عليه القانون الجديد الذي يجعل الطلاق بيد القاضى ولا يملك الزوج أن يوقعه؟

فهذه الأمثلة وغيرها توضح أبعاد مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان، وهي تتلخص في معرفة ما إذا كان القانون القديم مستمراً في السريان ليحكم هذه الآثار المستقبلية، أم أنه يقف عندئذ بصدر القانون الجديد تاركاً لهذا القانون وحده حكمها مستقبلاً.

طريقتان لحل مشكلة التنازع الزماني:

ولحل مشكلة التنازع الزماني بين التشريعين القديم والجديد توجد طريقتان؛ الأولى التشريع، أي أن المشرع يستطيع أن يفض ذلك النزاع بواسطة التشريع من خلال النص الكفيل بحله، فإذا وجدت مثل هذه النصوص في التشريع وجب تطبيقها على أساس أنها تفصح بصراحة عن قصد المشرع وإرادته، ولكن الصعوبة تنشأ حقاً إذا لم توجد مثل هذه النصوص في التشريع، فيترك المشروع للمفسر حلها بالوسائل الفنية ومن ثم يبدو أن لتلك المشكلة طريقتين في الحل؛ تشريعية، وفنية: وتخصص لبيان كل من هاتين الطريقتين فرعاً:

الفرع الأول

الوسيلة الفنية لفض التنازع الزماني

لا يثار النظر في استعمال الوسيلة الفنية لفض التنازع الزماني بين القوانين إلا في حالة عدم وجود نص يكشف عن قصد المشرع في فضه، وبعد ذلك علينا أن نفهم معنى عدم رجعية التشريع وفقاً لصريح عبارة نص المادة (٢٢٥) من دستور ٢٠١٤م التي تقرر انه: "لا تسري

أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز - في غير المواد الجنائية - النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

لأن عبارة النص لا تعنى سوى غل يد التشريع الجديد عن المساس بالوقائع التى تمت في الماضى، ولا أن يتعرض للآثار التى ترتبت عليها في الماضي - أيضاً - وإلا كان ذا أثر رجعى، وهو محذور، ولكن ذلك لا يعنى ان القانون الجديد لا يستطيع المساس بالآثار المستقبلية لهذه الوقائع والتصرفات، ويجب عدم الخلط بين رجوع التشريع إلى الماضى على هذا النحو، وبين انطباقه على الآثار المستمرة مسبقاً للوقائع القديمة، واعتباره رجعياً في كلتا الحالتين، لأن هذا خلط وخطأ، فانطبق القانون على الآثار المستقبلية ليس رجعة به إلى الوراء، وإنما تلك الرجعية لا تكون إلا عند العودة إلى الماضى لإلغاء شيء أو تعديله بعد ما تم واكتسب في الماضى، والآثار المستقبلية ليست ماضياً وإنما هي منسوبة إلى المستقبل ومحسوبة عليه، فإذا طبقنا القانون الجديد عليها لا يكون ذلك إعمالاً له بأثر رجعى، حيث لا يكون له وصف الرجعية إلا إذا مس الآثار التى تمت في الماضى.

وقد اختلف الفقه في حل ذلك التنازع، وأدى ذلك الاختلاف إلى وجود نظرتين هما، النظرية التقليدية المعروفة بنظرية الحقوق المكتسبة، والتي تقوم على أساس السماح للقانون القديم بحكم الآثار المستقبلية للوقائع اتلى نشأت في ظله، والنظرية الثانية، هي النظرية الحديثة التي تقوم على أساس إعمال القانون الجديد على تلك الآثار إعمالاً مباشراً وحالاً، ولذلك عرفت بنظرية الأثر الحال أو المباشر أو الفوري، ولكن أنصار كل من هاتين النظريتين يوردون على المبدأ الذي يضعونه فيهما طائفة من الاستثناءات، لدرجة أن الحلول التي تؤدي إليها كل منهما، تتماثل أو تتقارب في كثير من الفروض، وتبين ذلك:

أولاً: النظرية التقليدية (نظرية الحقوق المكتسبة):

وضعت هذه النظرية مبدأ معروفاً يقوم على التفرقة بين الحق المكتسب ومجرد الأمل، ويقول أنصارها: "إن القانون الجديد لا يجوز أن يمس الحقوق المكتسبة طبقاً للقانون القديم، بل يجب ان يبقى القانون القديم ليحكم وحده هذه الحقوق، ويضيفون إلى هذا أن القانون الجديد إذا مس الآثار المستقبلية للتصرفات والوقائع القانونية التي نشأت قبل نفاذه، لكان في ذلك مساس بحقوقهم التي اكتسبوها وفقاً

للقانون، وهذا لا يجوز لأنه إن فعل ذلك يكون ذا أثر رجعي وهو الأمر المحظور^(١).

والحكمة من عدم جواز مساس القانون الجديد بالحقوق المكتسبة قبل نفاذه هي ضرورة تأمين الأفراد على مراكزهم وعلى حقوقهم، حيث لن يطمئن الناس إذا ما عاشوا مهددين يصدر قانون يقلب مراكزهم القانونية في التصرفات التي ارتضوها بإرادتهم رأساً على عقب، ويجب أن يطمئن المتعاقدان وقت التعاقد إلى أن العقد سيكون سارياً بينهما بالشروط التي ارتضاها حتى التاريخ المحدد لتصرفهما، إذا أن لهما حقاً مكتسباً في أن يبقى مركزهما القانوني ثابتاً غير متقلب.

التفرقة بين الحق المكتسب ومجرد الأمل:

وإذا كان أنصار النظرية التقليدية قد أقاموا أساسها على فكرة الحق المكتسب ومجرد الأمل إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في معيار التفرقة بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٦٨ وما بعدها، د. جميل الشرقاوى - ص ١٨٥، وما بعدها، د. أحمد سلامة - ص ٢٠٦، د. حسن كيرة - ص ١٩١، توفيق فرج - ص ١٨٦ وما بعدها، د. شمس الدين الوكيل - ص ٢٣٤ وما بعدها، د. عبد المنعم فرج الصدة - ص ١٩٦ وما بعدها، د. عبد الحى حجازى - فقرة ٢٨٧، د. عبد الرازق فرج - ص ١١٩، د. منصور مصطفى - ص ١٧٩ وما بعدها..

فذهب بعضهم إلى أن الحق المكتسب هو الذي يدخل نهائياً
يف ذمة الشخص فلا يمكن سلبه أو نزعها بغير إرادته، وذلك مثل حق
الدائنية حتى لو كان معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل، فإذا لم
تتحقق هذه الضوابط فإننا نكون بصدد مجرد أمل، أى ترقب اكتساب
حق، أو وجود أمنية لدى الشخص قد تتحقق وقد لا تتحقق^(١)، وهو
الذي يستطيع صاحبه أن يرفع به دعوى أمام القضاء فإذا استطاع
ذلك كان صاحب حق مكتسب، وألا فهو مجرد أمل^(٢).

ويقولون بياناً لذلك بالمثال: إن الزوجين اللذين عقد زواجهما
قبل صدور القانون عام ١٩٣٨م، الذي أعطى المرأة الفرنسية حق
التصرف بدون إجازة الزوج، لم يكن لأيهما حق مكتسب في أن تظل
المرأة ناقصة الأهلية، فبقاء نقص أهلية الزوجة كان مجرد أمل ومحل
احتمال، ولذلك فإن القانون الجديد يطبق بأثر فوري ومباشر على
جميع الزوجات، فكل التصرفات التي يعقدنها منذ صدور هذا القانون
الجديد تعتبر صحيحة بدون إجازة الزوج.

وذهب بعض منهم في تعريف الحق المكتسب إلى أنه ذلك
الذي يقوم على سند قانوني، أما مجرد الأمل فلا يقوم على هذا السند.
الاستثناءات الواردة على النظرية التقليدية:

(١) د. أحمد سلامة - فقرة ٨٩، د. عبد الرزاق فرج - ص ١٢٠.

(٢) بلانيول وبرير وبولانجيه - ج ١ - فقرة ٢٣٦.

وقد أورد أصحاب تلك النظرية عليها استثناء من عدم مساس القانون الجديد بالحقوق المكتسبة، وهو القانون الذي يتعلق بالنظام العام فإنه يطبق بأثر فوري، ولا يكون للقانون القديم سلطان على تلك الواقعة، وذلك فضلاً عن حالة التصص الصريح على الرجعية، والتشريعات التفسيرية والقوانين الجنائية الأصلح للمتهم، حيث يقولون: "إنه لا يجوز لأحد أن يتمسك بحق مكتسب في مواجهة النظام العام، كالقوانين المتعلقة بالأسرة، وتلك التي تفرض سعراً إلزامياً للنقود فإنها يجوز أن يكون لها أثر رجعي - في رأيهم - فتطبق فوراً على الآثار المستقبلية للتصرفات والوقائع القديمة ولو مست بحقوق مكتسبة.

ويجب التنبيه - بداية - إلى أن هذا القول فيه خلط بين الأثر الرجعي، والأثر الفوري للتشريع الجديد، فإن حكم الآثار الممتدة للتشريع القديم ليس رجعية للتشريع الجديد، وإنما هو إعمال له بأثر فوري.

كما يلاحظ أن الاستثناء المتعلق بالنظام العام عندهم منحصر في أضيق نطاق، وليس أدل على ذلك مما ضربوه من أمثلة، فهو لا تدل على اتساع نطاق الفكرة عندهم على أساس التفرقة بين القوانين الآمرة والقوانين المكملية، وما فتئ ينفيك بعضهم بصرح بأن المراد بفكرة انلظام العام هي ذات الأهمية القصوى والخطر البالغ التي لا يتصور مع وجودها استمرار وضع مخالف، وذلك كالقانون الذي يحدد

أو الذي يلغى الرق، أو الذي يفرض السعر الإلزامي للنقود.

نقد النظرية التقليدية:

وقد تم توجيه النقد إلى تلك النظرية، ومن أبرز ما أخذ عليها من عيوب: أنها تعطي للقانون القديم قدسية وسلطاناً يتجاوز الحدود التي ينبغي أن يقف عندها قانون وضعي يفترض أنه يواجه وضعاً متطوراً، ولا يتصور أن يصدر قانون جديد لمواجهة هذا التطور فيجابه بذلك التقديس المجافى لطبيعة الأشياء، ولا يملك تنظيم كافة الآثار التي تسري في ظله، لمجرد أنها ترجع إلى وقائع نشأت قبل نفاذه، كما أن هذه الوقائع تعطي أهمية كبرى لتحقيق الوقائع دون الآثار^(١).

كما قيل أن التفرقة بين الحق المكتسب ومجرد الأمل تفرقة
تحكمية تقوم على تقسيم فاسد، والتعريفات التي قدمت لكل منهما لم
تسلم من النقد الذي يجعلها حرية بالرفض حتى قال الفقيه الفرنسي
(سوميير): إنه يتحدى أعظم الفقهاء في العالم أن يعرف الحق
المكتسب ومجرد الأمل تعريفاً يسلم من النقد أ و يرقى للقبول^(٢): بل أن

(۱) راجع فی هذا المعنى: د. جميل الشرقاوى - ص ۱۷۶، د. عبد المنعم فرج - ص ۱۹۶، د. منصور مصطفى منصور - ص ۱۹۰، د. عبد الرازق فرج - ص ۱۲۱، د. عبد المنعم النبراوى - ص ۱۷۵ وما بعدها.

(٢) بلانيول وريير ويولانجيه - السابق - فقرة ٢٣٧ وما بعدها.

أحداً منهم لم يستطع ان يضع لهذه التفرقة ضابطاً دقيقاً واكتفى معظم الشراح بضرب أمثلة هي من الوضوح لدرجة لا تثير أدنى شك. وأساس النظرية التقليدية محل نظر، لأن الآثار الممتدة للوقائع السابقة على صدور التشريع الجديد، هي مسائل مرتبطة بالمستقبل وتطبيقه عليها ليس إعمالاً لرجعية التشريع، وإنما هو إعمال فوري له، لكن تلك النظرية قد خلطت خطأً واضحاً بين الأثر الفوري والآثر الرجعي للتشريعين، فكان أساسها في تلك التفرقة خاطئاً لا يصح التعويل عليه.

حتى في الحالات التي اعتبروها استثناء من مبدأ الرجعية لتعلقها بالنظام العام، كالقانون الذي يلغى الرق، أو الذي يحدد سن الرشد

أو غيرهما، فإن التدقيق الصحيح يقول أن ذلك ليس إعمالاً للقانون الجديد بأثر رجعي، ولكنه إعمال له على الآثار الممتدة بأثر فوري، وقد خلطوا بين الأمرين خطأً يجعل أساس النظرية محل نظر ونقد^(١).

ثانياً: النظرية الحديثة (الأثر الفوري للتشريع الجديد):

قامت النظرية الحديثة على أساس النقد الذي وجه للنظرية التقليدية وانتصر لها في الفقه الفرنسي الأساتذة (بلانيول - وكولان - وكابيتان)، ومن أحسن المؤلفات التي وضعت فيها كتاب الأستاذ

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٧٧ وما بعدها.

(روبيه)، وعنوانه: تنازع القوانين في الزمان، الذي نشر الجزر الأول منه، في باريس عام ١٩٢٩، والجزء الثاني في عام ١٩٣٣، وكان لهذه النظرية تأثير كبير في القضاء، فكثير من أحكامه تشير إليها، وإن لم يهجر بعضها النظرية التقليدية.

التطبيق الفوري للتشريع الجديد:

وتقوم هذه النظرية على أساس أن التشريع الجديد لا يسرى فقط على الوقائع التي تحدث بعد صدوره، وإنما يطبق على الآثار الممتدة للوقائع التي نشأت في ظل القانون القديم، لأن القانون يجب أن يسرى بأثر فوري ومباشر.

الأسس التي تقوم عليها النظرية الحديثة:

وقد استند أنصار هذه النظرية إلى مبررات وحجج تؤيد ما ذهبوا إليها، فقالوا:

(١) إن هذا المبدأ يتفق مع النصوص التشريعية ولا يجافيها، كما أنها تؤيده وهو ما يفهم من نص المادة (٢٢٥) من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤م، حيث تقرر أنه: "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز - في غير المواد الجنائية - النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

(٢) ثم إن هذه النظرية تتفق مع الإرادة المفترضة للمشرع، لأنه إذا عدل تشريعاً قديماً أو ألغاه، فإن ذلك يعنى أنه غير صالح في نظره،

أو أن كفاءته في حكم الوقائع لم تعد في المستوى المطلوب، وهذا يعنى أن التشريع الجديد في نظره أفضل، ومن ثم يتعين تطبيقه فوراً، ليس على الوقائع المستقبلية، بل على الآثار الممتدة للوقائع السابقة عليه.

(٣) كما أن توحيد المركز القانونية للأفراد تؤيد تطبيق القانون الجديد بأثر فوري على كافة الوقائع حتى لا يؤدي تخلف تطبيقه على بعضها إلى التنوع والاختلاف في تنظيم الروابط القانونية، فلو صدر قانون جديد يحرم الطلاق أو يقيدده، وقلنا أنه لا يسرى إلا على عقود الزواج التي تقع بعد صدوره، لكان معنى ذلك أن هناك أزواجاً يستطيعون الطلاق دون قيد أو شرط، وأزواج لا يستطيعون ذلك، أو لا يقدرّون عليه إلا بقيود وشروط، ومثل تلك التفرقة في المراكز القانونية من شأنها أن تؤدي إلى مساوئ اجتماعية، لا تتسجم مع غايات القانون وأهدافه، ولا خروج من ذلك إلا بالتطبيق الفوري للقانون الجديد.

استثناء استمرار القانون القديم لحكم الروابط العقدية:

بيد أن أنصار النظرية الحديثة قد أوردوا على ما ذهبوا إليه من ضرورة إعمال القانون القديم لحكم الروابط العقدية: بأثر فوري، استثناءً أجازوا فيه استمرار القانون القديم لحكم الروابط العقدية، وذلك على أساس أن تطبيق القانون الجديد عليها بأثر فوري تطبيقاً عاماً قد يؤدي إلى مساوئ جسيمة، وقلب ما قدره أطرافه عند إبرامها رأساً على عقب،

لأن من يبرم عقداً وفق قانون معمول به، إنما يقدر مدى ما له وما عليه وفقاً لما يقضى به هذا القانون، وليس بمقدور المتعاقدين أن يتوقعوا تغيير التشريع في المستقبل، أو على أى نحو سوف يتغير، حتى يؤسسوا مراكزهم القانونية على ذلك التغيير المحتمل، ولو أن هذا قد أتيح لهم، لكان ذلك قماراً وغرراً لا يمكن التسليم بوجوه مشروعيتها، وهم إنما يوازنون بين مراكزهم في العقد على ضوء القانون السارى الذي يستطيعون العلم به، ولذلك فإن المنطق والعدل يقتضى استمرار القانون الذي نشأت تصرفاتهم في ظله لحكم آثار عقودهم الممتدة، حتى لا يؤدي أعمال القانون الجديد إلى إخلال بالتوازن في المراكز القانونية مما يقود إلى ظلم فادح.

ولا يصح الإخلال بالثقة المشروعة التى يضعها الأفراد في قوة عقودهم، وفيما يترتب عليها من آثار، لأنها عنصر أساسي يفي كل تنظيم قانوني، وهي توجب أن يطمئن المتعاقدون على مراكزهم القانونية الناشئة منه ليس في الحال فقط، بل وفي مآل أيضاً، ولو جاز أن يخل المشرع بهذه الثقة وفق مشيئته، لكان في هذا أكبر الضرر والاضطراب، بل والقلق للمعاملات القانونية^(١).

وهذا الاستثناء الخاص بالروابط العقدية يطبق على كل العقود التى لا تترتب آثارها عند انعقادها، وإنما يستمر تنفيذها مدة من

(١) في هذا المعنى: د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٨٠ وما بعدها.

الزمان، كعقد القرض، وعقد الإيجار، وعقد العمل، وعقد المقاوله، وغيرها، فهي تخضع لقانون واحد من وقت إنشائها حتى تاريخ انقضائها، دون أن تتأثر بأى تشريع مستقبل، وذلك استثناء من المبدأ العام الذي يقضى بوجوب تطبيق القانون الجديد تطبيقاً فورياً.

استثناء من استثناء استمرار العمل بالقانون القديم:

والاستثناء الذي أورده أصحاب النظرية الحديثة لاستمرار القانون القديم في حكم آثار لا لروابط العقوبة التى نشأت في ظله، لم يسلم من التقييد بل الاستثناء، حيث بدا لهم أن إعماله على إطلاقه، والقول باستمرار القانون القديم يفي اصطحاب الروابط العقدية حتى تمام تنفيذها وانقضائها استثناء من الأثر الفوري للتشريع الجديد، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الخلل في توحيد المراكز القانونية التى يحرص التشريع على خضوعها لنظام قانونى موحد، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقييد إطلاق هذا الاستثناء، لكن كيف ؟ ذلك ما اختلف الرأى فيه بين الفقهاء، ويمكن رد أقوالهم إلى اتجاهين:

أولهما: يفرق بين المركز التعاقدى والنظام القانونى:

وقد قال بتلك التفرقة طائفة من أنصار النظرية الحديثة منهم صاحبها ومبتكرها الأستاذ (روبيه)، الذي نادى بضرورة التفرقة بين النظام التعاقدى أو المركز التعاقدى والنظام القانونى، وتبياناً لذلك فإنه ومن معه يقولون:

(١) هناك طائفة من العقود يستقل المشرع بتنظيمها، وتنظيم ما يترتب عليها من آثار مثل عقد الزواج، والعقود التي ترد على الملكية، والحقوق العينية من حيث نظام الملكية ومداه، وعقد العمل يقتصر دور الإرادة فيها على مجرد قبول الدخول في النظام القانوني، ثم يتولى المشرع بعد ذلك تنظيم الآثار بطريقته، ولذلك فإن تلك الطائفة من العقود تدخل فيما سماه الأستاذ (روبيه): بالنظام القانوني، وما دام المشرع هو الذي يستقل بتنظيم هذه العقود، يكون من الطبيعي أن تخضع هذه العقود في جميع الأحوال لكل تنظيم يراه المشرع في أى وقت، ولا يقبل أن يميز فيها بين ما نشأ قبل صدور القانون الجديد بأثر فوري، وما نشأ بعده فيطبق في الحالتين بأثر فوري.

فالقوانين المنظمة للزواج، والحقوق العينية كالملكية وما يتفرع عنها من حقوق وعقد العمل، والسعر الإلزامي للنقود الورقية، وصلة الإدارة بموظفيها، يجب على التشريع بتنظيمها، ويقتصر دور الإرادة على الدخول فيها، ولهذا كان من الطبيعي أن يحتفظ المشرع دائماً بسلطانه في تنظيمها.

(٢) وأما العقود التي يستقل الأفراد بتنظيمها، فإنها هي التي تستثنى من قاعدة الأثر الفوري المباشر للتشريع، وفيها يستمر القانون القديم ليحكم آثارها وانقضائها لأن القانون إذا كان قد ترك لإرادة الأفراد تنظيم هذه العقود يكون قد سمح بتفاوتها واختلافها في التنظيم دون

حرص على توحيدها، ومن ثمت تنتقى فيها احكامه من تقرير الأثر المباشر للقانون، وذلك هو الشأن في معظم العقود التى تجرى في المعاملات المالية، فهذه العقود لا يطبق عليها القانون الجديد حتى ولو تضمن قواعد آمرة تتصل بالنظام العام، إذ العبرة في تحديد المركز القانونى يكون صاحبه في مركز تعاقدى أو قانونى، وليس يكون القانون آمراً او ليس آمراً^(١).

ثانيهما: يجب تقييد العقود بالنظام العام:

وهذا القيد هو ما قال به جانب من الفقه، ومضمون ما ذهبوا إليه: انه حيث يتعلق القانون الجديد بالنظام العام فإنه يجب تطبيق القانون تطبيقاً فورياً، ليس فقط على العقود والتصرفات التالية لصدوره، بل على الآثار الممتدة للعقود والتصرفات التى أبرمت قبله، لكنهم عند تقدير فكرة النظام العام ينظرون إليها في أضيق نطاق، ويعطونها مدلولاً أضيق من المدلول العادى لها، والذي يستمد أساسه من التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة، فلا يعتبر من النظام العام عندهم سوى القوانين التى تحمى مصالح عامة فقد، دون تلك التى تحمى مصالح خاصة، ومن ثم فإنهم لا يسمحون بتطبيق القانون تطبيقاً

(١) قرر ذلك الأستاذ (روبيه)، وقوله هذا محل نظر، لأن فكرة النظام العام هي أساس النظام القانونى، وتصور الفصل بينهما يؤدي إلى عكس ما يهدف إليه، لأنها ستؤدي إلى اختلاف المراكز القانونية في الأمور التى يرى المشرع أنها تشكل نظاماً عاماً في المجتمع لا يسمح لإرادات الأفراد بالخروج عليه.

مباشراً وفورياً إلا إذا كان تطبيق القانون القديم ينطوى على إهدار المصلحة عامة أو يؤدي إلى خطورة على النظام الاجتماعي العام.

خلاصة مضمون النظرية الحديثة:

ويمكن تلخيص مضمون النظرية الحديثة في أنه ليس للقانون أثر رجعي، فلا يجوز أن يرجع إلى الماضي ليحكم ما وقع قبل نفاذه، بل إن الوقائع والآثار التي نشأت في ظل قانون قبله تظل محكومة بهذا القانون القديم.

ومن جهة أخرى فإن القانون الجديد يسرى بأثر فوري على كل ما يقع من تصرفات أو آثار تترتب عليها في المستقبل، أو تترتب مستقبلاً على وقائع نشأت في ظل القانون القديم، واستثناء من الأثر الفوري للقانون الجديد، يستمر تطبيق القانون القديم بأثر ممتد بعد إلغائه ليحكم العقود التي نشأت في ظله من حيث آثارها المستقبلية وانقضائها، إلا أن يتصل العقد بمركز قانوني، أو بالنظام العام (بمعنى ضيق) فعندئذ تعود إلى القاعدة العامة التي تقضى بتطبيق القانون الجديد تطبيقاً فورياً مباشراً^(١).

تقييم النظرية الحديثة:

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ١٨٤ وما بعدها.

استطاعت النظرية الحديثة أن تحظى برضا الفقه، حيث وجد فيها محتوى لمجموعة من المميزات التي تتميز بها عن غيرها، ومن ذلك:

(١) أنها قد ميزت بين الرجعية والأثر المباشر للقانون الجديد، وانتهت إلى تطبيق القانون الجديد على كل ما يقع في المستقبل، حتى الآثار المستقبلية لوقائع قديمة، لا يعتبر من قبيل الرجعية، بل هو أعمال للأثر المباشر للتشريع الجديد، ذلك في الوقت الذي خلطت فيه النظرية التقليدية بين هذين الأمرين..

(٢) كما تلافت القول بمعيار الحق المكتسب ومجرد الأمل، وهو معيار تحكّمي وغامض، ولا أساس له قانوناً.

(٣) ثم إن ما ذهب إليه، وهو تطبيق القانون الجديد بأثر فوري ومباشر، يتفق مع نية المشرع، ومع ما ينبغي أن يتوافر للروابط القانونية من توحيد في نظامها القانوني.

(٤) لم تهمل مبدأ سلطان الإرادة في الروابط العقدية، فقررت استمرار القانون القديم لحكمها، ومع ذلك فإن النظرية لم توفق في المعيار الذي اقترحته لتحديد نطاق الأثر المستمر للقانون القديم، والأثر الفوري للقانون الجديد بالنسبة للروابط الناشئة عن العقود، فقد فرق الأستاذ (روبيه) فيها بين النظام القانوني والنظام العقدي، وهي تفرقة غامضة ليس من السهل تفريدها في كثير من الأحيان.

وحين أراد جانب آخر من أنصارها إحلال معيار آخر هو معيار النظام العام، أعطوا له مدلولاً ضيقاً عن مدلوله العادى، فأخرجوا من مدلوله بعض القواعد التى يجرى الفقه والقضاء على اعتبارها قواعد أمره لا يجوز الخروج عليها لاتصالها بالنظام العام.

رأينا في النظرية الحديثة:

ونحن نرى أن النظرية الحديثة كوسيلة فقهية لحل تنازع القوانين من حيث الزمان هي التى تلائم التطور القانونى المنتظر، كما أنها تتسجم مع النظام القانونى ككل، وذلك كما يلى:

أولاً: أن القانون عمل تشريعى يصدر عن هيئة تأتلف من أفراد، وهؤلاء الأفراد مهما أوتوا من العلم والخبرة والكياسة، ليس لديهم من الإحاطة الكافية التى يمكن أن تلم بكل جوانب التشريع الذى يقيمون بصياغته، خاصة وأنه يتناول أموراً سوف تقع في المستقبل، وهو غيب عن البشر، ومن ثم كان علمهم فيه قاصراً، ولا مجال لتلافى هذا القصور إلا بملاحقة التغيرات التى لم تكن متوقعة وقت إعداد التشريع بما يلائمها منه عند وقوعها، وتجاهل ذلك التطور أمر غير سائغ، ومن ثم فإنه لا يستقيم معه القول ببقاء التشريع الوضعى القديم ليحكم تلك الروابط، ومع ما استبان من عجزه، وعدم قدرته على النحو الذى أدى إلى استصدار تشريع جديد يعالج عجزه وقصوره، فإذا ما حكمنا

على هذا التشريع الجديد بما يقيد حركته ويحد من مهمته، يكون ذلك ضد طبيعة الأشياء، فالتطور القانوني يقتضى الأخذ بالنظرية الحديثة. **ثانياً:** أن النظام القانوني لا يجوز أن يتجاهل الواقع، كما أنه لا يجوز أن يتغافل عن طوارئ الأحداث وما تجرى به الأقدار على غير علم الأفراد، بل ومشيتهم، وقد هيا ذلك النظام القانوني بناءه على أساس مواجهة تلك التغيرات الطارئة بما يقوى على مواجهتها، ويعالج المراكز القانونية على ضوءها بما يحقق أقصى كسب ويتلافى أبلغ خسارة، وذلك في حدود العدل الذي يتعين المصير إليه في ظل الطوارئ الجديدة التي تطيح بالمراكز القانونية التي أرتأها الأفراد وقت قيامها، والتي لا يمكن القول معها: إن ثمة مركزاً قانونياً محصناً دائماً من تلك الطوارئ، بل إن أقوى المراكز القانونية، وهو حق الملكية يمكن ان يعتريه منها ما يجعله هباء، بل ولربما تنتقل به من منزلة الحق إلى مجال آخر، يرهق صاحبه من أمره عسراً ويقلبه وبالاً عليه والتزاماً في عنقه وليس ميزة له، هذا المعنى القانوني الذي يقوم على أساس استيعاب المتغيرات الجديدة وتقديم الحلول القانونية لها من خلال بعض الأفكار القانونية مثل نظرية الفسخ، نظرية البطلان، ونظرية الظروف الطارئة، إنما يستقيم معه ما تقضى به النظرية الحديثة، حيث تعتبر في إطار هذا المعنى القانوني العام عملاً مقبولاً وحلاً مرضياً.

ثم إنها في النهاية تبرز ما في التشريع الإسلامي من كمال جعله ثابتاً ثبوتاً شامخاً لا يعتريه التغيير، ولا تتناول إليه معاول النقد مع قدرته على مواجهة التغيرات الطارئه دون حاجة إلى تعديل فيه، أو خروج عليه، وهذا أمر عادي فيه، لأن الذي شرعه هو الله تعالى، وهو - سبحانه - حين شرعه لم يكن يحول دونه، ودون إدراك الغيب الذي سيقع في ملكه حاجب، فهو - سبحانه - الذي يعلم السر وأخفى، له غير السماوات والأرض، ولا شك أن تشريعاً يصدر من العليم الخبير الذي يعلم خافية الأعين وما تضره الصدور، وتتقلب إليه الأيام، لا يمكن إلا أن يكون محكماً، ومحصناً من التغيير والتبديل، وقادراً على ملاحقة التطورات التي تحدث في حياة الناس إلى يوم الدين، بل إن حياة الناس بتغيرها وتطورها هي التي تفرض وجوده.

ثالثاً: كما أن تلك النظرية ينبغي أن يعتريها من التعديل الذي يتلاقى ما يمكن أن يؤخذ عليها من نقد، سيما ما يتعلق بمفهوم فكرة النظام العام التي بدت محدودة فيها، ويجب أن يؤخذ بها في إطار مدلولها العادي الذي يقوم على أساس التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة، والأولى؛ لا يجوز أن يسمح للأفراد بالخروج عليها والقوانين الصادرة، بشأنها يجب أن تطبق بشكل فوري ومباشر، الثانية؛ هي التي تسمح للأفراد بالخروج عيها، ويجوز أن يختلف النظر بشأنها، ويظل القانون القديم حاكماً لها.

رابعاً: وفيما يتعلق بقاعدة عدم رجعية التشريع، فإنه من المقرر أن القانون الجديد لا يجوز أن يرجع إلى الماضي ليعيد النظر في الوقائع التي نشأت قبل العمل به، أو في الآثار التي ترتبت بالفعل، ولا يرد على هذه القاعدة إلا الاستثنائين المقررين بالقانون، وهما:

(١) نص المشرع؛ فمن المعروف أن المبدأ يخاطب المفسر والقاضي ولا يخاطب المشرع، فيجوز له أن يخرج عليه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي غير المواد الجنائية.

(٢) القانون الجنائي الأصلح للمتهم، والمنصوص عليه في المادة (٥) من قانون العقوبات، وأما القوانين التفسيرية فإنها - على الرأي الراجح يفي الفقه - لا تمثل استثناء من مبدأ عدم رجعية بالتشريع، لأنها لا تتضمن حكماً جديداً، وإنما تفصح عن قصد المشرع الحقيقي ولذلك فإنها تعتبر جزءاً من التشريع الذي تفسره ويرتبط تاريخها بتاريخه.

مثالان تطبيقيان على النظرية الحديثة:

ونود أن نوضح منهج النظرية الحديثة في فض التنازع الزماني بين التشريعين فنسوق مثلين أحدهما يتعلق بنص أمر، وثانيهما يتعلق بنص مكمل:

(١) النص الأمر المتعلق بالظروف الطارئة:

نظم المشرع الظروف الطارئة بنص أمر في المادة (١٤٧) مدني، فقال: "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع

توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضى تبعاً للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وهذه المادة تشير إلى نظرية الظروف الطارئة، ويبدو من نصها أنه أمر لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، ولهذا فإنها تنطبق على كافة العقود التى أبرمت قبل العمل بالقانون املدى الجديد والتى أبرمت بعده.

(٢) القاعدة القانونية المكملة:

والقانون الجديد لا يطبق - وفقاً للنظرية الحديثة - على القواعد المكملة، فيستمر القانون القديم في حكمها، وعلى هذا فإن نص المادة (٥٦٧) من القانون المدنى الجديد الذي يلزم المؤجر بتعهد العين المؤجرة بالصيانة، وأن يقوم بجميع الترميمات الضرورية، مخالفاً لما كان القانون المدنى القدين يقضى به في المادة (٣٧) التى كانت تنص على أن المؤجر لا يلتزم بعمل أى مرمة كانت، لن يسرى على العقود التى أبرمت في ظل القانون القديم، لأن النص مكمل وليس آمراً، ومن ثم فإنه يظل خاضعاً للقانون الذي نشأ في ظله.

الفرع الثانى

الوسيلة التشريعية لفض النزاع

اهتم المشرع المصري بوضع الحلول لبعض مسائل تنازع القوانين في الزمان، وقد أورد بعضاً من تلك الحلول في القانون المدني بالباب التمهيدي، المواد من (٦ إلى ٩)، حيث عالجت تلك المواد تنازع القوانين في مسائل الأهلية والتقدم والإثبات، كما ورد قانون المرافعات بعض المواد الخاصة بحل التنازع في مجال الاختصاص والإجراءات.

أولاً: تنازع القوانين في مسائل الأهلية:

نصت المادة (٦) من القانون المدني على أنه:

(١) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذا الخصوص.

(٢) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

ويبدو من هذا النص، أن القانون المنظم للأهلية يسرى بأثر فوري ومباشر على جميع الأشخاص ليستوى منهم من كان قد بلغ السن ومن لم يبلغ، فمن كان قد بلغ ثمانى عشرة سنة بناء على قانون ١٩٢٥، يعود قاصراً، وبالنسبة لتصرفاته التى قام بإبرامها وهو كامل الأهلية بالنسبة للقانون القديم، وبعد أن عاد قاصراً بالقانون الجديد

تظل صحيحة لا يؤثر فيها الأعمال المباشر والفوري للقانون الجديد، وكذلك إذا صدرت تصرفات من شخص يعتبره القانون ناقص الأهلية بقيت هذه التصرفات باطلة أو قابلة للإبطال حتى ولو أصبح هذا الشخص رشيداً نتيجة تخفيض سن الرشد وفقاً للقانون الجديد، فلو أن قاصراً بلغ عشرين سنة أبرم تصرفاً، كان هذا التصرف قابلاً للإبطال حتى لو صدر قانون جديد بتخفيض سن الرشد إلى أقل من عشرين سنة، فمثل هذا الشخص ولو أنه أصبح رشيداً وعقد التصرف في سن يعتبرها القانون الجديد هي سن الرشد، إلا أن تصرفه نشأ قابلاً للإبطال في ظل القانون القديم، فيظل كذلك، ويستطيع هذا الشخص أن يطلب إبطاله، وهذا تطبيق لفكرة عدم رجعية القانون الجديد.

ثانياً: تنازع القوانين في موضوع التقادم:

تنص المادة (٧) مدني، على أنه:

(١) تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

(٢) على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقته وإنقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

وتنص المادة (٨) على ما يأتي:

(١) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت من قبل ذلك.

(٢) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بإنقضاء هذا الباقي.

والتقادم؛ هو طريقة لاكتساب الملكية وبعض الحقوق العينية كالارتفاق والانتفاع عن طريق حيازتها مدة يحددها القانون، بنية تملكها وبشروط حددها القانون، وهذا هو التقادم المكسب، كما أن التقادم قد يكون - أيضاً - وسيلة لانقضاء الحقوق الشخصية (الالتزامات) وبعض الحقوق العينية كالارتفاق والانتفاع، غذا مضى على استحقاقها أو عدم استعمالها مدة يحددها القانون في كل حالة، وهذا هو التقادم المسقط.

ولما كان التقادم لا يتم إلا بعد مضى مدة من الزمان كان من الجائز أن يصدر قانون جديد يعدل في أحكامه، وهذا التعديل قد ينصب على مدة التقادم فيعدلها طويلاً أو قصراً، أو على شروط التقادم الأخرى فيجيز اكتساب حقوق التقادم أو سقوطها به، في حين أن القانون القديم كان لا يجيز ذلك أو العكس، وقد تكلفت المادتان المذكورتان بحل هذا التنازع، ويمكن استخلاص هذا الحل في الأحكام الآتية:

(١) التقادم الجديد يبدأ سريانه وفق القانون الجديد وينطبق عليه من جميع الوجوه.

(٢) التقادم الذي تمت مدته في ظل القانون القديم يعتبر مكتسباً في ظله، ولا دخل للقانون الجديد به.

(٣) التقادم الذي لم تكتمل مدته غنما جرى العمل بالقانون الجديد، ووفقاً للمادة (٧) من القانون المدني، فإن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل، وبناء على هذا فإنه:

(أ) إذا منع القانون الجديد كسب الشيء، او الحق بالتقادم امتنع بعد ذلك على الحائز إتمام التقادم على سبيل التمسك به، وكذلك إذا منع القانون سقوط حق بالتقادم.

(ب) إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، فإن التقدم لا يتم إلا باستكمال المدة الجديدة محسوباً فيها المدة السابقة على صدوره.

(ج) إذا قرر النص الجديد مدة أقصر للتقادم مما قرره النص القديم، فالأصل أن المدة الجديدة تسري كاملة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو أن المدة القديمة كانت قد بدأت قبل ذلك، ومن ثم يبدو أن الأمر يتوقف على قدر الباقي لاكتمال التقادم الذي بدأ في ظل القانون القديم، فإن كان هذا الباقي أكور من المدة الجديد بأكملها وجب صرف النظر عن المدة التي جرت من التقادم في ظل القانون القديم، وتبدأ مدة جديدة ابتداء من العمل بالقانون الجديد على أساس

المدة القصيرة التي يقررها، أما إذا كان هذا الباقي أقصر من المدة الجديدة فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

ثالثاً: فض النزاع في مجال الإثبات:

تنص المادة (٩) من القانون المدني على أنه: "اسرى في شأن الأدلة التي تُعد مقدماً؛ النصوص المعمول بها في الوقت الذي أُعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيع إعداده"، وهذه المادة تبين حكم تنازع القوانين المنظمة للأدلة التي تُعد مقدماً في الزمان، والدليل الذي يُعد مقدماً هو الدليل الذي يُعده الطرفان وقتا للتصرف لإثباته في حال حدوث نزاع بينها في المستقبل.

والمادة المذكورة تعول على القانون الذي نشأ التصرف في ظله، فتجعله حاكماً له في انعقاده وصحته وإثباته، ولا يجوز للقانون الجديد أن يرجع إلى الوراء ليحكم هذه المسائل وإلا كان ذا أثر رجعي، وهو أمر لا يجوز، ويترتب على خضوع الدليل المُعد مقدماً للقانون الذي أُعد في ظله أو كان واجباً إعداده في ظله ما يلي:

- (١) إذا أنشأ القانون الجديد وسيلة جديدة للإثبات أو ألغى وسيلة كان يستلزمها القانون القديم، فلا يجوز أن يكون له أثر بالنسبة للتصرفات التي انعقدت في ظله لأن القانون القديم هو الذي يحكمها.
- (٢) إذا عدل القانون في نصاب الشهادة، أو الكتابة، فلا يجوز أن يسرى هذا التعديل على إثبات التصرف الذي في ظل القانون القديم، وكذلك الأمر في حالة ما إذا اشتد القانون الجديد في الإثبات فإنه لا

يسرى على التصرف الذي نشأ في ظل قانون قبله، فإذا كان القانون القديم يستلزم الكتابة في إثبات الالتزام الذي تزيد قيمته عن مائة جنية، ثم صدر قانون جديد يستلزم الكتابة في كل تصرف يبلغ عشرين جنية، فإن المبلغ الذي يزيد عن ذلك يظل صالحاً لإثباته بدون الكتابة وفقاً للقانون القديم، وإذا خفف القانون الجديد في ادلة الإثبات فرفع نصاب الشهادة إلى مائة جنية أو خمسمائة جنية كما هو معمول به الآن، بدلاً من مائة، فإن التصرفات التي صدرت في ظل القانون السابق لا تخضع له، وتظل خاضعة للإثبات بالكتابة، وهكذا يبدو منهج المشرع في فض هذا اتلنازع الزماني.

الفصل الثانى

العرف كمصدر للتشريع

يعتبر العرف هو المصدر الثانى للتشريع، ويمكن تعريفه بأنه: اعتياد الناس على سلوك معين من ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية مع اعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم، وأن من يخالفه يتعرض لجزاء يوقع عليه، فالعرف عبارة عن عادات عامة ملزمة تقوم بتنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع.

وعلى هذا فإن الناس إذا درجوا على اتباع عادة (ما) في مسائل معينة، وتكرر هذا السلوك منهم مدة طويلة من الزمان، واضطرد اتباعهم لهذه العادة حتى تترسخ في أذهانهم وتكون لديهم الاعتقاد بضرورة احترامها، فإنه يتولد عن ذلك قاعدة قانونية مصدرها العرف. ولقد كان العرف في المجتمعات البدائية يحتل المرتبة الأولى كمصدر للقانون، لأنه المصدر الذي يلائم تلك المجتمعات نظراً لعدم وجود هيئة تهيمن على شئون المجتمع وتضع لهم القواعد التى تنظم سلوكهم.

غير أنه في الوقت الحاضر، نجد أن العرف قد انحسر سلطانه وأصبح التشريع يحتل المرتبة الأولى بدلاً منه^(١).

ونعالج في تلك الدراسة ما يتصل بالعرف من الموضوعات، وهي أركان العرف، ومزاياه وعيوبه، والفرق بينه وبين العادة الاتفاقية،

(١) د. جمال الدين العاقل - ص ١١٤، د. عبد الرازق حسن فرج - ص ٦١، د. جمال الدين زكى - فقرة ٦٣.

وأساس القوة الملزمة لعرف، ودور العرف في القانون المصرى، على
أن نخصص لكل موضوع مبحثاً:

المبحث الأول

أركان العرف

استبان لنا أن العرف هو اعتياد الناس على اتباع سلوك معين
في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية بحيث يتولد عنه اعتقاد بأنه
ملزم، ولا يسوغ لأحد مخالفته.

ويتبين لنا من هذا التعريف، أن للعرف ركنين: أولهما: الركن
المادى، ويتمثل في اعتياد الناس على سلوك معين، وثانيهما: الركن
المعنوي، ويتمثل في اعتقاد الناس بأن هذه القاعدة التى تولدت عن
العرف قاعدة ينبغى احترامها وأنها ملزمة، ويدر بيان ذلك:
أولاً: اعتياد الناس على السلوك:

يتمثل الركن المادى للعرف؛ في اتباد الناس على سلوك معين
بشأن أمر من أمور حياتهم الاجتماعية بحيث تتولد لديهم عادة نتيجة
اضطراد اتباعهم لهذا السلوك، وهذه العادة تبدأ اختياراً فمن مارسوها
دون أن تفرض من سلطة معينة، كما هو الحال بالنسبة للتشريع، أو
القواعد التى استقر عليها القضاء أو الفقه.

فقد يحدث ان يسلك بعض الأفراد طريقة معينة لتنظيم مسألة
(ما) بوحى من ضمائم وعقولهم، ومراعاة للظروف المحيطة بهم ثم
يتكرر هذا المسلك من غيرهم، مقلدين لمن سبقهم، ثم يفعل غيرهم ما

فعله الذين قبلهم، وهكذا تتولد العادة بينهم وتثبت وترسخ في المجتمع ويضطرد فعلها، وتستقر وينشأ لدى الناس الشعور بضرورة احترامها، ويتطلب الركن المادى للعرف ما يلي:

(١) ثبات الاعتقاد على سلوك معين:

فينبغي أن توجد عادة تأتلف من سلوك معين درج الناس على اتباعه استجابة لحاجة معينة ويتكرر منهم أى السلوك ويستمر فترة طويلة من الزمان، مثل: عادة قيام الزوجة بتأثيث منزل الزوجية في مصر، والعادات التى اتبعها الناس في المأتم والأفراح.

ويجب أن يتوفر في العادة الاختيار والاضطراد منذ القدم، ويقصد بالاختيار أن تنشأ العادة مما يقرره الأفراد لأنفسهم من تصرفات في ضوء الظروف المحيطة بهم، وألا يكون هذا السلوك مفروضاً عليهم من سلطة تجبرهم عليه أو موحى به من جهة معينة^(١)، وينبغي أن يضطرد اتباع الناس للسلوك على وتيرة واحدة حتى تتكون العادة، وتستمر فترة طويلة تستغرقها وتصبح ملزمة.

(٢) أن يكون الاعتقاد عاماً:

ويشترط في العادة ان تكون عامة غير متعلقة بفئة من الناس بل يتبعها أغليبيتهم ولا يشترط أن تكون متبعة في جميع أقاليم الدولة، بل يجوز أن تكون خاصة بإقليم معين، وكفى أن تكون متبعة بين طائفة معينة كأرباب مهنة معينة كالتجار أو الصناع وغيرهم، لأن

(١) د. جمال الدين العاقل - ص ١١٦، د. سليمان مرقس - ص ٢١٣، د. عبد الحى حجازى - فقرة ١٩٧، د. حسن كيرة - فقرة ٧٤.

العرف قد يكون عرفاً محلياً أو طائفيّاً، ويكون معتبراً في كل حالة دون أن يخل هذا بصفة العموم التي يجب توافرها في العادة المكونة له.

(٣) أن يكون الاعتياد في مجال السلوك الاجتماعي:

لا يكفي أن توجد العادة، وإنما ينبغي أن يكون هذه العادة اجتماعية، أي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وبخاصة مجال المعاملات، وعلى ذلك فإن العادة إذا كانت مقتصرة على السلوك الفردي، كالأكل بطريقة معينة، أو التحدث بطريقة خاصة فإنها لا تكون عرفاً لعدم اتصالها بتعامل الأفراد.

(٤) عدم مخالفة العادة للنظام العام:

كما يجب أن تتوافق العادة مع انظام العام والآداب، فإذا خالفت ذلك مثل عادة الأخذ بالثأر المتعارف عليها في بلاد الصعيد، فإنها لا تعد عرفاً رغم قدمها واستقرارها في ضمير المجتمع لمخالفتها للنظام العام والآداب.

ثانياً: الركن المعنوي (الإلزام):

لا يكفي أن يتوافر الركن المادي بشروطه المتقدمة لنشوء العرف، وإنما يجب أن يتوافر أيضاً الركن المعنوي، وهو ما يعبر عنه بركن الإلزام، ويراد به اعتقاد الناس بأن ما ساروا على اتباعه وألفوه قد صار ملزماً لهم، وأن هناك جزاءً مادياً سوف يوقع على كل من يخالفه.

ويلاحظ أن ركن الإلزام يفرق بين العرف، وبين عادات اجتماعية لا تعتبر عرفاً، مثل: عادة تبادل الزيارات أو عادة إقامة الزينات في الأفراح والليالي الملاح، فمثل تلك العادات لا تُعد عرفاً

لكونها غير ملزمة^(١)، ولا يشعر الناس بضرورة فعلها، وإن كان ذلك
الرأى محل اختلاف في البيئات المختلفة.

وجدير بالذكر، أنه ليس من اليسير تحديد الوقت الذي يتوافر
فيه ركن الإلزام، لأن الاعتقاد الذي يتكون لدى الأشخاص أن العادة
أصبحت ملزمة ينشأ تدريجياً، ومن ثم قد تختلف وجهات النظر في
الفقه والقضاء حول تحديد وقت تحقق هذا الإلزام، لكنه يستقر برضا
الناس عنه وتعاملهم به وتطبيق القضاء له.

المبحث الثاني

تفريد العرف عن العادة الاتفاقية

إذا كان العرف هو اعتياد الناس على نوع معين من السلوك
درجوا على اتباعه ومنأً مع الاعتقاد بأنه ملزم، وأن مخالفته تستتبع
توقيع جزاء مادي، فإن العادة الاتفاقية تعرف بأنها الاعتياد على إتيان
نوع معين من السلوك دون الشعور بأنه ملزم^(٢).

فإذا كان من شروط وجود العرف توافر ركنين مادي ومعنوي،
فإنه في العادة الاتفاقية يكفي قيام الركن المادي للعرف، دون الركن
المعنوي، وهذا ما يميز العادة الاتفاقية عن العرف.

(١) د. جمال الدين العاقل - ص ١١٧.

(٢) د. حسن كيرة - ص ١٥٣، د. أحمد سلامة - ص ١٠٩، د. توفيق فرج - ص ١٣٤، د.
عبد الحى حجازى - فقرة ٢٠٥، د. عبد المنعم فرج الصدة - فقرة ١٠١، د. جمال الدين
زكى - ص ١٢١، د. شمس الدين الوكيل - فقرة ١١١، د. جميل الشرقاوى - ص ١٤٠،
د. عبد الرازق حسن فرج - ص ٦٤.

ومن العادات ما يعرف بالعادة الاجتماعية، كتقديم الهدايا في المناسبات وتبادل الزيارات والمشاركة في السراء، والمشاطرة في الضراء، وما يعتاده الناس في ملابسهم وطريقة أكلهم، وغير ذلك من العادات غير الملزمة، والتي لا تعتبر في حد ذاتها قواعد قانونية.

ومن امثلة تلك العادات، ما جرت به العادة على أن اتباع الفاكهة على أساس المائة حبة، واختلاف العادة من جهة إلى أخرى، ففي بعض الجهات تباع المائة على أنها مائة، وفي البعض الآخر على أساس أنها مائة او عشرة أو عشرون أو ثلاثون، وكذلك الأمر فيما جرى به العرف من قيام رواد بعض الأماكن العامة كال فنادق والطاعم والمقاهي، بدفع نسبة معينة من قيمة الحساب على سبيل (الوهبة)، البقشيش للقائمين بالخدمة في هذه المحلات، وكانت هذه العادة أن تتحول إلى عرف ملزم.

والعادة الاتفاقية لا تلزم إلا بالاتفاق الصريح عليها فيما بينهم، أو يستبين من ظروف التعاقد إن إرادتهم قد اتجهت إلى الأخذ بها ضمناً، وذلك كأن يعلم كل منهم بوجودها، ولا يتفقان على استبعادها.

وقد نص المشرع المصري على حكم العادة الاتفاقية وأحال عليها في بعض الأحوال، ومن ذلك ما تقضى به المادة (٤٣٢) من التقنين المدني حين قالت: "ملحقات الشيء المبيع التي يلزم تسليمها معه للمشتري، تتحدد بعف الجهة"، والمراد به هنا هو العادة، فهذه الإحالة التشريعية تعتبر حكماً مكملاً لإرادة الطرفين، وبالتالي فإن

الحكم يجب اتباعه إذا لم يتفق الأطراف على استبعاده، أما بالنسبة إلى العادة الاتفاقية التي لم ترد بشأنها إحالة تشريعية، فإنها لا تنطبق إلا إذا اتجهت إلى تطبيقها الإرادة الصحيحة أو الضمنية للأفراد^(١).

آثار التفرقة بين العرف والعادة الاتفاقية:

ويترتب على التفرقة القائمة بين العرف والعادة الاتفاقية، أنه إذا توافرت في العرف الشروط المذكورة، نشأت عنه قاعدة قانونية ملزمة، وهو على هذا الأساس يطبق على الأشخاص سواء قصدوا تطبيق حكمه أم لا، ما لم يكن متضمناً لقاعدة مقررّة، أما العادة فإنها ليست قانوناً، وينبغي على هذا أنها لا تلزم الأفراد إلا إذا اتفقوا على اتباع حكمها، ويترتب على افتقاد ركن الإلزام في العادة الاتفاقية نتائج يمكن إجمالها فيما يلي:

أولاً: يعذر الجاهل بالعادة، ولا يعذر بإدعاء الجهل بالعرف:

إن العرف قانون، ولهذا فإنه لا يقبل من أحد أن يعذر بجهله له، أما العادة الاتفاقية فإنها ليست كذلك، ولهذا يعذر الأفراد في إدعاء الجهل بها إلا إذا اتفقوا عليها صراحة أو ضمناً، وهذا ما يؤكد ضرورة علم كل منهما بأحكامها، فهي لا تطبق إذا جهل المتعاقدان أو أحدهما

(١) د. حسن كيرة - ص ١٥٣، د. منصور مصطفى منصور - ص ١٣٧، د. عبد الرزاق فرج الصدة - ص ١٣٠، د. توفيق فرج - ص ١٣٤ وما بعدها، د. عبد الرزاق فرج - ص ٦٥ وما بعدها، د. جمال الدين العاقل، ص ١١٩ وما بعدها.

وجودها، ففي هذه الحالة تكون إرادتهما قد إنصرفت عن التقييد بأحكامها.

ثانياً: يفترض العلم بالعرف، ولا يفترض بالعادة:

ويترتب على كون العرف قانوناً؛ افتراض العلم به خاصة من جهة القاضى، ومن ثم فإن عليه أن يطبقه من تلقاء نفسه دون أن يطلب أحد منه ذلك، بل ولو لم يتمسك به الخصوم بينما العادة الاتفاقية لا يفترض العلم بها حتى يطبقها من تلقاء نفسه، بل يجب على كل صاحب مصلحة أن يتمسك بها ويطالب بتطبيقها.

ثالثاً: لا يلزم الإثبات في العرف، ويلزم في العادة:

العرف قانون؛ والقانون لا يحتاج إلى إثبات، ومن ثم فالعرف لا يحتاج إلى إثبات، ومن المفروض أن يعلم القاضى به، أما العادة الاتفاقية فلا تعتبر قانوناً، وإنما هي شرط في العقد، والشرط يقتضى ممن يتمسك به أن يثبت وجوده، أو أن يكشف عن الظروف التى يستفاد منها أن إرادة الخصوم قد انصرفت صراحة أو ضمناً إلى العمل بها، والتقييد بأحكامها.

رابعاً: تطبيق العرف يخضع لرقابة القضاء، والعادة لا تخضع:

ولما كان العرف قانوناً فإن القاضى عند تطبيقه يخضع لرقابة محكمة النقض^(١)، أما بالنسبة للعادة الاتفاقية فهي لا تخرج عن كونها واقعة من الوقائع التى يترك أمر تقديرها لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض، وإن كانت رقابة محكمة النقض على تطبيق العرف محل خلاف، ولهذا فقد ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى أن رقابة محكمة النقض تشمل ما يتعلق بسلامة تطبيق اقاضى للعرف على النزاع المعروض أمامه، وما يتعلق أيضاً بإثبات وجوده^(٢).

المبحث الثالث

أساس الإلزام في العرف

يعتبر العرف قاعدة قانونية تنشأ عن سلوك الأفراد أو اعتيادهم على اتباعه حتى يصبح ملزماً، أى أنها قاعد قانونية تنشأ على غير المنوال العادى الذى تصاغ فيه القاعدة القانونية وتتكون، أو أنها عادة قانونية تتولد من غير مكان الولادة الطبيعى للقانون، وذلك من شأنه أن يثير التساؤل حول الأساس الذى تستمد القاعدة العرفية منه قوتها الملزمة، لقد اختلف الفقهاء في هذا الشأن، وانقسموا إلى ثلاثة أقوال: قول يرى أن القوة الملزمة للعرف ترجع إلى السلطة العامة، ويرى

(١) د. منصور مصطفى منصور - ص ١٣٩، .

(٢) حسن كيرة - ص ١٥٧، د. عبد المنعم فرج الصدة - ص ١٣٤ وما بعدها، د. شمس الدين الوكيل - ص ١٨٨، د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٦٨.

آخرون: أن القوة الملزمة للعرف ترجع إلى أحكام القضاء، وذهب قول ثالث: إلى أن أساس القوة الملزمة للعرف هو رضا المجتمع، وينبغي بيان ذلك:

أولاً: الإلزام من السلطة العامة:

يرى أصحاب هذا الرأي: أن أساس القوة الملزمة للعرف تكمل في الإرادة المفترضة للسلطة العامة، لأن هذه السلطة عندما تكفل احترام العرف إنما تقره وترضى بوجوده رضا مفترضاً ولما كان التشريع مؤسساً على الإرادة الواضحة الصريحة لتلك السلطة العامة فإن العرف يرجع في أصله إلى الإرادة المفترضة لها^(١).

مناقشة هذا الرأي:

ويؤخذ على هذا الرأي، أنه قد ثبت تاريخياً أن العرف أسبق في وجوده من التشريع حيث كان هو المصدر الأول للقانون في المجتمعات القديمة، وكانت قواعده ملزمة قبل نشوء السلطة العامة بمعناها الحديث، فكيف يمكن القول: بأن العرف ترجع قوته الملزمة إلى رضا هذه السلطة، وهو موجود قبل وجودها؟^(٢).

(١) د. عبد الرازق فرج - ص ٦٩، د. جمال الدين العاقل، ص ١٢٥.

(٢) د. أحمد سلامة - ص ١١٦ وما بعدها، د. منصور مصطفى منصور - ص ١٥٢، د. جمال الدين العاقل - السابق، د. عبد الرازق فرج - ص ٧١، د. عبد المنعم فرج الصدة - ص ١٣٥، د. حسن كيرة - فقرة ٧٦، د. سليمان مرقس، ص ٢١٦.

ثانياً: إقرار القضاء له:

يرى أنصار هذا الرأي أن القوة الملزمة للعرف يرجع أصلها إلى إقرار القضاء له، فالعرف لا يكون ملزماً إلا إذا طبقه القضاء، كما أن تدخل القضاء أمر لا بد منه لنشوء العرف، وهو قبل تطبيق القضاء له لا يكون سوى مجرد عادة^(١).

مناقشة هذا الرأي:

ويؤخذ على هذا الرأي أن الأفراد في المجتمعات الحديثة لا يصنعون بأنفسهم القوانين وإنما يتنازلون عن هذا العمل إلى هيئة خاصة هي السلطة التشريعية، وذلك مردود على هذا بأن تنازل الأفراد عن سلطة سن القوانين إلى الهيئة المذكورة لا يعنى أن يفقد المجتمع حقه في هذا الشأن، لأن تحويل السلطة التشريعية سن التشريعات نيابة عن المجتمع لا يترتب عليه سلب الأصل هذا الحق، ومن ثم فإنه يحق للمجتمع اختلاق قواعد عرفية من العادات التي يتبعها الناس فترة طويلة من الزمان.

رأينا في الموضوع:

ونحن نرى أن أساس الإلزام في العرف يكمن في ألفة الناس لما عتادوا عليه، لأن ذلك الاعتقاد - في حد ذاته - مأمون العقاب بالنسبة لهم، حيث كرروا فعله مراراً، وفي كل مرة يقفون على

(١) د. عبد الرزاق فرج - ص ٧١، د. جمال الدين العاقل السابق.

تفصيلاته بدءاً وانتهاءً، ومن شأن الإنسان أنه إذا ألف شيئاً أحب فعله، وارتاح لتكراره، وليس من الطبيعي أن يترك الإنسان ما يحبه ويرتاح لتكراره ويلعم نهايته ونتيجته بأمر جديد عليه، ومجهول له، ولم يعرف خباياه، وقد قيل - أن الإنسان أسير عاداته - ومن ثم يكون أساس ذلك الإلزام كامن فيما يمكن أن يسمى بالميل الفطري للمألوف في الحياة فإن ذلك الميل هو الذي يدفعه لتكرار الفعل، ومن ثم تولد الإحساس بالحرص عليه.

المبحث الرابع

مزايا العرف وعيوبه

والعرف شأنه شأن أى عمل دنيوي تتقابل فيه المصالح ومالفاسد، وتوجد فيه المميزات والعيوب، وليس معنى وجود بعض العيوب فيه أنه غير سائغ أو لا يجوز العمل به، لأن تلك العيوب إذا ما قوبلت بالمميزات الموجودة فيه فإنها تبدو ضئيلة لا ترقى لحجبه عن العمل، ونشير إلى مميزات العرف وعيوبه.

أولاً: مميزات العرف:

وللعرف مميزات يمكن إجمالها فيما يلي:

(١) أنه يسائر إرادة المجتمع:

فمن المعروف ان العرف يعبر عن ضمير المجتمع، ويسائر إرادتها، ويتفق مع الحاجات العملية، حيث يستند إلى ما جرى عليه

الناس في حياتهم، وهذه الميزة تبدو واضحة عند المقابلة بالتشريع الذي يغلب فيه كثيراً أن يكون معبراً عن إرادة الهيئة الحاكمة التي يمكن أن تكون متفقة مع إرادة المجتمع أو مختلفة معه.

(٢) أنه يساير حاجات المجتمع:

والعرف يساير حاجات المجتمع، وذلك ميزة كبرى، لأنه يتغير بتغير الحاجات فيها، ويكون متلازماً معها، يتطور بتطورها، ويزول بزوالها، ولهذا فإنه يستجيب للظروف الاجتماعية المتغيرة، ويتطور بتطور الحياة، أما التشريع فإنه يقتضى تدخل المجتمع أو الهيئة التشريعية لتعديله.

(٣) أنه يكمل نقص التشريع:

ومما يمتاز به العرف أنه يكمل نقص التشريع، حيث لا يستطيع أن يحيط باحتياجات المجتمع، ومهما بذل المشرع من جهد، فإن التشريع يأتي قاصراً عن الإحاطة بكل مطلوبات الحياة، ومن هنا يجيء دور العرف ليكمل ما في التشريع من قصور، أضف إلى ذلك أن هناك بعض المسائل لا يمكن أن ينظمها تشريع واحد لتشعبها واختلافها من مكان إلى آخر، أو من فئة إلى أخرى، كما يعاون العرف في تنظيم الحياة الاجتماعية.

ثانياً: عيوب العرف:

ورغم هذه المزايا التي لا يمكن إنكارها، فإن له عيوباً تؤخذ عليه، لكنها - كما قلنا - لا تؤثر على أهمية العمل به، أو

مشروعيته، لأنها قليلة بجانب مميزاته، وهذه المؤاخذات أو العيوب تتمثل فيما يلي:

(١) عدم انضباط العرف:

مما يؤخذ على العرف ويعد عيباً فيه أنه ليس من السهل تحديد قواعده والتثبت منها أو تحديد وقت ظهورها، أو الوقت الذي تصبح فيه واجبة التطبيق، مما قد يؤدي إلى كثير من المنازعات حوله عند العمل به، ويكون النزاع حاصلاً حول مضمون القواعد العرفية.

(٢) لا يسعف العرف في علاج الظروف الطارئة:

ومن عيوب العرف أنه يتكون ببطء، ويستغرق وقتاً طويلاً حتى يستقر معنى الإلزام في قلوب الناس واعتقادهم، ومن ثم فإنه لا يكون قادراً على تقديم الحلول السريعة في الظروف التي تقتضى ذلك بطرء غير متوقع، ومن ثم لا يكون ملائماً للحاجات المتلاحقة، ولا للظروف الحادثة.

(٣) يتنافى العرف مع الوحدة القانونية:

من المعلوم أن الوحدة القانونية مطلوبة لجميع أبناء الدولة الواحد حول مركز قانوني متساو، ومن ثم كانت تلك الوحدة القانونية هي الأداة العملية لتطبيق مبدأ المساواة بين الناس، والعرف لا يلائم هذا المعنى، لأنه يختلف من جهة إلى أخرى مما يؤدي إلى تعدد القواعد العرفية في الدولة الواحدة، وبالتالي لا تتحقق الوحدة القانونية بها، ومن ثم تفتقد المساواة.

دور العرف في الحياة المعاصرة:

وبالرغم من ان دور العرف قد بدأ في الإنحسار التدريجي في المجتمعات الحديثة لما يحققه التشريع من مزايا في إيراد القواعد القانونية مكتوبة، على نحو يسهل التعرف عليها، وتحديد مضمونها بما يحق الاستقرار والنظام في المجتمع، إلا انه مصدر لا غنى عنه، فهو يكمل ما في التشريع من نقص، ويعاونه في تنظيم الحياة الاجتماعية، حيث لا يتصور أن يحيط التنظيم بكل شئون الحياة، ولهذا جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني ما يلي: "فالعرف هو المصدر الشعبي الأصل الذي يتصل إتصلاً مباشراً بالمجتمع، ويعتبر وسيلتها الفطرية لتنظيم تفاصيل المعاملات ومقومات المعايير التي يعجز التشريع عن تناولها بسبب تشعبها واستعصائها على النص، ولذلك فقد ظل هذا المصدر، وسيظل إلى جانب التشريع مصدراً تكميلياً خصباً لا يقف إنتاجه عند حدود المعاملات التجارية، بل يتناول المعاملات التي تسري في شأنها قواعد القانون المدني، وسائر فروع القانون الخاص والعام على السواء^(١).

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - ج ١ - ص ١٨٨.

المبحث الخامس

دور العرف في القانون المصري

يمكن القول: أن للعرف دوراً في القانون المصري من جهة أنه يكمل التشريع الوضعي عند نقصه، ويعاونه في حالات يشير إليها صراحة، وقد يقضى التشريع بتقديمه عليه في بعض القواعد المكلمة، وقد يسمح له - نادراً - بالتقدم عليه في بعض القواعد الآمرة، كما أن للعرف دوراً في فروع القانون المختلفة، ونبين هاتين الحالتين كما يلي:

أولاً: دور العرف في التشريع المصري:

إن هذا الدور بالاستقراء يتمثل في إكمال التشريع ومعاونته والسبق عليه في بعض القواعد المكلمة غالباً، أو الآمرة نادراً، وذلك كما يلي:

(١) العرف يكمل التشريع:

وهذه هي الوظيفة العامة التي يقوم بها العرف والتي أشارت إليها المادة الأولى من القانون المدني المصري، فهو يكمل التشريع، وإليه يجب أن يرجع القاضى المصرى، إذا لم يجد نصاً تشريعياً، وهو يقوم بتلك الوظيفة في كل فروع القانون الخاص، والقانون العام، فيما عدا القانون الجنائى، لأنه محكوم بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، التي تقضى بعدم جواز العقاب على فعل إلا إذا كان مستنداً إلى نص تشريعى يقرره، وبالتالي فإن العرف لا يعتد به في تقدير الجرائم

والعقوبات، وفيما عد ذلك يستطيع العرف أن ينشئ القواعد الآمرة، والمكملة على السواء.

(٢) العرف المعاين للتشريع:

قد ينظم المشرع موضوعاً معيناً، ولكنه يحيل إلى العرف أو إلى العادات للاستعانة بهما في أعمال بعض المعايير التي يضعها، أو للاستهداء بهما في تفسير قصد المتعاقدين، أو لبيان حدود فكرة معينة، يفضل ترك تحديدها للعرف، وبهذا يدعو التشريع العرف إلى معاونته صراحة.

ومن ذلك أن تحديد ملحقات المبيع - وفقاً لما تنص عليه المادة (٤٣٢) مدني - يخضع للعرف.

ومن ذلك نص المادة (٤٤٨) مدني التي تقضى بأنه: " لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه"، وهكذا جعل المشرع العرف محدداً للعيب الذي يضمنه.

ومن ذلك المادة (١٠١٩) مدني، التي تقول: " تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى عليه عرف الجهة.

(٣) العرف المقدم على القواعد المكملة:

وفي كثير من الحالات أوجب القانون الرجوع إلى العرف أو العادات، قبل الرجوع إلى أحكام التشريع، حيث ينص في كثير من الأحوال على أن القواعد التي جاء بها لا تطبق إذا وجد اتفاق

أو عرف يقضى بما يخالفها، وعندئذ يسبق العرف تطبيق القاعدة التشريعية.

ومن أمثلة ذلك: ما نصت عليه المادة (٤٥٦) مدني بقولها: "يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك"، ومن ذلك: نص المادة (٤٦٢) التي تقضى بأن: "نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك، ومن ثم فقد قضى المشرع في تلك الحالات وما يماثلها بتقديم العرف عليه في تلك القواعد المكملة.

(٤) العرف في مجال القواعد الآمرة:

وأخيراً فقد أجاز القانون أن يخرج العرف عليه في بعض القواعد القانونية الآمرة، وذلك في حالات استثنائية نادرة منها:

نص المادة (٢٣٢) مدني، والتي تقضى بأنه: "لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموعة الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال، وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية"، فالنص قد جاء بقاعدة أمرة تمنع الفوائد المركبة، كما جاء بقاعدة أمرة أخرى مفادها عدم جواز زيادة ما يتقاضاه الدائن من مجموع الفوائد على رأس المال، ثم أجاز الخروج عليهما إذا سمح العرف التجاري بذلك، وجرى على خلافهما.

ثانياً: دور العرف في مختلف فروع القانون:

كما أن للعرف دوراً بارزاً في مختلف فروع القانون العام
والخاص كما يلي بيانه:

(١) في القانون المدني:

هناك دور كبير للعرف في القانون المدني، وذلك إضافة إلى ما سبق بيانه من حالات، ومن ذلك، القاعدة العرفية التي تضع قرينة على اعتبار أثاث المنزل ملكاً للزوجة المسلمة، وذلك نظراً لما جرى به العرف في مصر من قيام الزوجة بتجهيز أثاث المنزل من مال المهر، وهو ملك لها، أو من مال والديها، أو من مالها.

ولكن يجوز إثبات عكس تلك القرينة بأن يثبت الزوج أو من له مصلحة في ذلك أن الأثاث ملك له لا للزوجة، كما يجرى العرف في مصر على احتفاظ الزوجة بلقب أسرتها، خلافاً لما جرى عليه العرف في أوروبا وأمريكا، بأن تسمى الزوجة بلقب زوجها.

وقد قضت إحدى المحاكم بأن العرف قد جرى في بعض جهات الوجه القبلي على وجوب رد الهدايا التي تقدم في بعض المناسبات، كالأفراح أو المآتم في مناسبة مماثلة لتلك التي قدمت فيها، وحكمت على هذا الأساس بأن للمهدى أن يلزم من أهده إذا وجد في نفس المناسبة مثل هديته^(١).

(٢) في القانون التجاري:

(١) محكمة ملوى الجزئية في ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤١، المحاماة، س ٢٢ - ص ٢٨.

من المعروف أن قواعد القانون التجاري تتقاصر عن تنظيم جميع العلاقات التجارية، وذلك لكثرة هذه العلاقات وتنوعها وتجدها وتطورها، ولهذا كان حظ العرف في المسائل التجارية أكبر منه في غيرها من المسائل المدنية.

ومن هذه القواعد تحديد أجر السمسار بمقدار (٢.٥) بالمائة، وافترض التضامن بين المدينين، وما يجرى به العرف من فرض فائدة على متجمد الفائدة، واقتضاء الفوائد التأخيرية بمجرد التأخير لا من وقت المطالبة الرسمية بسعر اعلى من سعر الفائدة التأخيرية وهو (٥) بالمائة، وإن كان ذلك يعتبر من قبيل الربا المحرم شرعاً، ومنها قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفع على حامل الورقة التجارية.

(٣) في القانون الدولي الخاص:

كثير من قواعد القانون الدولي الخاص نشأت نشأة عرفية، قبل ان تعتمد تشريعاً بنصوص خاصة، ومن تلك القواعد، قاعدة ان شكل العقد يخضع لقانون البلد الذي أبرم فيه، وقاعدة خضوع الميراث في المنقول لقانون موطن المتوفى، وقاعد خضوع المالك من حيث الحقوق العينية التي ترد عليه لقانون موقعه.

والعرف قد يكون داخلياً أو دولياً، فإذا لم يجد القاضى نصاً في التشريع، فإن عليه أن يرجع إلى العرف الداخلى، فإذا لم يجد فالى العرف الدولي المستقر في كثير من الدول، والذي يشهد به ضاؤها أو القضاء الدولي، وفي هذا نصت المادة (٢٤) مدني على أنه: "تتبع

فيما لم يرد نص بشأنه في المواد السابقة من أحوال تتنازع القوانين، مبادئ القانون الدولي الخاص".

(٤) في القانون الدستوري:

أما عن مجال العرف في القانون الدستوري، فإنه نظراً لأن قانوننا الدستوري مكتوب على خلاف الحال في إنجلترا مثلاً، حيث يتكون القانون الدستوري هناك تكويناً عرفياً، فإن دور العرف الذي يلعبه عندنا في القانون الدستوري ضئيل جداً، ومع ذلك فإنه يمكن أن يمثل لخاصة بما جرى عليه العرف الدستوري من إعطاء السلطة التنفيذية حق إصدار لوائح الأمن أو البوليس.

كما أن الدستور يشير في بعض نصوصه إلى العرف ومن ذلم ما كانت تقضى به المادة (٤٣) من دستور سنة ١٩٥٦ بقولها: "تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية في مصر، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب، وقد كان هذا النص تكراراً للنص الذي كان وارداً في المادة (١٣) من دستور سنة ١٩٢٣، ولم يرد نظير له في المادة (٤٦) من الدستور الحالي حيث تنص هذه المدة على أنه: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".

(٥) في القانون الإداري:

يعتبر العرف في القانون الإدارى مصدراً رسمياً يجيء بعد التشريع في المرتبة، ويقصد به في مجال هذا القانون: ما درجت عليه جهات الإدارة في علاقات بعضها ببعض، أو بالأفراد واضطراد سيرها عليه.

وقد أقر القضاء الإدارى المصرى كمصدر من مصادر القانون الإدارى يكمل التشريع فقضت محكمة القضاء الإدارى، بأن العرف الإدارى الذى استقر عليه العمل واضطرد هو بمثابة القاعدة التنظيمية المقررة بحيث تعتبر مخالفة الجهة الإدارية له، مخالفة للنظام المتبع مما تجوز المؤاخذة عليه، ذلك أن اامخالفة القانونية ليست مقصورة على مخالفة نص في قانون أو لائحة، بل هي تشمل كل قاعدة جرت عليها الإدارة واتخذتها منهجاً لها^(١).

(٦) في القانون الدولى العام:

أما في مجال القانون الدولى فلا يزال الشرط الأكبر من قواعده عرفياً، ويتكون العرف في مجاله من اضطرد سير الدول في عقاتها المتبادلة على سلوك معين، ويشترط في هذا العرف ان يكون عاماً، أى تسير عليه معظم الدول الأعضاء في الأسرة الدولية، وممت أصبح العرف الدولى عاماً على هذا النحو أصبح ملزماً لدول جميعاً حتى تلك التى لم تساهم في خلقه وتكوينه، فالدول حديثة العهد بالانضمام

(١) محكمة القضاء الإدارى في ١٩٥٠/٥/٤، المحاماة - ص ٣١ - رقم ٧٢ - ص ٢٣٥،
وراجع: د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ٢١٥ وما بعدها.

للسرة الدولية تلتزم بمراعاة العرف الدولي المستقر، كما تلتزم الدول باحترام القواعد الخاصة بشئون البحرية، حتى ولو لم يكن لها واطئ وقدت تكوين القواعد العرفية.

ويرجع في استخلاص القواعد العرفية الدولية، إلى كل ما يمكن أن يستنتج منه سير الدول فعلاً على مقتضاها والتزامها بها كقاعدة قانونية، فهي تثبت من استقراء الحوادث التاريخية، ومن الوثائق الرسمية، ومن تعليمات الدول لممثليها السياسيين، ومن احكام المحاكم الدولية والداخلية، ومن دراسات فقهاء القانون الدولي العام^(١).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٢١٨ وما بعدها.

الفصل الثالث

مبادئ الشريعة الإسلامية

يعتبر الدين هو المصدر الرسمي والأصيل من مصادر القانون في نطاق الأحوال الشخصية يأتي بعد التشريع في المرتبة، وهو هنا بمثابة التوضيح لما انتهى إليه التشريع، لأن التشريع مأخوذ منه مباشرة، لأن كما مل يتعلق بنظام الأسرة يطبق بشأنه القواعد الدينية سواء أكان الأمر متعلقاً بالمسلمين، فالدين مصدر رسمي أصيل في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين، وتطبق في هذا الشأن الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية كما تطبق على غير المسلمين، إذا لم تتوافر شروط تطبيق شريعتهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية.

ولما كانت مبادئ الشريعة الإسلامية قد أصبحت منذ صدور القانون المدني المصري الحالى، مصدراً رسمياً احتياطياً يأتي بعد التشريع في قانون العمل وبعد التشريع والعرف في غير مسائل الأحوال الشخصية، أى (العاملات المالية)، كما أنها تعتبر - أيضاً - مصدراً تاريخياً لبعض أحكام القانون المصري، فإنه يتعين الإشارة إلى ذلك:

أولاً: الشريعة الإسلامية مصدر رسمي للقانون:

تعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً احتياطياً للقانون، وفي هذا الخصوص تنص المادة الأولى من التقنين المدني المصري على أنه:

(١) "تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها.

(٢) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حك مالمقاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

ويبدو من هذا النص أن مبادئ الشريعة الإسلامية قد أصبحت مصدراً رسمياً للقانون، يأتى في المرتبة الثالثة بعج التشريع والعرف، وتسري مبادئ الشريعة في الخصوص على أساس الأحكام المقررة فيها للمعاملات المالية، وذلك عند عدم وجود نص في القانون، وعند عدم وجود العرف، وتطبق على المسلمين، وعلى غير المسلمين في جميع المسائل إلا ما تعلق منها بالأحوال الشخصية حيث يطبق الدين باعتباره مصدراً رسمياً على النحو الذي سلف بيانه، كما تعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر التالى للتشريع في قانون العمل، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (١٠٢) من القانون (١٣٧) لسنة ١٩٨١ بقولها: "تطبق هيئة التحكيم التشريعات المعمول بها ولها أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة"، فقد ورد النص على الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة"، فقد ورد النص على الشريعة الإسلامية للرجوع إليها بعد التشريعات المعمول بها.

المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية:

ويقصد بمبادئ الشريعة الإسلامية، المبادئ العامة في المذاهب المختلفة، دون التقيد بمذهب معين، ولهذا فإنه يتعين على القاضى

عند الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية أن يراعى الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي، وذلك للتنسيق فيما بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته، فلا يجوز الأخذ برأى في الفقه الإسلامي، يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ، وذلك حتى لا يفقد التشريع تجانسه وإنسجامه، وإنما يتعين الأخذ بالرأى الذي ينسجم مع تلك المبادئ، لأنه هو الذي يبدو أن التشريع قد تبناه، ورأى فيه الملاءمة لحكم الواقع التي يريد تنظيمها^(١).

ثانياً: مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر لقانون:

تعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً ضرورياً للقانون المصري في أحكام كثيرة حيث اخذ عنها كثيراً من المبادئ والنظريات، ومن ذلك الأحكام الخاصة بالأهلية، وبتصرف المريض مرض الموت، والشفعة والهبة، والغبن في بيع مال القاصر، وخيار الرؤية، وتبعة الهلاك في المبيع، وإيجار الأراضي الزراعية، وهلاك الزرع في العين المؤجرة، وانقضاء الإيجار والحكر، وأحكام العلو والسفل، والحائط المشترك، ومبدأ عدم إيلولة التركة إلى الورثة إلا بعد سداد الديون، ونظرية التعسف في استعمال الحق، وحالة الدين، ونظرية الظروف الطارئة، وبحصول الإبراء بإرادة الدائن وحده.

(١) د. السنهوري - الوسيط - ج ١ - ص ٤٩.

كما أخذ المشرع النصوص المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، ومنها القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠م والقوانين السابقة عليه، وهي القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٥، والقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٩م، كما أخذ القانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٤٣م، في شأن المواريث، والقانون رقم (١٨٠) لسنة ١٩٥٢م، والقانون رقم (١١٩) لسنة ١٩٥٢م، الخاصة بالولاية على المال، ومع مراعاة أن القانون المدني وكافة القوانين التي تخضع للمبادئ التشريعية العامة لا تخرج في تنظيمها وبيان أحكامها عن مبادئ الشريعة الإسلامية.

الفصل الرابع
مبادئ القانون الطبيعي
وقواعد العدالة

يقصد بمبادئ القانون الطبيعي، ما اتفقت عليه العقول البشرية واستحسنته في مجال العلاقات الاجتماعية، حين يراد إقامة العدل فيها بعيداً عن النص، أو ما يعتبر مثلاً يهتدى به المشرع الوضعي حتى يقترب من حد الكمال في إقامة العدل بين الناس^(١).

وأما العدالة: فهي الشعور الفطري الكامن في النفس، والمستكن في الضمير بإعطاء كل ذي حق حقه، أو هو الإحساس الفطري بالعدالة عندما يتم وضع الإنسان العادي في مكان الحكم بين اثنين لإعطاء كل ذي حق حقه^(٢)، أو هي الشعور الذي يختلف بحساب البلاد والشخاص دون أن يتخذ فكرة ثابتة ومحددة، في مجال العدل، أو ما يؤخذ في الاعتبار من الظروف الخاصة عند تطبيق فكرة الحق على واقع الحياة العملية، أو هي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم، ويوحى به الضمير المستنير بهدف إيتاء كل ذي حق حقه^(٣).

ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد اعدالة على هذا النحو تعتبر المصدر الرسمي الأخير من مصادر القانون المصري التي ورد النص عليها في المادة (٢/١) من القانون المدني حين قالت: "إذا لم يوجد

(١) د. جمال الدين زكي - ص ١٣٦، د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٣٤٥، د. عبد المنعم

فرج الصدة - ص ١٤٩، د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٨٥.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق.

(٣) د. منصور مصطفى منصور - ص ١٥٩، د. جميل الشرقاوى - فقرة ٢٣، د. جمال

الدين زكى - ص ١٣٧، د. عبد المنعم الصدة - ص ١١٤.

نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى القانون الطبيعى وقواعد اللغة.

مداخل للاجتهاد أمام القضاء :

لعل من أهم الفوائد المستفادة من إحالة المشرع على هذه المبادئ، أنها تشجع القاضى على المضى في حكمه، دون تنكب سبيل النكول عن القضاء حينما لا يجد للنزاع المعروض أمامه حكماً في التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية حيث تلزمه تلك المبادئ بأن يجتهد برأيه ولا يمل من الوصول إلى الحكم العادل، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون المجنى إلى هذا المعنى حين قالت: "وإذا كانت عبارة التقنيات الحديثة تفضل هاتين العبارتين (مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة) من بعض الوجوه بسبب ما يؤخذ عليها عادة من الإبهام، إلا ان الواقع يفيد أن هذه العبارات جميعاً لا ترد القاضى عن المضى في حكمه، بل تلزمه أن يجتهد برأيه حتى يلج سبيل النكول عن القضاء، وهي تحثه في اجتهاده هذا أن يصدر عن اعتبارات موضوعية عامة، لا عن تفكير ذاتى خاص، فتحيله إلى مبادئ او قواعد كلية تنسبها تارة إلى القانون الطبيعى،

وتارة إلى قانون الدولة، أو إلى القانون بوجه عام دون نعت أو تخصيص^(١).

وقد طبق القضاء المصرى تلك المبادئ في أحوال كثيرة، وجنى من ورائها نتائج طيبة في مجال العدالة وحفظ حقوق الناس، والحكم بينهم بالحق، ومن ذلك: الأحكام التى قررها بشأن الملكية الأدبية والفنية والصناعية، كحماية حقوق المؤلفين حتى قبل أن يصدر القانون رقم (٣٥٤) لسنة ١٩٥٤م، فهو استناداً إلى مبادئ العدالة ألزم من يعتدى على هذه الحقوق بأن يعرض أصحابها عما يلحقهم من ضرر بسبب الاعتداء عليها، وكذلك ما قرره المشرع بخصوص نظرية التعسف في استعمال الحقوق حيث قررى أن من يتعسف في استعمال حقه يكون مرتكباً لخطأ تقصيري يجعله مسئولاً عما يصيب الغير من ضرر بسببه.

وكذلك ما قرره المشرع بشأن نظرية تحمل التبعة، ومؤداها أن يتحمل صاحب الآلات أو المسئول عنها تبعة ما تحدثه من أضرار للغير، حتى ولو لم يثبت خطأ في جانبه، بناء على قاعدة (الغرم بالغنم) المأخوذة من الفقه الإسلامى، وكذلك على خلاف ما هو مقرر من قواعد المسئولية التقصيرية من ضرورة توافر الخطأ في جانب الشخص حتى يكون مسئولاً عن الضرر، ومبدأ اعتبار الجنين موجود

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية - ج ١ - ص ١٨٨.

في كل ما له فيه مصلحة، وسقوط الحقوق الشخصية بالتقادم، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنظرية الظروف الطارئة التي تقضى بأنه إذا أصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين بسبب حادث طارئ لم يكن في الوسع توقعه، وجب رد هذا الالتزام المرهق إلى الحد المعقول^(١).

حدود تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:

بيد أن تجب مراعاة أن القاضى لا يمكنه تحت ستار الأخذ بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، أن يخرج على النصوص التشريعية والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون مهما بدا له أن تلك النصوص أو هذه المبادئ غير متفقة مع مبادئ القانون الطبيعي أو العدالة، لأنه مصدر احتياطي لا يلجأ إليه إلا عند عدم وجود تنظيم قانوني للمسألة.

ومن ثم فإنه لابد من مراعاة أمرين:

أولهما: أنه لا يجوز للقاضى أن يحكم بقواعد العدالة إذا كان وجه الحكم في الدعوى بمقتضى القانون واضحاً وصريحاً، ومعنى هذا أنه لا يجوز للقاضى بحجة مراعاة العدل والإنصاف أن يقضى بغير القواعد التشريعية أو العرفية الواجبة التطبيق، وليس له أن يستبدل بهذه القواعد أخرى يسندها إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

(١) د. عبد المنعم فرج الصدة - ص ١٥٣، د. جميل الشرقاوى - ص ١٥٢، د. توفيق فرج، ص ١٥٢ وما بعدها، د. منصور مصطفى منصور - ص ١٥٨، د. عبد الرازق حسن فرج - ص ٨٧.

ثانيهما: أنه لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إذا كان من الممكن أن يسد هذا النقص عن طريق القياس، حيث يكون في العمل به غنى عن هذا المبدأ، ويستطيع القاضي من خلاله تعدية الحكم الوارد في النصوص، إلى حالات أخرى لم يرد بشأنها نص، لاتحاد العلة أو الحكمة^(١).

دور الفقه والقضاء في استخلاص تلك المبادئ:

والفقه هو الذي يستخلص المبادئ القانونية العامة التي يقوم عليها تشريع الدولة، وهو بهذا يعين القضاء معونة كبيرة، لأننا مت وضعنا مبادئ عامة أمكن أن نستخلص منها قواعد تفصيلية لتطبق على ما يجد من منازعات ومشاكل، كما يستطيع القاضي عند اجتهاده أن يأخذ بالمبادئ المشتركة في قوانين الدول، و القانون المقارن يستطيع أن يمد القاضي بقواعد تعسفه عندما لا يجد قاعدة في المصادر الرسمية.

وهذا ما سارت عليه المحاكم المصرية بالفعل، فهي من خلال الاستناد إلى هذا المبدأ استطاعت أن تطبق المبادئ العامة في القانون المصري، وأخذت ببعض قواعد الشريعة الإسلامية، واتبعت بعض القواعد المقررة في تشريعات أجنبية، أو في اتفاقات دولية، بل

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٢٢٨ وما بعدها.

واستحدثت أحكاماً وفق الروابط الاجتماعية المستجدة، دون أن يكون لها سند في التشريع أو العرف، توخاً لأصلح القواعد وأكثرها ملائمة لطبيعة الأوضاع التى قصر المشرع في تنظيمها.

الفصل الخامس
الفقه والقضاء مصدران تفسيريان

يعتبر الفقه والقضاء مصدران تفسيريان في القانون المصري، لأن المصادر الرسمية له هي: التشريع والدين في مسائل الحوال الشخصية وقانون العمل، والعرف، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وبالإضافة إلى ذلك يوجد هذا المصدران اللذان ليست لهما أية صفة رسمية، حيث يقتصر أمرهما على تفسير القانون، لأن القاضى يقوم بتفسير القانون تفسيراً قضائياً أو علمياً أو تطبيقياً، ويقوم الفقهاء بتفسير القانون فيما ينشرونه من مؤلفات وبحوث^(١).

ورغم أن دور هذين المصدرين مقتصر على مجال التفسير، إلا أن لكل منهما دوراً هاماً قد يؤدي إلى خلق القواعد القانونية الجديدة، مع ملاحظة أنهما غير ملزمين قانوناً، فالقضاء بمختلف درجاته لا يتقيد بآراء الفقهاء ولا بأحكام المحاكم، وكل ما يكن قوله: إنه قد يستأنس بما استقر عليه رأى الفقهاء، أو بما سارت عليه الأحكام، والأمر كذلك بالنسبة للمشرع فهو كثيراً ما يهتدى بآراء الفقهاء وأحكام المحاكم عند وضع التشريع الجديد أو عند تعديله،

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٢٣٥ وما بعدها، د. عبد المنعم فرج الصدة، فقرة ١١٥، د. حسن كيرة - فقرة ١١٨ وما بعدها، د. عبد الودود يحيى - ص ١٣٣ وما بعدها، د. جميل الشرقاوى - فقرة ٣٥ وما بعدها، د. جمال الدين زكى - ص ١٤٣ وما بعدها، د. عبد الرازق فرج - ص ٨٨ وما بعدها.

ولهذا يمكن القول وصفاً لهذين المصدرين، أنهما من وسائل الاستئناس أو الإقناع، ونبين حقيقة كل منهما في مبحث على حدة^(١).

المبحث الأول

الفقه

والفقه لغة الفهم، وفي اصطلاح فقهاء الشريعة: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، أى مصادر التشريع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وغير ذلك من الدلة المعتمدة في استنباط الأحكام.

وفي اصطرح فقهاء القانون: يقصد به استنباط الأحكام القانونية من النصوص التشريعية بالطرق المعروفة، والاستنباط يقابل عمل الأصوليين عند فقهاء الشريعة، وهو لفظ غير دقيق في الدلالة على الفقه، لأن الاستنباط يعنى جملة الوسائل العلمية التى يتم من خلالها استنباط الحكم من النص القانونى، ولذلك كان من المقبول أن يعرف الفقه بأنه: مجموعة الآراء التى يبديها شراح القانون وأساتذته، سواء اكان ذلك من مؤلفاتهم القانونية، أم في أبحاثهم، أم في فتاوهم، أم في تعليقاتهم على أحكام القضاء^(٢).

(١) د. عبد الرازق فرج - السابق.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق، د. جميل الشرقاوى - ص ١٥٩، د. جمال الدين زكى - ص ١٨٦، د. عبد الحى حجازى - فقرة ٢٣٤.

ويقوم الفقه بدور كبير في استنباط الأحكام من مصادرها وتحليلها، كما يقوم الفقهاء بشرح القوانين، وبيان شروط تطبيقها وضوابطه، ولفقه دور في التأصيل وبيان الاتجاه العام للتشريع والقضاء، كما أن الفقهاء يستنبطون المبادئ العامة من القواعد التفصيلية، ويعتبر الفقه هو المصدر العلمي والعملی للقانون^(١).

أولاً: دور الفقه في القانون الروماني:

كان الفقه مصدراً رسمياً في القانون الروماني، كما كان له فضل كبير في تقدمه، وتحوله إلى قانون يحكم إمبراطورية واسعة شملت حوض البحر الأبيض المتوسط وكثيراً من البلاد الأوروبية، ويكفي أن الفقه قد أسفر عن وجود أهم المجموعات التي جمعها الإمبراطور جوستينيان في القانون الروماني إبان القرن السادس الميلادي، وهي (الموسوعة) (الديجستب)، التي حوت أحكام القانون الروماني مستقاة من كتابات فقهاء العصر العلمي.

وقد كان علم القانون وفقاً على رجال الدين، إلا أنه في السنوات الأخيرة من القرن الرابع قبل الميلاد، استنطاع هذا العلم أن يصل إلى الأفراد، ومن ثم سنحت الفرصة للمعنيين بالتشريع أن يشتغلوا بفقه القانون، ولقوا قبولاً من العامة في الرجوع إليهم ومن ثم نشأ الفقه الحر في روما، وانتهى احتكار فئات معينة لعلم القانون.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق، د. عبد المنعم فرج الصدة - فقرة ١١٧.

وقد بلغ الفقه الرومانى أوج عظمتة فى العصر العلمى الذى بدأ من سنة ١٣٠ ق.م، حتى عام ٢٨٤ ميلادية، وأهم معالم هذا العصر موسوعة جوستينيان، ثم بدأ الفكر الرومانى فى التدهور منذ أواخر القرن الثالث الميلادى ووقف عن التطور والتجديد، واقتصر الأمر على الرجوع لمؤلفات العصر العلمى، واعترفت الدولة لبعض الفقهاء بإصدار فتاوى ملزمة للقضاء، ومن أشهرهم خمسة فقهاء هم: مودستيان، وبول، وأوليبان، وباتيبان، وجابوس، وقد أصبحت فتاواهم وآرائهم مصادر ملزمة بعد موتهم، ولما وضع جوستينيان مجموعته مجموعته فى القرن السادس الميلادى سنة ٥٢٣، استمد أحكامها من آراء هؤلاء الفقهاء^(١).

ثانياً: دور الفقه فى الشريعة الإسلامية:

وصلة الفقه بالشريعة الإسلامية وثيقة، فهو شارح ومفصل لما ورد فى الكتاب والسنة، ولما جاء فيهما من أحكام عامة ومبادئ كلية، وذلك من خلال أمرين هما:

(١) الإجماع:

ويقصد به اجتماع المجتهدين فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعى فى واقعة من

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٢٣٧ وما بعدها.

الوقائع قولاً أو فعلاً، ومتى انعقد الإجماع على هذا النحو من الفقهاء
وجب اتباعه والعمل به.

وبشرط أن يصدر الإجماع من فقهاء مجتهدين وليس عواماً
أو جهالاً بأحكام الشرعية، كما لا ينعقد الإجماع في عصر الرسول
- صلى الله عليه وسلم - لأنه هو المرجع في فهم وتعريف الأحكام
الشرعية.

(٢) الاجتهاد والرأى:

والاجتهاد هو بذل الجهد في معرفة حكم شرعى في غير موطن
الإجماع، فلا يكون الاجتهاد حجة في ثبوت الحكم الذي رآه المجتهد،
بل يجب عليه أن يأخذ بما أسفر عنه اجتهاده، وله أن يعدل عن رأيه
إذا انتهى اجتهاده مرة أخرى إلى رأى مخالف إذا كان فقيهاً، أما إذا
كان حاكماً أى قاضياً لا يجوز له أن يرجع.

ويشترط في المجتهد أن يكون عالماً بالكتاب والسنة، ومعرفة
وجوه القياس وما يقبل منه وما لا يقبل، وهذا يعنى أنه يجب أن يكون
متمكناً في أصول الفقه.

وعلى ضوء تلك المبادئ تكونت المذاهب الفقهية التى اشتهر
منها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل.

ولقد شيد الفقه الإسلامى تراثاً غنياً، وبناء ضخماً من الفكر
المضىء لفهم مبادئ الشريعة وأحكامها وفق النوازل المختلفة، كما

تشكلت منه القواعد الفقهية والأدلة المختلفة فيها كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلّة والعرف.

ثالثاً: الفقه في القانون المصري:

وفي القانون المصري يعدّ الفقه مصدراً يستأنس به القاضي في استخلاص القواعد القانونية وتقصى مفهومها، وكثيراً ما يرجع القاضي إليه يستوحى منه حكمه، كما أن الفقيه بدوره يقوم بالتعليق على أحكام القضاء فيبين للقاضي طريق الصواب، ويتجنب الإنزلاق في مواطن الزلل.

كما يقوم الفقه بشرح نصوص القوانين، وإظهار ما فيها من قصور أو نقص، وهذا يساعد المشرع في تدارك ما يعرض من قصور عند التشريع أو تعديله، ولهذا كان المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الحالي ينص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى التي تتكلم عن مصادر القانون على أنه: "يستلهم القاضي في ذلك الأحكام التي أقرها القضاء والفقه مصرياً كان أو أجنبياً وذلك استناداً إلى أن الفقه يعتبر من العناصر التي يستأنس بها القاضي في استخلاص قواعد القانون، وتقضى مفهومها دون أن تكون لها قوة الإلزام، ولكن هذا النص قد حذف لأن في القواعد العامة ما يغنى عن حكمه، ولكن هذا النص قد حذف لأن في القواعد العامة ما يغنى عن حكمه^(١)، لكنه

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - ج ١ - ص ١٩٢.

بالرغم من أهميته يعتبر مصدراً تفسيرياً للقانون، وليس مصدراً رسمياً ولا يلتزم به القاضى أو المشرع.

المبحث الثانى

القضاء

يطلق لفظ القضاء في القانون، ويراد بها أحد معنيين:

الأول: مجموعة المحاكم في بلد من البلاد، وهي التى تقوم بتطبيق القواعد العامة المجردة على ما يعرض عليها من منازعات.

والثانى: مجموعة الأحكام الصادرة من جهة قضائية، إما في جميع المسائل الداخلة في اختصاصها، أو في مسألة معينة من هذه المسائل، فيقال مثلاً: القضاء المدني، أو القضاء الإدارى، وقد يحدث أن يستقر قضاء المحاكم على اتجاه معين في مسألة من المسائل، وفي هذه الحالة يثور التساؤل عما إذا كان القضاء مصدراً من مصادر القانون^(١).

القضاء في القوانين القديمة:

(١) في القانون الرومانى:

كان للقضاء دور هام في القانون الرومانى حيث كان بريطور في روما يتولى القضاء إلى جانب وظيفته الإدارية، وكان بريطور يبدأ

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٢٤٤، د. جميل الشرقاوى - ص ١٦٨، د. عبد المنعم فرج الصدة - ص ١٥٩، د. جمال الدين زكى - فقرة ٧٦، د. عبد الرزاق فرج - ص ٩٢.

ولايته الوظيفية بإعلام منشور يبين فيه القواعد العمة التى سيسير عليها خلال فترة حكمه فيما يتعلق بسلطاته القضائية، أو اختصاصاته الإدارية والدعاوى التى تنظر، ويتوالى صدور تلك المنشورات يكون ما يعرف بالمنشور الدائم، الذى كان يسمى فيما بعد: القانون البريتورى، الذى أصبح مصدراً من مصادر القانون، يبين وسائل رفع الدعوى للبريتور في المجال القضائى والمجال التنفيذى أو الإدارى^(١).

(٢) في النظام الأنجلوسكسونى:

في النظام الأنجلوسكسونى يعتبر القضاء مصدراً رسمياً من مصادر القانون، لأن القانون في البلاد التى تطبق هذا النظام، قائم أساساً على السوابق القضائية، فالقانون العام الإنجليزى تكون تكويناً قضائياً، ولمعرفة أحكام هذا القانون يجب الرجوع إلى القضاء واستخلاصه منه، وما زال التشريع في إنجلترا يعتبر حدثاً استثنائياً لا يلجأ إليه إلا بقصد تكملة أو تعديل القانون العام الذى تكون تكويناً قضائياً بحتاً.

وتقوم هناك مجموعات الأحكام قام المجموعات القانونية، وتسمى Law Reports ولذلك يلتزم القاضى الإنجليزى عند فصله في دعوى مرفوعة إليه بأن يفتش في السوابق القضائية مع الاستعانة بكتب الفقهاء التى تهديه إليها، وتعتبر السوابق القضائية ملزمة إذا

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - - ص ٢٤٥ وما بعدها.

كان الحكم صادراً من المحكمة العليا (مجلس اللوردات)، فيلزم حكم كل المحاكم ولا يجوز تعديله إلا بقانون، وتليه في المنزلة: محكمة الاستئناف وحكمها ملزم لها ولما تحتها من المحاكم، كما أن أحكام محاكم المقاطعات، وهي تشبه في النظام اللاتيني المحاكم الجزئية، فهي غير ملزمة لأنها تستأنف دائماً أمام المحاكم الابتدائية، وطبقاً لهذا النظام ليس على المتقاضى إلا أن يبحث عن سابقة قضائية ملزمة فتحكم له املحكمة من أول جلسة بحقه، وليس من اللازم أن تكون هذه السابقة قد أصبحت قضاء مستقراً عليه حتى تعتبر حجة، بل يكفي أن يصدر حكم واحد فيعتبر سابقة قضائية، وما ذلك إلا لأن رجال القضاء هناك يختارون رجال القانون الذي امضوا مدداً طويلة في الاشتغال بالمحاماة، أو في غيرها من الأعمال القانونية^(١).

(٣) في النظام اللاتيني:

يقتصر دور القضاء في البلاد اللاتينية على تطبيق القانون لا خلقه، فلا يجوز للقضاء ان ينشئ قواعد قانونية، لأن هذا هو عمل السلطة التشريعية، وأن دور القضاء لا يعدو أن يكون مصدراً للاستئناف، ولا تعتبر أحكام المحاكم في البلاد اللاتينية سوابق قضائية، كالنظام الأنجلوسكسوني، فيجوز للمحاكم التي أصدرت الحكم أن تعدل عن المبدأ الذي جرت عليه، ولا تنقيد أحكام المحاكم الأخرى

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٢٤٦ وما بعدها، د. جمال الدين زكى - فقرة ٧٦.

بحكم هذه المحكمة، لأن القانون يتكون من معظم أجزائه من التشريع، ولذلك تسمى البلاد الخاضعة لهذا النظام، ببلاد القانون المكتوب، ووظيفة القضاء فيها هي تطبيق القانون لا صنعه.

ومع ذلك فإن بعض شراح القانون يرون أن القضاء مصدر للقانون على أساس أنه أوجد قواعد مستقرة أصبح لها من الاحترام ما للتشريع، ولذلك قالوا: غن القضاء يصنع القانون عن طريق خلق عرف قضائي أو قاعدة نظامية^(١).

ويقولون: أنه إذا صح القول بأن الأحكام لا تلزم المحكمة التي أصدرتها، أو أى محكمة أخرى، إلا أن هذا الإلزام وإن لم يكن قانونياً إلا أنه علمي، خاصة أحكام محكمة التقض، لأنها تعلم أن مصير حكمها في النهاية سوف يعرض عليها، فهذا الإلزام وإن لم يكن قانونياً إلا أنه إلزام أدبي أو علمي، وذلك من شأنه أن يكفي لجعل القضاء مصدراً من مصادر القانون، ويمكن الرد على ذلك بأن القانون هو الفيصل، وهو لا يلزم القاضى بقضائه ولا بقضاء غيره، ولو كان أعلى مرتبة منه، ومعنى ذلك أن القضاء لا يمكن اعتباره مصدراً رسمياً للقانون.

حقيقة دور القضاء في نظامنا القانوني:

(١) من هؤلاء الفقهاء: الأستاذ لامبير فى كتابه: وظيفة القانون المدني المقارن، والأستاذ مور وليميرو، وريبير/ وهيبرو، د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٢٤٨ هامش (١).

ليس هناك شك في ان أحكام القضاء غير ملزمة لأى درجة أخرى من درجاته وذلك أصل عام، ولهذا يصح القول بأنه لا يعتبر عندنا مصدراً رسمياً للقانون.

ولكن ليس معنى هذا أن القضاء لا يخلق قواعد قانونية، لأنه يساهم في تكوين مبادئ القانون الطبيعي والعدالة، وهي من مصادر القانون الرسمية التى يجب على القاضى أن يرجع إليها، لكن تبقى القواعد القانونية التى يجتهد فيها القضاء من خلال تلك المبادئ مستندة في قوتها الملزمة إلى تطبيقها بالفعل بواسطة احاكم نفسها، دون أن ترقى إلى مرتبة الإلزام التشريعى، فإذا اضطردت أحكام على مقتضاها، أمكن القول باستقرارها عملاً لا قانوناً، ولهذا تستطيع أى جهة قضائية أن تخرج عليها من الناحية النظرية المجردة، وهذه هو جوهر الخلاف بين النظام اللاتى والنظام الأنجلوسكسونى، وأما التوحيد الذى تؤدى إليه محكمة النقض، إنما هو توحيد من الناحية العملية أو الفعلية، ولكن المحاكم تحرص على تحرى اتجاهاتها خوفاً من تعرض أحكامها - عندما تعرض عليها - للنقض، وتقتصر وظيفتها على رقابة القاضى في تطبيقه للقانون وتفسيره، ولذلك يجب التفرقة بين ما يعتبر من الوقائع وما يعتبر من القانون، والأخير هو الذى يدخل في اختصاصها.

وفي إطار ذلك التوحيد القضائى صدر قانون المحكمة العليا في أول سبتمبر ١٩٦٩م، وجعل من اختصاصها تفسير النصوص

القانونية التي تستدعى ذلك تطبيقها، او أهميتها، ضماناً لوحدة التطبيق القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل، ويكون قراره الصادر بالتفسير ملزماً.

هذا، وبالله التوفيق ومنه العون والسداد
والحمد لله رب العالمين،،

الأستاذ الدكتور
عبد الله النجار

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	تقديم
٩	تمهيد تنوع الروابط الاجتماعية
١١	الباب الأول التعريف بالقانون وخصائصه وتمييزه عن القواعد التشريعية الأخرى
١٣	الفصل الأول: التعريف بالقانون وخصائصه
١٥	المبحث الأول: التعريف بالقانون
١٧	المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية
٣٣	الفصل الثاني: تفريد القواعد القانونية عن غيرها
٤٣	الفصل الثالث: دور القانون في تنظيم نشاط المجتمع
٤٥	المبحث الأول: الأساس العلمي للقانون
٦٢	المبحث الثاني: نطاق تدخل القانون من خلال القواعد الآمرة والقواعد المكملة
٦٢	المطلب الأول: القواعد القانونية الآمرة
٦٤	المطلب الثاني: القواعد القانونية المكملة أو المفسرة
٦٧	المطلب الثالث: معيار التفرقة بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة

الصفحة	الموضوع
٦٧	الفرع الأول: المعيار الشكلي
٦٩	الفرع الثاني: المعيار الموضوعي
٧٩	الباب الثاني أنواع القواعد القانونية
٨١	الفصل الأول: فروع القانون العام
٨٣	المبحث الأول: القانون الدولي العام
٨٨	المبحث الثاني: القانون العام الداخلي
٨٨	المطلب الأول: القانون الدستوري
٨٩	المطلب الثاني: القانون الإداري
٩٤	المطلب الثالث: القانون المالي
٩٥	المطلب الرابع: القانون الجنائي
١٠١	الفصل الثاني: فروع القانون الخاص
١٠٢	المبحث الأول: القانون المدني
١٠٦	المبحث الثاني: القانون التجاري
١٢٣	المبحث الثالث: قانون المرافعات المدنية والتجارية
١٢٥	المبحث الخامس: القانون الدولي الخاص
١٣١	الباب الثالث مصادر القانون
١٣٩	الفصل الأول: التشريع

الصفحة	الموضوع
١٤٠	المبحث الأول: دور التشريع في مواجهة الوقائع وتطبيقاته
١٤٠	المطلب الأول: دور التشريع في مواجهة الواقع
١٤٤	المطلب الثاني: دور التشريع في إطار الواقع المعاصر
١٤٥	المبحث الثاني: مزايا التشريع وعيوبه
١٤٥	المطلب الأول: مزايا التشريع
١٤٧	المطلب الثاني: عيوب التشريع ومناقشتها
١٥٠	المبحث الرابع: سن التشريع
١٥٣	المطلب الأول: سن التشريع الأساسى (الدستور)
١٥٩	المطلب الثاني: سن التشريع العادى
١٦٦	المطلب الثالث: سن التشريع الفرعى
١٧٥	المبحث الرابع: تفسير التشريع وإلغائه
١٧٥	المطلب الأول: تفسير التشريع ووسائله
١٧٩	الفرع الأول: تفسير النص السليم
١٨٧	الفرع الثانى: النص المعيب وكيفية تفسيره
١٨٧	المقصد الأول: النص المعيب
١٩٢	المقصد الثانى: كيفية تفسير النص المعيب
١٩٥	المطلب الثانى: إلغاء النص التشريعى
٢٠٢	المبحث السادس: سريان القانون من حيث المكان والزمان
٢٠٣	المطلب الأول: سريان القانون من حيث المكان

الصفحة	الموضوع
٢١٠	المطلب الثاني: سريان القانون من حيث الزمان
٢٢٤	الفرع الأول: الوسيلة الفنية لفض التنازع الزماني
٢٤٢	الفرع الثاني: الوسيلة التشريعية لفض التنازع
٢٤٧	الفصل الثاني: العرف كمصدر للتشريع
٢٥٠	المبحث الأول: أركان العرف
٢٥٣	المبحث الثاني: تفريد العرف عن العادة الاتفاقية
٢٥٧	المبحث الثالث: أساس الإلزام في العرف
٢٦٠	المبحث الرابع: مزايا العرف وعيوبه
٢٦٣	المبحث الخامس: دور العرف في القانون المصري
٢٧٣	الفصل الثالث: مبادئ الشريعة الإسلامية
٢٧٩	الفصل الرابع: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
٢٨٧	الفصل الخامس: الفقه والقضاء مصدران تفسيريان
٢٨٨	المبحث الأول: الفقه
٢٩٣	المبحث الثاني: القضاء
٢٩٨	الفهرس